



RICARDO NEGRÃO

Manual de **DIREITO**
EMPRESARIAL

10ª edição

Atualizada de acordo com a Lei de Liberdade
Econômica e com anotações ao PL
10.220/2018, que altera a Lei n. 11.101/2005

saraiva *jur*

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

ISBN 9788553616206

Negrão, Ricardo

Manual de direito empresarial / Ricardo Negrão. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

360 p.

Bibliografia

1. Direito empresarial 2. Direito empresarial - Brasil I. Título.

20-0154

CDD 340

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Direito empresarial 342(81)

Direção executiva *Flávia Alves Bravin*

Direção editorial *Renata Pascual Müller*

Gerência editorial *Roberto Navarro*

Gerência de produção e planejamento *Ana Paula Santos Matos*

Gerência de projetos e serviços editoriais *Fernando Penteado*

Consultoria acadêmica *Murilo Angeli Dias dos Santos*

Planejamento *Clarissa Boraschi Maria (coord.)*

Novos projetos *Melissa Rodriguez Arnal da Silva Leite*

Edição *Marisa Amaro dos Reis*

Produção editorial *Rosana Peroni Fazolari*

Arte e digital *Mônica Landi (coord.) | Amanda Mota Loyola | Camilla Felix Cianelli Chaves | Claudirene de Moura Santos Silva | Deborah Mattos | Fernanda Matajs | Guilherme H. M. Salvador | Tiago Dela Rosa | Verônica Pivisan Reis*

Planejamento e processos *Clarissa Boraschi Maria (coord.) | Juliana Bojczuk Fermino | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Fernando Penteado | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Projetos e serviços editoriais *Juliana Bojczuk Fermino | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Diagramação (Livro Físico) *Luciano Assis*

Revisão *Izabel Bressan*

Capa *Idée arte e comunicação*

Livro digital (E-pub)

Produção do e-pub *Guilherme Henrique Martins Salvador*

Data de fechamento da edição: 11-10-2019

Dúvidas?

Acesse sac.sets@somoseducacao.com.br

SUMÁRIO

Abreviaturas

Capítulo 1 - Da Empresa e das Pessoas que a Exercem

1. Plano de estudo
2. Teoria da empresa
3. Perfis da empresa
4. Empresários
5. Sociedades
6. Sociedades empresárias e sociedades simples
7. Classificação das sociedades
8. Constituição das sociedades – requisitos comuns
 - 8.1. Agente capaz
 - 8.2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável
 - 8.3. Forma prescrita ou não defesa em lei
9. Constituição das sociedades – requisitos específicos
 - 9.1. Pluralidade de sócios
 - 9.2. Constituição do capital social
 - 9.3. Affectio societatis
 - 9.4. Coparticipação nos lucros e perdas

10. Modalidades de constituição de sociedades

10.1. Requisitos comuns

10.2. Constituição privada ou simultânea

10.3. Constituição sucessiva ou pública

11. Direitos e deveres dos sócios

11.1. Dever de contribuir

11.2. Dever de probidade nas deliberações e gestão social

11.3. Direito-dever de coparticipação nos lucros e perdas

11.4. Direito de participar das deliberações

11.5. Direito de fiscalização

11.6. Direito de participar do acervo, em caso de liquidação

11.7. Direito de preferência

11.8. Direito de retirada

12. Resolução da sociedade em relação a sócio – casos de retirada

13. Resolução da sociedade em relação a sócio – casos de exclusão

13.1. Exclusão de sócio remisso

13.2. Exclusão por deliberação judicial

13.3. Exclusão por incapacidade superveniente

13.4. Exclusão por deliberação extrajudicial

14. Resolução da sociedade em relação a sócio – casos de morte e de pleno direito

15. Responsabilidade dos sócios

16. Responsabilidade de sócio com responsabilidade ilimitada, por ingresso e retirada

17. Responsabilidade de sócio com responsabilidade limitada, por ingresso e retirada

18. Responsabilidade em caso de falência

19. Responsabilidade por ingresso, retirada e falência:quadro-resumo
20. Teoria do superamento da personalidade jurídica
21. Aspectos processuais da aplicação da teoria da desconsideração
22. Teoria ultra vires societatis
23. Administração das sociedades de pessoas
 - 23.1. Incompatibilidades e impedimentos
 - 23.2. Impedimentos de ordem profissional
 - 23.3. Formas de exercício
 - 23.4. Deveres do administrador
 - 23.5. Substituição
 - 23.6. Poderes
 - 23.7. Abuso de poderes gerenciais
24. Sociedades não personificadas – sociedade em comum
25. Sociedades não personificadas – sociedade em conta de participação
26. A regência das normas da sociedade simples
27. Sociedade simples
28. Sociedade em nome coletivo
29. Sociedade em comandita simples
30. Sociedade limitada
 - 30.1. Principal característica e regência legal
 - 30.2. Sociedade limitada e sociedade simples
 - 30.3. Regras aplicáveis à empresa individual de responsabilidade limitada
31. Conselho Fiscal na sociedade limitada
32. Características das sociedades por ações
33. Sociedade em comandita por ações
34. Sociedade anônima

- 34.1. Fundadores
- 34.2. Estatutos
- 34.3. Número de sócios
- 34.4. Capital social inicial
- 34.5. Redução do capital social
- 35. Sociedade anônima de capital autorizado
- 36. Sociedades anônimas abertas e fechadas
- 37. Sociedade de economia mista
- 38. Sociedade anônima multinacional
- 39. Direitos essenciais do acionista
- 40. Ações
 - 40.1. Classificação das ações
 - 40.2. Valores das ações
 - 40.3. Certificado de ações e agente emissor
 - 40.4. Custódia de ações
 - 40.5. Certificado de depósito de ações
 - 40.6. Sistema único de custódia
 - 40.7. Constituição de direitos reais sobre as ações
- 41. Valores mobiliários
- 42. Valores mobiliários – debêntures
 - 42.1. Conversibilidade das debêntures
 - 42.2. Garantias outorgadas
 - 42.3. Agente fiduciário
 - 42.4. Assembleia de debenturistas
- 43. Valores mobiliários – partes beneficiárias
- 44. Valores mobiliários – bônus de subscrição

- 45. Valores mobiliários – papéis comerciais (commercial papers)
- 46. Quadro-resumo dos valores mobiliários
- 47. Órgãos da sociedade por ações – as assembleias
 - 47.1. Conceito
 - 47.2. Competência privativa da assembleia geral
 - 47.3. Espécies de assembleia e de quorum
- 48. Órgãos da sociedade por ações – Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal
 - 48.1. Conselho de Administração
 - 48.2. Atribuições do Conselho de Administração
 - 48.3. Composição do Conselho de Administração
 - 48.4. Diretoria
 - 48.5. Conselho Fiscal
 - 48.6. Conselho Fiscal permanente e não permanente
- 49. Reorganização de sociedades
 - 49.1. Transformação
 - 49.2. Incorporação
 - 49.3. Fusão
 - 49.4. Cisão
 - 49.5. Diferenças entre os procedimentos e efeitos
- 50. Grupos de sociedades
 - 50.1. Grupo de fato
 - 50.2. Grupo de direito
 - 50.3. Consórcio
- 51. Dissolução de sociedades no Código Civil
 - 51.1. Dissolução extrajudicial

51.2. Dissolução judicial

52. Dissolução de sociedades na Lei das Sociedades por Ações

52.1. Dissolução de pleno direito

52.2. Dissolução por decisão judicial

52.3. Dissolução por ato administrativo

Capítulo 2 - Estabelecimento Empresarial

53. Plano de estudo

54. Estabelecimento empresarial

55. Matriz, filiais e sucursais

56. Trespasse de estabelecimento

57. Trespasse e sub-rogação dos contratos não pessoais

58. Aviamento

59. Clientela

60. Cláusulas de interdição de concorrência

61. Ponto empresarial

62. Ponto empresarial – exceção de retomada

63. Direitos de propriedade industrial – conceitos

64. Patentes de invenção e modelos de utilidade

64.1. Primeiro requisito de patenteabilidade: a novidade

64.2. Segundo requisito de patenteabilidade: a industriabilidade

64.3. Terceiro requisito de patenteabilidade: a atividade inventiva

64.4. Quarto requisito de patenteabilidade: a licitude

65. Invenção de empresa, de empregado e comum

66. Desenho industrial

67. Marcas

- 67.1. Classificações
- 67.2. Requisitos
- 68. Cessão de uso e licenças
- 69. Licença compulsória
- 70. Extinção do direito de propriedade industrial
 - 70.1. Expiração do prazo de vigência (LPI, arts. 78, I, 119, I, e 141, I)
 - 70.2. Renúncia do titular (LPI, arts. 78, II, 119, II, e 142, II)
 - 70.3. Caducidade (LPI, arts. 78, III, e 142, III)
 - 70.4. Falta de pagamento da retribuição
 - 70.5. Nulidade do ato de concessão
 - 70.6. Inobservância do art. 217 (LPI, arts. 78, V, 119, IV, e 142, IV)

Capítulo 3 - Institutos Complementares à Empresa

- 71. Plano de estudo
- 72. Registro de empresa
 - 72.1. Regência legal
 - 72.2. Órgãos do registro de empresa
 - 72.3. Finalidades do registro
 - 72.4. Efeitos jurídicos do registro
 - 72.5. Atos de registro
 - 72.6. Impedimentos ao arquivamento
- 73. Nome empresarial
 - 73.1. Distinções
 - 73.2. Espécies
 - 73.3. Tutela legal do nome empresarial
 - 73.4. Extensão da proteção legal – princípios da especialidade e da territorialidade

- 73.5. Colidência entre marca e nome empresarial
- 73.6. Sistemas de formação do nome empresarial
- 73.7. Formação do nome
- 73.8. Nome empresarial de sociedade estrangeira
- 73.9. Alteração do nome empresarial
- 74. Prepostos, gerentes, contabilistas e auxiliares
- 75. Escrituração empresarial
 - 75.1. Funções da escrituração
 - 75.2. Princípios informadores
 - 75.3. Sanções penais decorrentes da ausência ou fraude na escrituração
 - 75.4. Espécies de livros
 - 75.5. Valor probante dos livros
 - 75.6. Recusa de apresentação de livros
 - 75.7. Livros empresariais e pequenos empresários
 - 75.8. Demonstrações financeiras diferenciadas
 - 75.9. Demonstrações financeiras comuns às sociedades por ações e de grande porte
 - 75.10. Demonstrações financeiras especiais
 - 75.11. Escrituração contábil e sociedades de grande porte

Capítulo 4 - Contratos Empresariais

- 76. Plano de estudo
- 77. Agência e distribuição
 - 77.1. Conceito
 - 77.2. Natureza
 - 77.3. Objeto e características
 - 77.4. Espécies ou qualificação jurídica

- 77.5. Retribuição
- 77.6. Extinção do contrato
- 78. Distribuição por conta própria (revenda ou concessão comercial)
 - 78.1. Conceito e distinções
 - 78.2. Objeto e características
 - 78.3. Espécies e qualificação
- 79. Mandato e comissão mercantil
- 80. Corretagem
 - 80.1. Conceito e definição
 - 80.2. Características
 - 80.3. Espécies e qualificação
- 81. Franquia (franchising)
 - 81.1. Definição legal
 - 81.2. Objeto
 - 81.3. Natureza
 - 81.4. Elementos do contrato
- 82. Compra e venda mercantil
 - 82.1. Conceito
 - 82.2. Elementos formadores
 - 82.3. Obrigações do vendedor
 - 82.4. Entrega da coisa
 - 82.5. Vícios
 - 82.6. Evicção
 - 82.7. Obrigações do comprador
- 83. Compra e venda mercantil – cláusulas e contratos especiais
 - 83.1. Retrovenda

83.2. Venda a contento e venda sujeita a prova

83.3. Preempção ou preferência

83.4. Venda com reserva de domínio

83.5. Venda sobre documentos

83.6. Crédito documentário

83.7. Contrato estimatório

83.8. Hedging

83.9. Incoterms

84. Arrendamento mercantil (leasing)

84.1. Definição legal

84.2. Objeto

84.3. Modalidades

85. Alienação fiduciária em garantia

85.1. Conceito

85.2. Objeto

86. Contratos bancários

86.1. Depósito bancário

86.2. Desconto e redesconto

86.3. Empréstimo bancário

87. Faturização (factoring ou fomento mercantil)

88. Transporte e seguro

88.1. Transporte

88.2. Seguro

Capítulo 5 - Títulos de Crédito

89. Plano de estudo

90. Teoria geral e institutos cambiários

90.1. Classificação

90.2. Títulos regulamentados no direito brasileiro

90.3. Princípios

91. Leis uniformes e leis nacionais

92. Títulos de crédito no Código Civil

93. Letra de câmbio

93.1. Emissão em moeda estrangeira

93.2. Cláusula de estipulação de juros

93.3. A época do pagamento

93.4. Saque

93.5. Aceite

93.6. Endosso

93.7. Aval

93.8. Pagamento

93.9. Pagamento por intervenção

93.10. Ressaque

93.11. Apresentação

93.12. Protesto

93.13. Ação cambial

93.14. Prescrição

93.15. Ações causais

93.16. Ação monitória

94. Nota promissória

94.1. Requisitos

94.2. Nota promissória incompleta

94.3. Requisitos não essenciais

94.4. Direito aplicável – regras compatíveis

94.5. Ação cambial e vinculação a contrato

95. Cheque

95.1. Legislação e regime jurídico do cheque

95.2. Conflitos em matéria de cheque

95.3. Requisitos

95.4. Cheque incompleto ou em branco

95.5. Revogação e oposição

95.6. Aval no cheque

95.7. Modalidades de emissão

95.8. Prazo para a apresentação

95.9. Perda do prazo para a apresentação

95.10. Ações judiciais

96. Duplicata

96.1. Conceito

96.2. Modalidades

96.3. Criação e requisitos

96.4. Aceite

96.5. Aceite presumido

96.6. Protesto por indicação

96.7. Motivos para a recusa

96.8. Triplicata

96.9. Endosso

96.10. Aval

96.11. Aval e ação monitória

- 96.12. Protesto
- 96.13. Prazo para pagamento
- 96.14. Pagamento antecipado
- 96.15. Prorrogação de vencimento
- 96.16. Ações fundadas na duplicata – incidência de juros e correção monetária
- 96.17. Prescrição
- 96.18. Aspectos penais relacionados à duplicata
- 96.19. Duplicata escritural

Capítulo 6 - Recuperação Judicial e Falência

- 97. Plano de estudo
- 98. Casos de incidência e de não incidência
- 99. Unidade do juízo falimentar
- 100. Prevenção do juízo falimentar
- 101. Indivisibilidade do juízo falimentar
- 102. Universalidade do juízo falimentar
- 103. Verificação e habilitação de créditos
- 104. Habilitação retardatária de créditos
- 105. Ação ordinária de exclusão de crédito
- 106. Administrador judicial
 - 106.1. Natureza jurídica
 - 106.2. Impedimentos
 - 106.3. Compromisso
 - 106.4. Funções e prazos
 - 106.5. Remuneração
 - 106.6. Substituição e destituição

- 106.7. Responsabilidade
- 106.8. Prestação de contas
- 107. Comitê de Credores
 - 107.1. Formas de constituição
 - 107.2. Composição e presidência
 - 107.3. Impedimentos
 - 107.4. Atribuições e deliberações
 - 107.5. Remuneração
 - 107.6. Substituição e destituição
 - 107.7. Responsabilidade
- 108. Assembleia geral de credores
 - 108.1. Classes de credores e direito a voto
 - 108.2. Quorum de instalação e de deliberação
 - 108.3. Sistemas de colheita de votos
- 109. Recuperação judicial – crise econômico-financeira e princípios norteadores
- 110. Sistemas de recuperação em juízo
 - 110.1. Requisitos comuns
 - 110.2. Distinções
- 111. Pedido inicial e processamento da recuperação
- 112. Meios de recuperação
- 113. Plano de recuperação
- 114. Impugnação ao plano
- 115. Deliberação sobre o plano de recuperação
- 116. Cumprimento da recuperação judicial
- 117. Conversão da concordata em recuperação judicial
- 118. Recuperação judicial especial

119. Recuperação extrajudicial

119.1. Modalidades

119.2. Efeitos

119.3. Documentação

119.4. Procedimento

120. Convolação da recuperação em falência

121. Pedido de falência

121.1. Natureza da dívida

121.2. Credor empresário

121.3. Credor domiciliado no exterior

121.4. Legitimidade ativa

121.5. Cônjuge, herdeiros e inventariante

121.6. Sócios e acionista da sociedade requerida

121.7. Legitimidade passiva

122. Procedimentos pré-falimentares

122.1. Falência requerida com base na impontualidade ou na frustração da execução (art. 94, I e II)

122.2. Falência requerida em razão da ocorrência de atos denominados falenciais, eleitos pelo legislador (art. 94, III)

122.3. Pedido de autofalência (art. 105)

123. Recuperação judicial incidental

124. Sentença judicial e recursos

124.1. Indenização

124.2. Recursos

125. Efeitos da falência sobre os credores

125.1. Suspensão do curso da prescrição

- 125.2. Suspensão das ações e execuções individuais dos credores
- 125.3. Vencimento antecipado das dívidas
- 125.4. Formação da massa de credores
- 125.5. Suspensão do direito de retenção
- 125.6. Suspensão da fluência de juros
- 125.7. Alteração de direito relativa a coobrigados solidários
- 126. Efeitos da falência sobre a pessoa do falido
 - 126.1. Restrições impostas
 - 126.2. Obrigações impostas
 - 126.3. Direitos atribuídos
- 127. Efeitos da falência sobre os sócios
 - 127.1. Efeitos sobre os sócios com responsabilidade ilimitada
 - 127.2. Efeitos sobre os sócios com responsabilidade limitada
 - 127.3. Suspensão do direito de retirada, do recebimento de suas cotas e classificação do crédito
 - 127.4. Efeitos não patrimoniais
- 128. Efeitos da falência sobre os bens do falido
 - 128.1. Casos de impenhorabilidade
 - 128.2. Patrimônio de afetação
- 129. Efeitos da falência sobre os contratos
 - 129.1. Regras em relação aos contratos unilaterais
 - 129.2. Regras em relação aos contratos bilaterais
 - 129.3. Falência do devedor que não entregou a coisa contratada
 - 129.4. Falência do comprador que não pagou a coisa contratada
 - 129.5. Contratos em que o comprador falido detém a posse indireta da coisa, mas não o domínio e ainda não pagou o preço

- 129.6. Vendas a termo, em que houve a falência do comprador ou do vendedor
- 129.7. Contratos imobiliários, de locação e venda
- 129.8. Mandato e comissão
- 129.9. Conta-corrente
- 129.10. Compensação de dívidas
- 129.11. Contrato de sociedade
- 129.12. Condomínio indivisível
- 130. Administração e arrecadação de bens
- 131. Classificação dos créditos na falência
- 132. Realização do ativo
 - 132.1. Alienação da empresa, de parte dela, dos estabelecimentos empresariais ou de bens individualmente
 - 132.2. Constituição de sociedade de credores ou de empregados do devedor
 - 132.3. Modalidades de alienações públicas
 - 132.4. Outras modalidades de alienação judicial
 - 132.5. Impugnações
 - 132.6. Especulação de lucro
- 133. Pagamento aos credores
- 134. Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido
 - 134.1. Prestação de contas do administrador judicial
 - 134.2. Sentença de encerramento
 - 134.3. Extinção das obrigações do falido
 - 134.4. Extinção das obrigações antes do encerramento da falência
 - 134.5. Procedimento de extinção
- 135. Ações de restituição
 - 135.1. Requisitos dos pedidos

- 135.2. Contratos de câmbio
- 135.3. Restituição de valor devido à Previdência
- 135.4. Procedimento
- 135.5. Execução da sentença
- 135.6. Recurso
- 135.7. Honorários e atualização monetária

136. Ações revocatórias

- 136.1. Atos praticados dentro do termo legal
- 136.2. Atos praticados dentro do biênio anterior à falência
- 136.3. Ato em que não se leva em conta o elemento temporal
- 136.4. Atos praticados após a decretação da falência
- 136.5. Ação revocatória
- 136.6. Processamento da ação revocatória
- 136.7. Medidas cautelares
- 136.8. Efeitos das ações revocatórias

Referências

Índice Onomástico

Índice Alfabético-remissivo

Em memória de meu pai, Professor Sebastião Ramos Nogueira, emérito
educador.

À minha mãe e primeira Professora, Elza Negrão Nogueira, de notável
caráter e senso de justiça.

À Maria Teresa, companheira, amiga, colaboradora e adjunta.

Aos meus amados filhos, Paula, André, Filipe, Augusta e Lucas.

Aos meus netinhos, Tito, Ana Luísa, Mariana e João Filipe.

A Jesus, meu Senhor e Salvador

“Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e, no ano de sequeidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto.”

(Jr. 17.7-8)

ABREVIATURAS

- ACC – Adiantamento de Crédito em Contrato de câmbio para exportação
- ADIn – Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo
- AgReg. – Agravo Regimental
- AI – Agravo de Instrumento
- Apel. – Apelação
- art. – artigo
- arts. – artigos
- BACEN – Banco Central do Brasil
- BSTJ – Boletim do Superior Tribunal de Justiça
- BTN – Bônus do Tesouro Nacional
- CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CBA – Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986)
- c/c – combinado com
- CC – Código Civil de 2002
- CC16 – Código Civil de 1916
- CCom – Código Comercial
- CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990)

Cf. – Conforme

CF88 – Constituição Federal de 1988

CIMC – Convenção Interamericana sobre Conflito em Matéria de Cheques —
Decreto n. 1.240, de 15 de setembro de 1994

CJF – Conselho da Justiça Federal

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CMN – Conselho Monetário Nacional

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

COF – Circular de Oferta de Franquia

CP – Código Penal

CPC – Código de Processo Civil de 2002

CPC15 – Código de Processo Civil de 2015

CPC39 – Código de Processo Civil de 1939

CPC73 – Código de Processo Civil de 1973

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas

CPP – Código de Processo Penal

CRDE – Câmara Reservada de Direito Empresarial (TJSP)

CTN – Código Tributário Nacional

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

D. – Decreto

Des. – Desembargador

DJ – Diário da Justiça

DJU – Diário da Justiça da União

DNRC – Departamento Nacional de Registro do Comércio

DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração

ed. – edição

Edcl. – Embargos de declaração

EPP – Empresa de Pequeno Porte

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

ICP – Infraestrutura de Chaves Públicas

IFA – International Franchise Association

IGP-DI – Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna

IN – Instrução Normativa

IPC – Índice de Preços ao Consumidor

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

j. – julgado em

LBCD – Lei de Contabilidade Digital

LC – Lei do Cheque (Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985)

LD – Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968)

LDA – Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1996)

LF45 – Lei de Falências Anterior (Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945)

LFE – Lei de Franquia Empresarial (Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994)

LLE – Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019, de 20 de setembro de 2019)

LLI – Lei de Locação de imóveis urbanos (Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991)

LPI – Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996)

LREF – Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005)

LRM – Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994)

LRP – Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973)

LS – Lei Saraiva (Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1968)

LSA – Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

LUG – Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966)

ME – microempresa

Min. – Ministro

MP – Medida Provisória

n. – número

NF-e – Nota fiscal eletrônica

p. – página

PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PTAC – Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo

QGC – Quadro Geral de Credores

RAET – Regime de Administração Especial Temporária

RDBMCA – Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem.

RE – Recurso Extraordinário

rel. – relator

REsp – Recurso Especial

Rev. – Revisor

RMS – Recurso em Mandado de Segurança

RT – Revista dos Tribunais

SINARM – Sistema Nacional de Armas

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TFR – Tribunal Federal de Recursos

TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo

TR – Taxa Referencial

TRD – Taxa Referencial Diária

TST – Tribunal Superior do Trabalho

v. – veja

vol. – volume

v.u. – votação unânime

CAPÍTULO 1

Da Empresa e das Pessoas que a Exercem

1. Plano de estudo

Este primeiro capítulo trata da empresa e das pessoas naturais e jurídicas que a exercem. Dada a extensão deste capítulo inicial, optamos pela representação em forma de tabela:

Empresas e empresários – itens 2-4	Teoria da empresa – item 2	
	Perfis da empresa – item 3	
	Empresários – item 4	
Sociedades – aspectos gerais – itens 5-10	Sociedades – itens 5-6	Sociedades – item 5
		Sociedades empresárias e sociedades simples – item 6
	Classificação das sociedades – item 7	
	Constituição das sociedades – itens 8-10	Requisitos comuns – item 8
		Requisitos específicos – item 9

		Modalidades – item 10
Direitos e deveres dos sócios – item 11		
Resolução da sociedade em relação a sócios – itens 12-14	Casos de retirada – item 12	
	Casos de exclusão – item 13	
	Casos de morte e de pleno direito – item 14	
Responsabilidade de sócios – itens 15-22	Responsabilidade ordinária – itens 15-19	Nas diversas sociedades – item 15
		Sócio com responsabilidade ilimitada – ingresso e retirada – item 16
		Sócio com responsabilidade limitada – ingresso e retirada – item 17
		Em caso de falência – item 18
		Quadro-resumo – item 19

	Responsabilidade extraordinária – itens 20-22	Teoria do superamento da personalidade jurídica – item 20
		Aspectos processuais da aplicação da teoria da desconsideração – item 21
		Teoria ultra vires societatis – item 22
	Administração das sociedades de pessoas – item 23	
	Sociedades não personificadas – itens 24-25	Sociedade em comum – item 24
		Sociedade em conta de participação – item 25

Sociedades no Código Civil – itens 23-31	Sociedade simples – itens 26-27	A regência normativa da sociedade simples – item 26
		Sociedade simples – item 27
	Sociedade em nome coletivo – item 28	
	Sociedade em comandita simples – item 29	
	Sociedade limitada – itens 30-31	Sociedade limitada – item 30 Características e regência – item 30.1 Sociedade limitada e sociedade simples – item 30.2 Regras aplicáveis à empresa individual de responsabilidade limitada – item 30.3
Conselho Fiscal na sociedade limitada – item 31		
Sociedades na LSA –	Características das sociedades por ações – item 32	
	Espécies – itens 33-38	Sociedade em comandita por ações – item 33
		Sociedade anônima – item 34
		Sociedade anônima de capital autorizado – item 35
		Sociedades abertas e fechadas – item 36
		Sociedade de economia mista – item 37
		Sociedade anônima multinacional – item 38
	Direitos essenciais do acionista – item 39	
	Ações – item 40	

ítems 32-48	Ações e valores mobiliários – itens 40-46	Valores mobiliários – aspectos gerais – item 41
		Debêntures – item 42
		Partes beneficiárias – item 43
		Bônus de subscrição – item 44
		Commercial papers – item 45
		Quadro-resumo – item 46
	Órgãos das sociedades por ações – itens 47-48	As assembleias – item 47
		Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal – item 48
Reorganização de sociedades – item 49		
Grupos de sociedades – item 50		
Dissolução de sociedades – itens 51-52	No Código Civil – item 51	
	Na LSA – item 52	

2. Teoria da empresa

Aplicam-se às relações empresariais o Código Civil e a legislação extravagante em matéria comercial, vigendo, ainda, substancial porção do Código Comercial: doze dos treze títulos da Parte Segunda, relativa ao Comércio Marítimo (arts. 457-756), observando que o Título IX (Naufrágios e salvados, arts. 731-739) foi revogado em 1986, pela Lei n. 7.542.

Até a promulgação do Código Civil de 2002, a legislação brasileira em matéria mercantil regia-se pela Teoria dos Atos de Comércio, construção de

origem francesa (Código Comercial de Napoleão, de 1807), adotada pelo legislador pátrio que elaborou o Código Comercial de 1850, a Lei Imperial n. 556.

O sistema francês centrava-se no conceito objetivo de comerciante – aquele que pratica atos de comércio com habitualidade e profissionalidade. A distinção entre atos de comércio e atos puramente civis mostrava-se de suma importância, sobretudo para permitir, ou não, a proteção da legislação comercial e, ainda, para fixar a competência judicial da matéria discutida pelos litigantes em juízo.

Com a adoção da Teoria da Empresa, grandemente desenvolvida pelo jurista italiano Alberto Asquini, o Código Civil brasileiro optou por introduzir o sistema italiano para a caracterização de atos empresariais.

É empresarial a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Será empresário aquele que exercer profissionalmente esta atividade.

Conquanto existam outras atividades econômicas com as mesmas características, preferiu o legislador limitar o conceito de empresariais, excluindo as profissões intelectuais, de natureza científica, literária ou artística.

Será, portanto, empresarial toda e qualquer atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, excluídas as decorrentes de profissão de cunho intelectual, de natureza científica, literária ou artística.

Não se deve perder de vista, entretanto, que sempre haverá atividades empresariais que compreendem serviços da natureza daqueles excluídos conceitualmente. Ao fornecer planos de saúde para a população, a administradora de serviços médicos está oferecendo serviços de natureza intelectual, de um oftalmologista, geriatra, urologista etc. Embora não se transmude a natureza desse serviço, a atividade da administradora de

serviços médicos é empresarial porque o exercício da atividade intelectual de medicina é elemento de sua empresa.

Percebe-se, assim, que as atividades excluídas do conceito são aquelas exercidas pessoalmente pelo profissional intelectual, pelo cientista, pelo escritor ou artista. Ao se constituírem elementos de empresa explorada por terceiro que administra e coordena essas atividades, serão necessariamente empresariais.

Serão empresariais as atividades que tenham as seguintes características: 1) economicidade: criação ou circulação de riquezas e de bens ou serviços patrimonialmente valoráveis; 2) organização: compreende tanto o trabalho, a tecnologia, os insumos e o capital, próprios ou alheios; 3) profissionalidade: refere-se à atividade não ocasional e à assunção em nome próprio dos riscos da empresa.

3. Perfis da empresa

O conceito poliédrico desenvolvido por Alberto Asquini concebe quatro perfis à empresa, visualizando-a, como objeto de estudos, por quatro aspectos distintos, a saber: a) perfil ou aspecto subjetivo; b) perfil ou aspecto objetivo; c) perfil ou aspecto funcional; e d) perfil ou aspecto corporativo ou institucional.

O primeiro aspecto – subjetivo – compreende o estudo da pessoa que exerce a empresa, isto é, a pessoa natural ou a pessoa jurídica (sociedades empresárias) que exerce atividade empresarial.

O segundo aspecto – objetivo – concentra-se nas coisas utilizadas pelo empresário individual ou sociedade empresária no exercício de sua atividade. São os bens corpóreos e incorpóreos que instrumentalizam a vida negocial. É essencialmente o estudo da Teoria do Estabelecimento Empresarial.

O terceiro aspecto – funcional – refere-se à dinâmica empresarial, ou

seja, a atividade própria do empresário ou da sociedade empresária, em seu cotidiano negocial. O termo empresa é concebido nesta acepção: exercício de atividade. Atividade nada mais é do que o complexo de atos que compõem a vida empresarial.

O quarto aspecto – corporativo ou institucional – volta-se ao estudo dos colaboradores da empresa, empregados que, com o empresário, envidam esforços à consecução dos objetivos empresariais.

No direito brasileiro o aspecto corporativo submete-se ao regramento da legislação trabalhista, daí por que Waldirio Bulgarelli prefere dizer que a Teoria Poliédrica da Empresa é reduzida, no Brasil, à Teoria Triédrica da Empresa, abrangendo tão somente os perfis subjetivo, objetivo e funcional, que interessam à legislação civil.

A partir desses elementos, Waldirio Bulgarelli define empresa como “atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário, em caráter profissional, através de um complexo de bens” (1995:100).

4. Empresários

O termo empresário substitui o vocábulo comerciante, mas, como deflui do conceito legal – art. 966 do CC –, é mais abrangente que este. Entre os atos de comércio que caracterizavam a atividade empresarial somente alguns se referiam à prestação de serviços, como, por exemplo, o transporte e a atividade bancária. No sistema empresarial, toda e qualquer produção ou circulação de serviços está submetida ao conceito de empresa, desde que não exercida pessoalmente por profissional intelectual, ou de natureza científica, literária ou artística.

Os empresários podem ser classificados em individuais ou societários. Os primeiros são pessoas naturais que exercem sua atividade individualmente, sem a colaboração de sócios, e os últimos, sociedades com fins

empresariais.

Com o advento da Lei n. 12.411, de 11 de julho de 2011, a classificação para o exercício individual da atividade econômica comporta uma subdivisão: (a) os simplesmente denominados empresários individuais cuja responsabilidade é ilimitada, alcançando todos seus bens pessoais; (b) as empresas individuais de responsabilidade limitada, de responsabilidade restrita ao valor do capital social integralizado.

Deve-se lembrar que as sociedades empresárias e as empresas individuais de responsabilidade limitada possuem personalidade jurídica. A afirmação decorre do disposto nos arts. 40-44 do CC que classifica as pessoas jurídicas em pessoas jurídicas de direito público – interno e externo – e pessoas jurídicas de direito privado, estas compreendendo as associações, sociedades e fundações (CC, art. 44).

A pessoa natural que exerce atividade empresarial de forma individual, sem constituir empresa individual de responsabilidade limitada, é pessoa capaz de direitos e obrigações na ordem civil; possui capacidade civil, atributo decorrente de sua condição humana.

As sociedades empresárias e as empresas individuais de responsabilidade limitada são construções legislativas, frutos da criação inventiva do homem e recebem capacidade de direitos e obrigações a partir de seu registro no órgão competente. Possuem personalidade não natural, também chamada ficta, legal ou jurídica.

5. Sociedades

Embora o art. 44 do CC inclua as sociedades como pessoas jurídicas, nem toda sociedade possui personalidade jurídica. É o que ocorre com as sociedades em comum – espécie de sociedade transitória – e a sociedade em conta de participação, reguladas pelos arts. 986-996 do CC.

Podemos, então, conceituar sociedade como “contrato em que pessoas

reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. É o que prevê o art. 981 do CC e no conceito legal estão presentes os principais elementos caracterizadores:

a) contrato: por instrumento público ou particular, registrado (todas as sociedades personificadas) ou não levado a registro (sociedade em comum e em conta de participação);

b) pessoas: a expressão genérica serve para abranger todas as possibilidades legais, isto porque a sociedade em nome coletivo somente pode ser constituída por pessoas naturais (CC, art. 1.039); a sociedade subsidiária integral somente pode ser constituída por pessoa jurídica (LSA, art. 251); a sociedade em comandita simples deve ser necessariamente formada por pessoas naturais na qualidade de sócios comanditados (CC, art. 1.045) e por pessoas naturais ou jurídicas como sócios comanditários;

c) contribuição com bens e/ou serviços e partilha dos resultados: a contribuição pessoal é essencial à constituição da sociedade, bem como a partilha dos resultados, sob pena de configurar-se sociedade leonina (veja item 9.4).

A definição do objeto social – atividade empresarial ou atividade intelectual, científica, literária ou artística – distinguirá as sociedades em empresárias e não empresárias.

6. Sociedades empresárias e sociedades simples

A expressão “simples” foi cunhada pelo legislador para distinguir as sociedades que exercem atividade econômica sem, contudo, submeterem-se à definição de empresariais.

“Simples”, no sistema da empresalidade, distingue a atividade empresarial da não empresarial, na mesma linha que, no sistema anterior, “sociedade civil” separava as sociedades não comerciais daquelas que

exerciam atos de comércio com habitualidade e profissionalidade.

Convém, contudo, acrescentar que a concepção legislativa brasileira atribuiu às sociedades simples duplo papel: o primeiro de distinguir o objeto social da atividade que será sempre não empresarial (CC, art. 982) e, o segundo, de prover modelo para os demais tipos societários (CC, arts. 996, 1.040, 1.046, 1.053 e 1.096).

No papel de sociedade distinta das empresariais, a sociedade simples pode revestir-se de outras formas constitutivas, à exceção da sociedade por ações. Por exemplo: uma sociedade de médicos será simples quanto ao objeto, mas, quanto à forma, poderá adotar o modelo da sociedade limitada. É uma sociedade simples porque seu objeto não é empresarial. E é limitada porque adotou o modelo de constituição dessas sociedades.

À exceção das sociedades cooperativas e das sociedades por ações, que, independentemente de seu objeto, foram classificadas pelo legislador, respectivamente, como simples e empresárias (CC, art. 982, parágrafo único), os demais tipos societários (em comum, em conta de participação, em nome coletivo, em comandita simples e limitada) poderão ser simples ou empresariais, conforme decorrer de seu objeto social (CC, art. 983).

Quanto à função de servir como padrão para outras sociedades, suas regras legislativas serão utilizadas pelos demais tipos societários, nos aspectos não específicos dessas sociedades, porque não previstos em contrato ou, ainda, porque o legislador deles não tratou. É o ocorre com questões que envolvem a administração da sociedade (CC, arts. 1.010-1.021), na relação com terceiros (CC, arts. 1.022-1.027), na resolução da sociedade em relação a um sócio (CC, arts. 1.028-1.032) ou, ainda, quanto à dissolução da sociedade (CC, arts. 1.033-1.038).

7. Classificação das sociedades

As sociedades podem ser classificadas por inúmeros critérios:

a) quanto à espécie legislativa, as sociedades podem ser: 1) em comum; 2) em conta de participação; 3) simples; 4) em nome coletivo; 5) em comandita simples; 6) limitada; 7) anônima; 8) em comandita por ações; e 9) cooperativas;

b) quanto à existência de personalidade jurídica: as sociedades são ordenadas em sociedades não personificadas e sociedades personificadas. As primeiras são as sociedades em comum (CC, arts. 986-990) e as em conta de participação (CC, arts. 991-996) e, as últimas, todas as demais. As segundas distinguem-se das primeiras porque possuem personalidade jurídica, o que decorre de sua constituição por documento inscrito no Registro Público (Registro Público das Empresas ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme sejam empresárias ou simples);

c) quanto às atividades desenvolvidas: as sociedades serão simples ou empresárias;

d) quanto à natureza da atividade econômica desenvolvida podem, ainda, ser chamadas empresárias por força de lei (CC, art. 982) ou por equiparação (CC, art. 984);

e) quanto à maior ou menor importância da *affectio societatis* ou do grau de dependência em relação às qualidades subjetivas dos sócios, as sociedades distinguem-se em sociedades de pessoas ou de capitais, havendo, ainda, entre os doutrinadores mais antigos quem vislumbre uma terceira modalidade: as sociedades mistas. São pessoais as sociedades em que o fator pessoal é preponderante para a realização do fim social: a incapacidade, a insolvência ou a morte do sócio podem acarretar a dissolução da sociedade. Nas sociedades de capital a garantia de terceiros e alienação da participação societária fundam-se exclusivamente no capital social;

f) quanto à identificação, as sociedades podem ser: 1) não identificadas por nome porque lhes falta personalidade jurídica. É o caso das sociedades

em comum e em conta de participação; 2) identificadas exclusivamente por firmas formadas por nomes pessoais dos sócios: sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples; 3) identificadas exclusivamente por denominação: sociedades anônimas; 4) identificadas por firmas ou por denominação social: as sociedades simples, as limitadas, as em comandita por ações;

g) quanto à subordinação de autorização para funcionamento, há sociedades que, para funcionar, dependem de autorização do Poder Executivo Federal. São as sociedades estrangeiras, as instituições financeiras em geral, as companhias hipotecárias, as sociedades de seguros, resseguros, previdência e capitalização;

h) quanto à nacionalidade, as sociedades são nacionais ou estrangeiras, distinguindo-se pelo critério de organização e sede: as nacionais são organizadas de conformidade com a lei brasileira e têm no Brasil a sede de sua administração. A contrario sensu, todas as que não atendem a esses requisitos são estrangeiras;

i) quanto às relações de capital, as sociedades são chamadas coligadas ou não coligadas. As primeiras são aquelas cujo capital ou parte dele pertence a outra sociedade. Subdividem-se em controladas por controle direto, controladas por controle indireto, filiadas ou de simples participação. A controlada por controle direto é aquela cujo capital pertence a sociedade que possui a maioria de votos nas deliberações, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores; a controlada por controle indireto é aquela cujo controle de ações ou cotas se encontra em poder de outra sociedade ou sociedades, que, por, por sua vez, é ou são controladas por outra, que possui a maioria de votos das deliberações, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores; filiada é a sociedade cujo capital na ordem de 10% ou mais, com direito a voto, pertence a outra sociedade, que, entretanto, não a controla; de simples participação é a sociedade cujo capital com direito a voto pertença em porção inferior a 10% a outra sociedade;

j) quanto à forma de constituição e dissolução, as sociedades são contratuais ou institucionais, isto é, ou se constituem por contrato social ou por adesão a um estatuto. São institucionais as sociedades regidas pela Lei das Sociedades por Ações e as cooperativas, e contratuais, todas as demais;

l) quanto à responsabilidade dos sócios, as sociedades podem ser classificadas em: 1) ilimitadas, nas quais todos os sócios possuem responsabilidade ilimitada, subsidiária ao capital social e solidária entre eles. É o que ocorre nas sociedades em nome coletivo; 2) limitadas: neste caso, integralizado o capital social, os sócios não mais respondem perante terceiros pela solvência da sociedade. Ocorre na sociedade anônima e na sociedade limitada, contudo há uma gradação de limitação: na sociedade anônima a responsabilidade de cada acionista é pessoal e independe do inadimplemento de outro sócio e, na sociedade limitada, a isenção de responsabilidade perante os credores da sociedade depende da integralização de todo o capital social, isto é, se um dos sócios não integralizar sua parte, todos os demais responderão solidariamente pelo que faltar; 3) mistas são as sociedades em que há sócios de ambas as categorias. É o que ocorre nas sociedades em comandita simples e por ações; nestas os sócios comanditados respondem ilimitadamente e os sócios comanditários, limitadamente.

8. Constituição das sociedades – requisitos comuns

Duas são as formas de constituição de sociedades: contratual e institucional, sendo esta última reservada para as sociedades por ações e cooperativas.

São elementos comuns a ambas as modalidades de constituição os três requisitos exigidos para os contratos em geral: a) agente capaz; b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e c) forma prescrita ou não defesa em lei.

8.1. Agente capaz

Quanto ao primeiro requisito, anota-se que, para garantir a continuidade da empresa, o Código Civil permite, na superveniência de eventos que envolvam a perda da capacidade ou morte de sócios, o prosseguimento do exercício empresarial por representação ou assistência legal.

Isto ocorre por força dos arts. 3º, 4º e 974 do CC. Os dois primeiros dispositivos tratam da hipótese de o titular se tornar incapaz de exprimir sua vontade, de forma transitória ou não, em razão de enfermidade ou deficiência mental, ou, ainda, tem seu discernimento reduzido em virtude de ebriedade habitual, vício em tóxico, bem como nos casos de desenvolvimento mental incompleto ou prodigalidade; o último – art. 974 – permite ao incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança.

Nas sociedades por ações os incapazes podem participar como acionistas, desde que detenham somente ações totalmente integralizadas. Serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores em seu status de acionista.

8.2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável

Lícito é tudo aquilo que não contraria a lei e está conforme o ordenamento jurídico.

Abrange, ainda, o conceito de licitude o quanto a Lei n. 8.934/94 (Lei de Registro Público de Empresas Mercantis) dispõe no inciso I do art. 35, ao proibir o arquivamento de “documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes ou à ordem pública (...)”.

Embora a noção de ordem pública seja inconsistente, conforme acentua Clóvis Beviláqua, há de corresponder ao senso jurídico de uma determinada

nação, isto é, aos princípios indispensáveis à vida em sociedade, segundo os preceitos do direito nela vigente.

Bons costumes são normas de procedimento nas relações sociais e no âmago da família; possuem conteúdo moral.

O objeto social deve ser possível, determinado ou determinável, não se admitindo que o contrato ou estatutos persigam fim impossível, isto é, “quando a prestação for irrealizável por qualquer pessoa, ou insuscetível de determinação” (Caio Mário da Silva Pereira, 1997, 1:311).

A determinação ou possibilidade de se determinar o objeto completa a exigência legal porque não é possível constituir sociedade sem se saber ao certo a finalidade pela qual se unem pessoas e capital.

8.3. Forma prescrita ou não defesa em lei

Para os contratos e estatutos de constituição de sociedades, a lei exige forma solene, escrita e plural.

Solene porque contêm requisitos especiais que os distinguem da forma permitida para outros contratos.

Escrita porque a atribuição de personalidade jurídica depende da inscrição no registro competente (Junta Comercial para as sociedades empresárias e Registro Civil das Pessoas Jurídicas para as sociedades simples). As exceções ficam por conta das sociedades não personificadas: em comum e em conta de participação, cujas constituições provam-se por quaisquer meios de direito.

Plural porque o legislador não impõe uma forma única, podendo os contraentes optar por uma ou várias formas fixas.

9. Constituição das sociedades – requisitos específicos

Além dos requisitos comuns à generalidade dos contratos, são elementos indispensáveis à constituição de qualquer sociedade: a) pluralidade de

sócios; b) constituição de capital social; c) affectio societatis; d) coparticipação nos lucros e perdas.

9.1. Pluralidade de sócios

A lei brasileira exige a reunião de duas ou mais pessoas, não sendo possível, em regra, no direito pátrio, a expressão sociedade unipessoal, preferindo o legislador brasileiro outra forma de unipessoalidade, atribuindo-a à empresa – não à sociedade – e denominando-a empresa individual de responsabilidade limitada.

A EIRELI mostra-se obsoleta a partir da sanção da LLE (Lei n. 13.874/2019), que alterou o Código Civil (art. 1.052, § 1º) e possibilitou o exercício da atividade econômica por uma única pessoa, sob a forma de responsabilidade limitada.

Entendemos que essa nova forma de exercício de atividade econômica que, na prática, a substitui, não é uma sociedade unipessoal, mas uma variação da empresa individual de responsabilidade limitada sem limitação de capital, permitida a qualquer atividade – simples ou empresarial.

Trata-se de uma nova pessoa jurídica de responsabilidade limitada, para a qual o legislador não encontrou denominação adequada, preferindo, à margem do sistema jurídico, denominá-la sociedade limitada unipessoal.

E, realmente, há dificuldade de dar-lhe um nome: empresa individual não é porque possível a adoção desse modelo para o exercício de atividades não empresariais.

E embora o sumário executivo da Lei n. 13.874/2019, redigido quando da tramitação no Senado Federal, proclame que o dispositivo previsto no art. 7º “admite sociedade limitada com apenas um sócio (sociedade limitada unipessoal) no novo parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil, seguindo tendência de países como Alemanha, China e Estados Unidos da América”,

na verdade não o faz.

Isto se afirma porque não há menção no novo texto legislativo de alteração do disposto no art. 981 do Código Civil que, textualmente, desabona a possibilidade de criação de uma sociedade unipessoal no Direito Brasileiro: “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício da atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Diversamente do que ocorre entre os sócios que celebram sociedade limitada, para se constituir uma pessoa jurídica em que o único instituidor responde limitadamente não há necessidade de contrato (ninguém contrata consigo mesmo). Nesse caso, o instituidor não contrata pessoa jurídica, mas simplesmente a institui.

Entre todas as dificuldades técnicas que apresenta, o texto aprovado inclui nova redação ao art. 980-A, § 7º, e afirma que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”.

Veja-se que, nesse dispositivo, o legislador utiliza o vocábulo “empresa” e não “sociedade”, dando a entender que longe de saber distinguir entre esses conceitos, pretendeu reafirmar que o exercício de empresa ou outra atividade econômica sob forma unipessoal se dá mediante a separação patrimonial (como já ocorre na EIRELI), não por celebração de “contrato unipessoal”.

A afirmação de que não é possível a constituição de sociedades unipessoais no Brasil, contudo, parece não ser absoluta, pois comportaria quatro exceções: subsidiária integral, empresa pública formada por capital de um único ente público e os dois casos de perda transitória desse requisito:

a) companhia subsidiária integral: constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira. Neste caso, permite-se que uma pessoa jurídica (uma sociedade por ações, constituída por dois ou mais sócios) possua todas as ações de outra sociedade, denominada subsidiária (LSA, art. 251);

b) empresa pública: criada por lei federal, estadual ou municipal, cujo capital seja formado exclusivamente de recursos públicos do ente que a criou;

c) sociedade prevista no Código Civil, que, momentaneamente, perde a pluralidade de sócio (art. 1.033, IV), podendo ser reconstituída no prazo de cento e oitenta dias. Sancionada a Lei n. 13.874/2019 (LLE), esse dispositivo passa a permitir ao sócio remanescente a transformação da sociedade em pessoa jurídica de responsabilidade limitada, constituída por uma só pessoa (CC, art. 1.052, § 1º);

d) sociedade por ações (não subsidiária integral) em que se verificar a existência de um único acionista. A sociedade subsistirá nesta condição até o ano seguinte ao da assembleia geral ordinária em que se verificou essa situação (LSA, art. 206, I, d).

Observa-se, contudo, que nos dois primeiros casos não transitórios acima anotados, o modelo distancia-se de um contrato de sociedade; trata-se, na verdade, de instituição de pessoa jurídica mediante separação de parcela patrimonial do instituidor. Exatamente como ocorre em outras pessoas jurídicas, como as EIRELI e as fundações.

Porém, todos os quatro casos distinguem-se do modelo de uma “sociedade unipessoal” formada por parcela de patrimônio de uma única pessoa natural, seja porque fere o modelo contratual previsto no art. 981 do Código Civil, seja porque afasta-se do princípio do patrimônio unitário também previsto nesse mesmo diploma, no art. 91.

9.2. Constituição do capital social

O patrimônio da sociedade é constituído por recursos pelos quais se obriga o sócio quando de seu ingresso no quadro social. Diz-se subscrito o capital prometido, mas ainda não integrado ao patrimônio da sociedade e integralizado o que efetivamente foi realizado pelos sócios a favor da sociedade.

O capital é sempre expresso em moeda corrente, mas a contribuição do sócio para sua formação pode ser realizada em dinheiro ou em qualquer outro bem suscetível de apreciação pecuniária, obedecendo, neste caso, às seguintes regras: 1) na hipótese de transmissão de domínio, de posse ou de uso de coisa a favor da sociedade, o sócio responde pela evicção; 2) em se tratando de cessão de crédito, o sócio responde pela solvência do devedor (CC, art. 1.005); 3) se a prestação se der pela entrega de imóvel, o contrato deve identificá-lo, descrevendo área, dados relativos à titulação, número de matrícula no Registro Imobiliário e outorga uxória ou marital, quando for o caso (Lei n. 8.934/94, art. 35, III e VII).

Quanto à realização do capital há, ainda, particularidades decorrentes do tipo societário: 1) nas sociedades por ações, há necessidade de realização em dinheiro, mediante depósito no Banco do Brasil, em valor mínimo equivalente a 10% do preço de emissão das ações subscritas (LSA, art. 80); 2) a transferência de bens a favor da sociedade por ações impõe sua avaliação por três peritos ou por empresa especializada (LSA, arts. 7º a 9º); 3) nas sociedades simples, admite-se que a contribuição se faça mediante prestação de serviços pessoais, vedando, ao sócio que assim o fizer, empregar-se em atividade estranha à sociedade, salvo convenção em contrário (CC, arts. 997, V, e 1.006); 4) nas sociedades limitadas, os sócios respondem solidariamente pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, pelo prazo de cinco anos, contados da data do registro (CC, art. 1.055).

Embora não se classifique como sociedade, o registro de uma empresa individual de responsabilidade limitada exige a constituição de um capital por uma única pessoa, titular de sua totalidade. Esse capital não pode ser inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País e deve ser devidamente integralizado no ato de sua constituição.

O legislador pátrio optou por conceder personalidade jurídica ao patrimônio separado a título de capital integralizado no momento de sua constituição. O mesmo ocorre com o ente jurídico fruto da Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), constituído por uma única pessoa para o exercício de qualquer atividade econômica, sob forma de responsabilidade limitada.

Assim, embora uma mesma pessoa disponha de duas massas patrimoniais, uma das quais para suportar as obrigações de sua atividade empresarial, é certo que, no momento da instituição da empresa individual de responsabilidade limitada ou desse novo ente jurídico, nasce uma pessoa jurídica, distinta da pessoa de seu titular.

Na criação desse novo instituto, o legislador teve o cuidado de respeitar o princípio da unidade patrimonial.

Deve-se compreender que se trata de duas pessoas distintas: a pessoa (natural ou jurídica) constituidora de outra pessoa, jurídica, denominada empresa individual de responsabilidade limitada. Cada uma das pessoas mantém uma única massa patrimonial.

9.3. Affectio societatis

Denomina-se *affectio societatis* ou *animus contrahendi societatis* a disposição de o contraente participar de sociedade, contribuindo ativamente à consecução de objeto comum, com vistas à partilha de lucros.

Carvalho de Mendonça (1958, 3:22-23) arrola quatro elementos essenciais à *affectio societatis*: (1) colaboração ativa, (2) consciente e (3)

igualitária dos contratantes (4) para realização de um lucro a partilhar.

9.4. Coparticipação nos lucros e perdas

É nula a cláusula social que exclua o sócio de participar dos lucros e das perdas (CC, art. 1.008), o que vale dizer que cada sócio toma parte nas perdas, na proporção de sua cota e, igualmente, recebe os lucros da empresa, na mesma medida.

Quando o contrato ou estatutos ferem este princípio, diz-se que a sociedade é leonina.

10. Modalidades de constituição de sociedades

Quanto à forma de constituição e de dissolução, as sociedades podem ser classificadas em sociedades contratuais e sociedades institucionais, ou estatutárias. As primeiras são as reguladas pelo Código Civil e as segundas, as sociedades cooperativas e as previstas na Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76).

Presentes os requisitos comuns e específicos, o contrato celebrado pelos sócios é levado a registro no órgão competente. Em se tratando de sociedade empresária, caberá à Junta Comercial do Estado em que tenha sede proceder ao arquivamento dos atos constitutivos; se a sociedade desenvolver objeto não empresarial, será considerada sociedade simples e o órgão registrário é o Cartório Civil das Pessoas Jurídicas.

10.1. Requisitos comuns

Para as sociedades por ações a lei estabeleceu duas modalidades de constituição: privada e pública, também conhecidas pelas expressões “simultânea” e “sucessiva”.

Em ambas as modalidades, os acionistas fundadores deverão conhecer o projeto de constituição, no qual deve constar: o objeto a que se propõem os

idealizadores, a definição da sede, o valor inicial do capital, o número de ações e acionistas e outros aspectos de interesse dos instituidores. É o projeto de estatuto.

Subscritas todas as ações em que se divide o capital social, impõe-se que, no mínimo, o equivalente a 10% do preço de emissão dessas ações seja realizado em dinheiro, o que se faz mediante depósito em estabelecimento bancário.

10.2. Constituição privada ou simultânea

Dá-se a constituição privada pela deliberação dos subscritores, aprovando a constituição da sociedade e os termos estabelecidos nos estatutos que lhe foram apresentados, o que pode ocorrer em assembleia geral ou mediante escritura pública.

O arquivamento dos atos constitutivos da nova sociedade se fará na Junta Comercial do Estado em que tem sede e exigirá a apresentação de: a) um exemplar do estatuto social, assinado por todos os subscritores; b) a relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo presidente da assembleia, dos subscritores do capital social, contendo qualificação, número de ações e o total de entrada de cada um deles; c) recibo de depósito do valor mínimo; d) cópia das atas das assembleias realizadas para a avaliação de bens, quando for o caso; e) cópia da ata da assembleia geral dos subscritores que houver deliberado sobre a constituição da companhia.

Se os subscritores optarem pela constituição mediante documento público, esses elementos deverão estar transcritos na escritura que, devidamente assinada por todos os subscritores, será encaminhada para registro.

10.3. Constituição sucessiva ou pública

O chamamento público de investidores é reservado para as companhias abertas, cujos valores mobiliários são admitidos à venda em bolsas ou mercado de balcão (veja item 36).

A lei exige maiores cuidados impondo complexo procedimento de constituição que, didaticamente, pode ser compreendido em sete distintas fases: 1) fase preliminar do projeto: além do projeto de estatuto social, os fundadores deverão elaborar um projeto de viabilidade econômica e financeira, contendo os requisitos do art. 84 da LSA; 2) fase de registro na Comissão de Valores Mobiliários: os fundadores devem requerer à CVM autorização para a emissão das ações, juntando os dois primeiros documentos; 3) fase de subscrição: a oferta das ações se dará por instituição financeira autorizada; neste momento o subscritor assina a lista ou boletim individual e apresenta dados de sua qualificação. É possível a dispensa da assinatura da lista ou do boletim de subscrição “na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários” (LLE, art. 8º); 4) fase de avaliação: encerrada a subscrição com a subscrição do total do capital social, os fundadores convocarão assembleia geral com a finalidade de promover a avaliação de bens que eventualmente tenham sido oferecidos à integralização de ações subscritas; 5) fase de deliberação de constituição: superada a fase precedente, os subscritores, devidamente convocados pelos fundadores, reunir-se-ão para deliberar acerca da constituição. Deverão estar presentes, em primeira convocação, subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social e, em segunda convocação, qualquer número de subscritores; 6) fase de eleição dos primeiros administradores: segue-se à constituição, obedecendo ao que dispuserem os estatutos recém-aprovados; 7) fase de registro: que se fará acompanhar dos mesmos documentos exigidos na subscrição privada.

11. Direitos e deveres dos sócios

Entre os direitos e deveres a que se submetem os sócios nas distintas formas societárias, aplicam-se às sociedades de uma forma geral os especificados a seguir.

11.1. Dever de contribuir

Os sócios obrigam-se a ingressar com os aportes estabelecidos na forma e prazo previstos no contrato ou no estatuto social, sob pena de serem considerados remissos, sujeitando-se aos efeitos da mora: a) cobrança do valor devido à integralização subscrita, acrescido da indenização devida pelo dano efetivo causado ao patrimônio social; b) redução do capital social pela exclusão do sócio remisso do quadro social; c) redução do capital social em razão da diminuição da participação do sócio remisso ao montante por ele realizado.

11.2. Dever de probidade nas deliberações e gestão social

O sócio a que for incumbida gestão da sociedade deve conduzir-se com cuidado e diligência que “todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios” (CC, art. 1.011).

Exemplificando a conduta esperada, o legislador estabeleceu alguns princípios de probidade na condução dos negócios sociais: 1) abstenção de distribuir ou de receber lucros fictícios (CC, art. 1.009); 2) abstenção de participar de deliberação quando tiver, em alguma operação, interesse contrário ao da sociedade (CC, art. 1.010, § 3º); 3) realizar operações administrativas em consenso com a maioria (CC, art. 1.013, § 2º).

11.3. Direito-dever de coparticipação nos lucros e perdas

Em regra, em qualquer modalidade societária, o sócio fica sujeito à participação nos lucros e nas perdas, na proporção de sua quota. Por exemplo: se sua cota social representa 40% do capital, esta será a

proporção nos lucros e nas perdas havidas no exercício. É possível que o contrato estipule outra divisão, distinta da cota social, entretanto, a legislação pátria não permite eximir por completo o sócio de participação nas perdas ou atribuir-lhe com exclusividade os lucros (CC, art. 1.008).

Como se dá a estimação da participação do sócio cuja contribuição consiste em serviços? Se o contrato não prevê valores, o sócio laborista somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas.

11.4. Direito de participar das deliberações

Como regra geral aos sócios compete decidir sobre os negócios da sociedade. Anote-se, porém, que nem todas as deliberações são objeto de consulta ao corpo social, cabendo aos administradores – sócios ou não – a condução da maior parte dos negócios, independente de reunião com os titulares das cotas sociais.

Nas decisões mais importantes, os sócios podem ser consultados informalmente, sem a necessidade de registro da deliberação. Em regra, a decisão respeitará o deliberado pela maioria, prevalecendo o princípio da probidade na gestão administrativa, segundo o qual “responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria” (CC, art. 1.013, § 2º).

Há casos, contudo, em que a lei, o contrato social ou os estatutos preveem a deliberação dos sócios que, neste caso, deverão ser convocados para decidir, em reunião ou em assembleia de sócios.

Algumas hipóteses foram previstas pelo legislador:

1) Na sociedade simples, as modificações que impliquem alteração das cláusulas previstas no art. 997 somente podem ser realizadas pelo consentimento de todos os sócios (CC, art. 999, caput), todas as demais serão decididas por maioria absoluta, salvo estipulação que obrigue

deliberação unânime (CC, art. 999, parágrafo único). Deliberarão, nesses casos, por maioria absoluta, pelo voto correspondente a mais da metade do capital (CC, art. 1.010).

2) Na sociedade em comandita simples, embora os sócios comanditários sejam proibidos da prática de atos de gestão, a lei lhes faculta o direito de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações (CC, art. 1.047).

3) Na sociedade limitada, as matérias previstas no art. 1.071 dependem de deliberação dos sócios. Observe o seguinte quadro:

INCISO	MATÉRIA	QUORUM
I	Aprovação das contas da administração.	Maioria dos presentes ou maioria mais elevada prevista no contrato.
II	Designação administradores efetivada em ato separado do contrato social.	Mais da metade do capital social.
III	Destituição dos administradores.	Mais da metade do capital social.
IV	Modo de remuneração dos administradores designados em ato separado do contrato social.	Mais da metade do capital social.
V	Modificação do contrato social.	3/4 do capital social.
VI	Incorporação, fusão e a dissolução da sociedade, bem como a cessação do estado de liquidação.	3/4 do capital social.
VII	Nomeação e destituição do liquidante e o julgamento de suas contas.	Maioria dos presentes ou maioria mais elevada prevista no contrato.
VIII	Pedido de recuperação de empresa em juízo.	Mais da metade do capital social.

Reunião de sócios é o encontro de cotistas, mediante convocação

anterior, em local e hora previamente determinados, para deliberação de matérias de interesse da sociedade, previstas no contrato social ou na lei. A formalização do encontro obedece ao que dispuser o contrato social ou, na sua omissão, o quanto previsto pelo legislador para as assembleias de sócios.

Distingue-se da assembleia de sócios porque esta obedece ao regramento que o legislador civil concebeu; a reunião de sócios segue fórmula de consenso prevista no contrato social e pode revestir-se de menor formalidade quanto à convocação, instalação e registro das deliberações.

Quando ocorrem reuniões e/ou assembleias?

À exceção das sociedades por ações, que possuem rígido regramento acerca das assembleias ordinárias e extraordinárias, cabe ao contrato social decidir a modalidade do encontro deliberativo. Será, contudo, obrigatória a convocação de assembleia de sócios quando o número de sócios na sociedade limitada for superior a dez (CC, art. 1.072, § 2º).

Em qualquer caso, contudo, se os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto da reunião ou da assembleia, dispensa-se a convocação.

A deliberação acerca de pedido de autofalência não foi prevista no Código Civil e, tampouco, na Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Contudo, é matéria que, a nosso ver, ultrapassa os limites dos poderes gerais de administração, devendo ser precedida de deliberação dos sócios a respeito. Atenta a esta consideração, a Lei das Sociedades por Ações estabelece a competência privativa da assembleia geral para deliberar, entre outros importantes assuntos, sobre a autorização para os administradores confessarem a falência (LSA, art. 122, IX).

De suma importância observar que na sociedade por ações nem todos os sócios têm direito de participar das deliberações sociais, faculdade concedida tão somente aos detentores de ações ordinárias. Distintamente, portanto, do que sucede nas modalidades societárias previstas no Código

Civil, a participação nas deliberações sociais não se inclui entre os direitos essenciais do acionista.

11.5. Direito de fiscalização

Todo sócio tem o direito de fiscalizar o andamento dos negócios sociais. Para o exercício desse direito, a lei lhe faculta examinar a qualquer tempo, ou em data que o contrato estipular, os livros e documentos sociais, o estado do caixa e da carteira da sociedade (créditos e débitos da sociedade).

Se alguma dúvida persistir, o sócio pode exigir a prestação de contas a qualquer tempo ou nas épocas que estiverem determinadas no contrato. Pode, ainda, interpelar judicial ou extrajudicialmente os administradores e, em especial, nos casos em que estes não apresentarem, no tempo certo, o inventário anual, o balanço patrimonial e o resultado econômico dos negócios.

11.6. Direito de participar do acervo, em caso de liquidação

A dissolução da sociedade, por consenso dos sócios ou decisão judicial, acarreta sua liquidação, procedimento que envolve a realização do ativo e pagamento dos credores. Satisfeitos os créditos de terceiros, o sócio terá direito de participar do rateio do acervo, na proporção de sua cota.

Mesmo sem liquidação definitiva, a maioria pode deliberar a distribuição do acervo por antecipação da partilha, à medida que forem apurados os haveres sociais que sobejarem após os pagamentos feitos aos credores (CC, arts. 1.107 e 1.108, e LSA, art. 215).

11.7. Direito de preferência

Nas sociedades simples, em nome coletivo e comandita simples o aumento de capital depende da anuência de todos os sócios que

deliberarão a cota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la (CC, arts. 997, IV, 999, 1.040 e 1.046). Não há direito de preferência, submetendo-se a deliberação ao consenso da unanimidade.

Na sociedade limitada, a situação é distinta. Após a integralização das cotas permite-se o aumento do capital, facultando-se aos sócios, trinta dias após essa deliberação, exercer o direito de preferência em subscrever novas cotas, na proporção de sua participação (CC, art. 1.081).

Assim, se o sócio detém participação de 35% das cotas sociais o direito de preferência lhe permite participar nessa mesma proporção (35%) do aumento deliberado. Isto lhe garantirá manter a mesma participação nas futuras deliberações sociais.

Os sócios, porém, são livres para ceder seu direito de preferência a outro sócio, independente de consulta aos demais (CC, arts. 1.081, § 2º, e 1.057).

Nas sociedades por ações, o direito de preferência pode ser exercido no prazo decadencial que dispuserem os estatutos da companhia ou a deliberação da assembleia geral, fixando a lei o mínimo de trinta dias (LSA, art. 171, § 4º). A operação se fará conforme previsto nos arts. 109, IV, 171 e 172 da LSA, e deverá obedecer ao princípio da proporcionalidade, respeitado o número de ações que os acionistas possuírem em distintas espécies e classes.

O legislador da Lei das Sociedades por Ações distingue três situações: a) a criação de novas ações abrange todas as espécies e classes na mesma proporção; b) a criação de novas ações importa alteração nas respectivas proporções do capital social; c) novas espécies ou classes não existentes são criadas.

No primeiro e terceiro casos, o acionista terá o direito de exercer sua preferência na mesma proporção das que possuir; na segunda hipótese, o direito de preferência se dará sobre as classes e espécies que o acionista possuir, podendo estender sobre as demais se aquelas forem insuficientes

para lhe assegurar a mesma proporção no capital social.

11.8. Direito de retirada

Ordinariamente, o sócio pode retirar-se, a qualquer tempo, da sociedade se o contrato foi celebrado por prazo indeterminado.

Nas sociedades reguladas pelo Código Civil o sócio que pretende retirar-se deverá notificar os demais sócios com antecedência mínima de sessenta dias (CC, art. 1.029). Dentro de trinta dias subsequentes à notificação, os demais sócios poderão optar por dissolver a sociedade (CC, art. 1.029, parágrafo único).

Se, entretanto, o contrato prevê duração determinada, a retirada deve ter o consentimento unânime dos sócios ou ser motivada por justa causa alegada pelo dissidente, a ser apreciada pelo Poder Judiciário em ação de resolução de sociedade.

Além das hipóteses de justa causa, há outras objetivamente consignadas pelo legislador, a primeira aplicável para a sociedade limitada e a segunda destinada a todas as sociedades reguladas pelo Código Civil: a) nos casos de “modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra” (art. 1.077), permitindo o direito de recesso dentro de trinta dias subsequentes à reunião; b) na transformação da sociedade (art. 1.114).

Nas sociedades por ações, o direito de retirada, também chamado de dissidência ou de recesso, é previsto em diversos dispositivos da LSA e pressupõe inconformismo com as deliberações tomadas pelos órgãos administrativos:

Deliberação aprovada pela assembleia	Observação
art. 136-A – aprovação da inserção de	

convenção de arbitragem no estatuto social.	
art. 136, I – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto.	Somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas (art. 137, I).
art. 136, II – alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida.	
art. 136, III – redução do dividendo obrigatório.	
art. 136, IV – fusão da companhia, ou sua incorporação em outra.	Não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação (art. 137, II).
art. 136, V – participação em grupo de sociedade (art. 265).	
art. 136, VI – mudança do objeto da companhia.	
	Somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja

art. 136, IX – cisão da companhia.	atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida; b) redução do dividendo obrigatório; ou c) participação em grupo de sociedades (art. 137, III).
Na transformação de sociedade, art. 221.	Salvo cláusula de renúncia, no contrato social, ao direito da retirada.
Na incorporação ou fusão de sociedades, art. 225, IV.	
Na constituição de sociedade de economia mista por desapropriação, art. 236, parágrafo único.	Salvo se a companhia já se achava sob o controle, direto ou indireto, de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso de concessionária de serviço público.
Na incorporação de ações na companhia subsidiária integral (art. 252, § 1º).	Idem ao art. 136, IV.
Na alienação do controle da companhia (art. 256).	Somente na hipótese do art. 256, § 2º, quando o preço da aquisição ultrapassar os valores que menciona.
Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada (art. 264, § 3º).	Idem ao art. 136, IV.
Na aprovação de convenção de grupo de sociedades (art. 270, parágrafo único).	

Em qualquer sociedade, contudo, regida por contrato ou estatuto, por prazo determinado ou indeterminado, o sócio que pretende retirar-se pode fazê-lo cedendo sua cota ou ação a terceiros.

Na sociedade anônima o direito de ceder ações é livre, salvo se houver acordo de acionistas que impeça a livre negociação.

Nas sociedades regidas pelo Código Civil, a cessão das cotas está sujeita

a determinadas condições: a) nas sociedades simples, em nome coletivo e comandita simples depende do consentimento de todos os sócios (arts. 1.003, 1.040 e 1.046); b) na sociedade limitada, salvo outra previsão contratual, o sócio pode ceder sua participação – parcial ou total – a outro sócio, sem a audiência dos demais; na cessão a pessoa estranha ao quadro social, impõe-se a não oposição de mais de um quarto do capital social. Devem os sócios ser ouvidos quanto à pretensão do dissidente para, querendo, apresentarem oposição.

12. Resolução da sociedade em relação a sócio – casos de retirada

Embora os arts. 1.028-1.032 do Código Civil, que tratam da “Resolução da sociedade em relação a um sócio”, limitem-se a regular três situações – retirada, exclusão ou morte de sócio –, as hipóteses podem ser desdobradas em pelo menos quatorze situações, agrupadas em: casos de retirada, de exclusão de sócios, resolução por morte e de pleno direito.

Os primeiros grupos de situações (retirada por cessão ou recesso e exclusão) foram tratados no estudo dos direitos e deveres do sócio (direito de retirada – supra 11.8), sendo necessário desenvolver algumas linhas acerca dos dois últimos, que se referem à exclusão de sócio e aos eventos morte, falência e execução da cota social.

13. Resolução da sociedade em relação a sócio – casos de exclusão

13.1. Exclusão de sócio remisso

A contribuição para formação do capital social é um dos principais deveres do sócio e, ao deixar de cumpri-lo, o sócio expõe a sociedade ao risco de não atingir seus objetivos sociais.

Sócio ou acionista remisso é aquele que não paga, no prazo e forma

acordados, a importância que originalmente prometeu integralizar, ficando em mora diante da sociedade.

Nas sociedades previstas no Código Civil, se um dos sócios se tornar remisso, os outros sócios poderão notificá-lo para que cumpra com suas obrigações sociais em até trinta dias, sob pena de responder pelo dano emergente da mora (art. 1.004). Decorrido este prazo, os demais sócios deliberarão entre as seguintes soluções: a) exigir a indenização; b) excluir o sócio remisso; c) reduzir sua cota ao montante já realizado (art. 1.004, parágrafo único).

Se a sociedade é limitada, os sócios podem ainda: a) tomar a cota do remisso para si; b) transferi-la para terceiro. Em ambos os casos o primitivo titular é excluído e se lhe devolve o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas (CC, art. 1.058).

Nas sociedades por ações (LSA, art. 107), a companhia pode executar o acionista remisso para receber as importâncias faltantes ou vender as ações em bolsa de valores, em leilão especial previamente comunicado mediante publicação de aviso. O comprador pagará o preço das ações e integrará o quadro social no lugar do acionista excluído. A sociedade colocará à disposição do remisso as importâncias decorrentes da integralização parcial do capital subscrito, deduzidas as despesas com a operação e, se previsto no estatuto, os juros, correção monetária e multa.

Se, entretanto, a sociedade não obtiver resultados com a execução ou com a venda pública, resta-lhe a possibilidade de integralizar as ações com lucros ou reservas que dispuser. Se, ainda assim, não for possível fazê-lo, as ações aguardarão pelo prazo de um ano, até caírem em comisso, expressão que indica sua caducidade, não mais possuem direito à integralização e, conseqüentemente, acarretam redução do capital social em importância correspondente.

13.2. Exclusão por deliberação judicial

Nas sociedades previstas no Código Civil, à exceção da excepcionalidade da sociedade limitada que será objeto de tópico próximo, a exclusão de sócio, ou sócios minoritários, se dará pela forma estabelecida no art. 1.030.

Os sócios que compõem a maioria deverão ingressar em juízo indicando a ocorrência de falta grave praticada pelo faltoso no cumprimento das obrigações. O legislador não discriminou as hipóteses de justa causa (CC, art. 1.030) que devem, assim, ser encontradas na doutrina. Franco Di Sabato (1999:90) considera justa causa a “que não permite o normal prosseguimento das relações sociais e que seja decorrente do comportamento de outros sócios, consistente na violação de obrigações contratuais específicas ou dos deveres de boa-fé e de probidade”.

13.3. Exclusão por incapacidade superveniente

A mesma solução é encontrada na superveniência de incapacidade do sócio. Os sócios que compõem a maioria deverão suscitar em juízo a exclusão do incapaz, dando-se, então, a liquidação de sua participação, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da declaração da incapacidade, verificada em balanço especialmente levantado.

13.4. Exclusão por deliberação extrajudicial

Nas sociedades limitadas os sócios podem deliberar a exclusão do sócio minoritário pela simples alteração do contrato social.

Trata-se de sanção aplicável extrajudicialmente por aqueles que detêm mais da metade do capital social, fundamentada em atos praticados por sócio (ou sócios) minoritário que, por sua inegável gravidade, põem em risco a continuidade da empresa.

O título da rubrica do dispositivo que trata da matéria (CC, art. 1.085) indica que a resolução extrajudicial somente se dará em relação aos sócios

minoritários. Isto porque, se os atos forem praticados por sócio (ou sócios) que representa metade ou maior parcela do capital social, inviável é a deliberação em reunião ou assembleia de sócios, restando aos minoritários valer-se da via judicial (veja item 13.2, supra).

14. Resolução da sociedade em relação a sócio – casos de morte e de pleno direito

A morte nem sempre acarreta a liquidação da cota social, podendo ocorrer outras soluções, como, por exemplo, o ingresso de herdeiros, permitido em contrato social ou por acordo com os sócios remanescentes. O contrato pode prever outras formas que evitem a liquidação da cota (aquisição pelos demais sócios, exercício de direito de preferência por acordo anterior etc.). Por deliberação posterior ou previsão contratual, os sócios poderão, ainda, optar pela dissolução total da sociedade.

Assim, falecido um dos sócios, e no silêncio do contrato social, podem os demais optar por: a) dissolver a sociedade (CC, art. 1.028, II); b) acordar, com os herdeiros, sua substituição no quadro social (CC, art. 1.028, III); ou c) pagar o valor da cota aos herdeiros, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, que coincide com a do evento morte, verificada em balanço especialmente levantado (CC, art. 1.031, caput).

A falência de sócio acarreta sua retirada da sociedade da qual participa em virtude da arrecadação de todos os seus bens nos autos falimentares para realização do ativo e pagamento dos credores da massa.

Similar é a solução legal para a falta ou insuficiência de bens executáveis: a cota social pode ser objeto de liquidação para pagamento de dívida pessoal de seu titular.

Em todos estes casos de resolução da sociedade em relação a um sócio, a venda das cotas sociais não obedece ao procedimento previsto na execução falimentar ou individual. Em razão da natureza pessoal das

sociedades previstas no Código Civil os sócios remanescentes não estão obrigados a permitir a substituição do executado ou falido por pessoa estranha, adquirente de sua participação acionária.

Nas sociedades simples, em nome coletivo, em comandita simples e limitadas regidas subsidiariamente pela sociedade simples a liquidação da cota do sócio obriga à redução do capital, no montante correspondente ao que pertencia ao retirante, salvo se os demais suprirem aquele valor (CC, art. 1.031, § 1º).

Na apuração do valor a ser liquidado observar-se-á o montante efetivamente realizado, com base em balanço especialmente levantado, salvo se prevista, no contrato social, outra forma de levantamento da participação social do falido (CC, art. 1.031, caput).

O prazo para a apuração e depósito do valor apurado nos autos de execução ou de falência é de noventa dias após o requerimento de liquidação pelo exequente ou pela massa falida, salvo se outra estipulação não decorrer de acordo ou do contrato social (CC, art. 1.031, § 2º).

É possível que a liquidação da cota de um sócio acarrete a dissolução total da sociedade, seja porque esta solução foi prevista no contrato social, ou porque posteriormente deliberaram os sócios remanescentes e, ainda, porque se trata de sociedade constituída por apenas dois sócios. A massa falida, os credores ou herdeiros e legatários arrecadarão a participação do sócio falido e aguardarão a realização do ativo na liquidação da sociedade dissolvida.

Nas sociedades por ações a liquidação da participação acionária se faz sem qualquer dificuldade: as ações penhoradas passam a pertencer a terceiro que as adquire por força de execução individual ou falimentar, ou, ainda, por sucessão hereditária.

15. Responsabilidade dos sócios

Entende-se responsabilidade primária o princípio jurídico previsto no art. 789 do CPC15, segundo o qual qualquer pessoa responde sempre de forma ilimitada, com bens presentes e futuros pelas obrigações assumidas.

É secundária a responsabilidade, legal ou contratual, que sujeita outras pessoas e seus patrimônios às obrigações do devedor primário.

O sócio com responsabilidade ilimitada é responsável secundário pelas obrigações da sociedade. A sociedade responde com patrimônio próprio pelas obrigações assumidas e, em segundo plano, nos casos em que a lei prevê e o contrato admite, os sócios responderão pelas dívidas sociais, observado o benefício de ordem – *beneficium excussionis personalis* –, ou seja, o direito de o sócio exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade.

Nas sociedades em que a responsabilidade do sócio é limitada, cumprida a obrigação de integralização do capital assumida no contrato, pelo sócio (individualmente – como ocorre na sociedade anônima) ou por todos os sócios (como ocorre na sociedade limitada), os contratantes, ordinariamente, não mais respondem por dívidas sociais.

Há sociedades, contudo, em que os tipos obrigacionais se misturam, coexistindo sócios que respondem de forma ilimitada, com ou sem o benefício de ordem; sócios que se obrigam de forma limitada, respondendo pela integralidade do capital subscrito, ou, ainda, somente pela parte individualmente contratada e, por fim, sócios que não se obrigam perante terceiros.

De forma geral, portanto, seriam três as classes de sociedades, conforme a responsabilidade dos sócios, como deflui da doutrina de Eunápio Borges (1959: 19-20):

“I – sociedades de responsabilidade ilimitada são aquelas nas quais todos os sócios, sem exceção, respondem ilimitadamente pelas obrigações contraídas pela sociedade. No caso do direito pertencem a essa classe: a)

as sociedades em nome coletivo; b) as sociedades irregulares de qualquer tipo [estas, segundo o atual Código Civil, chamadas simplesmente de sociedades em comum];

II – sociedades de responsabilidade limitada são aquelas nas quais todos os sócios respondem limitadamente pelas obrigações da sociedade. Só temos dois tipos de sociedade de responsabilidade limitada: a) as sociedades anônimas; b) as sociedades por quotas de responsabilidade limitada [estas últimas, hoje, nominadas simplesmente como sociedades limitadas];

III – sociedades por cotas de responsabilidade mista são todas aquelas em que há duas espécies de sócios, uns que respondem ilimitadamente e outros que ou não têm qualquer responsabilidade de ordem pecuniária ou respondem limitadamente pelas obrigações sociais. São elas: sociedades em comandita simples; sociedades em comandita por ações; sociedades de capital e indústria”.

A este número deve-se anotar o desaparecimento, na nova legislação civil, da sociedade de capital e indústria e acrescentar a sociedade em conta de participação, elevada à condição de sociedade, e cujo sócio meramente participante, ou oculto, não tem qualquer responsabilidade perante terceiros credores.

Com essas noções, resulta existirem no direito brasileiro sete tipos ordinários de responsabilidade de sócios perante os credores:

a) ausência completa de responsabilidade perante terceiros, salvo dolo ou fraude de sua parte: hipótese que ocorria na extinta sociedade de capital e indústria (CCom, art. 321) e hoje permanece na sociedade em conta de participação, com referência ao sócio participante (CC, art. 991, parágrafo único);

b) responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, como é o caso dos sócios acionistas das sociedades anônimas

(LSA, art. 1º, e CC, art. 1.088) e dos sócios comanditários das sociedades em comandita por ações (LSA, arts. 280 e 281);

c) responsabilidade individual limitada à integralização do capital subscrito pelos sócios comanditários (CC, art. 1.045), nas sociedades em comandita simples;

d) responsabilidade pelo total do capital social não integralizado, solidariamente com os demais sócios, nas sociedades limitadas (CC, art. 1.052);

e) responsabilidade pelo saldo das dívidas da sociedade, na hipótese de os bens sociais não cobrirem as dívidas, na proporção em que participem das perdas sociais: aos sócios das sociedades simples (CC, art. 1.023);

f) responsabilidade ilimitada e solidária entre os sócios, de forma subsidiária ao patrimônio social atribuída: a todos os sócios na sociedade em nome coletivo (CC, art. 1.039); ao sócio ostensivo (CC, art. 991) na sociedade em conta de participação; ao sócio comanditado (CC, art. 1.045) nas sociedades em comandita simples e nas sociedades em comandita por ações (LSA, arts. 281 e 282); ao sócio não tratador, na sociedade em comum (CC, art. 990) e ao sócio da sociedade simples, se assim for estipulado no contrato social (CC, art. 997, VII);

g) responsabilidade ilimitada e solidária entre os sócios da sociedade em comum, pelas dívidas assumidas em nome da sociedade, não podendo ser invocada o benefício de ordem ou a subsidiariedade ao patrimônio social (CC, art. 990).

É possível ilustrar em quadro os tipos de responsabilidade patrimonial dos sócios perante terceiros, por dívida da sociedade, conforme dispõem as mencionadas leis societárias:

TIPO DE SÓCIO	RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS	ORDINÁRIA
De indústria (ou outísta sociedade de capital de		

• De indústria (na extinta sociedade de capital de indústria); • Participante (oculto: na sociedade em conta de participação).	Nenhuma.
• Acionista (S/A); • Comanditário (na comandita por ações).	Preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
• Comanditário (na comandita simples).	Integralização do capital subscrito.
• Cotista (Ltda.).	Total do capital não integralizado, solidariamente.
• Cotista (na sociedade simples).	Pelo saldo, na proporção em que participe das perdas sociais, subsidiariamente ao patrimônio social.
• Sócio em nome coletivo; • Sócio de capital (na extinta de capital e indústria); • Sócio ostensivo (na sociedade em conta de participação); • Sócio comanditado (nas sociedades em comandita simples e nas sociedades em comandita por ações); • Sócio de sociedade simples, quando houver cláusula de solidariedade; • Sócio não tratador nas sociedades em comum.	Ilimitada e solidária entre os sócios, subsidiariamente ao patrimônio social.
• Sócio tratador nas sociedades em comum.	Ilimitada e solidária, de forma não subsidiária ao patrimônio social.

16. Responsabilidade de sócio com responsabilidade ilimitada, por ingresso e retirada

Verificamos que a condição dos sócios com responsabilidade ilimitada os conduz a um tratamento legislativo uniforme. Os sócios em nome coletivo,

ostensivo, comanditado e sócio em comum não tratador recebem idêntico tratamento legal: todos respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, subsidiariamente (em segundo plano) ao patrimônio social, podendo valer-se do benefício de ordem.

Outras situações podem surgir durante a vida da sociedade: a retirada voluntária, por exclusão ou morte, e o ingresso na sociedade no curso de suas atividades, substituindo sócio que se retirou ou subscrevendo aumento de capital.

Fica então a indagação: Se o sócio com responsabilidade ilimitada ingressa na sociedade em virtude de aumento de capital ou adquirindo cotas de outro que se retira, responderá pelas dívidas existentes antes de seu ingresso?

A resposta a esta pergunta suscitou, no passado, calorosa discussão doutrinária, ora ultrapassada em razão da regra estabelecida a partir de 2003, no art. 1.025 do Código Civil: "O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão".

E, em relação ao sócio que se retira voluntariamente, por exclusão ou por morte? Remanesce responsabilidade por dívidas então existentes?

A resposta encontra-se no art. 1.032 do mesmo Código: o sócio e, eventualmente seus herdeiros, responderão durante dois anos depois de averbada a resolução da sociedade, pelas dívidas até então existentes. Observe que, embora o dispositivo mencione "averbação", a precisão técnica reclama (veja item 72.5) o termo "arquivamento" (arquiva-se na Junta Comercial a alteração do contrato social).

E em relação às dívidas que se fizerem após sua retirada?

Depende. Se a saída ocorreu em razão da morte do sócio, nenhuma responsabilidade haverá pelas dívidas posteriores ao falecimento, mas tão somente pelas anteriores, pelo prazo de dois anos. Se alteração social decorre de retirada ou exclusão, a responsabilidade persiste até ser levada

a registro na Junta Comercial.

Quando se tratar de sócio com responsabilidade ilimitada, não sendo suficientes os bens sociais, os sócios responderão com seus bens pessoais pelas dívidas remanescentes.

Assim, se houver sócios que se retiraram antes de dois anos, ingressando outros no seu lugar, distintos serão os valores das obrigações pessoais: a) os sócios que permaneceram na sociedade responderão solidariamente pela dívida remanescente; b) igual responsabilidade têm os sócios que ingressaram no lugar dos retirantes (CC, art. 1.025); c) os sócios retirantes responderão solidariamente pelas dívidas existentes na data do arquivamento da alteração contratual (CC, art. 1.032).

17. Responsabilidade de sócio com responsabilidade limitada, por ingresso e retirada

Nas sociedades com sócios com responsabilidade limitada não há tratamento legal homogêneo. O acionista, o sócio cotista de sociedade limitada e o sócio comanditário não respondem de maneira idêntica. Diversamente do que vimos em relação aos sócios com responsabilidade ilimitada, as diferentes classes de sócios com responsabilidade limitada exigem soluções distintas.

Em regra, o cotista e o sócio comanditário que se retiram, levando consigo os fundos sociais que lhes correspondem, respondem pelas obrigações então existentes até aquela data, até o prazo de dois anos, no limite do que retiraram. Aplica-se, portanto, a regra geral, prevista no art. 1.032 do Código Civil.

Se a retirada se deu por cessão de cotas a terceiro, ambos respondem solidariamente, no mesmo prazo (CC, art. 1.003). Verifica-se, pois, que a responsabilidade do cessionário no ingresso por aquisição de cotas é idêntica ao do sócio cedente, durante o prazo de dois anos do arquivamento da alteração contratual na Junta Comercial.

Para o acionista distinguem-se duas situações:

a) acionista dissidente reembolsado – sócio que se retira da sociedade por ações em razão de deliberação em que se viu vencido, nos casos regulados pela Lei das Sociedades por Ações – somente responde em caso de falência, para pagamento dos credores mais antigos não satisfeitos, desde que, com a operação de reembolso, tenha ocorrido a redução do capital social (art. 45, § 4º);

b) acionista que cede as ações antes de integralizá-las responde solidariamente com o cessionário, pelo prazo de dois anos, contados da data em que efetuou a transferência das ações (art. 108).

Nos casos de aumento de capital, os sócios com responsabilidade

limitada obrigam-se conforme regra geral do tipo societário: o sócio cotista da sociedade limitada responde pela integralização do capital social, de forma solidária com os demais sócios; o sócio comanditário responde pela integralização da cota que subscreveu e o acionista pelo preço de emissão das ações subscritas.

18. Responsabilidade em caso de falência

Decretada a falência da sociedade da qual participam, os sócios com responsabilidade ilimitada são igualmente declarados falidos e terão seus bens arrecadados para pagamento, em primeiro plano (responsabilidade primária), de seus credores particulares e, em segundo plano (responsabilidade secundária), dos credores sociais, esgotados os bens do patrimônio da sociedade.

Se o sócio se retirou há menos de dois anos, a responsabilidade pelas dívidas sociais limita-se às dividas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, se ainda não solvidas até a decretação da falência (LREF, art. 81, § 1º).

A responsabilidade dos sócios com responsabilidade ilimitada segue a regra ordinária do tipo societário (veja item 15, último parágrafo).

19. Responsabilidade por ingresso, retirada e falência:quadro-resumo

			sóci na em res ilin pel
--	--	--	--

ob
soc
for
sul
pat
soc

seq
sóc
res
orc
de
sul
pat
soc
cas
da
sãc
arr
pai
paç
dív
exi
deç
exa
pat
soc

noi

**RESPONSABILIDADE
ORDINÁRIA E
FALIMENTAR**

			cap ext soc cap ind
			cor (sc cor sin
			adi (sc cor açô
	ILIMITADA		tra soc cor
			soc sin hoi cor nes
			res pel obr

TIPO DE RESPONSABILIDADE	SÓCIOS QUE SE RETIRAM	cor o l des um 2 a da arc da cor Órg Re
	SÓCIOS INGRESSAM QUE	aui cap res dív ant sua
		ces de ret res ret for pel obr exi

			dat da ob pos res sol cor que per
			pel inte ind da do da fali pa cre trê dis seq soc
			soc an soc cor aç

[illegible]

			pel cap for ent
			soc sin sóc res int do e, sal dív pro que pai das soc out dis for
			O s na com resp obrig até retir limit

TIPO DE RESPONSABILIDADE	LIMITADA	SÓCIOS QUE SE RETIRAM	coul de da arqu alter Junt O diss soci resp limit pela cont do alter perí cont arqu alter Con O resp a sit a) diss reer pag crec anti b) ocor inte ação havi pelo com adq
--	----------------------------------	---	--

		SÓCIOS QUE INGRESSAM	O resp limit com não pela ante sua solid resp ced obri tinha pelo Em de resp fixa prev soci a) s tota do forn os pre b) s até cota c) val açõ adq
--	--	-----------------------------	---

20. Teoria do superamento da personalidade jurídica

Em regra, a sociedade responde, para o cumprimento de suas obrigações, com seus bens presentes e futuros. É a chamada responsabilidade primária. Esse conceito também se aplica à empresa

individual de responsabilidade limitada.

O patrimônio pessoal dos sócios fica sujeito à execução, secundariamente, nos termos do contrato social, de acordo com o que a lei dispuser para o tipo social escolhido.

Nas empresas individuais de responsabilidade limitada e nas sociedades limitada e anônima, espécies mais difundidas no meio empresarial, uma vez integralizado o capital social, não há sequer responsabilidade secundária, respondendo unicamente o patrimônio social.

Em ambos os casos se atende ao princípio da autonomia patrimonial. Cada patrimônio responde pelas obrigações assumidas por seu titular.

Contudo, os atos cometidos abusivamente pelos sócios, na administração da sociedade, podem acarretar o superamento da personalidade jurídica com o fim exclusivo de atingir patrimônio dos sócios envolvidos. Por essa razão, a teoria do superamento da personalidade jurídica – disregard of legal entity – é também conhecida como teoria da penetração.

O Código Civil dispõe que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica” (art. 50).

São duas as hipóteses de abuso da personalidade jurídica: (a) desvio de finalidade e (b) confusão patrimonial.

Haverá desvio de finalidade quando o objeto social é mera fachada para exploração de atividade diversa. Na confusão patrimonial os bens pessoais e sociais embaralham-se, servindo-se, os administradores, de uns e de outros para, indistintamente, realizar pagamento de dívidas particulares dos sócios e da sociedade. Um exemplo de confusão patrimonial é a distribuição de patrimônio social aos sócios simuladamente, mediante elevada

remuneração de sócio, gastos ruinosos ou em proveito próprio.

As situações previstas no Código Civil devem ser demonstradas, provando-as o credor que se vê prejudicado pela constatação de ausência ou insuficiência de patrimônio social para pagamento de seu crédito. A estas, Fábio Ulhoa Coelho (2003, 2:46) denominava teoria maior da desconsideração. Em estudos mais recentes, o doutrinador paulista considerou ultrapassada essa classificação em decorrência da “evolução do tema na jurisprudência brasileira” (2016, 2:71).

A outra formulação teórica a que se referia Coelho denominava-se menor e não considerava a existência das mencionadas situações, mas tão somente a prova de insolvência.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 2:68-69) propõe distinguir a teoria da desconsideração em formulação subjetiva e formulação objetiva, considerando, na primeira, a intenção do administrador ou sócio e, na segunda, atos concretos de confusão patrimonial.

Antes do Código Civil, três leis anteriores, todas da década de 90 – 1990, 1994 e 1998 –, trataram da desconsideração em outros microssistemas jurídicos: a) na defesa do consumidor (CDC, art. 28); b) na defesa do mercado, o art. 18 da Lei n. 8.884/94, denominada antitruste; c) na defesa do meio ambiente, o art. 4º da Lei n. 9.605/98 regula a responsabilidade por lesões ao meio ambiente.

Em algumas situações descritas nessa legislação extravagante exige-se, para a desconsideração, tão somente a demonstração da insolvência da sociedade. É aplicação da teoria menor do superamento da personalidade jurídica.

21. Aspectos processuais da aplicação da teoria da desconsideração

Há controvérsia doutrinária acerca da necessidade ou não de ação

própria para a declaração judicial de desconconsideração da personalidade jurídica.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 2:78) é enfático ao rejeitar a possibilidade de “desconconsideração por simples despacho em processo de execução”, entendendo “indispensável a dilação probatória através do meio processual adequado”.

Contudo, movendo-se contra esta corrente doutrinária, a jurisprudência pacificou até o início da vigência do CPC15 entendimento diverso, achando juridicamente possível a desconconsideração da personalidade jurídica por despacho judicial, no curso de processo de execução.

Inúmeras decisões em todas as instâncias permitiam essa aplicação, algumas considerando tão somente a formulação menor da teoria, admitindo a prova de simples insolvabilidade como requisito único e seguro para configurar fraude aos credores.

Embora entendêssemos correta a linha jurisprudencial que permitia a penetração do patrimônio pessoal dos sócios em execução, desde que a decisão judicial estivesse legalmente fundamentada, consideramos exagerada a aplicação da teoria menor de forma indiscriminada, fora dos casos previstos na legislação extravagante.

A este respeito tivemos oportunidade de registrar no Curso de direito comercial e de empresa (2017, 1:312):

“A não satisfação dos credores não é, por si só, caracterizadora da fraude exigida para aplicação do superamento da personalidade jurídica. Se assim fosse, toda falência ou insolvência civil de sociedades exigiria a arrecadação dos bens pessoais dos sócios. A lei exige mais: o uso abusivo da personalidade jurídica, cuja caracterização deve ser objeto de apreciação judicial, caso a caso.

Na questão patrimonial, as perdas havidas durante a vida da sociedade devem estar suficientemente demonstradas por uma escrituração regular e

precisa que ampare a tese da infelicidade nos negócios. Entretanto, se o desaparecimento de bens do patrimônio não puder ser justificado, e os sócios não indicarem claramente seu destino, a fraude estará evidenciada. Ficará patente a confusão patrimonial entre as pessoas dos sócios e a pessoa jurídica por eles constituída”.

Nesse sentido, as conclusões das Jornadas de Direito Civil da Justiça Federal ao proclamar a adoção da Teoria Maior (Enunciados 7, 146 e 281):

Enunciado 7: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.

Enunciado 146: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).

Enunciado 281: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.

O CPC15 regulamentou nos arts. 133-137 o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto, a ser promovido “em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”, dispensando-se sua instauração somente nos casos em que o pedido integrar a petição inicial, sobrevivendo o Enunciado 91 das Jornadas de Direito Comercial, com a seguinte redação: “A desconsideração da personalidade jurídica de sociedades integrantes do mesmo grupo societário (de fato ou de direito) exige a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou na forma do art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil”.

22. Teoria ultra vires societatis

A teoria ultra vires refere-se a operações estranhas ao objeto social.

A seu respeito esclarece o Professor Waldirio Bulgarelli (1983:1): “Liga-se essa doutrina estreitamente aos limites impostos à sociedade pela cláusula do objeto social. Daí que a descrição do objeto social é de maior importância, pois parte-se da ideia de que a sociedade existe apenas para a realização do objeto social e sendo perigosos os atos que o violam, tanto para os acionistas como para os credores, devem ser declarados nulos por terem sido praticados ultra vires”.

Concluindo seus argumentos, o renomado mestre se posiciona a favor do “reconhecimento da invalidade das decisões e sua execução quando fora do objeto social, com o que se protegeriam a sociedade e os acionistas e se faria com que terceiros tomassem as cautelas necessárias ao contratar com sociedades personificadas, salvo ratificação unânime da assembleia geral. A ratificação unânime só seria válida se não prejudicasse terceiro, a quem seria facultado invocar a teoria ultra vires para não ser prejudicado” (1983:16).

Na jurisprudência brasileira a teoria encontra aplicação, tornando nulos os atos praticados por gerentes sociais em atividades estranhas ao objeto social da sociedade. Contudo, ao contrário dos efeitos buscados na aplicação da teoria, tem-se entendido que a sociedade responde por atos de seus administradores perante terceiros de boa-fé, porque realizados sob a aparência da legalidade contratual ou estatutária (teoria da aparência).

A matéria foi disciplinada pelo parágrafo único do art. 1.015 do CC, passando a legislação a admitir a oposição de excessos praticados pelos administradores, na ocorrência de uma das situações indicadas em seus incisos: (I) a limitação de poderes deve estar arquivada no órgão de registro ou (II) ser conhecida do terceiro contratante ou, ainda, (III) a operação deve ser evidentemente estranha aos negócios da sociedade.

O Código Civil prevê, portanto, a aplicação dos efeitos da teoria inglesa

ultra vires doctrine, atingindo o ato quando “evidentemente estranho” aos negócios sociais, invalidando-o, isto é, a sociedade não responderá pelo ato, mas sim o administrador ou sócio que o praticou.

O Enunciado 219 das Jornadas de Direito Civil da Justiça Federal, ao lado de entender positivada a teoria ultra vires, assinala sua adoção de modo restrito pelo direito brasileiro:

“Está positivada a teoria ultra vires no Direito brasileiro, com as seguintes ressalvas: (a) o ato ultra vires não produz efeito apenas em relação à sociedade; (b) sem embargo, a sociedade poderá, por meio de seu órgão deliberativo, ratificá-lo; (c) o Código Civil amenizou o rigor da teoria ultra vires, admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar negócios acessórios ou conexos ao objeto social, os quais não constituem operações evidentemente estranhas aos negócios da sociedade; (d) não se aplica o art. 1.015 às sociedades por ações, em virtude da existência de regra especial de responsabilidade dos administradores (art. 158, II, Lei n. 6.404/76)”.

23. Administração das sociedades de pessoas

Cabe aos sócios contratantes da sociedade fixar cláusulas regulando suas relações durante a vida da sociedade, inclusive a distribuição das funções que serão exercidas por cada um deles.

Nas sociedades essencialmente personalistas, salvo consentimento dos demais sócios e, portanto, unânime, com modificação do contrato social, as funções exercidas pelos sócios não podem ser delegadas a outro sócio ou a terceiros (CC, art. 1.002).

Entre essas tarefas, de cunho operacional ou administrativo, há as que se referem à administração da sociedade. A nomeação do administrador da sociedade deve ser indicada no contrato social e, se não o for, no silêncio a respeito de quem a exerce, a administração competirá separadamente a

cada um dos sócios.

Na sociedade simples, o administrador é sempre uma pessoa natural (CC, art. 997, VI), vedando-se o seu exercício às pessoas jurídicas.

A lei não proíbe expressamente que a administração da sociedade simples seja encarregada a não sócios, como o faz para outras sociedades.

É possível, à luz do que dispõe o art. 1.019 do Código Civil, distinguir, no caput, poderes de administração geral em relação aos sócios (poderes do sócio investido na administração), e, no parágrafo único, aos poderes conferidos na qualidade de mandatários (“são revogáveis os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio”).

A redação de toda a seção (arts. 1.010 usque 1.021) não permite uma conclusão única, pois distingue sócio e administrador, como se este último pudesse não pertencer àquela categoria. O art. 1.013, ao estabelecer que “a administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios”, permite se entender que, se o contrato social tiver cláusula expressa, a administração tanto poderia competir aos sócios em conjunto ou, ainda, a não sócios, em conjunto ou separadamente.

Essa faculdade, atribuindo poderes gerenciais a pessoa estranha aos quadros sociais, distinguiria a sociedade simples de outras sociedades de cunho pessoal definidas no Código Civil.

Na sociedade em nome coletivo somente os sócios podem fazer uso da firma (CC, art. 1.042). É o que também ocorre nas sociedades em comandita simples e em conta de participação (CC, arts. 1.045, 1.046 e 991).

Na sociedade limitada o Código Civil prevê a possibilidade de o contrato social decidir acerca da nomeação de administradores não sócios (art. 1.061), não vedando a assunção dessa responsabilidade por parte de pessoa jurídica. Contudo, doutrina recente entende que a proibição

resultaria do disposto nos art. 997, VI, aplicável à sociedade limitada por força do art. 1.054 (Pereira Calças, 2003:141).

Em resumo:

TIPO SOCIETÁRIO	PESSOA NATURAL	PESSOA JURÍDICA	NÃO SÓCIO
Em nome coletivo (CC, arts. 1.040 e 1.042)	γ	λ	λ
Em comandita simples (CC, art. 1.046)	γ	λ	λ
Limitada (CC, arts. 1.060-1.061)	γ	λ	γ
Simplex (CC, arts. 997, VI, 1.013 e 1.019)	γ	λ	■
LEGENDA γ = permite ou não veda λ = veda ■ = questão controvertida			

23.1. Incompatibilidades e impedimentos

A matéria dos impedimentos é parcialmente comum a todas as sociedades, sejam sociedades simples ou empresárias. Embora a lei use o mesmo vocábulo, é necessário distinguir entre as duas modalidades de impedimentos tratadas pelo art. 1.011, § 1º. Algumas são incompatibilidades profissionais e, neste caso, com tratamento distinto para o exercício das atividades empresárias e das não empresárias; outras são impedimentos de ordem geral aplicáveis para a administração de quaisquer sociedades, simples ou empresárias.

São de ordem geral, ainda, os impedimentos impostos aos estrangeiros, por exemplo, o exercício de atividade remunerada no Brasil de estrangeiros portadores de visto de visita (Lei n. 13.445/2017, art. 13, § 1º).

É impedimento de ordem geral, ainda, a condenação em sanção penal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa de concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto durarem os efeitos da condenação.

Impedem o acesso a cargos públicos as práticas previstas na Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, entre as quais se incluem o enriquecimento ilícito e atos que causam prejuízo ao erário público ou que atentam contra os princípios da Administração Pública.

A condenação por crimes falimentares reporta-se aos crimes previstos na Lei de Recuperação e Falência (arts. 168-182) que podem ter sido praticados tanto na falência como nos procedimentos de recuperação de empresa.

As expressões “prevaricação, peita ou suborno, concussão” são modalidades criminosas encontradas no Código Penal, no capítulo dos crimes praticados por funcionários públicos, especificamente nos arts. 316 (concussão), 317 (corrupção) e 319 (prevaricação). Há outros crimes que causam prejuízo ao erário ou à função pública, como o peculato (art. 312), a advocacia administrativa (art. 321), a facilitação de contrabando ou descaminho e a violação de sigilo funcional (art. 325) que não foram contemplados entre os impedimentos.

Outros crimes cuja condenação impede o exercício da administração social são os contra a economia popular (Lei n. 1.521, de 26-12-1951); contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492, de 16-6-1986); contra as normas de defesa de concorrência (art. 195 da Lei n. 9.279/96); contra as relações de consumo (Lei n. 8.078, de 11-9-1990); contra a fé pública, definidos no Código Penal e abrangendo as hipóteses de moeda falsa e similares (arts. 289 a 292); a falsidade de títulos e outros papéis públicos (arts. 292 a 295); a falsidade documental (arts. 296 a 305) e outras

falsidades (arts. 306 a 311); crimes contra a propriedade, isto é, crimes contra o patrimônio (furto, roubo, extorsão, usurpação, dano, apropriação indébita, estelionato e outras fraudes, receptação), crimes de violação de direito autoral ou usurpação de nome ou pseudônimo alheio; crimes contra a propriedade intelectual em geral, incluindo a violação de direitos de autor de programa de computador (art. 12 da Lei n. 9.609/98) e os crimes contra a propriedade industrial (arts. 183 a 194 da Lei n. 9.279/96).

23.2. Impedimentos de ordem profissional

Estão impedidos de exercer a atividade empresarial ou a administração de empresas alguns agentes políticos, para os quais a lei preservou a liberdade e o status político para o exercício pleno de suas funções: os membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, c, da CF88 e art. 44, III, da Lei n. 8.625, de 11-2-1993) e os magistrados (Lei Complementar n. 35, de 14-3-1979, art. 36, I); deputados e senadores em empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público (art. 54, II, a, da CF88).

Para outras funções públicas o legislador construiu regras próprias, encontradas nos estatutos das carreiras. Os funcionários públicos em geral e, em especial, os funcionários da Fazenda e militares, encontram vedações ou restrições, nos âmbitos municipais, estaduais e federais.

Inserem-se nos impedimentos profissionais as exigências de habilitação especial, licença ou autorização do Poder Público. É o caso das atividades securitária (Lei n. 4.594/64), financeira (Leis n. 4.595/64 e 6.385/76), de transporte rodoviário de bens (Lei n. 7.092/83), de serviços de vigilância e de transportes de valores (Lei n. 7.102/83) ou, ainda, administração de grupos de consórcio etc.

23.3. Formas de exercício

Os arts. 1.013 e 1.014 do Código Civil apresentam as formas de exercício da administração:

(1) disjuntiva: cada sócio exerce os atos de administração separadamente, cabendo, reciprocamente a cada um dos sócios, o direito de impugnar a operação pretendida pelo outro;

(2) conjunta: as decisões são tomadas por consenso entre todos os sócios, salvo nos casos urgentes, que poderão ser objeto de decisão de um ou alguns deles;

(3) conjunta com limitação: facultada a alguns sócios, tão somente; os atos de execução não podem desobedecer às deliberações dos sócios, que decidem por maioria.

A administração conjunta pode se referir a um, alguns ou todos os atos de administração e, em qualquer um destes casos, o legislador exigiu concurso de todos, o que somente pode ser excepcionado nos casos urgentes: naqueles em que a omissão ou o retardamento das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave (CC, art. 1.014).

23.4. Deveres do administrador

Três são os principais deveres impostos ao administrador: a) diligência; b) lealdade; e c) informação e prestação de contas.

Exige-se probidade no exercício da administração social, resumida pelo legislador na expressão “cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios”.

Além disso, o administrador deve ser leal aos interesses e finalidades da sociedade, prestando fielmente os serviços necessários para que ela atinja os fins comuns para o qual foi constituída.

Podemos encontrar um bom parâmetro para a interpretação do que seja lealdade no art. 155 da LSA. O administrador não pode usar oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo,

em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a empresa. É-lhe vedado, ainda, omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia; deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia, visando a obtenção de vantagens, para si ou para outrem, ou adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.

O dever de informar e de prestar contas é corolário do direito do sócio de fiscalizar os atos da administração.

23.5. Substituição

O administrador não pode ser substituído no exercício de suas funções, mas lhe é permitido constituir mandatários com poderes para a prática de atos e operações especificados na procuração. Os mandatos assim firmados seguem a disciplina geral desse contrato, mas não podem conter cláusula de irrevogabilidade, salvo com autorização unânime dos sócios (CC, art. 1.109, parágrafo único).

Na sociedade simples, em nome coletivo e em comandita simples, os poderes do administrador conferidos por cláusula expressa no contrato social são irrevogáveis, exceto se sobrevier modificação em virtude de morte do administrador indicado, sua interdição ou sua inabilitação por decisão judicial, decorrente de ação intentada por quaisquer sócios, demonstrando justa causa para a revogação (CC, art. 1.019, caput).

Se os poderes foram conferidos por ato separado do contrato social o princípio aplicável é o da revogabilidade a qualquer tempo, por deliberação da maioria (CC, arts. 1.019, parágrafo único, e 1.010).

A regra de irrevogabilidade dos poderes de administração se harmoniza com o sistema adotado pelo legislador, exigindo decisão unânime (CC, art. 999) para as alterações sociais que impliquem mudanças nas matérias do art. 997, entre as quais se incluem as cláusulas que mencionam “as pessoas

naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições”.

Nas sociedades limitadas regidas subsidiariamente pelas regras das sociedades simples, a substituição de administradores não encontra tantos obstáculos. Deve-se, entretanto, distinguir duas situações: a) se o sócio foi nomeado administrador no contrato social, a alteração para afastá-lo da gestão deve ser tomada em deliberação dos sócios, pelo voto que represente dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa (CC, art. 1.063, § 1º); b) se o sócio ou terceiro não sócio foram nomeados em ato separado, o quorum é inferior: basta o voto correspondente a mais da metade do capital social (CC, arts. 1.071, III, e 1.076, II).

23.6. Poderes

Os poderes dos administradores limitam-se à prática de atos pertinentes à gestão de sociedade, excluídos os de alienação, imposição de ônus sobre os bens imóveis, operação a título gratuito, com ônus ao patrimônio social ou aplicação de créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros.

Ordinariamente, compreendem-se nos poderes de administração: 1) a prática de atos e operações incluídas no contrato social da sociedade, inclusive a alienação de imóveis, quando for este o objeto da sociedade; 2) emissão, endosso e circulação de títulos de crédito, decorrentes do exercício de atividades pertinentes ao objeto social; 3) administração dos bens sociais com vistas à sua conservação e manutenção; 4) representação da sociedade, judicial e extrajudicialmente.

23.7. Abuso de poderes gerenciais

Como regra geral (CC, art. 1.016) os administradores respondem pessoal e solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados se agirem com culpa no desempenho de suas funções.

O Código Civil exemplifica duas condutas que configuram abuso de poder: a realização de operações quando ciente ou presumivelmente ciente de que age em desacordo com a vontade da maioria (CC, art. 1.013, § 2º); a aplicação de créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros (CC, art. 1.017). Em ambas as figuras normativas se coíbe o excesso, punindo, no primeiro caso, com perdas e danos e, no segundo, com o pagamento do equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.

Haverá abuso de poder quando o ato inquinado, apesar de previsto ou não vedado por cláusula do objeto social, é realizado em proveito próprio do administrador ou de terceiro. Neste caso, a colidência de interesses se dá entre o administrador e a sociedade.

É possível que o gestor viole cláusula do objeto social, incorrendo na prática de ato ultra vires, envolvendo terceiro, matéria objeto do item anterior.

24. Sociedades não personificadas – sociedade em comum

O sistema anterior ao Código Civil distinguia as sociedades de fato (as que sequer elaboravam seus contratos sociais) das irregulares (as relações eram reguladas entre os sócios, mas o documento não era levado a arquivamento na Junta Comercial).

Em seu lugar o Código Civil (arts. 986-990) estabeleceu regras especiais sob a rubrica “sociedades em comum”, denominação que se refere ao estado provisório de irregularidade, ou, na expressão legal, “enquanto não inscritos os atos constitutivos”.

Neste regramento destacam-se (a) o reconhecimento de um patrimônio especial, formado por bens e dívidas da sociedade não registrada, e (b) a faculdade de o sócio não tratador fazer uso do benefício de ordem, isto é, o sócio que não participou da realização de determinado negócio jurídico

pode invocar o direito de ver seus bens executados somente após o esgotamento do patrimônio que responde primariamente pelas dívidas sociais: os bens da sociedade e os do sócio tratador.

À falta de registro, como se prova a existência da sociedade em comum?

De duas formas distintas, dependendo da qualidade de quem a requer.

O terceiro pode fazê-lo de qualquer modo (CC, art. 987). O regime anterior (CCom, art. 305) exemplificava alguns desses meios probatórios: 1) negociação promíscua e comum; 2) aquisição, alheação, permutação, ou pagamento comum; 3) se um dos associados se confessa sócio, e os outros o não contradizem por uma forma pública; 4) se duas ou mais pessoas propõem um administrador ou gerente comum; 5) a dissolução da associação como sociedade; 6) o emprego do pronome nós ou nosso nas cartas de correspondência, livros, faturas, contas e mais papéis comerciais; 7) o fato de receber ou responder cartas endereçadas ao nome ou firma social; 8) o uso de marca comum nas fazendas ou volumes; 9) o uso de nome com a adição “e companhia”.

Aos sócios, contudo, a lei condicionou a demonstração de existência de sociedade à apresentação de documento escrito (CC, art. 987).

25. Sociedades não personificadas – sociedade em conta de participação

Sempre houve controvérsia doutrinária sobre a natureza jurídica das sociedades em conta de participação, considerando uns tratar-se de mero contrato de investimento e, outros, tipo societário.

O Código Civil adotou a corrente doutrinária que considera o contrato em conta de participação como sendo sociedade e, contudo, em linha diametralmente oposta a essa conclusão, atribuiu à contribuição do sócio participante (também chamado oculto) o caráter de patrimônio especial, separado do patrimônio social, conferindo ao seu possuidor título

quiografário, na falência do sócio ostensivo.

São características da sociedade em conta de participação:

a) Exercício da atividade: a atividade é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu próprio nome, sem a adoção de nome social. O sócio participante não pode tomar parte nas relações com terceiros, sob pena de responder solidariamente com o sócio ostensivo.

b) Responsabilidade perante terceiros: somente o sócio ostensivo se obriga perante terceiros.

c) Prova da sociedade: independe de qualquer formalidade, provando-se por todos os meios de direito.

d) Efeitos do contrato: somente entre os sócios. A inscrição no Registro Público não confere personalidade jurídica.

e) Direitos do sócio participante (oculto): fiscalizar a gestão dos negócios sociais.

f) Patrimônio: os fundos admitidos são considerados patrimônio especial.

g) Efeitos da falência do sócio ostensivo: dissolução da sociedade e liquidação da conta. O crédito do participante é quiografário.

h) Efeitos da falência do sócio participante (oculto): o contrato é tratado segundo as regras do contrato bilateral na falência (LREF, art. 117). O administrador judicial poderá cumpri-lo, se convier à massa.

i) Ingresso de novo sócio: somente com o consentimento do sócio participante.

j) Modo de liquidação: seguem-se as regras do procedimento da ação de exigir contas previsto nos arts. 550-553 do CPC15.

26. A regência das normas da sociedade simples

As sociedades de pessoas – simples, em nome coletivo, em comandita simples – e a híbrida limitada mantêm pontos comuns de tratamento

legislativo, em maior ou menor extensão, no que se refere às matérias das Seções II (direitos e obrigações dos sócios), III (administração da sociedade), IV (relações com terceiros), V (resolução da sociedade em relação a um sócio) e VI (dissolução da sociedade) do capítulo referente às sociedades simples (CC, arts. 997-1.038).

Por esta razão, no tratamento dessas matérias procurou-se, nesta obra, agrupar os pontos comuns e as peculiaridades de cada uma delas. Assim, os direitos e obrigações dos sócios foram tratados no item 10; a administração da sociedade foi estudada no item 22; a liquidação de cota de sócio, relativa a relações com terceiro, é objeto do item 13; a resolução da sociedade em relação a um sócio, nos itens 11, 12 e 13; a dissolução da sociedade é tema dos itens 51 e 52.

Resta, entretanto, traçar as características próprias de cada sociedade, apresentando os elementos que as distingue uma das outras, objeto dos próximos itens.

27. Sociedade simples

A sociedade simples pode ser classificada como sociedade personalista, tendo em vista a rigidez imposta pela regra legal no tocante à modificação do contrato social.

Há necessidade de consentimento unânime dos sócios, nas deliberações que alterem as cláusulas referentes aos elementos essenciais do contrato: a) nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas; b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; c) capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária; d) a cota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; e) as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; f) as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e

atribuições; g) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; h) se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Quanto às demais cláusulas que forem contratadas pelos sócios, as posteriores alterações submetem-se à aprovação da maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime.

Por se destinar às atividades não empresariais, a sociedade simples deve ser inscrita no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, dentro de trinta dias subsequentes à sua constituição (CC, art. 988) e, se constituir sucursal, filial ou agência, deverá fazê-lo na circunscrição correspondente, averbando-a, de qualquer modo, no registro civil da sede.

28. Sociedade em nome coletivo

A sociedade em nome coletivo rege-se pelas normas dos arts. 1.039-1.044 e, nas matérias omitidas por estes dispositivos, pelas regras da sociedade simples.

São características próprias da sociedade em nome coletivo:

a) quanto à responsabilidade pelas obrigações sociais: os sócios respondem ilimitada e solidariamente entre eles, subsidiariamente ao patrimônio social;

b) quanto à limitação de responsabilidade entre os sócios: os sócios podem convencionar, no contrato ou por deliberação posterior, a limitação da responsabilidade de uns para com os outros, sem alterar o direito de terceiros quanto às obrigações sociais;

c) quanto à qualidade de sócio: somente pessoas naturais podem tomar parte na sociedade;

d) quanto à administração: somente sócio – um, alguns ou todos – pode exercer a administração social; na falta de menção no contrato social, todos a exercem;

e) quanto ao nome adotado: admite-se apenas firma social, isto é, nome empresarial composto pelo nome de um ou alguns sócios, de forma reduzida ou integral, acrescido da expressão “e companhia”, abreviada ou completa, ou, ainda, o nome de todos os sócios, sem qualquer acréscimo.

O Código Civil traz, ainda, regra especial para a liquidação de cota de sócio por execução promovida por credor particular e o mesmo ocorre em relação à sociedade em comandita simples porque, nestas sociedades, a qualidade de sócio é pessoal, sendo vedado a terceiro estranho ingressar no quadro social, sem o consentimento dos demais, impossibilitando a penhora da cota social.

Por outro lado, exigir a liquidação da cota, sem o ingresso de novo sócio, acarretaria a descapitalização do patrimônio social, em prejuízo da empresa e dos demais sócios, podendo levar à extinção da sociedade, por esta última razão e, ainda, pela não recomposição do número mínimo de sócios.

Disso decorre a inexecutabilidade de execução direta sobre a cota social ou sua liquidação nas sociedades em nome coletivo e em comandita simples. Contudo, a intangibilidade da cota social não é absoluta, podendo ser liquidada pelo credor particular em duas oportunidades (CC, art. 1.043): a) na prorrogação tácita do prazo de existência da sociedade; e b) na prorrogação contratual, se o credor, no prazo de noventa dias da publicação da dilação, apresentar sua oposição ao ato, em juízo.

Entenda-se: as sociedades de pessoas, constituídas por prazo determinado, extinguem-se na data estabelecida no contrato. Ocorre prorrogação tácita quando, vencido o prazo de duração, a sociedade não entrar em liquidação, sem oposição de sócio. Neste caso, o contrato passa a vigor por prazo indeterminado (CC, art. 1.033).

Vale dizer que, se os sócios se opuserem à prorrogação tácita, a sociedade entra em liquidação porque decorrido o prazo de sua duração. Esse direito de oposição é estendido aos credores particulares dos sócios,

facultando-lhes não somente apresentarem oposição em juízo contra a prorrogação do contrato, no prazo de noventa dias após a publicação da deliberação dos sócios nesse sentido, como também na hipótese de prorrogação tácita, isto é, tendo os sócios silenciado quanto à liquidação, deixado de promovê-la no tempo certo.

Resulta, ainda, como consequência lógica das conclusões acima expostas que na sociedade em nome coletivo ou em comandita simples, com prazo de duração indeterminado, embora se vede a penhora da cota, nenhum óbice há à sua liquidação, o que se operará na forma do art. 1.026 do Código Civil, regra da sociedade simples aplicável às sociedades em estudo (veja item 13, acima).

29. Sociedade em comandita simples

A principal característica da sociedade em comandita simples é a exigência de o contrato social discriminar duas categorias de sócios: uma constituída por sócio, ou sócios, solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações sociais, subsidiariamente ao patrimônio social, e outra, pelo sócio, ou sócios, obrigado tão somente pelo valor de sua cota.

A sociedade obriga-se a manter, durante a vida social, as duas categorias de sócios; a falta de uma delas, por mais de cento e oitenta dias, acarreta a dissolução de pleno direito da sociedade.

Ocorrendo o evento morte, as soluções são distintas, dependendo da qualidade do sócio: a) se o falecido pertencer à classe dos comanditários, salvo disposição diversa no contrato social, seus sucessores herdam a cota social e designam quem os represente; b) se, entretanto, a morte sobrevier a sócio comanditado, os comanditários ficam responsáveis pela recomposição da categoria faltante no prazo de cento e oitenta dias e, até que isto ocorra, nomearão gerente que, sem assumir a condição de sócio, administre provisoriamente a sociedade.

Além da qualidade essencial quanto ao aspecto obrigacional, as duas categorias de sócios apresentam regramento próprio que as distingue acentuadamente.

Assim, os sócios comanditados: a) são sempre pessoas físicas; b) exercem privativamente a administração da sociedade; c) podem ter seu nome na firma social; d) possuem os mesmos direitos do sócio em nome coletivo.

Os sócios comanditários, por sua vez: a) podem ser pessoas físicas ou jurídicas; b) estão proibidos de exercer atos de gestão e de figurar na firma social, sob pena de se sujeitarem ao regime obrigacional dos sócios comanditados; c) podem, entretanto, exercer o mandato em nome da sociedade, para negócio determinado e com poderes especiais; d) ficam responsáveis, no limite contratado, pelas dívidas preexistentes à diminuição de sua cota social quando esta acarretar a redução de capital social, ou seja, respondem pela integralização de sua parte no capital então existente, somente em relação aos credores preexistentes; e) não são obrigados a repor lucros recebidos, desde que os tenha recebido de boa-fé, de acordo com o balanço; f) não podem receber lucros enquanto não recomposto o capital social reduzido em virtude de perdas supervenientes.

Incidem sobre a sociedade em comandita simples as disposições da sociedade em nome coletivo sempre que lhe forem compatíveis.

30. Sociedade limitada

30.1. Principal característica e regência legal

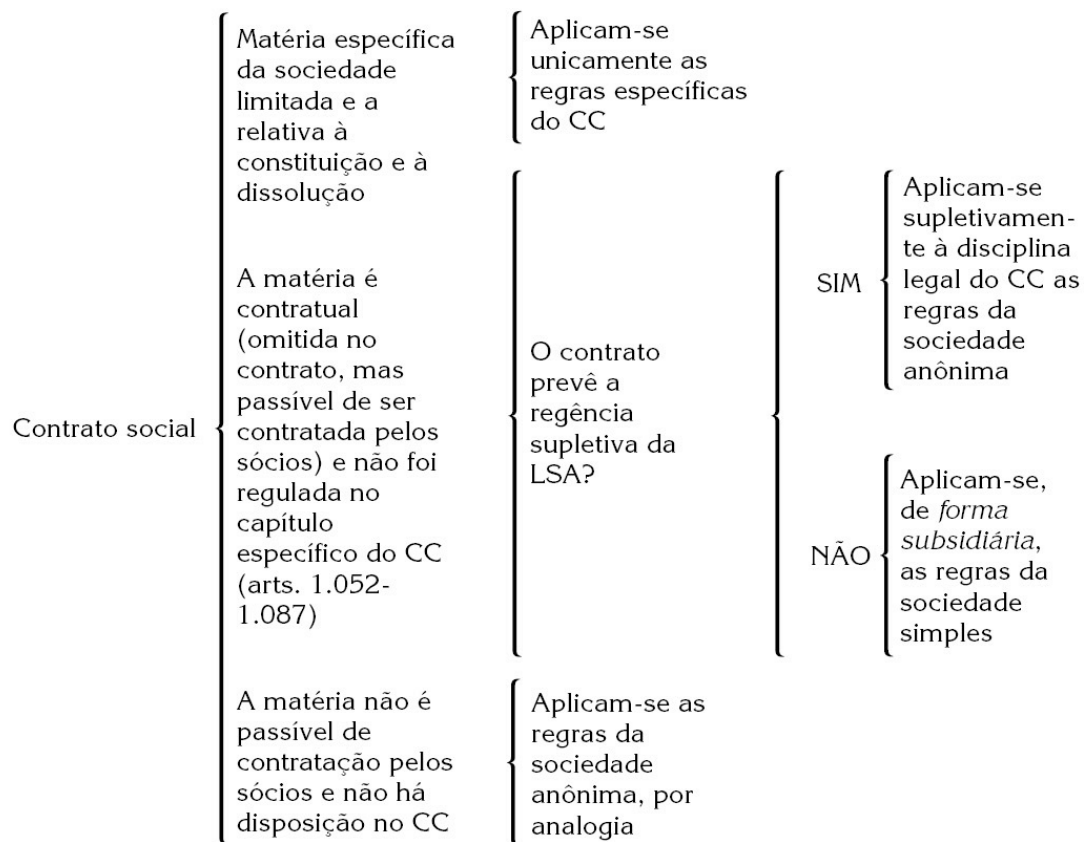
Qual é a principal característica da sociedade limitada? O que a faz distinta de todas as demais?

Sem dúvida é a possibilidade da escolha de sua natureza, de capital ou de pessoa, que se define pela vontade dos sócios, ao elaborarem as

cláusulas do contrato social.

A abrangência da legislação aplicável às sociedades limitadas é uma característica básica desse tipo societário.

Além das regras que lhe são específicas (CC, arts. 1.052-1.087), sempre aplicáveis na constituição e na dissolução da sociedade, o contrato social da sociedade limitada pode eleger, nas matérias suscetíveis de contratação, a regência supletiva das normas da sociedade anônima e, não o fazendo e for omissa o capítulo próprio, submeter-se-á às regras da sociedade simples.



Nas matérias não passíveis de contratação pelos sócios, inexistindo regra própria ou geral, isto é, não a tendo o Código Civil regulado nos capítulos relativos à sociedade limitada ou à sociedade simples, aplicam-se, por analogia, as normas da sociedade por ações, previstas na Lei n. 6.404/76.

Coube a Fábio Ulhoa Coelho (2016, 2:357-360, e 2003:18-25) a primazia e a mais eficiente exposição da matéria aqui resumida. Sobre a existência

de duas modalidades de aplicação da Lei das Sociedades por Ações o mestre paulista conclui, identificando-as: “Além da incidência supletiva ao regime específico do Código Civil, quando omissas as cláusulas contratuais, nas matérias sujeitas a negociação, cabe, também, a aplicação analógica da legislação do anonimato”.

Uma outra forma de visualizar as matérias é a sua divisão em negociável ou não negociável entre os sócios.

As não negociáveis são as relativas à natureza essencial das sociedades limitadas e às de constituição e de dissolução da sociedade. Nestas aplica-se, com exclusividade, o que dispõe o capítulo das sociedades limitadas e, nas lacunas, pelo princípio geral da analogia, as normas da sociedade anônima.

Nas matérias negociáveis, havendo omissão do capítulo específico, aplica-se o que o Código Civil dispõe sobre as sociedades simples, salvo se o contrato prever a regência da Lei das Sociedades por Ações que passa a ter função supletiva à disciplina legal do Código Civil.

MATÉRIA		REGÊNCIA
Matéria não passível de contratação pelos sócios	Específica das sociedades limitadas.	Aplicam-se somente as regras da sociedade limitada (arts. 1.052-1.087).
	Relativa à constituição e à dissolução.	
	Não regulada no Código Civil.	Aplicam-se, por analogia, as regras da LSA.
Matéria contratual – passível de ser contratada pelos sócios	O contrato prevê a regência supletiva da LSA.	Aplicam-se supletivamente à disciplina legal do Código Civil as regras da LSA.
	O contrato não prevê a	Aplicam-se subsidiariamente as

	regência supletiva da LSA.	regras da sociedade simples.
--	----------------------------	------------------------------

Acertada, pois, a conclusão de Manoel de Queiroz Pereira Calças (2003:39) quando afirma que a aplicação supletiva do regime das sociedades anônimas às limitadas subordina-se a “três pressupostos: (a) matéria não regulada no capítulo das sociedades limitadas; (b) contrato social omissivo sobre a matéria; (c) contratualidade da matéria, isto é, tema inserido no campo dispositivo dos contratantes”.

30.2. Sociedade limitada e sociedade simples

Embora as regras da sociedade simples possam ser aplicadas à sociedade limitada, uma estrutura própria a distingue de todas as demais. Podemos reconhecer a sociedade limitada por seus pontos bem distintos:

- Constituição do capital social: é vedada a contribuição de sócios, para constituição do capital social, que consista em prestação de serviços (CC, art. 1.055, § 2º), ao contrário do que ocorre na sociedade simples (CC, art. 1.006).
- Objeto: as sociedades simples possuem sempre objeto não empresarial, podendo constituir-se sob as normas que lhe são próprias ou revestir-se da forma das sociedades limitadas (CC, art. 983). É possível, portanto, uma sociedade simples, no objeto, e limitada, na forma.
- Cessão das cotas: na omissão do contrato, o sócio de responsabilidade limitada pode cedê-las, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independente de anuência dos outros, ou mesmo a estranho, se não houver oposição dos outros sócios que representem mais de 25% do capital social (CC, art. 1.057). O sócio da sociedade simples depende do consentimento de todos os sócios (art. 1.003).
- Sócio remisso: na hipótese de o sócio não completar sua contribuição ao capital social, os demais sócios podem transferi-la a terceiros na sociedade limitada (CC, art. 1.058). É possível, ainda, valer-se das outras soluções dadas pela regra aplicável às sociedades simples: exclusão, com ou sem redução do capital social, ou redução de sua participação, pelo valor já integralizado (CC, art. 1.004).
- Administração da sociedade limitada: competirá indistintamente a sócios ou a não sócios, conforme dispuser o contrato social (CC, art. 1.061); na sociedade simples, a administração é sempre realizada por pessoa natural (CC, art. 997, VI), sendo discutível a possibilidade de atribuir a pessoa estranha ao quadro social.
- Destituição de administrador: ocorrerá a qualquer tempo, na sociedade limitada, dependendo, se o administrador for sócio, de aprovação de titulares de cota correspondentes, no mínimo, a dois

terços do capital social, salvo estipulação em contrário (CC, art. 1.063, § 1º); na sociedade simples, a destituição de administrador sócio investido por cláusula expressa do contrato social depende de reconhecimento judicial (CC, art. 1.019).

- Conselho Fiscal: faculta-se sua constituição na sociedade limitada (CC, art. 1.066), inexistindo semelhante disposição para a sociedade simples.
- Deliberação dos sócios: depende de realização de assembleia se o número dos sócios for superior a dez, na sociedade limitada (CC, art. 1.072, § 1º), inexistindo similar na sociedade simples.
- Deliberação dos sócios: na sociedade limitada, as deliberações são tomadas por votos de três quartos; maioria do capital social ou maioria dos presentes (CC, art. 1.076); na sociedade simples, grande parte das deliberações exige unanimidade ou maioria absoluta (CC, art. 999).
- Exclusão de sócio: o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa pode ser excluído por decisão dos titulares de mais da metade do capital social, na sociedade limitada (CC, art. 1.085); na sociedade simples, a alegação de falta grave para exclusão de sócio dependerá sempre de decisão judicial, em pedido formulado pela maioria social (CC, art. 1.030).
- Responsabilidade ordinária: os sócios de responsabilidade limitada respondem pessoalmente pela integralização de sua cota e, solidariamente com os demais sócios, pela integralização de todo capital social; o sócio na sociedade simples responde pela integralização de sua cota e, ainda, subsidiariamente ao patrimônio social, pelo valor que exceder a dívida social, na medida de sua participação nas perdas sociais (CC, art. 1.023).
- Responsabilidade pela efetivação da contribuição: na sociedade limitada todos os sócios são solidariamente responsáveis pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social (CC, art. 1.055, § 1º); na sociedade simples, a responsabilidade é individual (CC, art. 1.005).

30.3. Regras aplicáveis à empresa individual de responsabilidade limitada

A Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011, manda aplicar à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

São compatíveis, entre outras, as regras relativas à estimação dos bens conferidos ao capital social (art. 1.055, § 1º); o aumento e a redução do capital (arts. 1.081, caput, e 1.082); a dissolução (art. 1.087, c/c arts. 1.033, I, V, e 1.044).

Dúvida há quanto à possibilidade de a EIRELI ser administrada por pessoa natural não titular da empresa, como ocorre com a sociedade limitada (art. 1.061).

Parece-nos que foge ao espírito da lei possibilitar a administração por terceiro quando o titular da empresa individual de responsabilidade limitada for uma pessoa natural.

O legislador pátrio possibilitou a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada por “uma única pessoa titular da totalidade do capital social”, sem distinguir tratar-se de pessoa natural ou jurídica (art. 980-A). A doutrina sustenta a possibilidade de uma pessoa jurídica constituir empresa individual de responsabilidade limitada¹.

Esse é entendimento adotado recentemente na III Jornada de Direito Comercial da CJC, no Enunciado 92: “A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) poderá ser constituída por pessoa natural ou por pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, sendo a limitação para figurar em uma única EIRELI apenas para pessoa natural”.

Assim, na hipótese de a constituição ser realizada por pessoa jurídica, adequado permitir-se a administração por pessoa que não seja a titular da empresa.

Contudo, no sentido de não se permitir a constituição por pessoa jurídica, encontra-se o Enunciado 468 da Jornada de Direito Civil: “Art. 980-A: A empresa individual de responsabilidade limitada só poderá ser constituída por pessoa natural”.

Em qualquer caso, constituída por pessoa natural ou por pessoa jurídica, a administração da empresa individual de responsabilidade limitada não poderá recair sobre pessoa jurídica. Isto porque as regras da sociedade limitada lhe são aplicáveis e, assim, ambas devem submeter-se ao regramento previsto no art. 997, VI, por força do disposto no art. 1.054 do Código Civil.

31. Conselho Fiscal na sociedade limitada

O Código Civil faculta aos sócios a adoção de um Conselho Fiscal, que deve ser composto por um mínimo de três membros, sócios ou não, residentes no País e eleitos em assembleia ordinária.

Uma vez constituído, ao Conselho Fiscal são atribuídos os seguintes deveres, além dos que o contrato social ou a lei estabelecerem: a) o exame, pelo menos trimestralmente, dos livros e papéis da sociedade e do estado da caixa e da carteira; b) a lavratura, no livro de atas e pareceres, do resultado desses exames; c) o registro de parecer anual sobre os negócios e operações sociais, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico; d) a denúncia de erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade; e) a convocação da assembleia de sócios se a diretoria retardar por mais de trinta dias sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes; f) a prática desses mesmos atos durante a liquidação da sociedade.

Qualquer pessoa capaz, idônea, no gozo da administração de seus bens, pode exercer as funções no Conselho Fiscal, não exigindo a lei nenhuma formação acadêmica especial. Entretanto, o contrato social pode fazer-se regular, nesse aspecto, supletivamente pelas normas das sociedades anônimas e, nessa hipótese, se lhe exigirá o curso universitário ou que tenha exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal (LSA, art. 162).

Independente da formação exigida, o órgão pode escolher contabilista legalmente habilitado para assisti-lo no exame dos livros, papéis e demais documentos contábeis.

Não podem servir no Conselho Fiscal: a) pessoa condenada às penas mencionadas no art. 1.011 (veja item 23.1); b) membro da administração da sociedade ou de controlada por ela; c) empregados da sociedade ou de empresa controlada pela sociedade ou, ainda, controlada por administrador

de quaisquer dessas sociedades; d) cônjuge ou parente até o terceiro grau dos administradores da sociedade ou das controladas.

As razões de impedimento legal (CC, art. 1.066, § 1º) são de fácil compreensão. Além da idoneidade, requisito indispensável para o exercício da função, há a constatação da necessidade de mantê-lo independente dos órgãos da administração fiscalizada, com o que se evita confundir numa só pessoa os atos de execução e de fiscalização. A não ser assim, o Conselho Fiscal seria órgão meramente referendário e, portanto, dispensável.

O raciocínio vale para as pessoas subordinadas ou ligadas por laços de parentesco ao administrador, bem como para o empregado das empresas controladas. Para garantia de seu exercício com desassombro, a legitimidade do membro do Conselho Fiscal tem origem em eleição realizada pela assembleia de sócios, destinatários últimos dos resultados sociais.

32. Características das sociedades por ações

A sociedade por ações distingue-se das demais principalmente em função da livre negociação de seus títulos e, em geral, do livre ingresso na sociedade.

Outra característica própria das sociedades por ações é que ela é sempre empresária, independentemente de seu objeto social, isto é, mesmo que este não se constitua em atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, sua estrutura denunciará sua qualidade empresarial. Em consequência, torna-se possível a constituição de sociedades anônimas para o exercício de atividades não empresariais por natureza, cujos fins sejam meramente intelectuais, artísticos, científicos ou literários (v.g. hospitais, escolas, centros de pesquisas), transmutando, ipso facto, a qualidade de seu objeto.

O capital social se divide em unidades denominadas ações e os

compradores destas, acionistas, respondem apenas até o preço de emissão das ações que subscreverem ou adquirirem.

33. Sociedade em comandita por ações

A sociedade em comandita por ações é a modalidade menos conhecida e difundida entre os tipos societários de natureza institucional, dada sua forma mista quanto à responsabilidade dos sócios, não apreciada entre os empresários e investidores brasileiros. Sua regulamentação legal remonta ao ano de 1882 – Lei n. 3.150, de 4 de novembro.

Apesar de regulamentado há 130 anos, este tipo societário não granjeou a estima do mundo empresarial, sobretudo em razão de impor, aos sócios administradores, a responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais.

Historicamente, esta sociedade tem a mesma origem da sociedade em comandita simples e da sociedade em conta de participação. Nascida a partir da necessidade de se restringir a responsabilidade de alguns sócios, fazendo surgir a figura do sócio comanditário, com responsabilidade limitada aos fundos com que contribuiu à atividade empresarial, em universo que, até então, somente conhecia a responsabilidade ilimitada e solidária entre sócios comerciantes.

Trata-se de um modelo híbrido, uma mistura de sociedade em comandita simples e sociedade anônima. Na responsabilidade dos sócios e na gestão social, segue o modelo proposto pelas comanditas: somente os sócios podem administrá-la. Na estrutura econômica, seu capital é dividido em ações, facultando-lhe emitir outros valores mobiliários.

Segundo Di Sabato, a intenção do legislador foi fazer “coincidir o poder de gestão com a responsabilidade pessoal, além de favorecer, em particular, a ampliação da empresa individual permitindo-lhe obter recursos no mercado de capitais e possibilitando, por outro lado, que seu fundador

consERVE com segurança uma posição de estabilidade em sua direção” (1999:398). E, como lembra o jurista italiano, a sociedade limitada igualmente se propõe a garantir o comando da direção e gestão da sociedade, sem abrir mão da limitação da responsabilidade dos sócios, sendo esta a razão de não ter obtido a popularidade desejada pelo legislador.

Difere da sociedade em comandita simples, tão somente, porque sua estrutura é de uma sociedade anônima, seu capital é dividido em ações e, ainda, porque os sócios comanditários podem exercer a gerência, com o ônus de responderem como se comanditados fossem.

O Código Civil a prevê nos arts. 1.090-1.092, com estrutura semelhante à que lhe deram os arts. 280-284 da LSA, sem qualquer novidade essencial.

Suas principais características são:

a) Previsão legal: arts. 280 a 284 da Lei n. 6.404/76 e 1.090 a 1.092 do Código Civil.

b) Categorias de sócios: tal qual a sociedade em comandita simples, a em comandita por ações exige a presença de duas classes de sócios: os sócios diretores (comanditados) são solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações sociais, de forma subsidiária ao patrimônio social; os sócios acionistas (comanditários) respondem tão somente pela integralização das ações subscritas ou adquiridas (LSA, art. 282).

c) Nome empresarial: sua natureza mista permite-lhe fazer uso de firma social ou de denominação. A primeira modalidade é formada pelo nome todo, ou parte dele, de um ou alguns sócios diretores, com a adição “e companhia”, de forma extensa ou abreviada, ou, ainda, de todos os nomes de sócios diretores, completos ou abreviados, sem o aditivo. A segunda forma de constituição do nome é o uso de expressão linguística designativa do objeto social. Em ambas as modalidades deve-se acrescentar a expressão comandita por ações (CC, arts. 1.157 e 1.161).

d) Gerência: pode ser exercida por qualquer acionista, que, nesta qualidade, responderá ilimitada e solidariamente com os demais diretores, pelas obrigações da sociedade, de forma subsidiária ao patrimônio social. A responsabilidade perdura até dois anos após a destituição ou exoneração, pelas obrigações contraídas durante sua gestão (LSA, art. 282, § 2º, e CC, art. 1.091, § 3º).

e) Restrição de poderes da assembleia geral, que não pode, sem o consentimento dos diretores, (1) mudar o objeto essencial da sociedade; (2) prorrogar-lhe o prazo de duração, (3) aumentar ou diminuir o capital social, (4) criar debêntures ou (5) partes beneficiárias (LSA, art. 283, e CC, art. 1.092).

f) Limitação da regência da LSA: não se aplicam à sociedade em comandita por ações o disposto relativo às seguintes matérias: 1) Conselho de Administração; 2) autorização estatutária de aumento de capital; e 3) emissão de bônus de subscrição (LSA, art. 284).

34. Sociedade anônima

34.1. Fundadores

A constituição da sociedade anônima se dá por subscrição privada (também chamada simultânea) e pública (denominada sucessiva), objeto de estudos no item 10.2.

Na constituição privada, todos os subscritores do capital inicial são considerados fundadores, o que não ocorre na forma pública, sucessiva, porque nesta a fase de subscrição é precedida por etapas preliminares de elaboração do projeto e do prospecto de chamamento e de prévio pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários.

O fundador (ou fundadores) tem papel preponderante nessas fases preliminares e, por seu trabalho, faz jus a uma remuneração, obriga-se por

prejuízos resultantes da inobservância dos preceitos legais e, ainda, agindo com dolo ou culpa, responde por atos ou operações anteriores à constituição da companhia (LSA, art. 92).

As despesas legalmente obrigatórias – registro, despesas com tabelião etc. – são suportadas pelos recursos arrecadados na subscrição.

Haverá, contudo, outras despesas (por exemplo: publicidade, difusão dos prospectos e boletins de ações, elaboração e impressão das cópias dos estatutos), às quais Tullio Ascarelli (2001:675-677) denomina “normalmente necessárias” que somente obrigarão os subscritores se constarem do prospecto (LSA, art. 84, V).

34.2. Estatutos

Os estatutos sociais devem conter os elementos essenciais comuns a qualquer contrato de constituição de sociedade, tais como sede, nome empresarial e objeto social.

Dependendo da forma adotada, os estatutos devem conter, obrigatória ou facultativamente, outros requisitos específicos, conforme indica a Lei das Sociedades por Ações:

REQUISITOS	ARTIGO DA LSA
Objeto social, de modo preciso e completo	2º, § 2º
Fixação do capital social, expresso em moeda nacional	5º
Forma de alteração do capital social	6º
Número das ações em que se divide o capital social, estabelecendo se as ações terão, ou não, valor nominal	11
Criação ou não de uma ou mais classes de ações preferenciais	17

Preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito	17, § 2º
Definição, ou não, a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração	18
Se o capital for dividido em ações preferenciais, o estatuto deve declarar as vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações de outra e em ações ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições	19
Forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma	22
Forma de convocação e instalação da assembleia geral	121
Quorum para deliberação das matérias, nas companhias fechadas	129, § 1º
Conselho Fiscal – permanente ou não (veja item 48.6)	132, III, e 161, §§ 2º-5º
Organização e estruturação administrativa da sociedade	138
Criação de órgão com funções técnicas	160
Autorização para aumento de capital social	168
Data de término do exercício social	175
Criação de reservas	194
Modo de liquidação da sociedade	208
Quorum diferenciado para promover a transformação da sociedade etc.	221

34.3. Número de sócios

Para a constituição da sociedade por ações é necessário se faça a subscrição de todas as ações em que se divide o capital social por, no mínimo, duas pessoas (LSA, art. 80, I).

A lei abre duas únicas exceções: a) a companhia subsidiária integral; e b) a sociedade com um único acionista, verificada em assembleia geral ordinária, no prazo em que a lei permite sua reconstituição: até a assembleia geral ordinária do ano seguinte (LSA, art. 206, I, d).

Subsidiária integral é a sociedade prevista no art. 251 da LSA, podendo originar-se através de escritura pública ou mediante a aquisição de todas as ações de uma companhia por outra. É essencial que seu único acionista seja uma sociedade brasileira.

34.4. Capital social inicial

O capital social fixado nos estatutos corresponde ao montante inicial que a sociedade disporá para a consecução de seus objetivos sociais. A lei brasileira não estabeleceu um capital mínimo obrigatório, como também não fixou uma faixa de valores para a obrigatoriedade de se adotar esta ou aquela estrutura social.

Salvo na hipótese das sociedades dependentes de autorização e das companhias abertas, inexistente interferência do Poder Público ou do legislador na consideração do valor necessário à viabilidade do empreendimento a ser desenvolvido pelas sociedades no território brasileiro.

São exemplos de exigências as companhias hipotecárias, as quais, segundo o art. 1º da Resolução n. 2.607, de 28 de maio de 1999, do Banco Central do Brasil, somente podem se constituir com pelo menos R\$ 3.000.000,00 de capital realizado. Desse mesmo dispositivo são extraídos outros exemplos: os bancos comerciais (mínimo de R\$ 17.500.000,00), os bancos de investimentos (mínimo de R\$ 12.500.000,00), as sociedades de

crédito, financiamento e investimento (mínimo de R\$ 7.000.000,00). Deve-se observar, ainda, que as instituições financeiras devem realizar o capital inicial e os aumentos sempre em moeda corrente, exigindo-se, no ato, a realização de, pelo menos, 50% do montante subscrito (Lei n. 4.595/64, arts. 26 e 27).

A dispensa legal quanto à fixação de um capital mínimo permite a criação de sociedade por ações para pequenos ou grandes empreendimentos. Este mesmo raciocínio vale para as sociedades limitadas: não havendo faixas obrigatórias para a escolha do tipo societário, é possível sua constituição para um largo espectro de empreendimentos, como realmente ocorre na prática.

A expressão “capital subscrito” é usada para designar o total que consta nos estatutos da sociedade, tenha sido ou não efetivamente pago pelos acionistas subscritores das ações. “Capital realizado” corresponde à soma do que efetivamente ingressou na sociedade, isto é, a parte que os acionistas subscritores realmente efetivaram. “Capital a realizar” é o valor que falta a ser integralizado pelos acionistas.

Na constituição do capital social a Lei das Sociedades por Ações exige a realização mínima, em dinheiro, a título de entrada, de 10% sobre o preço de emissão das ações subscritas, depositados junto ao Banco do Brasil ou instituição autorizada (art. 80).

O restante do capital pode ser formado por contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação monetária. No caso de transferência de bens a favor da companhia, exige-se avaliação por três peritos ou por empresa especializada, sendo certo que estes, bem como o subscritor, respondem perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido. No caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.

Para algumas sociedades a realização do capital inicial será sempre em

dinheiro, como é o caso das instituições financeiras públicas e privadas (art. 26 da Lei n. 4.595/64).

Durante a vida da sociedade, seu capital pode ser mantido, aumentado ou até reduzido, dependendo da conveniência e situações que ocorrem.

Em geral compete à assembleia geral, em reunião ordinária ou extraordinária (LSA, art. 166), aumentar o capital social; contudo, nem sempre a modificação depende de sua decisão.

34.5. Redução do capital social

É possível a redução do capital social anteriormente fixado, em quatro hipóteses contempladas pela Lei n. 6.404/76:

a) Perdas. A primeira hipótese é o acúmulo de perda ou prejuízo pela companhia. A redução se dará até o limite do prejuízo acumulado pela sociedade, conforme estipula o art. 173 da LSA: "A assembleia geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo".

b) Excesso de capital. A lei contempla a eventualidade de excesso de capital e, neste caso, a solução é a retirada de circulação definitiva de um determinado volume de ações, mediante resgate do excesso que se encontra em mãos dos acionistas (LSA, art. 44, § 1º).

c) Reembolso dos acionistas dissidentes, sem substituição. A redução do capital pode ocorrer pelo pagamento dos acionistas dissidentes, isto é, aqueles que, não se conformando com as decisões tomadas pelos órgãos sociais, decidem, unilateralmente, retirar-se, levando consigo fundos aplicados. Se no prazo de cento e vinte dias, contados da publicação da ata da assembleia que autorizou a retirada, não se substituir o acionista dissidente, considerar-se-á reduzido o capital da companhia, no limite dos fundos retirados.

Em caso de falência, duas situações podem ocorrer, levando em conta se

os dissidentes retiraram ou não os fundos correspondentes.

Os acionistas dissidentes que receberam efetivamente os fundos ficam responsáveis pela restituição do reembolso pago, até o limite dos credores então existentes, na mesma proporção, pelo valor dividido entre todos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas.

Considerou-se que o reembolso não deva ser integral, mas proporcional à sua participação no capital social e, ao mesmo tempo, da dívida existente, para não impor aos dissidentes obrigação superior a que se sujeitariam se permanecessem na sociedade.

O reembolso se baseia em balanço especial que leva em conta o patrimônio líquido apurado no momento da retirada. Operações posteriores podem inviabilizar a manutenção daqueles valores, mas não se justifica sua imposição aos sócios retirantes. É justo, portanto, que não respondam com o valor integral da retirada – salvo se a apuração levantada por balanço especial for inidônea – mas, tão somente, na proporção ao que aquela retirada representava no capital social e sobre a dívida que foi acumulada até a data da operação e não foi saldada em razão de fatos posteriores não atribuíveis a esses sócios dissidentes.

No caso de os acionistas dissidentes não saldarem amigavelmente os débitos, a ação para recebimento dessas importâncias é de natureza tipicamente falimentar, prevista no art. 82 da LREF.

Se, à data da falência, o acionista dissidente ainda não recebeu seu crédito, apesar de autorizado pela assembleia, sua situação não é a de devedor por reembolso, mas a de credor sujeito ao rateio final, recebendo apenas antes da distribuição do saldo entre os acionistas.

d) Pagamento de acionista remisso. A redução ainda pode ocorrer na hipótese de devolução das importâncias já efetuadas pela integralização parcial do capital subscrito, pelo acionista remisso (veja item 13.1, supra), sem que a sociedade tenha êxito na sua venda a terceiros.

35. Sociedade anônima de capital autorizado

Há casos de aumento de capital automático, por força do que determinar o estatuto da companhia. É o que ocorre na companhia de capital autorizado, cujo estatuto pode conter autorização para aumento de capital social, independente de reforma estatutária. Neste caso, a autorização deve especificar: a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas; b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembleia geral ou o conselho de administração; c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões; d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição, ou de inexistência desse direito.

Se o limite de autorização for fixado em valor do capital social, será anualmente corrigido pela assembleia geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social.

Emprega-se, ainda, o capital autorizado para beneficiar administradores, empregados e pessoas naturais que prestem serviços direta ou indiretamente à sociedade, através de opção de compra de ações.

Sociedade anônima de capital autorizado é, portanto, aquela que adotou, como sistema de formação do capital, a subscrição do capital em valores inferiores ao permitido pelos estatutos sociais. Neste caso, o capital a ser realizado já está autorizado de antemão, independente de reforma dos estatutos ou convocação de assembleia para deliberação, bastando aos órgãos de administração lançar novas ações, paulatinamente, conforme sua necessidade.

As sociedades que adotarem esse tipo de aumento de capital devem, necessariamente, estabelecer como órgão de deliberação, ao lado da diretoria, o conselho de administração (LSA, art. 138).

36. Sociedades anônimas abertas e fechadas

Vimos dois tipos especiais de sociedades anônimas, a primeira leva em conta a forma especial de aumento de capital – sociedade anônima de capital autorizado – e a segunda se revela por ser exceção à regra quanto ao número de integrantes – a subsidiária integral.

Há, ainda, certas peculiaridades que as sociedades podem assumir durante sua existência, permitindo as seguintes classificações: a) quanto à emissão e distribuição de valores mobiliários: as sociedades serão abertas ou fechadas; b) quanto à origem de seu capital: considerar-se-ão de capital privado ou de capital misto; c) quanto à transnacionalidade de seu capital, de sua direção e atuação, classificam-se em multinacionais, nacionais ou estrangeiras.

Sociedades abertas são as que têm – e as fechadas as que não têm – seus valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa ou no mercado de valores imobiliários.

O acesso ao mercado aberto é precedido de autorização da Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda.

A negociação dos valores mobiliários de uma sociedade aberta pode ser realizada junto ao público em geral.

Bolsa de Valores é uma entidade privada que mantém um local para negociação de valores mobiliários, em mercado livre e aberto, organizado e fiscalizado pelos próprios corretores e pelas autoridades monetárias, sendo exatamente esses seus dois principais objetivos: a) manter local para a realização de venda e compra de títulos e valores mobiliários, destinado a seus membros; b) fiscalizar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de seus membros – corretoras – e das sociedades emissoras de títulos.

Algumas ações, embora autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, não são listadas entre as negociadas em bolsa, por não

satisfazerem determinados requisitos para efeito de negociação de seus títulos em pregão. Cada bolsa fixa suas exigências em termos de tamanho de capital, rentabilidade mínima etc. Assim, negada a negociação num determinado pregão, o valor mobiliário pode ser negociado em outra bolsa ou no mercado de balcão.

Podemos adotar a definição de “mercado de balcão” do Vocabulário da Comissão Nacional de Bolsas de Valores: “mercado de títulos sem lugar fixo para o desenrolar das negociações. Os títulos são fechados via telefônica, entre instituições financeiras. São negociadas ações de empresas não registradas em Bolsa de Valores e outras espécies de títulos”.

Além da Comissão de Valores Mobiliários, o mercado acionário está sujeito à fiscalização do Ministério Público cabendo a este órgão do Estado propor ação civil pública (Lei n. 7.913, de 7-12-1989, art. 1º) para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado, decorrentes de práticas irregulares.

Uma última observação sobre este tema: na linguagem econômica denomina-se mercado primário aquele realizado pelo investidor diretamente com a companhia, quando da emissão dos papéis (ações e valores mobiliários) e secundário, o referente à circulação desses títulos por força de alienações posteriores, entre o investidor originário e terceiro.

37. Sociedade de economia mista

Previstas nos arts. 235-240 da LSA, as sociedades de economia mista fazem parte do complexo de empresas estatais, ao lado das empresas públicas e outras mantidas pelo Poder Público. Por força do art. 173, § 1º, II, da CF88, as sociedades de economia mista são criadas para explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, visando atender a uma função social e sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas.

Em razão de seu regime híbrido, sujeita-se à obediência aos princípios da Administração Pública, inclusive na contratação de obras, serviços, compras e alienações. Obriga-se, ainda, a manter conselhos de administração e fiscal, órgãos facultativos, em regra, para as sociedades anônimas em geral.

Caracterizam-na: a) sua constituição: a criação e extinção por lei (LSA, art. 236); b) seu objeto social: o exercício de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços; c) sua finalidade: necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei; d) seu controle: sujeita-se sempre a órgão governamental, pessoa jurídica de direito público que exerce a função de acionista controlador, com todos os seus encargos; e) seu regime legal: submete-se às normas de direito público nas licitações, contratações de serviços e compras, mas rege-se também pelas regras da sociedade por ações; f) sua forma: adota sempre a forma de sociedade anônima, distintamente da empresa pública stricto sensu, que pode adotar outra modalidade societária; g) seu capital misto: fundos públicos e em investimento de particulares; h) subordinação administrativa: a responsabilidade dos dirigentes, além do que ordinariamente a LSA impõe, funda-se em regime próprio da administração estatal (CF88, art. 173, § 1º, V), inclusive às penas em decorrência de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92, art. 1º).

A partir dessas características próprias quanto a seu controle, criação e objeto é possível formular o seguinte conceito de sociedade de economia mista: sociedade anônima de direito privado, sujeita aos princípios da Administração Pública e controlada pelo Poder Público, criada por lei para atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, tendo por objeto atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços.

38. Sociedade anônima multinacional

Três usos podem ser feitos da expressão empresa multinacional: (a) o uso econômico, mostrando o processo de expansão extraterritorial dessas empresas, (b) a indicação de Estados-sócios comuns a um empreendimento e (c) empresas constituídas sob regras comuns e uniformes de dois ou mais Estados.

39. Direitos essenciais do acionista

Entre os direitos gerais, a LSA arrola, no art. 109, os chamados essenciais que não são passíveis de privação pela assembleia geral ou pelo estatuto. O direito de voto não se insere entre eles por existirem frações do capital que não o concedem.

São direitos essenciais:

a) Participação nos lucros sociais: Em regra o acionista tem o direito de participar dos lucros da empresa, recebendo dividendos periodicamente. A lei estabelece a exigência de pagamento de parcela dos lucros pelo menos uma vez em cada exercício da sociedade. Este dividendo é chamado obrigatório (LSA, art. 202) e é de tal forma protegido que cabe à Comissão de Valores Mobiliários, no exercício de seus atos de fiscalização, verificar o cumprimento desse dispositivo, por parte das companhias de capital aberto. Sua redução, ainda, exige quorum qualificado (LSA, art. 136).

Dividendo é a parte do lucro líquido do exercício, dos lucros acumulados ou da reserva de lucros a ser distribuída em dinheiro aos acionistas, na proporção que cada um possuir da fração do capital social. Se os estatutos não fixarem um dividendo mínimo, a companhia deverá distribuir pelo menos 25% de seu lucro líquido no final de cada exercício, sendo que as ações preferenciais devem receber 10% a mais que as ordinárias (LSA, art. 17, § 1º, I e II).

O direito à percepção de dividendos é um direito essencial do acionista e, dessa forma, não pode ser objeto de decisão contrária ou de previsão

diversa nos estatutos sociais. Contudo, seu exercício depende de haver numerário suficiente em caixa, conforme estabelece o art. 202 da LSA.

Adota-se no direito pátrio o princípio da anualidade do exercício social, com término fixado nos estatutos (LSA, art. 175), data em que a diretoria da companhia fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I – balanço patrimonial; II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III – demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado (LSA, art. 176).

É com base nas demonstrações sociais que se calculam os lucros, que por sua vez fundamentam a distribuição de dividendos. Entretanto, é possível que isto ocorra também em outra época, dando origem ao chamado dividendo intermediário, semestral ou intercalar, previsto no art. 204 da LSA.

Nesse caso, quando a companhia, por força de lei ou de disposição estatutária, tiver que levantar balanço semestral, poderá declarar – se assim for deliberado, devidamente autorizado pelos estatutos – dividendo que pode, ainda, ser levantado em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda do montante das reservas de capital de que trata o § 1o do art. 182 da mesma lei.

b) Participação do acervo da companhia, em caso de liquidação: Liquidação é o processo de apuração do ativo e pagamento do passivo da companhia, com vistas à sua extinção. Durante esse período o acionista tem não só o direito de participar do acervo da companhia, isto é, de receber a parte que lhe cabe por rateio, depois de pagos os credores, como, também, o de exercício de voto nas assembleias gerais, independente da natureza das ações que possuir (LSA, art. 213).

c) Fiscalização, na forma prevista na lei, da gestão dos negócios sociais: Ao administrador em qualquer sociedade incumbe prestar contas de sua administração, informando o andamento dos trabalhos aos sócios. Como decorrência, cabe a qualquer acionista o direito de fiscalizar a gestão dos negócios.

d) Preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos arts. 171 e 172 da LSA: Este direito visa à conservação da posição do acionista no quadro social em relação aos demais sócios. O possuidor de 20% das ações de uma companhia que não seja consultado sobre a emissão de um grande número de debêntures conversíveis em ações, pode perder sua participação acionária se não exercer o direito de aquisição. Essas debêntures posteriormente convertidas em ações podem corresponder, por exemplo, a um aumento de 100% do capital social. Para conservar sua posição, este acionista deveria ter adquirido 20% dessas debêntures (e por consequência dessas novas ações), sob pena de ver sua proporção cair de 20% para 10% do capital social.

e) Retirar-se da sociedade nos casos previstos na lei: Configura o chamado direito de recesso, objeto das anotações supra (item 11.8).

40. Ações

O capital social de uma sociedade tipicamente de capitais, como as sociedades anônima e a em comandita por ações, divide-se em unidades denominadas ações, e os compradores destas, acionistas, respondem apenas até o limite da integralização das frações de que sejam titulares, em seus valores de emissão.

Conceituam-se as ações como a menor parte do capital social. Esta definição é restrita à ideia de unidade de capital. Há outras duas ideias:

representam o direito à participação acionária, para exercício de direitos próprios de sócio, e, ainda, são consideradas por alguns como títulos de crédito. Este é o magistério de Waldirio Bulgarelli: “Não se trata, como se vê, de um título exatamente igual ao modelo da letra de câmbio ou da letra promissória que serviram de base para a construção da teoria geral dos títulos de crédito e do direito cambiário, mas de um título característico ligado às próprias características da sociedade anônima” (1996(a):112).

40.1. Classificação das ações

Classificam-se as ações em três critérios distintos: espécie, classe e forma.

QUANTO À ESPÉCIE OU NATUREZA DO DIREITO CONFERIDO		
Espécies de ações	Direito conferido	Regra legal
Ordinárias; também chamadas comuns	Conferem direitos normalmente concedidos ao acionista comum, inclusive o direito de voto	LSA, art. 16
Preferenciais	Outorgam vantagens especiais, consistentes em prioridade na distribuição de dividendos fixos ou mínimos, prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele e acumulação de ambas as vantagens. A lei admite que até 50% do total do capital social seja dividido em ações preferenciais sem direito a voto. Até 2001 era possível a emissão de 2/3 de ações preferenciais	LSA, art. 17 e art. 15, § 2º, com a redação que lhe deu Lei n. 10.303, de 2001
De fruição	São as que resultam da amortização das ações ordinárias e das ações preferenciais. Distinguem-se o resgate e a amortização: o primeiro se dá no pagamento do valor das ações, retirando-as de circulação; já a amortização é a distribuição aos acionistas, a título de antecipação e	LSA, art. 44, § 5º

	sem redução do capital social, de quantias que lhe seriam devidas em caso de liquidação. Se integralmente amortizadas, podem ser substituídas por ações de fruição	
--	--	--

QUANTO À CLASSE		
QUANTO À CLASSE		
Espécies de ações	Classes – vantagens conferidas em função de:	Regra legal
Ordinárias, emitidas exclusivamente por sociedades fechadas. Obs.: nas sociedades abertas não há diversidade de classes de ordinaristas	Conversibilidade ou não em ações preferenciais	LSA, art. 16
	Exigência ou não de nacionalidade brasileira do acionista	
	Direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos	
Preferenciais	O estatuto deve especificar as classes de ações preferenciais, atendendo aos direitos que conferem: a) prioridade na distribuição de dividendos fixos ou mínimos; b) prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; e c) acumulação de ambas as vantagens. Pode emitir, por exemplo, ações preferenciais de classe A, conferindo um dividendo mínimo de 20% maiores que os da classe ordinária; ou, ainda, fixar para a classe B um dividendo fixo de 12% sobre seu preço etc.	LSA, art. 17

QUANTO À FORMA		
Formas	Tipo de registro	Regra legal
	Escriturais: quando mantidas em conta de depósito em nome	

Nominativas	de seu titular, sem emissão de certificados, em instituição do sistema financeiro, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Em razão dessa exigência, a circulação das ações se faz pela transcrição no livro de registro	LSA, arts. 31, 34 e 35
	Não escriturais	
Endossáveis	Permitiam a circulação mediante endosso, presumindo-se a propriedade pela posse, com base na regularidade da série de assinaturas lançadas no título O exercício dos direitos de ação exigia a averbação do nome do acionista no livro de Registro de Ações Endossáveis e no certificado das ações	Existiram até a promulgação da Lei n. 8.021, de 12-4-1990, quando foram extintas no direito brasileiro
Ao portador	Presumia-se proprietário da ação seu portador, operando-se a transferência por mera tradição das ações	

Dentro dessa classificação, as bolsas de valores utilizam uma codificação para identificar os títulos negociados. São encontradas no mercado com as siglas ES (escriturais), ON (ordinárias nominativas) e PN (preferenciais nominativas). Estas últimas podem ser divididas por classes (A, B, C, D etc.), gerando códigos como PNA, PNB etc.

40.2. Valores das ações

A ação possui um preço de emissão, pago por quem a subscreve. Entretanto, conforme o objetivo que se persegue, é possível reconhecer três outros valores para a ação: nominal, patrimonial e bolsístico, este último também conhecido pelas expressões valor de mercado ou bursátil.

O valor nominal é obtido dividindo-se o capital social pelo número de ações. Se o estatuto expressar esse valor, ter-se-á ação com valor nominal. Nas companhias abertas, ele não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, porque representaria uma venda de parcela de capital a preço abaixo de seu valor real, ou, na linguagem de

mercado, a venda se daria com abatimento ou deságio.

Se a venda da ação por preço inferior ao valor de emissão é vedada, contudo, a prática do inverso – venda com valor superior ao nominal – é permitida. A diferença entre o valor e o preço de venda é chamada ágio, classificada como reserva de capital, categoria de valores positivos não resultantes do lucro realizado pela companhia, cuja finalidade servirá para: a) absorver prejuízos que ultrapassem os lucros acumulados e as reservas de lucros; b) resgatar, reembolsar ou comprar ações; c) resgatar partes beneficiárias; d) incorporar-se ao capital social; e) pagar dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada.

Atente-se que, além dessa fonte – valor superior obtido na venda de ações ou de outros valores mobiliários –, a reserva de capital pode ter origem em: a) produto da alienação de partes beneficiárias e de bônus de subscrição; b) prêmio recebido na emissão de debêntures; c) doações e subvenções para investimento; d) resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado.

Ações sem valor nominal: a companhia pode não fixar um valor nominal – pré-valor para a venda da ação – deixando ao mercado a formação de seu preço, segundo princípios orientadores dos investimentos: a perspectiva de lucros, o bom nome da empresa, a cotação na bolsa ou no mercado de balcão, o patrimônio e a solidez dos negócios etc.

O art. 170 da LSA estabelece que o preço de emissão de novas ações deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: I – a perspectiva de rentabilidade da companhia; II – o valor do patrimônio líquido da ação; III – a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.

É correto, portanto, afirmar que ambas as modalidades de emissão – com ou sem valor – têm em comum a necessidade de ter seu preço de

emissão em valores iguais ou superiores ao valor encontrado no resultado da divisão capital/número de ações, sob pena de ver anulada ou frustrada sua colocação no mercado.

Fixado seu preço, na constituição da companhia e nos aumentos de capital, a ação ingressa no mercado sem valor facial, isto é, sem indicação do valor da parcela que corresponde ao capital social. No Brasil esse sistema foi adotado pelo legislador, mas vem sendo aceito com certa relutância pelo mercado acionário.

É possível a coexistência, numa mesma sociedade, de ações com valor e sem valor nominal (LSA, art. 11, § 1º), sendo, entretanto, preferível a escolha de apenas uma modalidade, em razão de dificuldades de ordem prática.

Valor patrimonial ou contábil é o resultado da divisão entre o valor do patrimônio líquido e o número de ações. É o que se paga ao acionista em caso de liquidação ou reembolso. A lei fixa minuciosos critérios contábeis para a avaliação do ativo e do passivo da sociedade, bem como a apuração dos lucros e perdas da sociedade, tudo visando dar a conhecer a real situação da empresa.

Valor de mercado ou bolsístico: é o de compra e venda na alienação da ação e que depende do desempenho da empresa e da economia em geral. Compreende uma classificação própria: ações de primeira, segunda e terceira linhas. As primeiras são chamadas blue chips e representam as que são mais procuradas em razão da reputação ou âmbito de atividade da empresa emissora; as segundas possuem um volume menor de negócios; e as terceiras, de companhias menos conhecidas. Os preços das ações são formados em pregão e, como ocorre com todo produto de comércio, dependem da lei da oferta e da procura.

40.3. Certificado de ações e agente emissor

Depois de praticados todos os atos necessários à constituição da companhia – e, se a subscrição não se fez em dinheiro, cumpridas eventuais formalidades necessárias à avaliação e à transmissão de bens – a sociedade deverá emitir certificados representativos da propriedade das ações, que são os documentos cartulares denotativos do direito que ele desempenha.

O acionista tem direito à indenização pelos danos que lhe forem causados por erros contidos no documento, sendo certo que a responsabilidade pela correta emissão dos certificados cabe aos diretores, em cuja gestão tenham sido emitidos.

É possível, ainda, a emissão de cautelas e de certificado múltiplos de ações, servindo a primeira para demonstração provisória dos direitos representados e, a segunda, para agrupar inúmeras ações em um só documento.

Para se desincumbir do importante papel de escrituração, registro, transferência de ações e emissão de certificados, a companhia pode contratar instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço – agente emissor –, a quem competirá realizá-los com exclusividade e cujo nome constará das publicações e ofertas públicas de valores mobiliários feitas pela companhia.

A impressão, reprodução ou, de qualquer modo, a fabricação ou colocação de certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário, sem autorização escrita da sociedade emissora, são figuras típicas previstas no art. 2º da Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986.

Igualmente, configura o crime do art. 7º da mesma lei emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: a) falsos ou falsificados; b) sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados; c) sem lastro ou garantia insuficiente nos

termos da legislação; d) sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida.

40.4. Custódia de ações

Adotou-se no direito brasileiro a custódia das ações com o objetivo de reduzir os custos de administração de carteiras de títulos.

Partindo da premissa que os valores mobiliários são títulos emitidos em lotes, conferindo em cada classe e espécie direitos iguais, tendo o acionista entregue um determinado número de ações para serem administradas por instituição financeira, ele pode vir a receber igual número de ações, consubstanciadas em certificado diverso do originalmente confiado. A instituição depositária se obriga a devolver o mesmo número de ações daquela modalidade – classe e espécie –, embora com outro número de ordem, representada por certificado diverso do primitivo.

Esta qualidade de as ações poderem ser substituídas por outras da mesma espécie e quantidade decorre de sua natureza fungível (CC, art. 85).

Dois aspectos devem ser salientados quanto ao direito ao voto e à responsabilidade da sociedade:

1º) O contrato de custódia não outorga à instituição o exercício do direito de voto, e é por esta razão que a depositária deve comunicar, em listas ao menos uma vez por ano, à sociedade emissora o nome dos depositantes das ações, assim como a quantidade das ações pertencentes a cada um.

2º) O contrato de custódia não gera qualquer responsabilidade à companhia emissora, uma vez que é firmado apenas entre acionista e instituição financeira. A depositária se obriga a representar os acionistas junto à sociedade emissora somente para o exercício de dois atos jurídicos: a) receber dividendos e ações bonificadas e b) exercer direito de preferência para subscrição de ações.

40.5. Certificado de depósito de ações

Quando a instituição financeira depositária de ações for autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a emitir certificados de ações, também poderá pôr em circulação título representativo das ações que receber em depósito.

A função destes é permitir que o contrato de custódia de títulos seja representado por papel de livre negociação, sem a necessidade de o titular movimentar os títulos originais em poder da instituição financeira.

40.6. Sistema único de custódia

O sistema de tradição física de certificados representativos de valores mobiliários traz alguns inconvenientes: ao se operar a venda ou a compra de um título nas bolsas de valores, as cautelas que representam as ações negociadas ou os certificados devem ser transferidos de um lugar a outro, gerando o risco de sua perda ou roubo. Com a evolução dos sistemas de bancos de dados informatizados, introduziu-se um serviço único de custódia, a cargo das bolsas de valores: os certificados representativos de companhias abertas passaram a ser emitidos de forma unicamente contábil (escritural), permitindo sua transferência sem necessidade de deslocamento ou guarda física de títulos que representam milhões de reais.

A Bolsa de Valores de São Paulo centralizou os serviços de custódia dos títulos das companhias abertas, e as transferências de titularidade das ações passaram a ser feitas em um único ambiente.

40.7. Constituição de direitos reais sobre as ações

Por serem coisas móveis, as ações podem ser objeto de penhor e de outros direitos e ônus reais (LSA, arts. 39 e 40).

A efetivação do penhor se dá, em regra, pela averbação do respectivo contrato no livro de "Registro de Ações Nominativas", salvo se escriturais,

quando então se averbará o penhor da instituição financeira, anotando-se no extrato contábil correspondente.

A lei brasileira não atribui o exercício do direito ao voto ao credor pignoratício, dispondo textualmente: o “penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito de voto; será lícito, todavia, estabelecer, no contrato, que o acionista não poderá, sem consentimento do credor pignoratício, votar em certas deliberações” (LSA, art. 113). Confere, entretanto, o direito de o credor praticar atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado (CC, art. 1.454) e, conseqüentemente, faculta-lhe, por meio de cláusula contratual, a possibilidade de intervir em decisões sociais que comprometam ou reduzam as garantias ofertadas.

Um dos usos do penhor é mencionado pela própria lei societária, ao permitir, no art. 148, que o estatuto estabeleça que o exercício do cargo de administrador da companhia seja assegurado mediante o penhor de ações de propriedade de terceiros ou do próprio administrador, podendo essa garantia somente ser levantada após a aprovação das últimas contas desse diretor.

Se as ações forem gravadas com cláusula de usufruto, o direito de voto deverá estar previsto no contrato que estipulou o gravame e, não o sendo, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário (LSA, art. 114).

Há outras hipóteses de imposição de ônus sobre as ações, tais como o fideicomisso e a alienação fiduciária em garantia.

41. Valores mobiliários

São chamados valores mobiliários tanto a ação como também os demais títulos de investimento, previstos na LSA: debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição.

A distinção essencial entre as ações e os demais valores mobiliários é

que as primeiras formam o capital próprio da sociedade, concedendo aos titulares a participação na vida da sociedade e as segundas são obrigações assumidas pela companhia perante terceiros que ingressam com investimento próprio, ou mesmo sem ele, objetivando receber, no prazo que for estipulado, direito de crédito contra a sociedade.

42. Valores mobiliários – debêntures

As debêntures – também chamadas simplesmente de obrigações – são instrumentos de captação de recursos às sociedades por ações que concedem direito de crédito ao seu possuidor.

A companhia, de acordo com sua necessidade, pode realizar várias emissões, podendo dividi-las em séries que guardarão, em cada conjunto, as mesmas características de valores nominais e a concessão de iguais direitos.

Chama-se emissão pública a realizada por companhias abertas e privada a por companhias fechadas.

Distinguem-se as emissões privadas das públicas quanto ao órgão de deliberação, necessidade de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários e obrigatoriedade de constituição de agente fiduciário.

	Emissões públicas	Emissões privadas
Órgão de deliberação	Em regra compete à assembleia geral deliberar sobre a emissão, podendo, contudo, delegar ao conselho de administração algumas condições (vencimento, pagamento de juros, modo de subscrição etc. – LSA, art. 59, § 4º). O conselho de administração, quando constituído, também pode deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações (LSA, art. 59, § 1º).	Competência privativa da assembleia geral
	Prévio registro na CVM (art. 1º, I, da Lei n. 6.385, de 7-12-1976,	

Prévia autorização	com a redação dada pela Lei n. 10.303, de 31-10-2001). A última disciplina contendo procedimento simplificado para a emissão de debêntures consta da Instrução CVM n. 404, de 13-2-2004.	Mera comunicação à CVM.
Constituição de agente fiduciário	Obrigatória (LSA, art. 61, § 1º)	Facultativa (LSA, art. 61, § 1º)

42.1. Conversibilidade das debêntures

Em relação à conversibilidade, ou seja, à transformação ou não em ações, a lei permite duas espécies de debêntures: as conversíveis e as não conversíveis. A regra é a não conversibilidade, quando omissa a escritura de emissão. Vale dizer que as debêntures somente serão conversíveis em ações, se a escritura de emissão assim dispuser.

O mercado adotou ainda a expressão “debêntures permutáveis”, correspondendo àquelas que podem ser convertidas em ações de outra companhia que não seja a emissora dos papéis, o que ocorre quando as sociedades participam do mesmo grupo societário.

No ato de emissão dos títulos, em sendo possível a conversão para ações da companhia, a escritura deve especificar: a) as bases da conversão, tanto em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, como na relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações; b) a espécie e a classe das ações em que admitirá sua conversão; c) o prazo ou época para o exercício do direito à conversão; d) as demais condições às quais a conversão acaso fique sujeita.

Nesse tipo de debênture, justamente por ser conversível em parcela do capital social, os possuidores terão preferência em sua aquisição, na proporção do número de ações, espécies e classes que a escritura permite sejam titulares, seguindo a regra geral de preferência prevista nos arts. 171 e 172 da LSA.

Obviamente, enquanto ainda não são acionistas, mas na expectativa de virem a sê-lo pela conversão que seus títulos outorgam, os debenturistas têm a prerrogativa de opor-se a certas mudanças que possam prejudicar seus direitos. Exige, portanto, a lei, a prévia aprovação dos titulares de debêntures conversíveis em ações para qualquer alteração do estatuto da companhia no que se refere: a) à mudança do objeto da companhia; b) à criação de ações preferenciais ou modificação das vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures.

42.2. Garantias outorgadas

Em relação às garantias outorgadas, as debêntures subdividem-se em:

a) Debêntures com garantia real: é a outorgada sobre um determinado bem ou conjunto de bens: um prédio, um terreno etc. Os credores debenturistas, com tal garantia, possuem privilégio real e, como tal, a coisa dada em garantia sujeita-se ao cumprimento da obrigação. Sua posição em caso de concurso de credores é a do credor com direito real de garantia.

b) Debêntures com garantia flutuante: conferem garantia geral sobre o ativo da companhia, mas não impedem a negociação dos bens que compõem esse ativo. Os debenturistas estarão na situação comum de qualquer credor: o ativo da sociedade é a garantia futura do pagamento de seus créditos, não possuindo nenhuma ação contra eventual venda do ativo por parte da companhia. Ocorrendo execução ou a falência da sociedade, têm preferência sobre os créditos quirografários e receberão logo após o pagamento da classe dos credores com privilégio especial sobre determinado bem. Se as debêntures forem emitidas por companhia integrante de grupo de sociedades (LSA, art. 265) poderão ter garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades do grupo, conforme dispõe o art. 58, § 6º, da LSA.

c) Debêntures sem preferência: são considerados credores quirografários,

sem qualquer preferência no concurso de credores.

d) Debêntures subordinadas: em caso de falência, sua posição no quadro de credores da companhia antecede apenas à dos acionistas, figurando abaixo do último credor.

No tocante à forma de emissão, a Lei n. 8.021/90 extinguiu a possibilidade de emissão de debêntures endossáveis e ao portador (art. 2º, II) e, assim, elas serão sempre nominativas, podendo ser emitidas na forma escritural.

A emissão dar-se-á através de certificados contendo unidades ou múltiplos de debêntures. Poderão, entretanto, ser lançadas cautelas provisórias que representem esses títulos.

42.3. Agente fiduciário

Dois são os órgãos de organização dos debenturistas: a assembleia e o agente fiduciário. O primeiro é sempre obrigatório e o segundo é facultativo nas emissões por companhias fechadas.

Chama-se agente fiduciário o representante da comunhão dos debenturistas, nomeado no momento da lavratura da escritura de emissão de debêntures. Sua função é proteger os interesses dos debenturistas, notificando-os de qualquer inadimplência da sociedade e elaborando relatórios à disposição dos titulares desse direito, anualmente, ou, conforme dispõe a lei (LSA, art. 68), a figura do agente fiduciário é semelhante à de outros representantes de entes não personalizados, cabendo-lhe usar qualquer ação para proteger direitos ou defender os interesses dos debenturistas, sobretudo em caso de inadimplemento da companhia. Sua função, nesta oportunidade, será: a) declarar antecipadamente vencidas as debêntures; b) cobrar o principal e acessórios; c) executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional, das obrigações; d) requerer a falência da companhia

emissora, se não existirem garantias reais; e) representar os debenturistas em processos de falência, recuperação judicial, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, exceto deliberação em contrário da assembleia dos debenturistas; f) tomar qualquer providência necessária para que os obrigacionistas realizem seus créditos.

A escritura de emissão pode atribuir outras funções ao agente fiduciário, como autenticar os certificados, administrar o fundo de amortização, manter em custódia os bens dados em garantia e efetuar pagamentos de juros, amortização e resgate.

42.4. Assembleia de debenturistas

A assembleia de debenturistas reúne titulares de debêntures da mesma emissão ou série e tem por finalidade deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas, podendo ser convocada: a) pelo agente fiduciário; b) pela companhia emissora; c) por debenturistas que representem 10%, no mínimo, dos títulos em circulação; e d) pela Comissão de Valores Mobiliários.

A convocação será indispensável em alguns casos previstos na LSA: a) para deliberar sobre a redução do capital da sociedade emissora, nos casos previstos no art. 174; b) para decidir sobre a incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora (art. 231); c) para alterar o estatuto a fim de mudar o objeto da companhia, criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures, quando emitidas com esse direito e enquanto puder ser exercida a conversão.

43. Valores mobiliários – partes beneficiárias

Partes beneficiárias são títulos de crédito, literais, autônomos, onerosos ou gratuitos, sempre nominativos, estranhos ao capital social que conferem

direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação, de até 10% dos lucros anuais. Somente podem ser emitidos por companhias fechadas.

De Plácido e Silva (1946:184) esclarece a função original destes títulos: “São títulos negociáveis, sem valor nominal, emitidos pela sociedade, sem alteração ou modificação do capital social, como bonificação, ou paga a serviços prestados, aos fundadores, acionistas ou mesmo a estranhos”.

Modernamente, durante o prazo estipulado nos estatutos, o titular desses títulos receberá participação sobre os lucros anuais, sem que possa exercer qualquer direito privativo dos acionistas, a não ser o de fiscalizar os atos dos administradores. O prazo de duração das partes beneficiárias, quando estas forem emitidas gratuitamente, é de dez anos.

Em caso de liquidação ou falência, os titulares receberão apenas antes dos acionistas, após pagamento dos credores quirografários.

44. Valores mobiliários – bônus de subscrição

Os bônus de subscrição são títulos nominativos emitidos pelas companhias de capital autorizado, no limite do aumento consentido pelo estatuto, conferindo o direito de subscrever ações do capital social, mediante sua apresentação e o pagamento do preço de emissão. A lei concede preferência ao acionista em sua aquisição.

Os bônus de subscrição podem ser onerosos ou gratuitos, outorgados como vantagem adicional aos subscritores de emissões de ações ou de debêntures.

45. Valores mobiliários – papéis comerciais (commercial papers)

Também chamados notas promissórias de emissão pública são, como denota o nome, promessas de pagamento vencíveis no prazo de trinta a

trezentos e sessenta dias, emitidas com exclusividade pelas sociedades por ações. O prazo máximo é reduzido para cento e oitenta dias quando a emitente for companhia fechada.

No Brasil foram inicialmente regulamentados pela Instrução n. 134, de 1º de fevereiro de 1990, da Comissão de Valores Mobiliários, posteriormente alterada pela Instrução n. 292, de 15 de outubro de 1998, seguindo-se a de n. 155, de 7 de agosto de 1991, e a de n. 429, de 22 de março de 2006 e, mais recentemente, a de n. 400, de 29 de dezembro de 2003, e a de n. 566, de 31 de julho de 2015, com a redação dada pela Instrução CVM n. 538/2016.

A finalidade desses papéis comerciais é obter recursos para a consecução dos objetivos e desenvolvimento da sociedade por ações. Suas principais características são:

- a) conferem a seus titulares direito de crédito contra a companhia emitente;
- b) circulam por endosso em preto, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no art. 15 do Anexo I da Convenção para Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966;
- c) o valor nominal unitário não poderá ser inferior a R\$ 500.000,00;
- d) a emissão é precedida de concessão de registro na Comissão de Valores Mobiliários e de divulgação de aviso contendo, de forma resumida, as principais características de distribuição, constantes da deliberação da assembleia geral ou dos órgãos da administração, conforme dispuserem os estatutos da companhia: I – o valor da emissão e a sua divisão em séries, se for o caso; II – a quantidade e o valor nominal das notas promissórias; III – as condições de remuneração e de atualização monetária, se houver; IV – o prazo de vencimento dos títulos; V – as garantias, quando for o caso; VI – o demonstrativo para comprovação dos limites previstos na

regulamentação da CVM; VII – o local de pagamento; VIII – a contratação de prestação de serviços, tais como custódia, liquidação, emissão de certificados, agente pagador, conforme o caso;

e) negociabilidade em bolsa de valores ou mercado de balcão.

46. Quadro-resumo dos valores mobiliários

Valor Mobiliário	Direitos conferidos e espécies	G?	O?	Quem pode emitir	Base legal
Debêntures	Conferem direito de crédito e podem ser: Quanto à conversibilidade: • Conversíveis em ações • Permutáveis Quanto às garantias: • Com garantia real • Com garantia flutuante • Sem preferência • Subordinadas	não	sim	Companhias abertas – emissão pública. Companhias fechadas – emissão privada	LSA, arts. 52-74
Partes beneficiárias	Direito de participação nos lucros anuais, no limite máximo de 10%	sim	sim	Companhias abertas ou fechadas	LSA, arts. 46-51
Bônus de subscrição	Direito de subscrever ações do capital social	sim	sim	Companhias de capital autorizado	LSA, arts. 75-79
Commercial papers	Conferem direito de crédito, são promessas de pagamento	não	sim	Companhias com elevado patrimônio líquido	Instruções CVM n. 400/2003, 566/2015 e 538/2016

LEGENDAS: G? – gratuitos?; O? – onerosos?

47. Órgãos da sociedade por ações – as assembleias

São quatro os órgãos sociais previstos para as sociedades por ações, aos quais competem dirigir os negócios sociais: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral e a Diretoria, sendo que os dois primeiros são facultativos à maioria das sociedades constituídas.

47.1. Conceito

A assembleia geral “é a reunião de subscritores ou acionistas de uma sociedade por ações, convocada e instalada de acordo com a lei ou estatuto, a fim de constituir a companhia ou, se já constituída esta, deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social” (Dylson Doria, 1995:224).

Esse conceito pode ser ampliado para incluir, além daqueles, os assuntos referentes à reorganização societária, dissolução e liquidação, resultando numa expressão mais completa: “reunião de subscritores ou acionistas de uma sociedade por ações, convocada e instalada de acordo com a lei ou estatuto, a fim de constituir a companhia ou, se já organizada, deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social e, ainda, sobre os assuntos referentes à sua reorganização, dissolução e liquidação”.

47.2. Competência privativa da assembleia geral

Como órgão soberano de deliberação, com poderes para exprimir a vontade social e decidir seus principais assuntos, compete-lhe privativamente (LSA, art. 122):

I – Reformar o estatuto social

O estatuto social, aprovado no momento da constituição da companhia, contém as cláusulas de aceitação comum dos sócios e os elementos essenciais encontrados em qualquer contrato de constituição de sociedade, tais como sede, nome empresarial e objeto social e alguns outros

específicos à forma adotada. Nele se estabelecem os laços comuns que unem os associados a uma determinada empresa; por ser expressão do liame social entre todos os acionistas, somente estes podem decidir sobre a alteração de suas cláusulas.

A reforma do estatuto ocorre em assembleia geral extraordinária, sendo instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem dois terços, no mínimo, do capital com direito a voto (LSA, art. 135).

Por se tratar de matéria de alta relevância, os documentos pertinentes ao assunto a ser debatido deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia geral (LSA, art. 135, § 3º).

II – Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia

Em regra, compete à assembleia geral eleger e destituir todos os administradores.

A afirmação é verdadeira em relação ao Conselho Fiscal, sua eleição e destituição ocorrem sempre por deliberação da assembleia geral (LSA, art. 161, § 1º).

Se, entretanto, a sociedade constituir Conselho de Administração, o estatuto pode atribuir-lhe competência para eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições (LSA, art. 142, II).

III – Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas

As demonstrações financeiras espelham o sucesso ou o insucesso da empresa e os acionistas são os principais interessados nesses resultados, expressão clara da situação do patrimônio da companhia e das mutações ocorridas no exercício. Uma vez por ano, apresentadas as contas pelos administradores, a assembleia geral deve, nos quatro primeiros meses

seguintes ao término do exercício social, reunir-se para examinar, discutir e votá-las (LSA, art. 132).

O art. 176 estabelece que, ao fim de cada exercício social, a Diretoria deve elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, demonstrações financeiras, num total de cinco. Três são obrigatórias a todas as sociedades por ações, a saber: a) o balanço patrimonial; b) a que espelha os lucros e prejuízos acumulados; c) o resultado do exercício. A quarta, demonstração dos fluxos de caixa, tem aplicação para a sociedade fechada com patrimônio não inferior a dois milhões de reais na data do balanço e para as sociedades abertas. A quinta (demonstração do valor adicionado) é exclusiva para as sociedades abertas. Sobre o assunto, veja 75.8 a 75.11.

Nas sociedades por ações que preveem Conselho de Administração e Conselho Fiscal, esses órgãos terão papel prévio na manifestação e análise das contas apresentadas, cabendo-lhes, respectivamente: a) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria (LSA, art. 142, V) e b) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia, bem como examinar as referentes ao exercício social e sobre elas opinar (LSA, art. 163, VI e VII).

A deliberação, contudo, cabe privativamente à assembleia geral.

IV – Autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 59

Por se tratar de obrigações que podem comprometer o acervo social ou reduzir a participação dos acionistas nos lucros sociais, a assembleia geral deve deliberar a respeito de sua emissão.

A competência privativa da assembleia geral para autorizar as emissões não é universal, compreendendo peculiaridades nas sociedades abertas. Nestas o estatuto pode fixar que a atribuição caiba ao Conselho de

Administração, quando se trate de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real (LSA, art. 59, § 1º, com a redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001).

É possível, ainda, a delegação desta atribuição da assembleia geral ao Conselho de Administração para que este fixe a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver e o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures (LSA, art. 122, IV e VII).

V – Suspende o exercício dos direitos do acionista (art. 120)

Compete privativamente à assembleia geral suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto.

O principal encargo do acionista é o de integralizar, na forma e condições previstas no estatuto, as ações subscritas. Há, ainda, alguns outros deveres: a) manter, no País, representante com poderes para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento nos preceitos da lei (LSA, art. 119); b) exercer o direito a voto no interesse da companhia (LSA, art. 115); c) abster-se de votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia; d) usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, quando acionista controlador (LSA, art. 116, parágrafo único).

VI – Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social

O capital social constitui um dos elementos essenciais à formação da sociedade e pode ser integrado por valores em dinheiro ou bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, que serão incorporados somente depois

de sua avaliação e de deliberação da assembleia geral.

A falta de realização do capital subscrito, sua redução em razão de incorporação de valores irreais ou a fraude decorrente de superavaliação pode inviabilizar a empresa, gerando responsabilidades perante terceiros, daí por que é do interesse exclusivo dos sócios a deliberação sobre a incorporação de bens ao capital social.

VII – Autorizar a emissão de partes beneficiárias

A emissão em massa de títulos que conferem direito de crédito contra a companhia (debêntures e de partes beneficiárias) atinge parcela de distribuição dos lucros sociais, justificando o interesse dos acionistas.

Por esta mesma razão a emissão de commercial papers submete-se à deliberação da assembleia geral, salvo se o estatuto possibilitar a emissão por um dos órgãos de administração, conforme faculta o art. 9º da Instrução n. 134, de 1º de fevereiro de 1990, da Comissão de Valores Mobiliários.

VIII – Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas

As hipóteses de transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia representam mudanças de forte efeito sobre o pacto societário: a sociedade altera sua forma; funde-se com outra, desaparecendo do cenário empresarial; incorpora outra, aumentando seu capital social e, eventualmente, modificando seu objeto; desagrega valores de seu patrimônio ou dissolve-se passando ao regime de liquidação.

Valores essenciais da vida societária são modificados, alterando-se direitos e cominando novas obrigações perante a sociedade e terceiros. É essencial, portanto, que a assembleia geral, constituída soberanamente por todos os acionistas titulares de direito de voto, manifeste-se sobre as importantes alterações que as deliberações trarão à vida social.

IX – Autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial:

A recuperação judicial submete alguns atos de administração ao controle jurisdicional e à fiscalização externa do administrador judicial, credores, órgão do Ministério Público e Poder Judiciário, inibindo o livre desempenho empresarial, sobretudo no que se refere à sua vida financeira. Impõe-se, portanto, a manifestação da assembleia geral para tão importante decisão.

A falência é um dos modos de se operar a dissolução judicial da sociedade e, desta forma, deve ser, como as demais, submetida à deliberação dos sócios em assembleia geral.

O parágrafo único do art. 122 da LSA acrescenta que, “em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de concordata (leia-se: de recuperação judicial) poderá ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se imediatamente a assembleia geral, para manifestar-se sobre a matéria”.

Na hipótese de a assembleia geral discordar da iniciativa, poderá manifestar-se contrariamente à deliberação dos administradores e, neste caso, apresentará desistência ao pedido formulado, que será processado conforme o estado do processo.

Se os efeitos desses pedidos ainda não atingiram terceiros, porque a falência ainda não foi decretada ou o pedido de recuperação judicial não foi processado, o magistrado pode homologá-lo de plano, sem ouvir os credores.

Diversa é a hipótese em que já houver sentença falimentar ou decisão de processamento do pedido de recuperação. A extinção da falência somente poderá ocorrer com o pagamento de todos os créditos ou concordância de todos os credores habilitados, ouvidos o administrador judicial e o Ministério Público. A desistência de pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento somente pode ser deferida se obtiver aprovação na

assembleia geral de credores (LREF, art. 52, § 4º).

47.3. Espécies de assembleia e de quorum

a) Assembleia geral ordinária: Conforme o fim a que se destina, a assembleia pode ser classificada por quatro tipos diferentes: assembleia geral constituinte, ordinária e extraordinária e assembleias especiais. A primeira distingue-se das outras três porque sua função precede o exercício da empresa, objetivando unicamente realizar a constituição da sociedade, ao passo que as demais deliberam sobre os atos durante toda a vida social.

A assembleia geral ordinária é realizada anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e tem por fim apreciar as matérias enumeradas no art. 132 da LSA: I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III – eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso (veja item 47.6, infra); IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social.

Sua denominação – ordinária – guarda relação com o fato de seus objetivos e época de realização estarem fixados na Lei das Sociedades por Ações. Trata-se de realização obrigatória e comum a todas as sociedades por ações.

b) Assembleia geral extraordinária: As matérias que não forem objeto de deliberação da assembleia geral ordinária – *numerus clausus* (LSA, art. 132) – serão objeto de decisão em assembleia geral extraordinária, convocada sempre que necessário.

Em algumas oportunidades a legislação exige o quorum qualificado, por força da importância da questão a ser votada, como é o caso das ocorrências relacionadas no art. 136 da LSA, que reclamam a adesão de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a

voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia: I – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; II – alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; III – redução do dividendo obrigatório; IV – fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; V – participação em grupo de sociedades; VI – mudança do objeto da companhia; VII – cessação do estado de liquidação da companhia; VIII – criação de partes beneficiárias; IX – cisão da companhia; X – dissolução da companhia.

c) Assembleias especiais: Enquanto as assembleias gerais destinam-se às deliberações de interesse dos sócios titulares de ações ordinárias, com direito de voto, as assembleias especiais reservam-se às reuniões de titulares de ações ordinárias quando houver diversidade de classes, na companhia fechada e a titulares de outros valores mobiliários.

As mudanças pretendidas nos direitos de cada uma das classes de acionistas dependerão de aprovação dos titulares dessas ações reunidos em assembleia especial dessa respectiva categoria (LSA, art. 16, parágrafo único).

Os debenturistas são credores da sociedade e, nessa condição, têm direito de se manifestar em algumas oportunidades, reunindo-se em assembleia para deliberar sobre questões sociais que possam repercutir sobre seus direitos.

Da mesma forma, os titulares de partes beneficiárias possuem direitos sobre os lucros da companhia que podem ser atingidos por uma reforma estatutária. Neste caso, sempre que a reforma do estatuto modificar ou reduzir suas vantagens, os titulares de partes beneficiárias se reunirão em assembleia geral especial para deliberar a respeito.

d) Quorum de instalação e de deliberação: Quorum de instalação “é

condição de realização da assembleia”, isto é, sem sua observância, a reunião não se realiza. Quorum de deliberação “é requisito de validade” das resoluções tomadas (Egberto Lacerda Teixeira, 1979:395).

Na Lei das Sociedades por Ações são previstos três números distintos de sócios ou debenturistas presentes às assembleias (um quarto, metade e dois terços), em quatro situações que não se confundem: a) o quorum ordinário do art. 125, que estabelece a necessidade da presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social com direito de voto; b) o quorum especial de constituição, previsto no art. 87, que exige a presença de metade do capital social em primeira convocação e qualquer número em segunda convocação; c) o quorum especial da assembleia de debenturistas, que reclama a presença de credores que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação (art. 71, § 3º); d) o quorum especial qualificado (art. 135), que impõe, em primeira convocação, a presença mínima de acionistas que representem dois terços, no mínimo, do capital com direito a voto, para a reforma do estatuto social. Em segunda convocação, a instalação se dará com qualquer número de presentes.

Para as deliberações, a Lei das Sociedades por Ações apresenta cinco ordens de quorum: a) o ordinário, previsto no art. 129: maioria absoluta de votos dos presentes, não se computando os votos em branco; b) o qualificado, encontrado no art. 136, que exige a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto; c) o especial qualificado (art. 71, § 5º): exige a aprovação mínima por parte de metade dos titulares das debêntures em circulação, quando a matéria da assembleia especial pretender a aprovação da modificação nas condições das debêntures; d) estatutário nas sociedades fechadas, que pode ser superior ao previsto na lei; e) a unanimidade, quando a matéria se referir à alteração do projeto de estatuto (art. 87, § 2º), por ocasião da assembleia constituinte e, ainda, na hipótese de transformação da sociedade (art. 221).

48. Órgãos da sociedade por ações – Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal

48.1. Conselho de Administração

A administração pode contar com um único órgão de deliberação ou prover-se de um sistema de administração bipartida. Neste último, um dos órgãos é o Conselho de Administração.

Embora não seja obrigatório na estrutura de todas as sociedades anônimas, salvo nas sociedades de economia mista (LSA, art. 239), companhias abertas e de capital autorizado (LSA, art. 138, § 2º), apresenta-se como recomendável supervisor das atividades de gestão administrativa nos grandes empreendimentos.

48.2. Atribuições do Conselho de Administração

Quando constituído, o Conselho de Administração deve dividir suas funções com uma diretoria e terá as seguintes atribuições (LSA, art. 142): a) fixar a orientação geral dos negócios da companhia; b) eleger e destituir os diretores da companhia e estabelecer-lhes as tarefas, observado o que a respeito dispuser o estatuto; c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; d) convocar a assembleia geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132; e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; f) opinar previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; g) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; h) autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; i) escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

48.3. Composição do Conselho de Administração

O art. 140 da LSA estabelece que “o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, três membros, eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo”. Não havendo número máximo, caberá ao estatuto determinar qualquer outra quantidade acima de três, bem como: o processo de escolha e substituição do presidente e dos membros do conselho, pela assembleia ou pelo próprio órgão; o prazo de gestão, que não poderá ser superior a três anos, permitida a reeleição; as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer quorum qualificado para certas decisões, desde que especifique as matérias.

O exercício do cargo de conselheiro é privativo dos acionistas, pessoas naturais residentes, no País (LSA, art. 146), mas é possível que o estatuto preveja a participação de representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem.

O estatuto pode, ainda, prever que até o máximo de um terço dos conselheiros ocupe simultaneamente cargos na diretoria da companhia (LSA, art. 143, § 1º).

A eleição dos membros do Conselho de Administração se dá pelo voto de acionistas com direito a voto, reunidos em assembleia geral ordinária (LSA, art. 132, III). Há, ainda, a possibilidade de eleição por voto múltiplo, criado com a finalidade de prover certa proporcionalidade na composição do órgão, tendo em vista o poder de decisão dos acionistas – titulares majoritários ou titulares representando a minoria.

O voto múltiplo possibilita à minoria eleger seu representante, o que seria impossível no sistema do voto único.

Em qualquer companhia, havendo ou não previsão estatutária, os titulares que representem pelo menos 10% do capital social com direito a

voto – ou porcentagens menores fixadas para as companhias abertas, pela Comissão de Valores Mobiliários (LSA, art. 291) – podem requerer a adoção do sistema de voto múltiplo, através do qual todos os acionistas com direito a voto terão o direito a tantos votos quanto forem os cargos a serem preenchidos, facultando-lhes a cumulação em um só candidato ou, ainda, sua dispersão entre todos eles (LSA, art. 141). Para evitar que a assembleia geral anule os benefícios dessa forma de eleição, que permite que a minoria indique e eleja seu candidato, se houver a destituição de um membro do Conselho de Administração eleito desta forma, todos os demais serão destituídos, convocando-se nova eleição (LSA, art. 141, § 3º).

A mesa que preside a assembleia é obrigada a informar aos acionistas o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho de Administração (LSA, art. 141, § 1º).

48.4. Diretoria

É órgão de execução, composto de dois ou mais diretores, pessoas naturais residentes no País, acionistas ou não, eleitos para um mandato de três anos (permitida a reeleição), destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração ou, onde não existir, pela assembleia geral. Os diretores, se forem acionistas, poderão ser eleitos membros do Conselho de Administração até o máximo de 1/3. Cabe à Diretoria executar as deliberações destes outros órgãos.

Suas funções se resumem a dois grandes grupos de atividades: a) representação da companhia, judicial ou extrajudicialmente, atribuição que, no silêncio do estatuto, faculta-se a qualquer um dos diretores; e b) prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.

48.5. Conselho Fiscal

Composto por três, quatro ou cinco membros, sendo um deles eleito

pelos titulares de ações preferenciais sem direito a voto e outro por acionistas minoritários que representam pelo menos 10% das ações com direito a voto. Sua função é fiscalizatória.

A escolha do conselheiro fiscal deve recair sobre qualquer pessoa natural, residente no País, diplomada em curso de nível superior ou que tenha exercido, pelo menos, três anos o cargo de administrador de empresas ou de conselheiro fiscal. Se na localidade não se encontrar pessoas com essas qualidades, a companhia pode requerer ao juiz da comarca dispensa destes requisitos.

48.6. Conselho Fiscal permanente e não permanente

É exigência legal toda sociedade anônima tenha um Conselho Fiscal que, contudo, poderá ter caráter permanente ou transitório, segundo dispuser o estatuto da companhia (LSA, art. 161).

Se o estatuto prevê a constituição de um conselho permanente, sua eleição deve ocorrer na assembleia geral ordinária (LSA, art. 132, III), mas, se seu caráter for transitório, sua instalação é determinada na assembleia geral que decidir o pedido de acionistas (LSA, art. 161 e §§ 2º e 3º). Neste caso, os eleitos permanecerão no exercício de suas funções até a próxima assembleia geral ordinária (LSA, art. 161, § 5º).

Na sociedade de economia mista, o funcionamento do Conselho Fiscal será sempre permanente (LSA, art. 240).

49. Reorganização de sociedades

As sociedades possuem a prerrogativa de alterar sua estrutura fundamental, mediante operações de transformação, incorporação, fusão e cisão.

49.1. Transformação

É a operação de mudança do tipo societário ou de modalidade de constituição da empresa (como, por exemplo, na ocorrência de concentração das quotas de uma sociedade num único sócio, resultando numa empresa individual de responsabilidade limitada), independentemente de dissolução e liquidação. Exige o consentimento unânime dos acionistas ou sócios, exceto se houver outra previsão no contrato ou estatuto. Ao dissidente cabe o direito de retirar-se da sociedade, salvo se, ao ingressar na sociedade, tenha renunciado a este direito. Essa modalidade vem prevista nos arts. 220-222 da LSA e nos arts. 1.113-1.115 do CC.

49.2. Incorporação

É o processo pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas pela outra, que lhes sucede em todos direitos e obrigações. Está previsto no art. 227 da LSA e nos arts. 1.116-1.118 do CC.

49.3. Fusão

É a execução de atos tendentes à reunião de duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade, que lhes sucederá em todos direitos e obrigações (LSA, art. 228, e CC, arts. 1.119-1.121).

49.4. Cisão

É o processo pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para este fim ou já existentes. Há a cisão total quando ocorre a versão de todo seu patrimônio e parcial quando não for integral a transferência. Proceda-se segundo o art. 229 da LSA.

49.5. Diferenças entre os procedimentos e efeitos

Cada modalidade de deliberação tendente à reorganização empresarial gera distintos efeitos quanto à forma societária, à responsabilidade dos sócios e da sociedade e ao procedimento exigido para sua ocorrência.

Nem sempre ocorre a mudança do tipo societário, salvo na transformação, que, por definição, opera a adoção de uma outra forma societária. Deste modo, v.g. uma sociedade em nome coletivo que, passando pelo processo, vem a se transformar em sociedade limitada, sofrerá mudanças de três importantes ordens: a) da responsabilidade dos sócios, de solidariamente responsáveis pelas obrigações sociais, de forma solidária para responsabilidade limitada à integralização do capital social; b) do nome social, podendo adotar denominação ou firma social, faculdade concedida para as sociedades limitadas, uma vez que as sociedades em nome coletivo somente podem valer-se das firmas sociais. Haverá, necessariamente, a inclusão do sufixo “limitada” ou, abreviadamente, “Ltda.”; c) do quorum para futuras deliberações, salvo se o contrato social mantiver a rigidez da unanimidade para as matérias do art. 997 do Código Civil (arts. 999, 1.040 e 1.076, III).

Na incorporação, fusão ou cisão, a mudança do tipo societário poderá não ocorrer. Uma sociedade limitada pode incorporar, fundir ou cindir o patrimônio, envolvendo outras duas sociedades limitadas, ou uma sociedade em nome coletivo e outra em comandita simples, por exemplo.

50. Grupos de sociedades

As sociedades podem associar-se em: a) grupo de fato; b) grupo de direito; c) consórcio.

50.1. Grupo de fato

O grupo de fato é constituído por controladora e controlada ou sociedades coligadas. O Código Civil prevê três espécies de empresas

coligadas (veja acima item 7, “i”): controladas, filiadas e de simples participação.

50.2. Grupo de direito

O grupo de direito, também chamado holding, está previsto no art. 265 da LSA e se estabelece mediante convenção pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

A sociedade-mãe, ou comandante, deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na Junta Comercial. A ligação contratual é identificada pela expressão “grupo de sociedades” ou, simplesmente, “grupo” e pressupõe a instituição de uma nova estrutura administrativa, facultando-se a criação de órgão de deliberação colegiada e cargos de direção-geral.

São requisitos da convenção (art. 269 da LSA): I – designação do grupo; II – indicação da sociedade de comando e das filiadas; III – condições de participação das diversas sociedades; IV – prazo de duração, se houver, e condições de extinção; V – condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que componham o grupo; VI – órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham; VII – declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII – condições para alteração da convenção.

Considera-se sob domínio brasileiro o grupo se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas letras “a” e “b”.

Somente após o registro da convenção de constituição na Junta Comercial é que o grupo passa a existir e está legitimado a usar essa

expressão.

Para o registro do grupo é necessária a apresentação da convenção devidamente aprovada, acompanhada: a) das atas das assembleias ou instrumentos de alteração social que a autorizaram; b) de declaração autenticada do número das ações ou cotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada (LSA, art. 271).

Os administradores das sociedades filiadas no grupo de direito devem observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores eleitos que não importem violação da lei ou da convenção do grupo.

50.3. Consórcio

O consórcio – ou em inglês joint venture – nada mais é do que o contrato entre duas sociedades, sob o mesmo controle ou não, para executar determinado empreendimento. Sua constituição prescinde de estarem as sociedades consorciadas sob o mesmo controle (de fato ou de direito).

Restringem-se as obrigações entre as sociedades às condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. Mesmo em caso de falência de uma consorciada, nenhum efeito se produzirá sobre os bens das outras, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma estabelecida no contrato de consórcio. Tratando-se de contrato bilateral, caberá ao administrador judicial decidir se prossegue ou não com sua execução (LREF, art. 117), ponderando os benefícios e prejuízos que sua decisão acarretará à massa.

A competência para aprovar a realização de consórcio é do órgão a quem

o contrato ou o estatuto atribuem deliberação sobre a alienação de bens do ativo permanente.

51. Dissolução de sociedades no Código Civil

A doutrina clássica agrupa as hipóteses de dissolução quanto à forma e quanto à extensão de seus efeitos.

Na primeira, a dissolução denomina-se: a) de pleno direito, quando se opera pela ocorrência de situação prevista em lei, com ou sem necessidade de vir a ser declarada por sentença judicial; b) judicial, se houver litígio e se impuser o conhecimento e a constituição dessa situação por sentença judicial; c) consensual, também denominada “distrato social”, se decorrente da vontade dos sócios.

Um melhor estudo da matéria, contudo, abrange outras classificações não percebidas pela doutrina clássica, categorizando as formas tendo em vista: a) o instrumento de viabilização: judicial e extrajudicial; b) a extensão de seus efeitos: total e parcial; c) a natureza do ato de dissolução: decorrente de lei (pleno direito) ou da vontade dos sócios.

Nota-se, em relação à primeira classificação, que há causas judiciais não obrigatórias e causas obrigatoriamente judiciais, sejam casos decorrentes de determinação legislativa ou da vontade dos sócios.

No tocante aos efeitos, o Código Civil preferiu denominar a dissolução parcial de “resolução em relação a sócio”, matéria objeto do item 12, acima.

Vamos dividir a matéria quanto aos instrumentos utilizados: dissolução extrajudicial ou judicial.

51.1. Dissolução extrajudicial

a) Quando expirado o prazo de duração da sociedade, sem que seja iniciada a liquidação: Expirado o prazo de duração da sociedade, opera-se,

de pleno iure, a dissolução da sociedade.

Os sócios podem alterar o contrato e levá-lo ao registro público competente, ampliando o período de vida da sociedade, mas devem fazê-lo até a data nele estabelecida, sob pena de extinção.

O prazo determinado pode ser certo ou incerto, dependendo de estar consignada expressamente ou não a data de seu término ou sujeitar-se à realização de um objeto social específico.

O legislador permitiu uma solução diversa, que evita o desaparecimento da empresa quando constituída numa das formas previstas no Código Civil: a prorrogação indeterminada da duração da sociedade se, vencido o prazo fixado no contrato social, os sócios não se opuserem e deixarem de promover a sua liquidação (art. 1.033, I).

Ocorrendo uma das hipóteses de dissolução societária, os administradores devem providenciar imediatamente a investidura do liquidante, escolhido na forma do que dispuser o contrato social ou, na sua falta, por deliberação dos sócios. Se não o fizerem e se nenhum sócio intentar a liquidação judicial, a sociedade prossegue em sua atividade.

b) Consenso unânime ou deliberação, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado: Trata-se de dissolução consensual. Por distrato os sócios consentem na extinção da sociedade.

Para a sociedade simples e para as personalíssimas é obrigatório o consenso unânime na hipótese de a sociedade ter sido constituída por prazo determinado (CC, arts. 997, II, 999 e 1.033, III). Entretanto, para as sociedades limitadas constituídas por prazo determinado ou indeterminado a dissolução se obtém pelo voto de, no mínimo, três quartos do capital social (CC, arts. 1.076, I, e 1.071, VI).

Concordes os sócios, a única formalidade exigida para efetivar a dissolução é o arquivamento do instrumento de distrato no órgão de registro público competente, por escritura pública ou particular,

independente da que foi adotada no ato constitutivo (Lei n. 8.934/94, art. 53).

Não havendo consenso é possível que a dissolução venha a exigir pronunciamento judicial, uma vez que os sócios que dissentiram poderão valer-se do recurso jurisdicional para evitar a extinção da empresa ou para discutir a forma de liquidação e apuração de seus haveres.

c) Falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias: No intuito de preservar o exercício da empresa, a jurisprudência, há muito, construiu soluções que permitem o prosseguimento das atividades por certo período de tempo, visando à recomposição do número mínimo legal de sócios.

A solução judicial aplica-se, sobretudo nas hipóteses de perda da pluralidade por ausência ou morte de sócio, sem que o contrato viabilize o ingresso de herdeiros ou legatários.

Atento à tendência jurisprudencial e submetendo-se ao ideal empresarial e não mais à doutrina individualista, o Código Civil prevê a não dissolução se a sociedade for reconstituída no período de cento e oitenta dias. Este prazo conta-se da data da ocorrência da perda da pluralidade: a) se decorrente de decisão judicial, a pedido de retirada de sócio, da data do trânsito em julgado da sentença; b) no caso de morte, da data do óbito; c) se de declaração de ausência, da data que a sentença que declarar a ausência e abrir provisoriamente a sucessão produzir seus efeitos (art. 28).

d) Extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar: A causa de dissolução tem origem na Administração Pública. Algumas sociedades, em razão de sua atividade – de maior interesse social, econômico ou em razão de segurança nacional – ou de sua origem, dependem de autorização do Poder Executivo federal. Por exemplo: as sociedades estrangeiras dependem de autorização do governo central; o D. 8.803, de 6 de julho de 2016, delegou competência para esse fim ao ministro de Estado Chefe da Casa Civil; as instituições financeiras sujeitam-se à autorização do Banco

Central etc. Cassada a autorização ou extinta por decurso de prazo de concessão, sem que tenha havido prorrogação, essas sociedades deverão ser dissolvidas e liquidadas. Eventualmente, pode ocorrer disputa no âmbito judicial, visando afastar as causas que motivaram a extinção da autorização concedida.

A hipótese, tratada pelo art. 1.033, V, do Código Civil, pode ser completada pelos casos em que não apenas a autorização se extingue, mas naqueles nos quais o Poder Público determina a liquidação extrajudicial da sociedade, como ocorre, por exemplo, com as instituições financeiras, ou suas coligadas, que, incidindo em ocorrências que comprometam sua situação financeira e outras violações graves, são liquidadas administrativamente.

51.2. Dissolução judicial

Prevê o Código Civil três causas para a dissolução judicial obrigatória: a) decorrente de decisão de anulação de sua constituição social (art. 1.034, I); b) se exaurido o fim social ou verificada sua inexecutabilidade (art. 1.034, II); c) prevista no contrato social e vier a ser contestada em juízo (art. 1.035).

a) Dissolução por anulação do ato de sua constituição: A hipótese do art. 1.034, I, do Código Civil reporta-se às sociedades personalizadas, e ao parágrafo único do seu art. 45: “Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro”.

Assim, nas hipóteses de defeito do contrato social, os sócios poderão requerer, dentro de três anos, a anulação do ato constitutivo, o que se dará nos raros casos de nulidade admitidos pela legislação societária.

A LSA menciona a existência de vício e defeito e a possibilidade de saná-los por deliberação da assembleia geral (art. 285, parágrafo único).

Por este último dispositivo, verifica-se que o direito brasileiro preferiu adotar, nas sociedades de capitais, soluções menos gravosas para a ocorrência de defeitos nos atos jurídicos constitutivos, optando pela anulabilidade, sanável, portanto, como regra geral. É possível afirmar que, salvo raros casos, os contratos societários não são nulos, mas, tão somente, as cláusulas viciadas, resultando na anulabilidade da sociedade, corrigível por ato subsequente dos sócios.

Há, por certo, casos de violação da ordem pública, em razão de ser ilícito seu objeto ou serem incapazes os agentes que a contrataram e, neste caso, a sociedade não pode subsistir.

b) Exaustão do fim social ou verificação de sua inexecutabilidade: Esses dois fatos — perda total ou insuficiência do capital social — são exemplos da inexecutabilidade do fim social. Se não há mais capital e tampouco possibilidade de seu aumento, o fim para o qual foi constituída a sociedade torna-se inatingível, levando os sócios a admitirem a dissolução da sociedade. Entretanto, é possível que inexista consenso a respeito da inviabilidade, e, neste caso, o sócio deve buscar sua demonstração pela via judicial.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 2:439) anota, como causas de dissolução por inexecutabilidade, a falta de mercado e a insuficiência do capital social.

O fim social pode, ainda, mostrar-se exaurido por inúmeras razões: a atividade tornou-se proibida por lei; a empresa explora recursos naturais e houve esgotamento da reserva, acarretando a inviabilidade de seu exercício naquele lugar ou época; a sociedade dispõe de tecnologia ultrapassada, não possuindo recursos ou meios legais para a modernização necessária; o contrato de franquia não foi renovado etc.

c) Causa prevista no contrato social que vier a ser contestada em juízo: O Código dispõe sobre outras causas, de livre desígnio dos sócios, pertinentes a aspectos internos da sociedade — objeto social, qualidade dos sócios,

interesses comuns etc. – que, uma vez ocorridas, acarretarão a dissolução da sociedade. Esses fatos, desde que não violem regra legal ou social, são lícitos como motivadores da dissolução social.

d) Falência: A falência foi incluída a entre os casos considerados como de dissolução judicial (LSA, art. 206, II, c), conquanto o Código Civil a tenha considerado na ordem de dissolução de pleno direito (art. 1.044) e, topograficamente, a separou das outras hipóteses assim intituladas (art. 1.033), como também dos casos de dissolução judicial (art. 1.034). Embora se condene o entendimento do legislador civil quanto à espécie – trata-se de dissolução judicial necessária, mas não de dissolução de pleno direito –, a separação legislativa – não a incluindo entre os casos gerais dos arts. 1.033 e 1.034 – fez-se com acerto, tendo em vista sua aplicação somente para as sociedades empresárias.

A causa falimentar para a dissolução da sociedade empresária possui outra particularidade em relação a todos os demais casos de dissolução judicial. Nas tutelas judiciais cujo objeto é a dissolução, o pedido visa à extinção da sociedade. Seu objeto é a própria dissolução e, portanto, correto seria intitulá-la de dissolução judicial própria. Na falência, a dissolução é uma das consequências ou um dos efeitos daquela execução coletiva. A dissolução judicial não é a pretensão inicial do autor, embora esteja potencialmente implícito no pedido. Trata-se, portanto, de dissolução judicial imprópria ou consequente de outra tutela judicial (Marco Antonio Marcondes Pereira, 1995:115-135).

Anote-se, por fim, que a dissolução nem sempre é efeito da falência, mas, muitas vezes, a antecede. É possível que durante o processo de liquidação – judicial ou extrajudicial – se constate a impossibilidade de pagamento de credores, resolvendo o liquidante requerer a autofalência da sociedade. A falência, neste caso, sucede à dissolução e o processo liquidatório ocorre no processo falimentar.

52. Dissolução de sociedades na Lei das Sociedades por Ações

Nas sociedades de capitais a dissolução se dá, nos termos do art. 206 da LSA, em três casos: a) dissolução de pleno direito; b) dissolução judicial; c) por ato administrativo. Essas três hipóteses foram reproduzidas pela lei civil e se assemelham aos casos estudados para as sociedades contratuais.

52.1. Dissolução de pleno direito

A dissolução dá-se pelo término do prazo de duração (art. 206, I, a), tal qual ocorre no estatuto civil (art. 1.033, I): trata-se da hipótese em que a companhia foi constituída com prazo determinado, fixado no estatuto que, uma vez decorrido, não se prorroga. É fato que não necessita de qualquer declaração administrativa ou judicial, decorrendo tão só da vontade dos acionistas estabelecida nos estatutos. É curial que até a data do termo estipulado no contrato é possível decidir-se pela prorrogação, levando a deliberação a registro na Junta Comercial. Contudo, vencido este, os órgãos de registro não podem mais proceder ao arquivamento, conforme determina o art. 35, IV, da Lei n. 8.934/94.

A segunda situação diz respeito aos casos previstos nos estatutos (art. 206, I, b), respeitando-se a vontade dos acionistas. A ocorrência daqueles acarreta, ipso facto, a dissolução da sociedade. O Código Civil, no art. 1.035, reproduziu o texto da Lei das Sociedades por Ações.

A terceira hipótese é a que decorre de deliberação da assembleia geral (art. 206, I, c). À semelhança do que dispõe o art. 1.033, III, do Código Civil, os acionistas, em assembleia geral extraordinária especialmente convocada para esse fim, decidem a dissolução por maioria qualificada – aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto –, salvo se quorum maior não for exigido pelos estatutos da companhia, conforme decorre do art. 136, X, da LSA.

A quarta situação é semelhante à já estudada no art. 1.033, IV, do Código Civil: a existência de um único acionista, verificada em assembleia geral ordinária, se o mínimo de dois não for reconstituído até a assembleia do ano seguinte (art. 206, I, d), ressalvado o disposto no art. 251, que trata da subsidiária integral. Consagra-se aqui o requisito da pluralidade de sócios, sem o qual não é possível a existência de uma sociedade no direito brasileiro, princípio este mitigado pela possibilidade de reestruturação da sociedade no prazo fixado pela lei.

A quinta forma de dissolução foi reproduzida pelo art. 1.033, V, do Código Civil: a extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.

52.2. Dissolução por decisão judicial

As dissoluções denominadas judiciais, estabelecidas pela LSA (art. 206, II), são em número de três e trazem redação semelhante às previstas nos arts. 1.034 e 1.044 do Código Civil.

a) Anulação de sua constituição: Quando anulada sua constituição, por ação de qualquer acionista (LSA, art. 206, II, a): a decisão judicial que anular o ato de constituição de uma sociedade é causa de dissolução da sociedade pelo simples fato de faltar, a partir de então, o ato que deu origem à sua vida jurídica. Difere esta previsão legislativa daquela prevista no Código Civil, tão somente, pela diversidade de prazo decadencial que, na lei acionária, é de um ano (LSA, art. 285) e, no Código, de três anos (CC, art. 45, parágrafo único).

b) Por impossibilidade de preencher o fim social: É possível se obter judicialmente a dissolução da sociedade por ações, à semelhança do que ocorre com as sociedades de pessoas (CC, art. 1.034, II). Por ação de acionistas que representem pelo menos 5% do capital social, provando a impossibilidade de preencher o seu fim (LSA, art. 206, II, b).

Por impossibilidade de preencher o fim social entende-se não somente a

impossibilidade técnica, mas também a incapacidade de a sociedade atingir seus fins sociais, como, por exemplo, por analogia e adotando o princípio da interpretação histórica para as lacunas do direito (sobre este veja Cláudio De Cicco, 2006:303-305), as situações previstas no art. 336, 1, do CCom: perda inteira do capital social ou deste ser insuficiente ou mesmo as encontradas no art. 336, 2, do mesmo Código: inabilidade de alguns dos sócios ou incapacidade moral ou civil, julgada por sentença.

c) Falência: Conforme objeto de considerações acima, a falência é uma das causas motivadoras da dissolução social, mas seu procedimento liquidatório não ocorrerá pelos meios preconizados no Código Civil (arts. 1.102 usque 1.112), por meio de um liquidante, mas por ato do administrador judicial da falência.

52.3. Dissolução por ato administrativo

A última hipótese se refere aos casos de decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e nas formas estabelecidos em lei especial.

Os casos previstos em lei (LSA, art. 206, III) referem-se a decisões administrativas, como, por exemplo, os de liquidação extrajudicial de empresa do sistema financeiro (Lei n. 6.024/74).

A liquidação é o procedimento administrativo que tem a mesma finalidade do instituto da falência: arrecadar bens, avaliá-los e vendê-los para o pagamento de credores. Algumas vezes, no interesse de preservar o crédito público, o Estado prefere liquidar administrativamente uma sociedade comercial, ao invés de permitir submetê-la ao processo falimentar comum.

No caso do sistema financeiro são três as modalidades: a) liquidação ex officio, decretada pelo Banco Central nas hipóteses do art. 15, I, da Lei n. 6.024/74: 1) ocorrências que comprometam sua situação econômica ou

financeira, especialmente quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que autorizem o decreto falimentar; 2) violação grave das normas legais e estatutárias ou determinações do Conselho Monetário Nacional ou Banco Central; 3) prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores quirografários; 4) cassação de autorização para funcionamento, sem que a instituição inicie sua liquidação ordinária em noventa dias; b) a requerimento dos administradores da instituição, nos termos do artigo 15, inc. II, da Lei n. 6.024/74, em que podem ser alegadas as mesmas situações acima; c) por proposta do interventor, quando a sociedade financeira estiver sob o regime de intervenção, antes do decreto administrativo de liquidação.

Há, além das sociedades financeiras, outros regimes especiais de liquidação administrativa, previstos em lei, v.g. empresas seguradoras, usinas de açúcar, sociedades cooperativas e sociedades de capitalização.

Estabelecimento Empresarial

53. Plano de estudo

Este capítulo compreende estudos acerca do estabelecimento empresarial e os temas podem ser agrupados em quatro unidades: teoria do estabelecimento empresarial, qualidades do estabelecimento empresarial, ponto comercial e direitos de propriedade industrial:

Teoria geral do estabelecimento empresarial – itens 54-57	- Estabelecimento empresarial – item 54 - Matriz, filiais e sucursais – item 55 - Trespasse de estabelecimento – item 56 - Trespasse e sub-rogação de contratos não pessoais – item 57
Qualidades do estabelecimento empresarial – itens 58-60	- Aviamento – item 58 - Clientela – item 59 - Cláusulas de não restabelecimento – item 60
Ponto empresarial – itens 61-62	- Ponto empresarial – item 61 - Ponto empresarial – exceção de retomada – item 62
Direito de propriedade industrial – itens 63-70	- Conceitos – item 63 - Patente de invenção e modelos de utilidade – item 64 - Invenção de empresa, de empregado e comum – item 65 - Desenho industrial – item 66 - Marcas – item 67 - Cessão de uso e licenças – item 68 - Licença compulsória – item 69 - Extinção dos direitos de propriedade industrial – item 70

54. Estabelecimento empresarial

O Código Civil define estabelecimento empresarial no art. 1.142: “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

O conceito merece alguns desdobramentos. A palavra “bens” compreende coisas corpóreas e incorpóreas que reunidas pelo empresário ou pela sociedade empresária passam a ter uma destinação unitária – o exercício da empresa.

Constitui-se, pois, o estabelecimento uma universalidade de fato e, como tal, pode ser objeto de relações jurídicas próprias, distintas das relativas a cada um dos bens singulares que o integram.

A doutrina concebe o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo, embora integrado por coisas corpóreas. Este entendimento permite compreender a extensão das operações a que se sujeita, envolvendo negócios traslativos ou constitutivos. O estabelecimento pode ser objeto de

usufruto, cessão, arrendamento etc.

O que compõe o estabelecimento empresarial? Dependendo da criatividade e necessidade do empresário ou da sociedade empresária, o estabelecimento constará dos bens que seu titular escolher. Para exercer a atividade no ramo de restaurante, por exemplo, os bens corpóreos singulares utilizados pelo empresário serão similares aos escolhidos por empresário concorrente, mas distintos no que se refere à qualidade e ao desenho e programação visual e artística. A organização os distingue e é fruto de concepção do titular que os ordenou de maneira própria.

55. Matriz, filiais e sucursais

As expressões sucursal, filial e agência não possuem distinção jurídica e, embora sejam mencionadas de forma diversificada em outros dispositivos do Código Civil (arts. 969, 1.000, 1.136 e 1.172), referem-se a uma só realidade: o estabelecimento subordinado a um principal. São, portanto, ramificações de uma estrutura administrativa.

Conforme De Plácido e Silva (1998:782), é possível considerar a sucursal, sob a ótica hierárquica e organizacional da empresa, como sendo um braço institucional ligado à matriz, mas com certa autonomia decisória, apresentando-se muitas vezes como departamento regional de uma empresa; as filiais operam diretamente sob o comando de um estabelecimento matriz, mantendo ou não agências representativas em mercados menores.

Ao estabelecer sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à atribuição de outro Registro Público de Empresa, o empresário ou a sociedade empresária devem inscrevê-las, mediante apresentação da inscrição original (da sede). Por exemplo: se a sede está localizada na capital de São Paulo e o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade foi feito na Junta Comercial de São Paulo, a criação de uma filial em Curitiba obriga o

empresário a inscrever o novo estabelecimento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

É, ainda, obrigatória a averbação do estabelecimento secundário no órgão registrário em que se localiza a sede da empresa. Assim, o empresário fará a inscrição no órgão que for responsável pelo registro do novo endereço e a averbação desta inscrição no local da sede. Se o local da sede e o da filial se sujeitarem a um mesmo órgão de registro de empresa, nele se fará tanto o arquivamento dos órgãos constitutivos como a averbação da filial.

56. Trespasse de estabelecimento

A doutrina consagrou a expressão trespasse para indicar a cessão ou alienação do estabelecimento empresarial.

Distintamente do que ocorre na alienação das coisas singulares, o trespasse de estabelecimento empresarial é cercado de certas exigências legais que dão validade e segurança aos contraentes.

Em primeiro lugar, a alienação, como também o usufruto e o arrendamento, somente produzem efeitos em relação a terceiros depois que os interessados averbarem o contrato à margem da inscrição do empresário (individual ou sociedade empresária) no órgão de registro de empresa e o ato for publicado na imprensa oficial (CC, art. 1.144).

Em segundo lugar, a alienação somente será eficaz na ausência de dívidas. Havendo credores, estes deverão ser notificados e consentir, em até trinta dias, de modo expresso ou tácito, com a alienação.

O Código Civil não regulamentou a forma de notificação que, entretanto, foi objeto de disposição na Lei n. 11.101/2005, na seção relativa à ineficácia de atos praticados antes da falência: “(...) devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos” (art. 129, VI).

Exige-se, pois, que a notificação para fins de alienação se faça por estes meios, sob pena de, ocorrendo a falência, o ato vir a ser declarado ineficaz em relação à massa falida, sofrendo o adquirente prejuízo com a perda do estabelecimento.

Em terceiro lugar, há solidariedade entre os contraentes pelos débitos contabilizados, anteriores à transferência. Os credores decaem do direito de cobrar o devedor alienante se não o fizerem no prazo de um ano. Conta-se o prazo decadencial, em relação às dívidas vencidas anteriormente à alienação, a partir da data da publicação do contrato e, da data do vencimento, em relação às dívidas vincendas. Decorrido o prazo de um ano, somente o adquirente do estabelecimento empresarial responderá pelas dívidas então existentes.

57. Trespasse e sub-rogação dos contratos não pessoais

Os contratos integram o estabelecimento empresarial e, assim, com o trespasse, ocorre sua sub-rogação ao adquirente, salvo se o contrato tiver por objeto prestação de caráter pessoal. Os terceiros contratantes podem rescindir o contrato até noventa dias depois da publicação da alienação do estabelecimento, justificando a ocorrência de justa causa (por exemplo: não pagamento de parcela; apresentação de fiador não idôneo; ausência de garantias suficientes etc.).

Não ocorre, contudo, sub-rogação do contrato de locação relativo ao imóvel em que se encontra instalado o estabelecimento empresarial. Para tanto, há necessidade de autorização do locador, conforme exige a Lei de Locações de imóveis urbanos (Lei n. 8.245/91, art. 13), que poderá ser obtida por negociação direta ou, ainda, mediante expedição de notificação por escrito. O locador deve manifestar sua oposição no prazo de trinta dias (LLI, art. 13, § 2º), sob pena de sua inércia caracterizar consentimento tácito.

Com a alienação do estabelecimento ocorre a cessão dos créditos, negócio jurídico que produz efeitos desde a publicação do trespasse no órgão oficial. É possível, contudo, que algum devedor pague sua dívida diretamente ao antigo titular do estabelecimento, desconhecendo a cessão. Neste caso, se caracterizada sua boa-fé, o devedor fica desobrigado da dívida (CC, art. 1.149).

58. Aviamento

Aviamento é atributo do estabelecimento empresarial, resultado do conjunto de vários fatores de ordem material ou imaterial que lhe conferem capacidade ou aptidão de gerar lucros.

Cada estabelecimento possui um aviamento maior ou menor. Diz-se que o aviamento é pessoal ou subjetivo quando a capacidade de gerar lucros resulta substancialmente de qualidades do titular da empresa. E será real ou objetivo se decorrente da qualidade do estabelecimento empresarial.

Há, contudo, doutrinadores que entendem que o aviamento é resultado tanto do exercício da empresa pelo titular como igualmente das qualidades do estabelecimento, optando por conceituar aviamento como atributo da empresa.

É o magistério de Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:136) que prefere identificá-lo como sinônimo de “fundo de empresa”, porquanto designam ambas as expressões “o sobrevalor nascido da atividade organizacional do empresário”; esse também é o ensino de Rubens Requião (2003, 1:334).

Para Oscar Barreto Filho (1988:171), “o aviamento existe no estabelecimento, como a beleza, a saúde ou a honradez existem na pessoa humana, a velocidade no automóvel, a fertilidade no solo, constituindo qualidades incindíveis dos entes a que se referem. O aviamento não existe como elemento separado do estabelecimento e, portanto, não pode constituir em si e por si objeto autônomo de direitos, suscetível de ser

alienado, ou dado em garantia”.

Considerando o magistério de Barreto Filho, se o aviamento está intimamente ligado ao estabelecimento empresarial, mesmo que resulte da atividade empresarial nele desenvolvida pelo titular da empresa, passa a qualificá-lo de forma distinta a tal ponto que, no trespasse do estabelecimento, o sobrevalor que lhe foi outorgado o acompanha e se expressa economicamente, independentemente da permanência de seu titular. É por esta razão que entendemos aviamento como atributo do estabelecimento e não da empresa.

59. Clientela

Clientela é mera situação de fato. Conceitua-se como “conjunto de pessoas que, de fato, mantém com o estabelecimento relações continuadas de procura de bens e de serviços” (Barreto Filho, 1988:178).

Freguesia e clientela são termos jurídicos sinônimos e a legislação brasileira as emprega indistintamente: a palavra freguês é utilizada na Lei de Economia Popular (Lei n. 1.521/51), cliente é o termo escolhido pelo legislador da Lei de Preconceito Racial (Lei n. 7.716/89, art. 15).

Na origem, a primeira traz conotação de lugar e a segunda exprime relacionamento com as qualidades subjetivas do titular.

O cliente não pode ser objeto de direito. Não há um direito à clientela, mas sim proteção contra práticas de concorrência desleal ou atentado ao estabelecimento empresarial que impeçam o regular exercício da empresa.

Por não ser um direito, mas mera situação de fato, não é correta a expressão “cessão de clientela”, como se fosse possível contratar clientela. Contrata-se o trespasse de estabelecimento empresarial, na expectativa de que seus atributos (aviamento e clientela) representem boa perspectiva de lucratividade.

60. Cláusulas de interdição de concorrência

Em qualquer contrato se presume a boa-fé dos contratantes. É lícito esperar que o alienante de estabelecimento empresarial não abra concorrência ao novo adquirente, logo em seguida ao trespasse. Muitas vezes não ficam evidenciadas as condições temporais ou espaciais que norteiam o esperado não restabelecimento.

Para evitar discussões tardias, os contratantes podem estabelecer, no contrato de trespasse, cláusulas que obriguem o alienante a fazer ou deixar de fazer certos atos, ampliando as possibilidades de êxito do comprador na manutenção e ampliação da clientela.

Oscar Barreto Filho (1988:242) menciona três encargos restritivos, objetivando a não concorrência do alienante ao adquirente: obrigações de dar, de fazer e de não fazer.

Em relação às primeiras, os contraentes inserem compromisso do alienante em transmitir os bens que constituem os fatores da clientela. Na entrega desses bens – corpóreos e incorpóreos – preserva-se ao adquirente o aviamento real, ou seja, a capacidade de gerar lucros que advém especialmente do conjunto dos bens que foram objeto da cessão.

Consistem as obrigações de fazer na prática de atos do antigo titular com vistas a possibilitar a rápida e eficiente transmissão das informações necessárias ao êxito da empresa em mãos do adquirente. É, por exemplo, a apresentação do novo titular a seus clientes; a autorização para o adquirente intitular-se como sucessor; a comunicação dos dados relativos à atividade (endereços e fichas de clientes, listas de fornecedores, correspondência) etc.

Obrigações de não fazer reportam-se especialmente ao não restabelecimento do antigo titular, obrigando-o a obediência a certas condições precisas de tempo, espaço ou objeto.

Em relação a tempo, o Código Civil, atento à doutrina e jurisprudência

dominantes, estabeleceu o limite de cinco anos, quanto à alienação e o tempo de duração do contrato quando se tratar de arrendamento ou usufruto do estabelecimento. É o que reza o art. 1.147.

Por constituírem restrição de direitos, as cláusulas de interdição de concorrência devem ser limitadas no tempo, território (região de influência da empresa) e atividade empresarial, sob pena de afrontar o direito de o alienante exercer profissão lícita, conforme garantia constitucional prevista no art. 5º, XIII.

61. Ponto empresarial

O ponto empresarial integra o estabelecimento; é o local onde o empresário fixa seu estabelecimento para ali exercer sua empresa.

Duas espécies de direito protegem o ponto empresarial:

a) a indenização por responsabilidade civil comum: 1) indenização pelos danos emergentes e por lucros cessantes, se o imóvel pertence ao empresário individual, sociedade empresária ou sociedade simples e ocorrer privação de uso, embaraço ou dano causado ao imóvel; 2) se o imóvel não pertence ao empresário individual, sociedade empresária ou sociedade simples: ao titular do domínio é devida a indenização pelo dano e, ao locatário, os lucros cessantes;

b) o direito à permanência no imóvel ou à indenização devida pela não renovação do contrato de locação firmado no prazo e nas condições fixadas em lei.

No tocante ao último, a Lei de Locações estabelece que o locatário tem direito à renovação compulsória, uma vez cumpridos os requisitos legais, que são os seguintes:

1) Subjetivo: o locatário deve ser empresário, sociedade empresária ou sociedade simples. Na ocorrência de evento morte, estende-se a proteção ao sucessor ou ao sócio sobrevivente. Se ocorrer sublocação total, cessão,

arrendamento ou usufruto do estabelecimento empresarial, por ato inter vivos, assiste o mesmo direito ao sublocatário, cessionário, arrendatário, usufrutuário, desde que consentida pelo locador. Na hipótese de o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte, o direito de locação poderá ser exercido por ambos, locatário e sociedade, indistintamente.

2) Formal: o contrato deve ser escrito e com prazo determinado e estabelecer um período mínimo de cinco anos, admitindo-se a soma dos intervalos, em contratos sucessivamente renovados, e o uso da contagem pelo sucessor – sublocatário total. A jurisprudência admite que, na soma dos prazos, se incluam períodos de locação verbal, desde que breves.

3) Funcional: o locatário deve explorar o mesmo ramo de atividade econômica pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, à data da propositura da ação renovatória.

4) Processual: decai do direito de promover a ação renovatória o contratante que não o fizer no intervalo entre um ano e seis meses anteriores ao término do contrato a renovar. A demora na citação não acarreta a decadência, salvo se imputável ao próprio autor do pedido.

62. Ponto empresarial – exceção de retomada

O proprietário do imóvel pode exercer sua defesa na ação renovatória de aluguel, mediante exceção de retomada, em algumas situações, apresentando como fundamento, além da ausência dos requisitos legais:

a) realização de obra por determinação do Poder Público, desde que estas importem em mudança radical (LLI, art. 52, I);

b) realização de obras para modificação que aumente o valor do negócio ou da propriedade (LLI, art. 52, I);

c) utilização do imóvel para uso próprio ou para transferência de fundo de comércio já existente há mais de um ano, quando o detentor do capital

social for o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente (LLI, art. 52, II). Neste último caso, é vedado o uso para o mesmo ramo do locatário, salvo se a locação envolver o arrendamento do próprio estabelecimento empresarial (LLI, art. 52, § 1º). A permissão (exceção de retomada para transferência de estabelecimento próprio) não abrange imóvel localizado em shopping center (LLI, art. 52, § 2º), porque a atividade do locador é a de administrar o pool de locatários e não de exercer atividade varejista (Restiffe Neto, 2000 (b):262);

d) insuficiência da proposta apresentada pelo locatário, considerando o valor locatício real, excluída a valorização decorrente do ponto (LLI, art. 72, II);

e) existência de melhor proposta de terceiro (LLI, art. 72, III), permitida contraproposta pelo autor no momento da réplica (LLI, art. 72, § 1º).

Ocorrendo a conversão – falta de renovação do contrato de locação – o locatário terá direito à indenização, em três situações, duas previstas em lei e a última por entendimento sumular: a) na aceitação de melhor proposta; b) na retomada para realização de obra pelo Poder Público e o proprietário quedar-se inerte por prazo igual ou superior a três meses da data da entrega do imóvel; c) na retomada para construção mais útil. Nos primeiros casos, a indenização inclui o efetivo prejuízo e os lucros cessantes e, no último, limita-se às despesas de mudança.

Somam-se a estas situações a inércia ou insinceridade (desvio de uso) na retomada por parte do locador (LLI, art. 44, parágrafo único), circunstâncias que implicam imposição, em ação própria, de multa a ser fixada pelo magistrado, equivalente a um mínimo de doze e a um máximo de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel.

63. Direitos de propriedade industrial – conceitos

Os direitos que decorrem da proteção à propriedade imaterial (equivocadamente denominada propriedade industrial) estão previstos na Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Código da Propriedade Industrial), e podem ser resumidos no seguinte quadro:

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	
Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade	• De invenção • De modelo de utilidade
Concessão de registro de desenho industrial	• De desenhos industriais
Concessão de registro de marca	• De marca de produto ou serviço • De marca de certificação • De marca coletiva
Repressão a falsas indicações geográficas	Definindo as regras para a indicação de procedência ou denominação de origem
Repressão à concorrência desleal	Definindo os crimes contra a propriedade industrial: a) contra as patentes; b) contra os desenhos industriais; c) contra as marcas; d) por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda; e) contra indicações geográficas e demais indicações; f) crimes de concorrência desleal

Invenção é o ato humano de criação original, lícito, não compreendido no estado da técnica e suscetível de aplicação industrial.

Modelo de utilidade, também chamado “pequena invenção”, é “o objeto

de uso prático, ou parte deste, não compreendido no estado da técnica, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (LPI, arts. 9º e 11).

Desenho industrial é “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial” (LPI, art. 95). Compreende tanto o modelo industrial como o desenho industrial, categorias consideradas distintamente na legislação de propriedade industrial anterior (Lei n. 5.772, de 21-12-1971).

Marca, em sua tríplice aplicação (LPI, art.123), é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de determinada entidade.

O Código de Propriedade Industrial Português simplifica sua aceção reduzindo-a ao uso empresarial: “é um sinal utilizado por um empresário para distinguir os produtos sobre os quais incide a sua atividade econômica” (Correia, 1999:329).

Indicação geográfica é a designação de procedência ou a denominação de origem de um produto ou de prestação de determinado serviço. Seu uso é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local indicado.

Ambas as expressões se reportam ao “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território”.

Considera-se indicação de procedência o local “que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado

produto ou de prestação de determinado serviço” (LPI, art. 177) e denominação de origem o local “que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (LPI, art. 178).

A repreensão à concorrência desleal se dá em termos indenizatórios (repreensão civil, LPI, 207-210) e sob forma de tipificação criminal (repreensão penal, LPI, art. 195), punindo o infrator.

Alberto Luís Camelier da Silva (2013:63-64) conceitua concorrência desleal “todo e qualquer ato praticado por um industrial, comerciante ou prestador de serviço contra um concorrente direto ou indireto, ou mesmo um não concorrente, independentemente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar sua clientela, podendo ou não desviar, em proveito próprio ou de terceiro, direta ou indiretamente, clientela de outrem. Esses atos são contrários às práticas e usos honestos perpetrados na indústria, comércio e serviços”.

Exemplo típico de concorrência desleal é o uso de marca, rótulo, embalagem, configuração visual e/ou ambiental que se assemelhe a outra existente, visando aproveitar o reconhecimento obtido por outrem junto ao público consumidor. É, basicamente, copiar “tudo aquilo que deu certo nos negócios alheios, procurando encurtar a distância entre o esforço natural a ser despendido e o resultado econômico” (Camelier, 2013:85).

A violação do chamado “conjunto-imagem” ou trade dress é uma forma parasitária de concorrer no mercado consumidor e configura ato de concorrência desleal.

64. Patentes de invenção e modelos de utilidade

Para conferir o privilégio de exclusividade, as patentes de invenção e as de modelo de utilidade devem apresentar quatro requisitos: a) ser novas (novidade); b) suscetíveis de aplicação industrial (industriabilidade); c) fruto

da atividade inventiva; e d) lícitas, conforme à lei, ou não vedadas por ela (licitude).

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:185) prefere denominar este último de “desimpedimento”, expressão que serve para indicar a ausência de impedimento legal (LPI, art.18), fundado em princípios de ordem pública que impedem a proteção legal.

Rubens Requião (2003, 1:305-306) traz distinta classificação: prefere originalidade à expressão “atividade inventiva” e acrescenta aos quatro requisitos o do estado da técnica que, segundo entendemos, está contido no conceito de novidade.

64.1. Primeiro requisito de patenteabilidade: a novidade

Novo é tudo aquilo que é desconhecido pela comunidade científica, técnica ou industrial, ou, na expressão legal, “algo não compreendido pelo estado da técnica”.

Essa expressão – estado da técnica – informa o grau de absolutização que a lei brasileira exige para tornar patenteável uma criação inventiva, definindo-a como “tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer meio, no Brasil e no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17” (LPI, art. 11, § 1º).

O caráter de novidade absoluta, excluindo tudo o que compreende o estado da técnica, comporta o abrandamento previsto nos mencionados dispositivos. Não se compreendem no estado da técnica os pedidos com direito de prioridade solicitados por titulares de patentes depositadas em países ou organizações que mantenham acordo com o Brasil, uma vez obedecidos os prazos firmados na convenção internacional.

64.2. Segundo requisito de patenteabilidade: a industriabilidade

Para ser patenteável, a invenção ou o modelo de utilidade devem ser suscetíveis de aplicação industrial, isto é, podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria (LPI, art. 15).

A extensão da expressão legal afasta as concepções puramente teóricas e que não possam ser produzidas pela indústria, seja porque depende de mecanismo, peça ou combustível ainda não existente ou, ainda, porque ausentes conhecimentos técnicos suficientes à sua industrialização.

64.3. Terceiro requisito de patenteabilidade: a atividade inventiva

O conceito de originalidade ou de atividade inventiva encontra-se nas definições legais de invenção e de modelo de utilidade.

A primeira está no art. 13 da LPI: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

A segunda foi definida no art. 14 da mesma Lei: “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”.

64.4. Quarto requisito de patenteabilidade: a licitude

É lícito o que está de acordo com a lei ou por ela não é vedado. Excluem-se, portanto, as hipóteses previstas nos arts. 10 e 18 da LPI.

O primeiro dispositivo contempla as hipóteses de não incidência:

I – as descobertas, as teorias científicas e os métodos matemáticos;

II – as concepções puramente abstratas que, à semelhança das teorias científicas, são privadas de aplicação industrial;

III – os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, de natureza puramente intelectual;

IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer

criação estética;

V – os programas de computador em si;

VI – a apresentação de informações;

VII – as regras de jogo;

VIII – as técnicas e os métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano e animal;

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Complementando a compreensão da licitude, o art. 18 afasta do conceito de patenteabilidade algumas hipóteses, em razão do interesse social ou do Estado que, neste momento, preferiu colocá-los à margem da licitude:

I – qualquer criação que for contrária à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes da modificação do núcleo atômico;

III – o todo ou parte dos seres vivos não pode ser objeto de proteção, reconhecendo a lei o caráter de mera descoberta de algo preexistente, concebido pela natureza. São exceções os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam meras descobertas.

Há quem desdobre os casos aqui mencionados entre os de exclusão de atividade inventiva ou de industriabilidade (art. 10) e de desimpedimento (art. 18). É a sistematização adotada por Fábio Ulhoa Coelho.

65. Invenção de empresa, de empregado e comum

Invenção de empresa é a obtida dentro do estabelecimento empresarial, sobre a qual não ocorre a individualização do inventor.

Invenção de serviço é a obtida na empresa pelo empregado ou prestador de serviços, na vigência do contrato destinado à pesquisa no Brasil, desde que a atividade inventiva do empregado esteja prevista no contrato ou decorra da natureza da atividade contratada.

Invenção livre é a desenvolvida pelo empregado sem utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Caracteriza-se por ter sido obtida de forma desvinculada do contrato de trabalho, sem vínculo de prestação de serviço. Pertence exclusivamente ao empregado.

Invenção comum, mista ou conexa é a desenvolvida pelo empregado, de forma desvinculada do contrato do trabalho ou vínculo de prestação de serviços, mas com utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. O invento será de propriedade comum de ambos.

Aplicam-se estas distinções ao desenho industrial. Haverá, assim, desenho industrial da empresa, desenho industrial livre ou de empregado e desenho industrial comum, misto ou conexo.

66. Desenho industrial

Os requisitos exigidos para o registro de desenho industrial são os mesmos da patenteabilidade da invenção e do modelo de utilidade (veja item 64), com algumas peculiaridades:

a) Novidade: decorre do universo de coisas não compreendidas no estado da técnica. O período de divulgação autorizada, antes do depósito do pedido no INPI, é de cento e oitenta dias, conforme deflui do art. 96, § 3º, da LPI: "Não será considerado como incluído no estado da técnica o

desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os cento e oitenta dias que precederam a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12". Significa que o titular do desenho industrial pode, por exemplo, apresentar o desenho em público em congresso ou a eventuais clientes, antes de efetivar o depósito no INPI, sem ficar impedido de encaminhar seu pedido de registro dentro de seis meses, mantendo intacto o requisito da novidade.

b) Originalidade: é a que resulta de configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, excluída qualquer obra de caráter puramente artístico. A forma comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (LPI, art. 100, II) não é passível de registro.

c) Industriabilidade: não é registrável obra puramente artística, mas tão somente a que propicie fabricação industrial.

d) Legalidade: é vedado o registro de desenho industrial que seja contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração (LPI, art. 100, I).

67. Marcas

67.1. Classificações

As marcas podem ser classificadas segundo sua aplicação, finalidade, forma e conhecimento comum, o que pode ser visualizado nos seguintes quadros:

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO

CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	
Marca de produto ou serviço	Distingue produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
Marca de certificação	Atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
Marca coletiva	Identifica produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FINALIDADE	
Marca específica ou singular	Destinada a assinalar um só objeto.
Marca genérica ou geral	Identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são, individualmente, caracterizados por marcas específicas. Somente pode ser usada quando acompanhada de marca específica.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FORMA	
Verbal ou nominativa	Constitui-se somente de nomes, palavras, denominações ou expressões.
Emblemática ou figurativa	Adota monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou quaisquer outros sinais distintivos.
Mista	Formada por expressões nominativas e figurativas.
Tridimensional	Apresentada nas várias dimensões visuais, com desenhos em vista frontal, lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO CONHECIMENTO COMUM		
	NOÇÕES	DIFERENCIAÇÕES
Marcas de alto renome	São as notoriamente conhecidas no Brasil, em toda a sua extensão territorial, e têm proteção especial em todos os ramos de atividade; trata-se de inovação brasileira prevista no art. 125 da LPI, sem regulação similar na Convenção Unionista.	• Extensão territorial: proteção no território nacional. • Extensão de aplicação: em todos os ramos de atividade. • Fonte legislativa: art. 125 da LPI. • Registro no Brasil: indispensável para a proteção.
Marcas notórias	São as notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade e estão previstas na Convenção da União de Paris, no artigo 6 bis, inciso 1, e reguladas pelo art. 126 da LPI. Gozam de proteção especial, independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil.	• Extensão territorial: proteção nos territórios dos países signatários da Convenção da União de Paris. • Extensão de aplicação: proteção, tão somente, em relação a produtos idênticos e similares. • Fonte legislativa: art. 6º, bis (I), da CUP e art. 126 da LPI. • Registro no Brasil: dispensável para a proteção.

67.2. Requisitos

São três os requisitos exigidos para o registro de uma marca: novidade, originalidade e legalidade.

Observa-se que embora esta classificação seja adotada por outros doutrinadores, como, por exemplo, Rubens Requião (2003, 1:244-249), Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:188-191) prefere indicar três outras condições: novidade relativa, não colidência com marca notória e desimpedimento. Neste último requisito estariam as distinções que fazemos entre licitude e originalidade.

a) Novidade: Para as marcas o requisito da novidade é relativo, isto é, na criação de uma marca não se exige o desconhecimento público da expressão ou da figura adotada. Estrela não é um símbolo ignorado pelos povos e, entretanto, pode servir para identificar, com exclusividade, brinquedos de um determinado fabricante ou veículo automotor de outro.

A proteção legal se dá por classes, salvo na hipótese de marca de alto renome para a qual se concede direito de proteção sobre todos os ramos de atividade.

A proteção limitada a uma determinada classe (ramo de atividade definido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial) decorre da aplicação do princípio da especificidade, segundo o qual a novidade exigida para o registro de uma marca restringe-se à não colidência com outra preexistente, isto é, a ausência de uso exclusivo da expressão ou figura na classe pretendida.

b) Originalidade: Uma ideia pode não ser original, mas será nova desde que não exista colidência com outra existente.

Considerando os casos arrolados pelo legislador no art. 124 da LPI, podemos estabelecer uma linha distintiva entre os critérios de originalidade e novidade.

Não são originais os símbolos e expressões mencionadas nos incisos I (brasões, armas etc.), II (letra, algarismo e data), V (reprodução de título

de estabelecimento e de nome comercial), VI (sinal de caráter genérico), VIII (cores e suas denominações), XI (cunho oficial), XIII (nome, prêmio ou símbolo de evento), XIV (reprodução de título, apólice etc.), XV (nome civil), XVI (pseudônimo), XVIII (termo técnico) e XXI (forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico). Observe-se, contudo, neste último caso, que o sinal comum pode adquirir um sentido secundário (secondary meaning), o que ocorre quando dissociado de seu significado semântico, viabilizando a proteção marcária.

Violam o requisito da novidade os incisos IV (sigla de entidade ou órgão público suscetível de registro como marca pelo próprio órgão), IX (indicação geográfica de produto), X (falsa indicação de origem etc.), XII (imitação de marca coletiva ou de certificação), XVII (obra literária etc.), XIX (marca alheia), XX (dualidade de marcas), XXII (desenho industrial de terceiro) e XXIII (marca conhecida).

c) Legalidade: Tudo é permitido, desde que a lei não vede. Nos incisos III (expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração) e VII (limitação à proteção de sinal ou expressão de propaganda) do art. 124 da LPI encontramos a regulamentação da licitude.

68. Cessão de uso e licenças

Os direitos de propriedade transferem-se por ato inter vivos ou por sucessão e em qualquer caso a transferência deve ser averbada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para que produza efeitos legais erga omnes.

Quanto ao objeto, os direitos de propriedade imaterial são indivisíveis, não podem ser fracionados sem alteração do uso a que se destinam.

Entretanto, quanto à titularidade a cessão do direito imaterial pode ser feita de forma parcial ou total, isto é, pode ser feita a vários titulares, em condomínio ou a um detentor do domínio.

A cessão pode ser aperfeiçoada em documento público ou particular ou, ainda, se a transferência ocorrer em virtude de morte ou ausência do titular, mediante decisão judicial: certidão de homologação de partilha ou cópia da sentença que declarar a ausência.

Distintamente do que ocorre na cessão, o contrato de licença não transfere a propriedade do direito imaterial, mas tão somente o direito de usá-lo e explorá-lo, com ou sem exclusividade.

69. Licença compulsória

Em relação às patentes de invenção e de modelos de utilidade, pode ocorrer o licenciamento compulsório, sem exclusividade e sem permissão de sublicenciamento, nas cinco situações previstas na LPI, arts. 68-74:

a) exercício abusivo de direitos de patente ou prática de abuso de poder econômico por meio dela, definidos por lei, decisão administrativa ou sentença judicial (art. 68);

b) inércia do titular: ausência de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado no Brasil, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando, então, é permitida a importação (art. 68, § 1º, I);

c) a comercialização não satisfaz a necessidade do mercado (art. 68, § 1º, I);

d) situação de dependência de uma patente à outra, e o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à anterior, não tendo o titular realizado acordo com o detentor da patente dependente para exploração da patente anterior (art. 70);

e) emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder

Executivo Federal.

70. Extinção do direito de propriedade industrial

O direito à exclusividade de exploração do direito à propriedade industrial extingue-se nos seis casos previstos no Código da Propriedade Industrial.

Essas situações trazem regras distintas a cada uma das modalidades jurídicas. Por este motivo, convém estudar as peculiaridades aplicáveis a cada uma delas.

70.1. Expiração do prazo de vigência (LPI, arts. 78, I, 119, I, e 141, I)

Em relação à invenção o prazo de exploração é de vinte anos e, no tocante ao modelo de utilidade, quinze anos. Em ambos os casos o prazo conta-se da data do depósito. Se decorrer longo período entre a data do depósito e a da concessão, o titular não pode ser prejudicado em demasia, tendo a lei lhe garantido a exploração por período não inferior a dez e sete anos contados da data de concessão.

O direito de exploração do registro de desenho industrial é concedido pelo prazo de dez anos, contados a partir da data do depósito, prorrogável por quinze, em três períodos distintos e sucessivos de cinco anos cada.

O direito à marca é concedido pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, podendo ser prorrogado, mediante pedido no último ano do decêndio vigente, por períodos iguais e sucessivos.

DIREITO	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Invenção	20 anos da data do depósito	O direito de exploração não pode ser inferior a dez anos contados da data da concessão.
Modelo de utilidade	15 anos da data do depósito	O direito de exploração não pode ser inferior a sete anos contados da data da concessão.

Desenho industrial	10 anos da data do depósito	Prorrogável por mais 15 anos, em três períodos sucessivos de 5 anos.
Marca	10 anos da concessão do registro	Prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

70.2. Renúncia do titular (LPI, arts. 78, II, 119, II, e 142, II)

A renúncia deve ser expressa e se realizada por procurador exige poderes especiais, uma vez que o mandato, em termos gerais, somente confere poderes de administração. Anota-se que o ato de renúncia se insere entre aqueles que exorbitam da administração ordinária (CC, art. 661 e § 1º).

Ressalva o legislador o direito de terceiro (LPI, arts. 78, II, e 119, II), antevendo a possibilidade de existir litígio sobre o objeto da proteção industrial.

Não se compreendem entre as atribuições do administrador judicial na falência a de renunciar a direitos (LREF, art. 22). Cabe ao administrador judicial, entretanto, no interesse da massa, “requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento” da lei falimentar, “a proteção da massa ou a eficiência da administração” (LREF, art. 22, III, o). A renúncia pela massa, portanto, em caso de falência dependerá da demonstração de que a medida lhe confere proteção ou propicia eficiente administração.

70.3. Caducidade (LPI, arts. 78, III, e 142, III)

Ocorre a caducidade de patente pelo decurso do prazo de dois anos sem que o titular de licença compulsória (veja item 69) tenha iniciado sua exploração (LPI, art. 80).

Ocorre a caducidade de registro de marca se, decorridos cinco anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou, ainda, se

iniciado, tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos. Equivale a ambas as situações o uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, constante do certificado de registro (LPI, art. 143, I e II).

70.4. Falta de pagamento da retribuição

O detentor de direito de propriedade industrial deve pagar retribuição pecuniária ao INPI, em parcelas distintas conforme o direito concedido, em períodos estipulados no Código da Propriedade Industrial. A retribuição será regular, adicional ou específica, conforme a época de seu pagamento:

RETRIBUIÇÃO	PERIODICIDADE	PERÍODO DE VENCIMENTO
REGULAR (DE PATENTE)	Anual, a partir do 3º ano, da data do depósito.	No vencimento normal, dentro dos 3 meses de cada período anual.
ADICIONAL (DE PATENTE)	Anual, a partir do 3º ano, da data do depósito.	O pagamento da retribuição pode ser feito, independente de notificação, dentro de 6 meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional (LPI, art. 84, § 2º).
ESPECÍFICA (DE PATENTE)	Anual, a partir do 3º ano, da data do depósito.	O pagamento da retribuição pode, ainda, ser feito dentro de 3 meses contados da notificação do arquivamento ou do pedido de extinção da patente, mediante o pagamento de retribuição específica (LPI, art. 87).
REGULAR (DE DESENHO INDUSTRIAL)	Quinquenal, a partir do 2º quinquênio da data do depósito.	O pagamento do segundo quinquênio deve ser feito durante o 5º ano de vigência do registro e os subsequentes com a apresentação do pedido de prorrogação (LPI, art. 120, §§ 1º e 2º).
ADICIONAL (DE DESENHO INDUSTRIAL)	Quinquenal, a partir do 2º quinquênio da data do depósito.	O pagamento poderá ainda ser efetuado dentro de 6 meses subsequentes ao prazo, mediante pagamento de retribuição adicional (LPI, art. 120, § 3º).

--	--	--

Em relação às marcas, a falta de pagamento não acarreta a extinção do direito de propriedade porque o recolhimento da retribuição se dá antes da expedição do certificado de registro (LPI, art. 161). Se o pagamento do primeiro decênio não se efetuar até sessenta dias depois do deferimento, ou, ainda, independentemente de notificação, dentro de trinta dias desse primeiro vencimento, o pedido é arquivado, sem a expedição de certificado (LPI, art. 162).

70.5. Nulidade do ato de concessão

A decisão administrativa de concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade e o ato de registro de desenho industrial ou de marca podem ser declarados nulos quando violarem disposições da Lei da Propriedade Industrial.

Para tanto, o legislador permite a proposição de procedimento administrativo de nulidade, de ofício ou a partir de requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, bem como a proposição de ação judicial, com curso na Justiça Federal, por pessoa que demonstre interesse processual.

Distinguem-se os prazos de prescrição, segundo a natureza do direito concedido: a) as ações para a nulidade de concessão de invenções e de modelos de utilidade e registro e de desenho industrial podem ser movidas a qualquer tempo da vigência da patente ou do registro (LPI, arts. 56 e 118); b) a ação para declarar a nulidade do registro de marca prescreve em cinco anos, com início de fluência a partir da data de sua concessão (LPI, art. 174).

70.6. Inobservância do art. 217 (LPI, arts. 78, V, 119, IV, e 142, IV)

Finalmente, aplica-se a pena de extinção de direito de propriedade imaterial ao titular que, não sendo residente no País, deixa de constituir e de manter aqui procurador qualificado e domiciliado, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Institutos Complementares à Empresa

71. Plano de estudo

O Título IV do Livro “Direito de Empresa” do Código Civil traz a rubrica “Institutos Complementares à Empresa” que trata do registro, do nome empresarial, dos prepostos e da escrituração, ordem que seguimos no presente capítulo:

- Registro de empresa – item 72
- Nome empresarial – item 73
- Prepostos, gerentes, contabilistas e auxiliares – item 74
- Escrituração empresarial – item 75

72. Registro de empresa

72.1. Regência legal

O registro de empresa rege-se principalmente pela Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins. Sua regulamentação encontra-se no Decreto n. 1.800, de 30 de janeiro de 1996.

Além dessa disposição específica, o Código Civil estabelece princípios a serem observados no registro: a) quanto ao início da existência legal das pessoas jurídica de direito privado (art. 45); b) quanto aos requisitos formais do registro (art. 46); c) quanto à obrigatoriedade de inscrição do empresário (art. 967); d) quanto aos requisitos formais da inscrição empresarial (art. 968); e) quanto às filiais, sucursais e agências (art. 969); f) quanto ao tratamento diferenciado ao empresário rural e ao pequeno empresário (art. 970); g) quanto à facultatividade de inscrição do empresário rural (art. 971); h) quanto às regras de constituição e de inscrição do nome empresarial (arts. 1.155 a 1.168).

72.2. Órgãos do registro de empresa

São órgãos incumbidos do registro público de empresas mercantis e atividades afins, e integram o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM): o Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) e as Juntas Comerciais de cada unidade da Federação.

Compete ao DREI: a) supervisionar; b) orientar; c) coordenar e normatizar, no plano técnico; d) coordenar e suplementar, no plano administrativo.

Às Juntas Comerciais dos Estados da Federação compete, nos termos do art. 8º da Lei n. 8.934/94: I – executar e administrar os serviços de registro; II – elaborar a tabela de preços de seus serviços; III – processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais; IV – elaborar os respectivos regimentos internos e suas alterações, bem

como resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais; V – expedir carteiras de exercício profissional de pessoas legalmente inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; e VI – o assentamento dos usos e práticas mercantis.

72.3. Finalidades do registro

São três as finalidades do registro de empresas, conforme decorre dos incisos I a III do art. 1º da Lei n. 8.934/94: a) dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis; b) cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no Brasil e manter atualizadas as informações pertinentes; c) proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento.

72.4. Efeitos jurídicos do registro

É obrigatório o registro do empresário – individual, empresa individual de responsabilidade limitada ou sociedade empresária – antes do início das atividades empresariais, conforme dispõe o art. 967 do Código Civil. A falta de sanção para a desobediência a este dispositivo não livra de punição o empresário desidioso. À margem da regularidade legal, o empresário ou a sociedade empresarial submetem-se às restrições próprias da clandestinidade, impostas pela legislação administrativa, processual e mercantil.

No âmbito administrativo-tributário, a irregularidade implica a não obtenção de registro nos cadastros de contribuintes fiscais e de seguridade social, impossibilitando sua contratação com o Poder Público (CF88, art. 195, III, § 31), de participar de licitações públicas (Lei n. 8.666/93, art. 28, II e III) e de enquadrar-se como microempresário.

É, entretanto, a legislação empresarial que impõe restrições mais severas. Ao empresário irregular é vedado requerer sua recuperação judicial (LREF, art. 48, caput) e a falência de outrem (LREF, art. 97, IV, § 1º), sujeitando-se, ainda, na ocorrência de sua falência, à pena de detenção de um a dois anos, e multa, prevista no art. 178 da LREF.

A configuração do crime de omissão de documentos contábeis obrigatórios decorre da não autenticação de sua escrituração contábil na Junta Comercial, faculdade somente concedida aos titulares de “empresas mercantis registradas” (Lei n. 8.934/94, art. 32, III).

No campo societário, a ausência de registro impede a personalização da sociedade, sujeitando seus sócios aos efeitos legais da sociedade em comum, e entre estes, a responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais e, ainda, em relação ao sócio que contratar pela sociedade (sócio tratador), a exclusão do benefício de ordem (CC, art. 990).

Para o único titular da empresa individual de responsabilidade limitada, as consequências são semelhantes: se pessoa natural, ele responderá de forma ilimitada pelas obrigações sociais; se pessoa jurídica, esta responde pelas obrigações sociais assumidas em nome da EIRELI não registrada.

Por outro lado, no tocante às sociedades, do registro decorre a personalidade jurídica, isto é, faz nascer no âmbito do direito pessoa capaz de direitos e obrigações, detentora de patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios.

72.5. Atos de registro

São de três distintas classes os atos de registro:

- Matrícula: ato que se refere tão somente aos leiloeiros (registro regulamentado nas IN DREI n. 17/2013 e n. 44/2018), tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros (administradores de armazéns para importação ou exportação) e administradores de armazéns-gerais.
- Arquivamento: envolve atos de constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas individuais (empresários individuais e empresa individual de responsabilidade limitada), sociedades empresárias ou cooperativas, bem como atos relativos a consórcio e grupos de sociedade,

empresas estrangeiras, declaração de microempresa e outros documentos que possam interessar ao empresário e às sociedades empresárias.

Quanto à eficácia do arquivamento, cumpre distinguir: 1) os documentos devem ser apresentados dentro de trinta dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; 2) decorrido esse prazo, o arquivamento somente terá eficácia a partir do despacho que o conceder (Lei n. 8.934/94, art. 36).

- Autenticação de documentos: de escrituração empresarial e de cópias dos documentos e usos e costumes assentados em seus registros.

Um quadro resume as modalidades registrárias:

MODALIDADE	A QUE SE DESTINA
MATRÍCULA	Matrícula e cancelamento de: • leiloeiros; • tradutores públicos e intérpretes comerciais; • trapicheiros; • administradores de armazéns-gerais.
ARQUIVAMENTO	• constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, sociedades e cooperativas; • os atos relativos a consórcio e grupo de sociedades previstos nos arts. 278 e 279 da Lei n. 6.404/76; • os atos relativos a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil; • as declarações de microempresa; • os atos e documentos que possam interessar ao empresário ou à empresa mercantil.
AUTENTICAÇÃO	• instrumentos de escrituração das empresas (livros mercantis); • as cópias dos documentos assentados.

72.6. Impedimentos ao arquivamento

A Lei de Registro de Empresas Mercantis proíbe o arquivamento de documentos que apresentem vícios de cinco modalidades, decorrentes de:

a) impedimento da pessoa que contrata; b) ofensa ao direito de sócios – o

impedimento visa à defesa dos sócios contratantes; c) ofensa a direito de terceiros – o impedimento visa à defesa destes; d) cláusulas contratuais irreconciliáveis; e e) impedimentos formais.

Impedimento da pessoa que contrata	- O titular ou administrador condenado pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil (LRE, art. 35, II). - O titular casado não tiver juntado a outorga uxória ou marital, em havendo a incorporação de imóveis à sociedade (LRE, art. 35, VII, <i>b</i>).
Impedimentos em defesa dos sócios	Alterações societárias por decisão majoritária, quando houver cláusula restritiva (LRE, art. 35, VI).
Impedimentos em defesa de terceiros	Atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente (LRE, art. 35, V).
Impedimentos decorrentes de cláusulas irreconciliáveis	- Atos de prorrogação do contrato social das empresas mercantis, uma vez findo o prazo nele fixado (LRE, art. 35, IV). - Atos que colidirem com os respectivos estatutos ou contrato não modificado anteriormente (LRE, art. 35, I, final).
Impedimentos de caráter formal	- Documentos que não obedecem à forma legal, ferem os bons costumes e a ordem pública (LRE, art. 35, I). - Atos constitutivos que não designarem o respectivo capital ou não declararem precisamente seu objeto (LRE, art. 35, III). - Documentos relativos à incorporação de imóveis, quando não houver descrição e identificação do imóvel, área, dados relativos a sua titulação e número de matrícula no Registro de Imóveis (art. 35, VII, <i>a</i>). - Contratos, estatutos e alterações de empresas ainda não aprovados pelo governo, quando for o caso (LRE, art. 35, VIII).

Além desses impedimentos, previstos na Lei de Registro de Empresas Mercantis, a Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011, trouxe modificação ao

art. 980 do Código Civil, sob n. 980-A, em seu § 2º: "A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade". Insere-se essa causa, em nosso quadro, na espécie de impedimento da pessoa que contrata.

73. Nome empresarial

Do ponto de vista prático-jurídico, nome empresarial é um direito pessoal, protegido pela lei contra atos de concorrência desleal, com vistas ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

73.1. Distinções

Distingue-se o nome empresarial de outros institutos empresariais: marca, título de estabelecimento, insígnia:

DISTINÇÕES		
Nome	É atributo de personalidade, por meio do qual o empresário exerce a empresa. Natureza jurídica: atributo de personalidade, protegido mediante registro no Órgão de Registro de Empresa.	
Marca	É sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificação técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de determinada entidade. Natureza jurídica: direito de propriedade industrial, protegido mediante registro no INPI.	
Título de estabelecimento	É a designação de um objeto de direito – o estabelecimento empresarial – e insígnia.	Ambos têm em comum idêntica natureza jurídica e destinação: designar o estabelecimento do empresário; na forma, contudo, diferem: a insígnia utiliza a forma emblemática, e o título, a nominativa.
	É um sinal, emblema,	

Insígnia	formado por figuras, desenhos, símbolos, conjugados ou não a expressões nominativas.	Natureza jurídica: direito intelectual amparado contra o uso indevido, sem necessidade de prévio registro.
-----------------	--	---

73.2. Espécies

São espécies de nome empresarial a firma individual, a firma social e a denominação. Distinguem-se em razão da estrutura e destinação.

Quanto à estrutura, as firmas são sempre compostas por nomes civis de titular da empresa, sócios ou diretores da sociedade ou titulares da empresa, de forma completa ou abreviada. A denominação adota qualquer expressão linguística, complementada pelo objeto da sociedade.

No tocante à destinação, a firma individual serve para identificar o empresário pessoa natural e a empresa individual de responsabilidade limitada; a firma social destina-se principalmente às sociedades personalistas, e, a denominação, às sociedades de capitais.

São personalistas as sociedades reguladas no Código Civil: simples, em nome coletivo e em comandita simples. É de capital a sociedade anônima. É híbrida a sociedade limitada, podendo assumir um ou outro caráter. A sociedade em comandita por ações, tal qual a similar em comandita simples, possui estrutura social heterogênea, submetendo-se, contudo, ao regime jurídico da sociedade anônima.

Em razão de sua dúplici classificação, a sociedade limitada, ao lado da extravagante em comandita por ações, afasta-se de uma classificação rigorosa, podendo adotar firma social ou denominação.

A partir dessa diferenciação, os conceitos podem ser assim formulados:

- Firma individual é o nome adotado pelo empresário, pela empresa individual de responsabilidade individual ou pela pessoa jurídica de responsabilidade limitada criada pela LLE, equivocadamente chamada sociedade limitada unipessoal, no exercício de sua atividade, mediante o qual se identifica no mundo empresarial, sendo composto por seu nome civil completo ou abreviado, acrescido ou não de designação precisa de sua pessoa, ou do gênero de sua atividade. No caso de empresa

individual de responsabilidade individual, acrescido necessariamente da modalidade empresarial (a expressão EIRELI), e para as pessoas jurídicas de responsabilidade limitada criadas pela LLE o nome civil deverá ser acompanhado da palavra limitada, por extenso ou abreviada;

- Firma social é o nome adotado pela sociedade empresária para o exercício de sua atividade, pelo qual se identifica no mundo empresarial. Compõe-se pelos nomes civis (ou partes destes) de todos os sócios da sociedade, sem outro acréscimo ou, ainda, se omitido algum sócio, a inclusão da expressão “e companhia”, por extenso ou abreviadamente, “e cia”. Quando se tratar de sociedade limitada e em comandita por ações exige-se, na sua formação, a adição de expressões indicadoras da espécie societária adotada, por extenso ou abreviadamente.
- Denominação é o nome adotado pela empresa individual de responsabilidade limitada e pela sociedade empresária para o exercício de sua atividade, nome pelo qual se identifica no mundo empresarial; é formado por expressão linguística que contenha o objeto social e o tipo societário, no caso da empresa individual de responsabilidade limitada, a modalidade empresarial (a expressão EIRELI).

Deve-se atentar para o uso correto da palavra “firma”, que em direito é uma das espécies de nome empresarial. Por influência do direito estrangeiro, principalmente o alemão, utiliza-se vulgarmente firma como sinônimo da atividade empresarial, da pessoa do empresário ou da sociedade empresária. Esse grave erro terminológico ganhou força popular e alcança, hoje, infelizmente editais públicos, documentos emitidos por repartições oficiais, petições e documentos exarados no exercício das atividades de advocacia, pareceres ministeriais, decisões de tribunais administrativos e sentenças judiciais.

73.3. Tutela legal do nome empresarial

A partir do arquivamento dos atos constitutivos do empresário e da sociedade empresária no Órgão de Registro de Empresas, o nome passa a ser juridicamente tutelado, e, assim: a) não pode ter seu elemento característico ou diferenciador reproduzido ou imitado em marcas a ponto de causar confusão ou associação indevida (LPI, art.124, V). Entende-se por elemento característico ou diferenciador do nome empresarial qualquer parte deste capaz de causar engano no mercado consumidor; b) não pode ser usado indevidamente em produto destinado à venda, em exposição ou

em estoque (LPI, art. 195, V); c) sujeita o infrator por atos de concorrência desleal ao pagamento de indenização ao titular do nome (LPI, art. 209); d) permite ação para anulação de inscrição de nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato (CC, art. 1.167).

73.4. Extensão da proteção legal – princípios da especialidade e da territorialidade

São dois os princípios que regem a extensão da proteção legal: especialidade, relativo ao ramo de atividade do empresário, e territorialidade, quanto à base geográfica.

Quanto ao primeiro, o Código Civil procurou solucionar os conflitos gerados pela colidência entre empresários e sociedades empresárias, cujas atividades são distintas, determinando o acréscimo de seu objeto na constituição da denominação adotada pelas sociedades limitadas, anônimas e comanditas por ações (CC, arts. 1.158, § 2º, 1.160 e 1.161). Para a firma individual, o Código tornou facultativa a inclusão do objeto ou gênero de atividade (CC, art. 1.156), omitindo-se em relação às firmas sociais. Na tendência jurisprudencial, a legislação parece caminhar para garantir a proteção dos nomes empresariais nos limites de sua atividade, isto é, do objeto social, cuja designação se torna obrigatória para as denominações.

Em relação ao segundo, o legislador optou pela proteção absoluta, limitada à unidade federativa (CC, art. 1.166), facultando, contudo, a extensão a todo território nacional, se registrado na forma da lei especial (CC, art. 1.166, parágrafo único).

73.5. Colidência entre marca e nome empresarial

A utilização da marca e do nome empresarial decorre de registros diferentes e para fins diversos. Tratando-se de direitos distintos, seus detentores têm, ambos, legitimidade para utilizá-los em seus campos

específicos, para a finalidade a que se propõe.

Na hipótese de exercício de uma mesma atividade pelos detentores dos direitos, e podendo disso resultar confusão ao consumidor ou desvio de clientela, deve-se atender a dois critérios para sua solução: a) a especificidade: o ramo de atividade de uma e de outra empresa; e b) a novidade ou precedência de registro: na hipótese de colidência entre empresários de um mesmo ramo, impõe-se atentar primeiramente à anterioridade de cada um dos registros, prevalecendo o princípio da novidade. Até o julgamento da Ação Rescisória n. 512 ², o STJ considerava o prazo de vinte anos, previsto para as ações pessoais (CC16, art. 177), o que veio a ser consolidado na Súmula 142, cancelada nesse julgamento.

A partir daí, cumpre distinguir: a) nos casos submetidos à vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para a propositura de ação visando à abstenção de uso de marca rege-se pelo prazo das ações reais (CC16, art. 177): dez anos entre presentes e quinze anos entre ausentes – conforme entendimento do STJ ³; b) no Código Civil de 2002, na falta de fixação de prazo especial para as ações de direito real de natureza inibitória (abstenção de uso), o prazo para a propositura dessa ação segue a regra geral de dez anos (CC, art. 205). Contudo, se a ação visa à reparação de danos por violação do uso da marca, o prazo é quinquenal, “porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado”, conforme lição de Caio Mário da Silva Pereira, citado no REsp 1.320.842/PR, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 15-5-2013.

73.6. Sistemas de formação do nome empresarial

São três os sistemas utilizados para se estabelecer os critérios de formação do nome empresarial: veracidade, plena liberdade e eclético, ou misto, também chamado das firmas derivadas.

No sistema da veracidade, a constituição do nome empresarial obedecerá, no caso das firmas individuais e das firmas sociais, ao nome de

seu titular (firma individual) e a dos seus sócios (firmas sociais).

No sistema de plena liberdade há ampla escolha do nome, não vinculando, necessariamente, ao nome de seus titulares ou sócios.

No sistema eclético, exige-se a aplicação do princípio da veracidade para o registro do primeiro nome do empresário. Transferida a titularidade da empresa ou das cotas sociais, permite-se a permanência do mesmo nome, com a concordância dos antigos titulares. Este é o sistema adotado pelo Código Civil italiano, de 1942, nos arts. 2.563 e 2.565.

A lei brasileira adotou o sistema da veracidade, de forma expressa no art. 34 da Lei n. 8.934/94, aplicável às firmas, pois exige a indicação do nome pessoal, completo ou abreviado, do empresário ou de um dos sócios das sociedades.

73.7. Formação do nome

As regras encontradas no Código Civil para a formação do nome empresarial são bastante simples. Além da veracidade, a lei brasileira adota o requisito da novidade, para constituição do nome comercial, consistindo, este último, no impedimento à utilização de nome já existente no Registro Público de Empresas:

- A firma individual é constituída pelo nome do empresário, admitindo-se o aditamento de designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero de atividade (art. 1.156). Para a empresa individual de responsabilidade individual, acrescida da expressão EIRELI (art. 980-A, § 1º), e na pessoa jurídica de responsabilidade limitada criada pela LLE (equivocamente chamada de sociedade limitada unipessoal) será formada pelo nome civil do instituidor, acrescido da palavra limitada, por extenso ou abreviadamente.
- O nome do empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito na Junta Comercial, na unidade da Federação (art. 1.163).
- Na hipótese de o nome ser comum a outros empresários já registrados, o interessado deve acrescentar designação que o distinga (art. 1.163, parágrafo único).
- A firma social pode ser utilizada por todas as sociedades, à exceção da anônima (art. 1.160), e é constituída pelo nome dos sócios que respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas pela sociedade (art. 1.157), salvo quando se tratar de sociedade limitada e de sociedade

em comandita por ações, que devem, obrigatoriamente, fazer uso das expressões “limitada” e “em comandita por ações”, respectivamente (arts. 1.158, § 3º, 1.157 e 1.161).

- A denominação pode ser utilizada pela empresa individual de responsabilidade limitada e pelas sociedades limitadas (art. 1.158, § 2º), em comandita por ações (art. 1.161) e anônimas (art. 1.160), sendo formada por expressão linguística não vedada em lei, acrescida de designação de seu objeto social e das expressões correspondentes à modalidade empresarial (a expressão EIRELI) ou ao tipo societário escolhido, conforme o caso: (a) “limitada” ou “ltda.”; (b) “em comandita por ações” e (c) “sociedade anônima”, “S/A”, “companhia” ou “cia.”. Neste último caso, a partícula “companhia” e a correspondente “cia.” não podem figurar no final da expressão adotada.
- O nome do fundador, acionista, pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa, nas sociedades anônimas (art. 1.160, parágrafo único), bem como o dos sócios, na limitada (art. 1.158, § 2º), podem figurar nas denominações.
- Até 1º de janeiro de 2018, se o empresário e/ou a sociedade empresária obtivessem o enquadramento fiscal especial, deveriam utilizar as expressões correspondentes (microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP), conforme determinava o art. 72 da Lei Complementar n. 123/2006. Contudo, com a promulgação da Lei Complementar n. 155/2016, esse dispositivo foi revogado e a IN DREI n. 45, de março de 2018, passou a vedar a inclusão no final do nome do porte da empresa.
- Nas denominações é obrigatório incluir o objeto social a partir de 1º de janeiro de 2018 (IN DREI n. 45/2018).

73.8. Nome empresarial de sociedade estrangeira

As regras de constituição de nome de sociedade não se aplicam às estrangeiras. O Código Civil estabeleceu regra própria impondo-lhes que usem nome de origem – formado segundo as leis do país onde primeiro se estabeleceram –, facultando-lhes acrescentarem a expressão “do Brasil” ou “para o Brasil” (art. 1.137, parágrafo único).

73.9. Alteração do nome empresarial

Em geral a alteração do nome empresarial depende da vontade dos sócios ou é motivada por oposição de outro empresário detentor anterior do nome. Há também a hipótese de transformação da sociedade (veja item 49.1), que acarreta, entre outras mudanças, a do nome empresarial, porque alterado o tipo societário, segue-se a necessária adaptação em obediência

ao princípio da veracidade.

No tocante especialmente às firmas, haverá necessidade de alteração nos seguintes casos: a) retirada, exclusão ou morte de sócio cujo nome civil constava da firma social (CC, art. 1.165); b) alteração da categoria de sócio figurante na firma social (CC, art. 1.157, parágrafo único).

Facultativamente, permite-se clausular em contrato de trespasse de estabelecimento empresarial que o novo adquirente use o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor: "Fulano de Tal & Cia., sucessor de Primeira Firma Social" (CC, art. 1.164).

74. Prepostos, gerentes, contabilistas e auxiliares

De Plácido e Silva define preposto como "a pessoa ou o empregado que, além de ser um prestador de serviços, está investido no poder de representação de seu chefe ou patrão, praticando os atos concernentes à avença sob direção e autoridade do preponente ou empregador" (1998:633).

Por empregar-se em interesses alheios, a figura do preposto pode trazer confusão com outras duas, a do mandatário e a do comissário.

A distinção entre os institutos da preposição, do mandato e da comissão não traz qualquer dificuldade. O mandatário recebe poderes de outrem para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses (CC, art. 653); o comissário adquire ou vende bens em seu próprio nome, à conta do comitente (CC, art. 693); o preposto emprega-se em serviços do preponente mediante contrato de prestação de serviços, com ou sem vínculo empregatício.

Carvalho de Mendonça percebe no contrato de preposição a participação "tanto do mandato como da locação de serviços", mas reconhece que não reúne "os caracteres exclusivos de nenhum desses contratos. A subordinação ou dependência do preposto em relação ao preponente

arreda-lhe a qualidade de mandatário, para lhe imprimir a de locador de serviços; a representação, que, muitas vezes, o preposto exerce relativamente a terceiros, afasta-o da posição de locador de serviços para o elevar a mandatário” (2001, 2.1:498).

Pesa sobre o preposto a autoridade do preponente, a quem se subordina, sendo-lhe vedado fazer-se substituir sem autorização escrita (CC, art. 1.169), ou negociar por conta própria ou de terceiro (CC, art. 1.170).

Se a preposição é permanente no exercício da empresa ou em um de seus braços organizacionais (sede, matriz, filial, agência, sucursal etc.) o preposto é denominado gerente e, nessa função, está autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados (CC, art. 1.173).

Qualquer limitação aos poderes do gerente deve ser arquivada no Órgão de Registro de Empresas, sob pena de não poder ser oposta a terceiro que com ele contratar em nome da empresa. Na ausência dessa providência restaria ao preponente a difícil tarefa de demonstrar que as limitações eram anteriormente conhecidas da pessoa que tratou com o gerente (CC, art. 1.174).

Distinguiu, entretanto, o legislador, duas situações, levando em conta o lugar em que o ato do preposto, relativo à atividade empresarial, é praticado. Se ocorre no interior do estabelecimento empresarial, o preponente responde pelo ato, ainda que não o tenha autorizado por escrito (CC, art. 1.178); se fora do estabelecimento, somente obriga o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito (CC, art. 1.178, parágrafo único).

Deu-se, portanto, efetividade à teoria da aparência, para proteger direito de terceiros que adentram o estabelecimento empresarial. É o caso, por exemplo, de venda efetuada no interior de concessionária de automóveis por vendedor empregado ou comissionado da loja. Na qualidade de preposto seus atos vinculam o preponente, empresário ou a sociedade

empresária, ao cliente interessado em ali adquirir produtos.

Além do gerente, cuidou o legislador de regulamentar a atividade de outros prepostos qualificados, a do contabilista e de outros auxiliares, explicitando que os assentos contábeis, salvo demonstração de má-fé, reputam terem sido efetuados pelo preponente.

Em regra, o preposto age com autorização e sob as ordens do preponente, ficando, diante deste, pessoalmente responsável pelos atos culposos que praticar no exercício de suas funções. Perante terceiros o preposto somente responde, solidariamente com aquele, se o ato de sua parte foi feito com dolo (CC, art. 1.177, parágrafo único).

Se, entretanto, praticar atos em seu próprio nome, à conta do preponente, ambos ficam responsáveis pelo ato perante terceiros (CC, art. 1.175).

75. Escrituração empresarial

75.1. Funções da escrituração

Carvalho de Mendonça (2001, 2.1:212) explicita três propósitos para a exigência da escrituração empresarial: a) é a história da vida mercantil, permitindo a seu titular o levantamento, a qualquer tempo, do vigor de sua empresa, as alterações ocorridas no patrimônio empresarial, possibilitando-lhe tomar decisões tendentes à redução ou ampliação de sua atividade; b) propicia a fiscalização e a adoção de medidas visando coibir simulação de capital para obtenção de maior crédito, pagamentos antecipados ou irregulares, fraudes mediante desvio de bens ou simulação de dívidas etc.; c) permite que o empresário faça prova em juízo quando em litígio contra outro empresário.

São três, portanto, as funções da escrituração empresarial, que se tornaram conhecidas com as expressões “gerencial”, “fiscal” e

“documental”, cunhadas por Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:117).

75.2. Princípios informadores

Os princípios informadores da escrituração são: fidelidade, sigilo e liberdade.

Consiste o primeiro na exigência legal de exprimir, com fidelidade e clareza, a real situação da empresa (CC, arts. 1.183-1184).

Em segundo lugar, seguindo a tradição do direito pátrio, o Código Civil manteve o princípio do sigilo dos livros empresariais (CC, arts. 1.190 e 1.191). Protegidos pela garantia da inviolabilidade, para garantia do bom andamento da atividade empresarial, os livros somente se submetem à exibição integral quando esta for necessária à solução de questões relativas à administração ou gestão por conta de outrem, comunhão ou sociedade, sucessão ou falência.

O escopo do princípio do sigilo imposto sobre os livros e documentos mercantis “é evitar ou impedir a concorrência desleal” (Sylvio Marcondes, 1977:69), daí por que não se aplica às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos (CC, art. 1.193).

Nos casos legalmente mencionados (CPC15, art. 420; CC, art. 1.191, e Súmula 260 do STF), a requerimento da parte contrária, o juiz pode determinar a exibição integral dos livros comerciais e dos documentos de seu arquivo.

A exibição total é, portanto, exceção, podendo ser requerida como medida preventiva (Súmula 390 do STF), ou, na falta de lide pendente, ser estruturada como ação cautelar, nos seguintes casos: a) na liquidação da sociedade (CPC15, art. 420, I); b) na sucessão por morte de sócio (CPC15, art. 420, II); c) quando e como determinar a lei (CPC15, art. 420, III).

Esta última expressão inclui pelo menos os seguintes casos: 1) comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem (CC, art. 1.191);

2) atos violadores da lei ou do estatuto ou suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia, mediante pedido de acionistas que representem pelo menos 5% do capital social (LSA, art. 105).

O terceiro princípio informador é o da liberdade. Algumas legislações impõem não apenas a obrigação de manter os livros, mas, também, enumera-os como obrigatórios. A regra brasileira sempre escolheu a liberdade de escolha, caracterizada pelas expressões hoje utilizadas pelo § 1º do art. 1.179 do Código Civil: "Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados".

A exceção é, e sempre foi, o livro Diário, único livro obrigatório comum a todos os empresários, matéria que será objeto de melhor explanação a seguir.

75.3. Sanções penais decorrentes da ausência ou fraude na escrituração

Em relação à escrituração dos livros, o empresário pode sofrer penas de natureza criminal, condicionada sua aplicação, porém, em alguns casos, à ocorrência do evento falimentar ou processo de recuperação judicial, como, por exemplo, as hipóteses de agravação de pena previstas nos incisos I, II e III do art. 168 da Lei n. 11.101/2005.

75.4. Espécies de livros

Os livros utilizados pelos empresários podem ser classificados, quanto à exigência legal, em obrigatórios e não obrigatórios ou facultativos, também chamados auxiliares. A falta de escrituração dos primeiros impõe sanções de ordem administrativa, processual ou penal.

Subdividem-se os livros obrigatórios em empresarial comum e especiais, conforme sejam destinados a todos os empresários ou a uma determinada

categoria destes. Somente o livro Diário, previsto no art. 1.180 do Código Civil, é comum a todos os empresários.

Entre as novidades introduzidas pela nova lei civil, encontra-se a possibilidade de sua substituição pelo Livro Balancetes Diários e Balanços, desde que se mantenham as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para o primeiro. Este novo livro é de introdução inédita na tradição contábil pátria e sua escrituração visa expressar as mesmas situações contábeis do livro Diário, conforme se depreende do art. 1.186:

I – a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo respectivo saldo, em forma de balancetes diários;

II – o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no encerramento do exercício.

Além do livro obrigatório comum – Diário – imposto pela legislação empresarial, há outros obrigatórios por força de outros diplomas. É o caso dos livros de interesse fiscal e de índole trabalhista, entre os quais se encontram: Entrada e Saída de Mercadorias, Apuração de ICMS, Apuração de IPI, Registro de Inventário, Registro de Empregados, além de outros.

Tais livros são obrigatórios por força de legislação própria, não empresarial. São livros que podem ser – facultativamente – levados a registro na Junta Comercial.

Ao lado dos livros obrigatórios, a lei faculta ao empresário adotar outros visando à melhor organização de seus negócios. São exemplos de livros facultativos ou auxiliares: Livro Caixa, Contas-Correntes, Copiador de Cartas, Razão, Obrigações a Pagar e a Receber etc. É-lhe facultado, ainda, criar novos livros, sempre com vistas à liberdade de administração de sua atividade empresarial.

O número de livros facultativos é ilimitado, enquanto os livros obrigatórios são somente os definidos pela lei, segundo a atividade desempenhada pelo empresário.

75.5. Valor probante dos livros

Somente se extrai valor probatório de livros revestidos de formalidades de ordem extrínseca (externa) e intrínseca (interna). A primeira ordem de exigências formais refere-se ao modo de abertura e encerramento dos livros e fichas e seu registro. A segunda ordem se assenta na necessidade de ser completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, com individualização e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes sobre as margens (CC, art. 1.183).

Algumas regras foram delineadas pelo legislador quanto à apreciação do conteúdo probatório dos livros escriturados pelo empresário: 1) sempre provam contra seus possuidores, isto é, assumem o caráter de confissão (CC, art. 226; CPC15, art. 417); 2) provam também a favor do possuidor quando, escriturados em vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios (CC, art. 226; CPC15, art. 418); 3) os lançamentos podem ser ilididos por comprovação de falsidade ou inexatidão (CC, art. 226, parágrafo único; CPC15, art. 417); 4) a demonstração isolada extraída de lançamento contábil não será considerada suficiente se a lei exigir escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais (CC, art. 226, parágrafo único); 5) a escrituração contábil é indivisível, seguindo a regra da confissão, isto é, a parte não pode aceitá-la no que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável (CPC15, arts. 395 e 419).

75.6. Recusa de apresentação de livros

A recusa em apresentar os livros comerciais pode se firmar em vários fatores, como menciona Moacyr Amaral Santos (1976:144-146): a) no fato de o documento não existir ou não estar em poder do comerciante, por perda ou perecimento; b) na inexistência de obrigação legal de exhibir; c) na falta de interesse do requerente; d) em um dos motivos previstos no art.

404 do CPC15.

O Código Civil (art. 1.192) distingue as soluções para a recusa da apresentação dos livros: a) quando se tratar de exibição integral (comunhão, sucessão, gestão e falência), os livros serão apreendidos judicialmente; b) nas hipóteses de exibição parcial, ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Entretanto, essa confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário.

Se a negativa basear-se na alegação de estar o documento em poder de terceiro, a solução é outra: o juiz deve mandar citar o terceiro a responder, no prazo de quinze dias (CPC15, art. 401). Negando-se a exibir os livros, o terceiro será ouvido em depoimento, podendo ser expedido mandado de apreensão, com uso de força policial e posterior apuração de crime de desobediência.

Anote-se, por fim, que o perecimento do livro não é motivo bastante para a recusa, uma vez que compete ao empresário a guarda e a conservação do livro, impondo-lhe a lei, igualmente, sua restauração em caso de perda ou extravio. Se a perda ou extravio se deu por motivo de força maior, o ônus dessa prova cabe a quem alega (Vampré, 1921: 215).

75.7. Livros empresariais e pequenos empresários

A Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n. 155, de 27 de outubro de 2016, regulamenta, em seu art. 3º, as microempresas e empresas de pequeno porte, determinando, para seu enquadramento fiscal, seja observado, além da regularidade (registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil, no caso das sociedades simples), o limite de receita bruta (produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos) igual ou inferior a R\$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para as microempresas e de valor superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para as empresas de pequeno porte.

Além desses requisitos, há a vedação de enquadramento de pessoas jurídicas (Lei Complementar n. 123/2006, art. 3º, § 4º): I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse os limites acima citados; IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite fixado; V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite fixado; VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; X – constituída sob a forma de sociedade por ações; XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante de serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

O Código Civil dispensa o pequeno empresário de seguir um sistema de

contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros (art. 1.179, § 2º), levando à conclusão de que estaria dispensado de qualquer escrituração contábil.

Há de distinguir, contudo, as definições legais introduzidas no Estatuto da Microempresa. Nem todo microempresário é considerado “pequeno empresário” para fins do art. 1.179 do Código Civil. Para essa finalidade, o art. 68 da Lei Complementar n. 123/2006 abrange tão somente o empresário individual caracterizado como microempresário e que “aufera receita bruta anual até o limite previsto no § 1º do art. 18-A”, que, a partir de novembro de 2011 (Lei Complementar n. 159), passou a ser R\$ 60.000,00. Estão excluídos: a) a sociedade empresarial, mesmo enquadrada como microempresária; b) o empresário individual que não atenda aos requisitos de enquadramento como microempresário; c) o microempresário individual que, mesmo atendendo aos requisitos de enquadramento, aufera renda bruta anual acima do teto legal.

Temos assim:

	Requisito comum	Limites da renda bruta anual	Dispensa de escrituração	Pessoa jurídica impedida de enquadramento
ME	Registro no órgão competente	Igual ou inferior a R\$ 360.000,00	Somente se a renda bruta anual for igual ou inferior a R\$ 60.000,00	I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse os limites da renda bruta anual; IV – cujo titular ou sócio participe com mais
EPP	Registro no órgão competente	Superior a R\$ 360.000,00 e inferior a R\$ 4.800.000,00	Não é dispensado	

				de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite fixado; V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite fixado; VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
				IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; X – constituída sob a forma de sociedade por ações; XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante de serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

Acrescenta-se aos conceitos de microempresa (ME) e de empresa de pequeno porte (EPP) o de microempreendedor individual (MEI) previsto nos

arts. 18-A, B e C, introduzidos pela Lei Complementar n. 128, de 19-12-2008, na Lei Complementar n. 123, de 14-12-2006, com as alterações da Lei Complementar n. 139, de 10 de novembro de 2011.

Além do regime fiscal, matéria de interesse do direito tributário, distinguem-se esses três conceitos em razão de suas características próprias, destacando-se as seguintes: a) **a renda bruta anual:** até R\$ 60.000,00 para os MEIs; até R\$ 360.000,00 para as MEs e de R\$ 360.000,01 a R\$ 4.800.000,00 para as EPPs; b) **a atividade e forma de seu exercício:** os MEIs são sempre empresários individuais, enquanto as MEs e EPPs podem ser empresários individuais, sociedades simples ou sociedades empresárias não constituídas sob a forma institucional (isto é, não podem ser sociedades por ações ou cooperativas – para estas há a exceção relativa às cooperativas de consumo); c) **o número de empregados:** limita-se ao MEI a colaboração de um único empregado que perceba até um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional, enquanto para as MEs e EPPs não há qualquer limitação; d) **a obrigatoriedade de escrituração:** os MEIs são considerados pequenos empresários para fins do disposto nos arts. 970 e 1.179 do Código Civil, ficando dispensados de seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração de seus livros. É o que decorre da regra do art. 68 da Lei Complementar n. 123/2006; as MEs somente são dispensadas dessas exigências se exercerem a atividade de forma individual e sua renda bruta anual for igual ou inferior a R\$ 60.000,00; as EPPs submetem-se à regra geral de escrituração.

75.8. Demonstrações financeiras diferenciadas

As sociedades por ações e as sociedades de grande porte (veja 75.11) devem seguir regras contábeis diferenciadas previstas na LSA e sujeitas a três princípios básicos: periodicidade, anualidade e competência exclusiva da assembleia geral.

Os dois primeiros decorrem do art. 175 da LSA: a apuração contábil e a

demonstração econômico-financeira devem obedecer a um período de um ano, sendo que seu término será fixado no estatuto da empresa

Exceções à anualidade ocorrem na alteração estatutária e na constituição da companhia. Nesses dois casos, entre a data da constituição ou do término do período anterior e a data fixada no estatuto pode transcorrer período inferior a um ano. Ex.: a empresa foi constituída em maio de 2008 e fixou como data de término de seu exercício contábil todo dia 31 de dezembro. Esse primeiro período será de sete meses tão somente. Outro exemplo: o estatuto alterou a data de término de dezembro para junho. O período de apuração após a alteração será de apenas seis meses.

O princípio da competência exclusiva da assembleia geral decorre dos arts. 87 e 122, I, da LSA que determinam a competência desse órgão para aprovar os estatutos e deliberar sobre sua reforma. Cabe, portanto, à assembleia geral, de forma exclusiva, fixar o término do exercício social.

75.9. Demonstrações financeiras comuns às sociedades por ações e de grande porte

Três são as demonstrações financeiras comuns a todas as sociedades por ações e de grande porte: (I) balanço patrimonial; (II) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (III) demonstração do resultado do exercício.

Balanço patrimonial: é a representação contábil, gráfica e aproximada, da situação econômico-financeira da empresa, sempre quantitativa, isto é, a partir de valores do ativo e passivo relativos à sua universalidade jurídica. O ativo compõe-se de dois grupos de contas: ativo circulante e ativo não circulante. Este último subdivide-se em ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo compreende três grupos de contas: passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, que, por sua vez, é composto de seis contas: capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em

tesouraria e prejuízos acumulados.

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados: é o instrumento contábil pelo qual a empresa dá a conhecer quanto operacionalmente recebeu e quanto gastou no exercício. Realizada a subtração entre essas contas, temos o resultado: se positivo, há, contabilmente, lucro; se negativo, prejuízo.

Demonstração do resultado do exercício: reflete o desempenho da empresa e vem acompanhada de informações relativas à apuração de lucro líquido ou de prejuízo, a partir das rubricas indicadas no art. 187 da LSA.

75.10. Demonstrações financeiras especiais

Duas são as demonstrações especiais:

1) demonstração de fluxos de caixa, somente obrigatória para as companhias fechadas com patrimônio líquido não inferior a dois milhões de reais na data do balanço e para todas as companhias abertas. Fluxos são alterações ocorridas no saldo de caixa durante o período de apuração e referem-se a três episódios: operações, financiamentos e investimentos;

2) demonstração de valor adicionado: somente obrigatória para as sociedades abertas, consiste no “valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza distribuída” (LSA, art. 188, II).

75.11. Escrituração contábil e sociedades de grande porte

A Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, no parágrafo único de seu art. 3º, definiu sociedade de grande porte: “sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de

reais)”, equiparando-a, para efeitos de escrituração e elaboração das demonstrações financeiras, às sociedades por ações, mesmo quando não constituídas segundo essa forma legal. Sujeitam-se, ainda, à obrigatoriedade de auditoria independente por profissional registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Contratos Empresariais

76. Plano de estudo

Visando ao melhor aproveitamento dos estudos, os vinte e sete contratos e cláusulas especiais tratados neste capítulo foram distribuídos segundo o grau de relação entre eles, conforme critérios de sinonímia ou de atividade desenvolvida:

Agência e distribuição – item 77	
Distribuição por conta própria – item 78	
Mandato e comissão mercantil – item 79	
Corretagem – item 80	
Franquia – item 81	
Compra e venda mercantil – item 82	
Compra e venda mercantil – cláusulas e contratos especiais – item 83	- Retrovenda – item 83.1 - Venda a contento e venda sujeita a prova – item 83.2 - Preempção ou preferência – item 83.3 - Venda com reserva de domínio – item 83.4 - Venda sobre documentos – item 83.5 - Crédito documentário – item 83.6 - Contrato estimatório – item 83.7 <i>Hedging</i> – item 83.8 <i>Incoterms</i> – item 83.9
Arrendamento mercantil – item 84	
Alienação fiduciária em garantia – item 85	
Contratos bancários – item 86	- Depósito bancário – item 86.1 - Desconto e redesconto – item 86.2 - Empréstimo bancário – item 86.3
Faturização – item 87	
Transporte e seguro – item 88	- Transporte: de pessoas e de coisas – item 88.1 - Seguro: de pessoas e de coisas – item 88.2

77. Agência e distribuição

77.1. Conceito

Agência é o contrato oneroso, em que alguém assume, em caráter profissional, não eventual, e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outrem, a realização de certos negócios, em determinado território ou zona de mercado.

77.2. Natureza

A natureza contratual do contrato de agência e distribuição emerge de seu conceito: a) onerosidade, porque a intermediação do agente se faz mediante retribuição pecuniária; b) pessoalidade (“alguém assume”) ou intransferibilidade, em razão de se exigir exercício pessoal do agente ou distribuidor; c) bilateralidade, que decorre do fato de ambos os contratantes assumirem obrigações.

77.3. Objeto e características

É da essência do contrato de agência e de distribuição (anteriormente conhecido como representação comercial): a) aproximação ou promoção: o agente desenvolve atividade de aproximação de clientela e promoção de vendas ou de serviços para o representado; b) profissionalidade do agente, regulada pela Lei n. 4.886/65, exigindo registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais (art. 2º); c) determinação de uma zona de atividade do agente ou distribuidor; d) resolução do contrato a qualquer tempo, quando firmado por prazo indeterminado, mediante aviso prévio de noventa dias, observado, porém, o transcurso de prazo razoável tendo em vista a natureza e vulto do investimento exigido pelo agente (CC, art. 720); e) regência por regras próprias (CC, arts. 710-721), pelas concernentes ao mandato e à comissão e as constantes na Lei n. 4.886/65; e f) retribuição dos serviços prestados.

Em razão da livre disposição das partes, não se alinha entre as características essenciais a possibilidade de: a) assunção das despesas a cargo do agente (CC, art. 713); b) dúplice exclusividade ou exclusividade recíproca: o representado garante ao representante a exclusividade quanto à zona de negócio que for delimitada no contrato (CC, art. 711) e o agente se obriga a não tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes (CC, art. 711).

77.4. Espécies ou qualificação jurídica

O contrato de agência qualifica-se de distribuição se o agente tem à sua disposição a coisa a ser negociada (CC, art. 710, *in fine*): "Eventualmente, o representado pode confiar ao agente os bens a serem colocados junto à clientela, caso que o Código trata como distribuição, mas não como revenda, visto que os atos de negociação se realizam em nome e por conta do comitente" (Humberto Theodoro Júnior, 2003:115).

77.5. Retribuição

Quanto à retribuição, tanto o Código Civil como a lei especial traçaram extenso regramento. Além da remuneração relativa aos negócios que efetivamente concluir, o agente tem direito à percepção dos valores correspondentes aos negócios (a) concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência (CC, art. 714), (b) não realizados por fato imputável ao proponente (CC, art. 716) e (c) pendentes, na hipótese de dispensa sem culpa (CC, art. 718).

77.6. Extinção do contrato

Ocorrendo causa que acarrete a extinção do contrato, devem-se distinguir algumas situações previstas em lei:

- Dispensa por justa causa alegada pelo representado: o agente tem direito à remuneração pelos serviços úteis. O proponente pode exigir perdas e danos por prejuízos que sofrer (CC, art. 717). São motivos justos para a rescisão pelo representado as causas previstas no art. 35 da Lei n. 4.886/65: a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial; d) a condenação definitiva por crime considerado infamante; e) força maior.
- Dispensa por justa causa alegada pelo representante: neste caso o agente, salvo a hipótese de força maior, terá direito à indenização, porque a dispensa se dá sem culpa sua, equiparando-se sua situação à dispensa imotivada por parte do representado, descrita a seguir. São motivos legais (Lei n. 4.886/65, art. 36) para a rescisão: a) redução da esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato; b) quebra, direta ou indireta, da exclusividade; c) fixação

abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular; d) não pagamento de sua retribuição na época devida; e) força maior.

- Dispensa sem justa causa: neste caso o agente tem direito à remuneração sobre os negócios pendentes e às indenizações constantes da Lei n. 4.886/65, cujo valor deverá estar previsto em contrato, não podendo ser inferior a um doze avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j). No contrato firmado com prazo determinado, a indenização corresponde à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual (art. 27, § 1º).
- Cessação do trabalho pelo agente, por motivo de força maior: o agente, ou, em caso de morte, seus herdeiros, terão direito à percepção correspondente aos serviços realizados.

78. Distribuição por conta própria (revenda ou concessão comercial)

78.1. Conceito e distinções

A expressão genérica “distribuição” pode trazer dificuldades à correta classificação do contrato.

Humberto Theodoro Júnior (2003:111) explica que “a palavra ‘distribuição’ é daquelas que o direito utiliza com vários sentidos. Há uma ideia genérica de distribuição como processo de colocação dos produtos no mercado. Aí se pensa em contratos de distribuição como um gênero a que pertencem os mais variados negócios jurídicos, todos voltados para o objetivo final de alcançar e ampliar a clientela (comissão mercantil, mandato mercantil, representação comercial, fornecimento, revenda ou concessão comercial, franquia comercial etc.). Há, porém, um sentido mais restrito, que é aquele com que a lei qualifica o contrato de agência. No teor do art. 710 do CC, a distribuição não é a revenda pelo agente. Este nunca compra a mercadoria do preponente. É ele sempre um prestador de serviços, cuja função econômica e jurídica se localiza no terreno da captação de clientela”.

Com essa mesma preocupação, Fábio Ulhoa Coelho apresenta

classificação que distingue os contratos de distribuição-aproximação dos contratos de distribuição-intermediação, ensinando que os primeiros, contratos típicos, regulam-se pelos arts. 710-721 do Código Civil e os segundos, atípicos (não disciplinados em lei), caracterizam-se pelo ato de comprar para revender: “um empresário assume (distribuidor)” a obrigação, “perante o outro (distribuído), de criar, consolidar ou ampliar o mercado dos produtos deste último, comprando-os para revender” (2016:415).

Maria Helena Diniz (2006:427) não assinala a distinção e vê o contrato de distribuição como sinônimo de concessão mercantil lato sensu, expressão adotada pela Lei n. 6.729/79, antes da regulação pelo Código Civil (arts. 710-721).

Adotamos aqui a distinção entre “contrato de agência e distribuição (sem revenda), sucedâneo do contrato de representação comercial” e “contrato de distribuição por conta própria (revenda), também conhecido como concessão comercial”.

O primeiro (contrato de agência e distribuição) é regido pelos arts. 710-721 do Código Civil, pela Lei n. 4.886/65 e pelas regras concernentes ao mandato e à comissão (CC, art. 721). O segundo (contrato de distribuição por conta própria) é, em geral, contrato atípico, não disciplinado legalmente, a não ser quando envolver revenda de automóveis, regendo-se, então, pela Lei n. 6.729/79.

78.2. Objeto e características

O contrato de distribuição por conta própria (revenda), por ser atípico, não se reveste de características próprias, comuns a todos os contratos, podendo, entretanto, ser citada como essencial a cláusula de contratação de exclusividade recíproca de distribuição e de definição de territorialidade, em maior ou menor amplitude.

Ordinariamente, outras cláusulas são previstas: a) indenização ao

concessionário em caso de resolução contratual para cobrir prejuízos decorrentes de assistência técnica pós-venda e estoques de peças (Bulgarelli, 1997(a):451); b) casos de resolução e prazos de notificação; c) cotas de fornecimento e de aquisição; d) condições especiais de pagamento do produto adquirido; e) concessão de uso limitado de direitos de propriedade industrial, assistência, conhecimento e treinamento técnicos etc., conforme grau de sofisticação contratual.

78.3. Espécies e qualificação

A revenda de automóveis, exceção ao caráter de atipicidade destes contratos, traz regramento específico (Lei n. 6.729/79) quanto à zona de atuação (art. 5º): a) área demarcada para o exercício das atividades do concessionário, que não poderá operar além dos seus limites; b) distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede, fixadas segundo critérios de potencial de mercado; c) a área demarcada poderá conter mais de um concessionário da mesma rede; d) na eventualidade de venda de veículo automotor ou implementos novos a comprador domiciliado em outra área demarcada, o concessionário que a tiver efetuado destinará parte da margem de comercialização aos concessionários da área do domicílio do adquirente; e) por deliberação do concedente e sua rede de distribuição, o concessionário poderá efetuar a venda de componentes novos fora de sua área demarcada; f) poderá o concessionário abrir filiais, agências ou dependências secundárias, circunscritas às distâncias mínimas entre o estabelecimento de concessionários e atendidas as condições objeto de ajuste entre o produtor e sua rede de distribuição.

79. Mandato e comissão mercantil

O Código Civil manda aplicar ao contrato de agência e distribuição, no que couber, as regras concernentes ao mandato e à comissão. Isto ocorre em razão da afinidade de todos os contratos mencionados servirem à

intermediação.

Há, contudo, distinções. Cada contrato possui conceitos e características próprios.

No contrato de mandato, o mandatário recebe poderes de outrem para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses (CC, art. 653). A distinção entre mandato e agência é facilmente percebida: na agência o contrato envolve relacionamento duradouro, sem a necessidade de poderes inerentes ao mandato, visando à aproximação indeterminada de clientes ao representado. No contrato de mandato, há determinação de certos atos no instrumento de procuração, a serem praticados pelo mandatário.

Na comissão mercantil, o comissário adquire ou vende bens em seu próprio nome, à conta do comitente (CC, art. 693). O comissário não atua em nome do comitente, mas por conta do comitente e, assim, somente ele, comissário, é que se obriga perante a pessoa com quem contrata (CC, art. 694), não respondendo, contudo, por sua solvência perante o comitente (CC, art. 697), salvo se agir com culpa ou o contrato estipular cláusula del credere (CC, art. 698).

A cláusula del credere deve ser expressa e pode ser enunciada por outras expressões equivalentes, como bem expressa Carvalho de Mendonça (1956, 6:310): “fazer bom”, “tomando tudo sobre nós, garantimos a execução do contrato”, “assumimos a garantia”. Em outras palavras, impõe a responsabilidade de o comissário pagar o preço da mercadoria que vendeu, em solidariedade com as pessoas com quem tratou. Para compensá-lo desse ônus, sua remuneração será mais elevada (CC, art. 698).

Orlando Gomes explica o objetivo da cláusula del credere: “servir de estímulo à criteriosa seleção dos negócios, evitando que o comissário, atraído pela comissão, possa concluir para o comitente negócios prejudiciais” (2008:448).

	Função	do	Consumação do		Previsão
--	---------------	-----------	----------------------	--	-----------------

Contrato	contrato	negócio	Cláusulas gerais e especiais	legal
Agência	Promoção de certos negócios em zona determinada.	A aproximação é feita pelo agente, mas o negócio é concretizado entre cliente e proponente.	Salvo ajuste, há de reciprocidade exclusividades.	CC, arts. 710-721 L. 4.886/65
Distribuição (sem revenda)	Promoção de certos negócios em zona determinada, mas o agente tem à sua disposição a coisa negociada.	A aproximação é feita pelo agente, mas o negócio é concretizado entre cliente e proponente.	Aplicam-se as regras relativas ao mandato e à comissão, no que couberem.	CC, arts. 710-721 L. 4.886/65
Mandato	Prática de atos ou administração de interesses alheios.	O mandatário delibera e realiza o negócio em nome do mandante.	Só confere poderes de administração. Para alienar, hipotecar, transigir ou atos que exorbitem a mera administração, exige-se cláusula expressa.	CC, arts. 653-691
Comissão	Aquisição ou venda de bens, em nome do comissário, à conta do comitente.	Somente o comissário aparece no negócio. Ele fica diretamente obrigado com as pessoas com quem contratar.	Normalmente não responde pela solvência da pessoa com que contratar, salvo se agir com culpa ou, ainda, se o contrato de comissão previr cláusula del credere.	CC, arts. 693-709

80. Corretagem

80.1. Conceito e definição

Corretores são profissionais capacitados a “informar os interessados das

condições e vantagens do mercado, aproximá-los, promover o acordo de suas vontades, prepará-los para celebrarem determinado contrato, tal é o trabalho técnico do corretor. Em resumidas palavras: o corretor intervém, com pessoa experimentada e neutra, para facilitar e auxiliar a conclusão de um contrato entre duas ou mais pessoas. Conseguindo o acordo das vontades dos interessados, cessa o seu ofício. Ele não figura nesse contrato; não é contratante. Na expressiva frase de Vidari, é o instrumento material da convenção” (Carvalho de Mendonça, 2001, 2:327).

Define-se contrato de corretagem como aquele em que “uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas” (CC, art. 722).

80.2. Características

São características do contrato de corretagem: a) execução de mediação de negócios, sem vínculo de mandato, de prestação de serviços ou relação de dependência (CC, art. 722); b) prestação de informações sobre o andamento dos negócios e de esclarecimentos acerca da segurança ou risco dos negócios, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência (CC, art. 723); c) a remuneração somente é devida quando ocorre o resultado previsto no contrato de mediação ou, em virtude de arrependimento das partes (CC, art. 725). Acertadamente, Maria Helena Diniz lembra que o objeto do contrato “não é propriamente o serviço prestado pelo corretor, mas o resultado desse serviço” (2006:447).

Verifica-se, pois, que, essencialmente, o contrato de corretagem envolve mediação, aconselhamento e resultado.

80.3. Espécies e qualificação

Além dos corretores de espetáculos públicos, de automóveis, de bens

móveis e imóveis etc., há categorias de corretores designadas legalmente:

a) Corretores de mercadorias, anteriormente nomeados por ato das Juntas Comerciais na vigência da anterior Lei de Registro de Comércio (Lei n. 4.726/65, art. 10, III), a quem competia fixar o número, processar a habilitação e a nomeação, fiscalizar, punir, exonerar os tradutores públicos e intérpretes comerciais, leiloeiros, avaliadores comerciais, corretores de mercadorias e os prepostos ou fiéis desses profissionais. Com a revogação da Lei n. 4.726/65, expressa no art. 67 da Lei n. 8.934/94, que introduziu o registro público das empresas mercantis, sem que houvesse menção aos corretores de mercadorias entre os agentes sujeitos à matrícula (art. 32, I), estes perderam essa condição, não mais estando sujeitos às Juntas Comerciais.

b) Corretores de navios – intermediários nas negociações com transportes marítimos, fretamentos, seguros marítimos e outras atividades ligadas a navios – eram nomeados por atos do Presidente da República e se sujeitavam às administrações das alfândegas para o exercício de seu mister. O Decreto n. 5, de 4 de abril de 1966, retirou-lhes a exclusividade de seu exercício, permitindo que suas atribuições pudessem ser exercidas por armadores e seus prepostos.

c) Corretores de valores mobiliários, que têm por função: 1) operar na Bolsas de Valores e seu exercício é realizado sempre por sociedades registradas previamente no Banco Central do Brasil, nos termos dos arts. 5º e 11 da Lei n. 4.728/65, mediante prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários (art. 16 da Lei n. 6.385/76) quando operarem a distribuição de emissão no mercado; 2) a compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria e quando exercerem a mediação ou corretagem na Bolsa de Valores.

d) Corretores de seguros, cuja profissão é regulada pela Lei n. 4.594, de 29 de dezembro de 1964, são “os intermediários legalmente autorizados a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação

vigente, entre as sociedades de seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado (art. 1º)".

81. Franquia (franchising)

81.1. Definição legal

A Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia Empresarial – LFE), dispôs sobre essa modalidade de contrato e o definiu em seu art. 2º: "sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

81.2. Objeto

Essencialmente, o contrato de franquia envolve prestação de serviços, distribuição de produtos, cessão de uso de marcas e/ou patentes, bem como prestação sucessiva, continuada desses recursos.

81.3. Natureza

É contrato bilateral: um dos contratantes obriga-se a fornecer produtos, uso de tecnologia, uso de marcas e patentes e prestação de serviços; cabe ao outro contratante pagar remuneração por esses direitos, cessões e serviços.

81.4. Elementos do contrato

Para a formação do contrato de franquia exige-se:

a) a presença de dois contratantes, de um lado o franqueador, ou concedente, empresário que detém a fabricação, distribuição ou licenciamento do produto ou marca e, de outro, o franqueado, empresário que se dispõe a distribuí-los no mercado;

b) obrigação de o franqueador fornecer uma Circular de Oferta de Franquia ao interessado em tornar-se franqueado, por escrito e em linguagem clara e acessível, dez dias antes da assinatura do contrato, ou pré-contrato, ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa, contendo as informações previstas no art. 3º da LFE, fazendo acompanhar modelo de contrato-padrão (item XV):

Item	Informações necessárias
Quanto à franqueadora, sua rede e higidez financeira	(I) histórico resumido, forma societária e nome completo ou empresarial do franqueador e de todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e endereço; (II) balanços de demonstrações financeiras da franqueadora relativa aos dois últimos exercícios; (III) indicação das pendências judiciais envolvendo franqueador, empresas controladoras e titulares das marcas,
	patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia; (IX) relação da rede (franqueados, subfranqueados e subfranqueadores) contendo os nomes completos do atuais e daqueles que se retiraram nos últimos 12 meses;
Quanto ao produto contratado	(IV) descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado; (XIII) situação das marcas ou patentes perante o órgão de registro (INPI); (XII) indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere à supervisão da rede, serviços de orientação e outros prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento de funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado;

Quanto às características e comportamento esperado do franqueado, durante e depois da extinção do contrato	(V e VI) perfil do que se convencionou “franqueado ideal”, isto é, as qualidades e requisitos obrigatórios ou desejados para o exercício da atividade, bem como quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio; (XIV) situação do franqueado após a expiração do contrato, quanto ao segredo de indústria e restrições concorrenciais;
Quanto aos ônus do contrato	(VII e VIII) especificação de valores a serem disponibilizados, inclusive sobre as taxas periódicas, remunerações, instalações, aluguéis etc.; (XI) informações sobre a obrigatoriedade de o franqueado adquirir bens, produtos ou insumos;
Quanto à extensão territorial e exclusividade	(X) especificação da zona de atendimento, da exclusividade ou não do franqueado.

c) a celebração por escrito, assinado na presença de duas testemunhas (LFE, art. 6º).

82. Compra e venda mercantil

82.1. Conceito

Contrato de compra e venda é aquele em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro (CC, art. 481). O contrato será empresarial quando as partes forem empresárias ou sociedades empresariais.

82.2. Elementos formadores

Em geral a doutrina apresenta três elementos essenciais à formação do contrato de compra e venda: a coisa, o preço e o consentimento.

Há, contudo, quem entenda que o contrato se forma quando comprador e vendedor acordam quanto à coisa, preço e condições. Nessa linha, o consentimento não é específico ao contrato de compra e venda, mas é comum a todos os contratos, surgindo um terceiro elemento essencial em seu lugar: as condições.

É o magistério de Fábio Ulhoa Coelho (2016, 3:74): “comprador e vendedor devem acertar quanto às condições do contrato, isto é, os fatos que postergam a exigibilidade da obrigação (condição suspensiva) ou as desconstituem (resolutiva)”.

Em oposição encontra-se Waldirio Bulgarelli (1997a:178), na vigência do Código Civil de 1916: “Tem-se entendido que a referência às condições é dispensável, pois que elas não integram propriamente o contrato, mas são modalidades contratuais, tanto que o Código Civil, no art. 1.126, não se refere a elas, estatuinto que, se a venda é pura, será desde logo perfeita e obrigatória, bastando que o comprador e o vendedor se acordem sobre o objeto e o preço”.

Na mesma dicção encontra-se o art. 482 do Código Civil de 2002: “A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço”.

Seria, portanto, essencial ao contrato de compra e venda somente o ajuste sobre o preço e a coisa.

Maria Helena Diniz (2006:185) especifica os requisitos da coisa: a) existência corpórea ou incorpórea, que pode ser potencial no momento da celebração do contrato, mas efetiva na data de sua entrega ao comprador; b) individualidade, isto é, sobre objeto determinado ou determinável; c) disponibilidade no comércio; d) possibilidade de ser transferida ao comprador.

O contrato será nulo se deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço (CC, art. 489). Contudo, a fixação pode: a) ficar ao arbítrio

de terceiro designado pelos contratantes (CC, art. 485); b) ser contratada à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar (CC, art. 486); c) submeter-se a índices ou parâmetros suscetíveis de objetiva determinação (CC, art. 487); d) sujeitar-se a tabelamento oficial ou, ainda, na sua falta, ao preço corrente das vendas habituais do vendedor, quando as partes convencionarem a não fixação de preço (CC, art. 488); e) estabelecer-se pelo preço médio, se, no caso anterior, as partes não acordarem (CC, art. 488, parágrafo único).

82.3. Obrigações do vendedor

Basicamente três são as principais obrigações do vendedor: a) entregar a coisa e transferir o domínio da coisa vendida; b) garantir o uso e gozo pleno da coisa vendida, obrigando-se pelos vícios ocultos; e c) responder por evicção.

82.4. Entrega da coisa

No que respeita à obrigação de entregar a coisa, impõem-se importantes considerações acerca dos riscos, lugar de entrega e despesas, podendo as partes, entretanto, dispor livremente a respeito. As regras legais são as seguintes:

a) Quanto aos riscos: de modo geral a entrega se faz de modo real ou simbólico (também chamado alegórico ou ficto), isto é, efetivada em mãos do comprador ou à sua disposição, nos casos em que a lei presume, advindo daí os ônus pelos riscos que recaírem sobre a coisa. Há, ainda, dois outros modos que serão tratados como cláusulas especiais, previstos nos art. 529 do Código Civil: a entrega do título representativo e de documentos exigidos no contrato e, no silêncio deste, pelos usos.

Até o momento da tradição os riscos correm por conta do vendedor (CC, art. 492), salvo três situações, em que os riscos correrão por ordem do

comprador: 1) os “casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador” (CC, art. 492, § 1º); 2) se houver mora do comprador de recebê-las, “quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados” (CC, art. 492, § 2º) e 3) se por ordem do comprador o objeto do contrato tiver que ser expedido para lugar diverso do local onde se encontrava no tempo da venda, tendo o vendedor cumprido as instruções e entregue a coisa ao transportador (CC, art. 494).

As hipóteses excepcionadas referem-se à tradição simbólica, pela qual o vendedor exime-se de riscos supervenientes.

b) Quanto ao lugar de entrega: salvo estipulação expressa, deve ocorrer no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda (CC, art. 493).

c) Quanto às despesas da tradição: salvo convenção em contrário, são devidas pelo vendedor. Se, entretanto, forem exigidos escritura e registro, as despesas correm a cargo do comprador (CC, art. 490).

82.5. Vícios

Os vícios que permitem rejeitar (ação redibitória) ou reclamar abatimento de preço (ação quanti minoris) são qualificados de redibitórios. Redibir traz a ideia de enjeitar.

O adquirente pode escolher entre as ações, não podendo, contudo, depois de ingressar com uma delas em juízo, valer-se da outra.

Se o contrato se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, além das ações acima, pode o adquirente valer-se, ainda, de pedido de substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (CDC, art. 18, § 1º, I), conforme nos lembra Fábio Ulhoa Coelho (2002, 3:80).

Vícios são falhas ou defeitos ocultos, graves a ponto de tornar a coisa

imprópria ao uso a que é destinada, ou, ainda, diminuir-lhe o valor (CC, art. 441). É por esta razão que, em se tratando de coisas vendidas em conjunto, o defeito de uma não autoriza a rejeição de todas (CC, art. 503).

É necessário demonstrar que os defeitos preexistiam no momento da celebração da compra e venda e não poderiam ter sido ordinariamente percebidos pelo comprador.

A obrigação de garantir a coisa contra defeitos ocultos está presente em todo contrato comutativo, isto é, aquele em que as “prestações são equivalentes e insuscetíveis de variação”, característica que o distingue do contrato aleatório, em que “intervindo o risco, subordinam-se as prestações à alea de acontecimento desconhecido e incerto, de que pode resultar para um e outro contratante perda ou vantagem e cuja extensão é ignorada” (Washington de Barros Monteiro, 1973:70).

82.6. Evicção

A evicção é garantia inerente a todo contrato oneroso. Pode ser ampliada, reduzida ou excluída pelas partes, em cláusula expressa no contrato.

Refere-se à perda – total ou parcial – da coisa vendida ou de sua posse, por força de decisão judicial proferida em virtude de reivindicação de terceiro.

Obriga-se o vendedor a pagar o preço que o comprador lhe pagou, bem como a indenizar-lhe pelos frutos restituídos, despesas do contrato, prejuízos, custas judiciais e honorários advocatícios despendidos (CC, art. 450).

82.7. Obrigações do comprador

O comprador tem, essencialmente, a obrigação de pagar o preço. Não o fazendo, o vendedor não é obrigado a lhe entregar a coisa (CC, art. 491),

salvo se o contrato foi celebrado para pagamento a prazo.

Há, ainda, outros deveres que lhe são inerentes: suportar os riscos do preço (CC, art. 492) e das situações referidas acima (82.4, “a”, previstas no CC, arts. 492 e 494).

83. Compra e venda mercantil – cláusulas e contratos especiais

83.1. Retrovenda

Retrovenda é modalidade de cláusula especial, permitida nos contratos de compra e venda de coisa imóvel, mediante a qual o vendedor reserva para si o direito de recobrá-la no prazo decadencial máximo de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador.

Entre as despesas incluem-se “as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias” (CC, art. 505).

São legitimados ativamente, em virtude de causa mortis, herdeiros e legatários do vendedor e, passivamente, terceiros adquirentes.

Maria Helena Diniz (2006:212) assinala que o direito de retrato – de resgate – não é cessível a terceiros por ato inter vivos, por ser personalíssimo.

A recusa em devolver o bem permite ao vendedor depositar a quantia em juízo (CC, art. 506).

83.2. Venda a contento e venda sujeita a prova

Venda a contento é aquela sujeita a condição (suspensiva) de o adquirente manifestar seu agrado (CC, art. 509). Considera-se perfeita a venda somente depois da exteriorização favorável do comprador.

A condição potestativa inerente ao contrato submete seu

aperfeiçoamento ao arbítrio do comprador, impedindo sua contestação pelo vendedor. Clóvis assim se expressa: “O vendedor não tem direito de apelar para o parecer de perito, porque não se trata de determinar a boa qualidade da coisa vendida, mas de saber se agrada ao comprador. A opinião pessoal deste último é decisiva” (1975, 2:255).

Venda sujeita a prova é a contratada sob condição suspensiva de o comprador experimentá-la para o fim de comprovar que a coisa tem as qualidades asseguradas pelo vendedor e é idônea para o fim ao qual se destina (CC, art. 510).

Em que momento deve o comprador manifestar-se?

O contrato pode estipular o prazo para a declaração do comprador e, no silêncio, ao vendedor cabe o direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para esse fim, em prazo improrrogável (CC, art. 512).

Em ambos os contratos, enquanto não se realizar a condição, a venda e compra, o contrato não se aperfeiçoa. Qual é, então, a situação jurídica do comprador em relação à coisa que detém?

É a de mero comodatário (CC, art. 511), isto é, detém a coisa em empréstimo gratuito, obrigando-se a conservá-la, como se sua própria fora (CC, art. 582), devendo restituí-la quando vencido o prazo convencionado (CC, art. 581) ou, se não previsto, pelo tempo razoável para o fim contratado.

83.3. Preempção ou preferência

Preempção é modalidade de cláusula especial, permitida em contrato de compra e venda, mediante a qual o comprador, na eventualidade de venda ou dação em pagamento da coisa, obriga-se, por certo prazo, a notificar o vendedor a exercer direito de prelação (ou preferência) na aquisição do bem, em igualdade de condições com terceiro.

O Código Civil regulamenta vários aspectos do pacto adjeto de

preferência: a) o prazo máximo para exercício da preempção é de seis meses para móveis e de dois anos para imóveis (art. 513, parágrafo único); b) se o comprador não notificar o vendedor, este pode intimá-lo para que cumpra a avença (art. 514); c) decai o direito de preempção sobre coisa móvel e imóvel, em três e em sessenta dias após a notificação, respectivamente (art. 515); d) se o direito couber a mais de uma pessoa, qualquer uma delas pode exercer o direito sobre o todo e, recusando ou decaindo uma delas, remanesce o direito da outra (art. 517); e) a falta de cumprimento por parte do comprador, deixando de dar ciência sobre o preço e vantagens oferecidas por terceiro, resolve-se em perdas e danos, respondendo solidariamente o terceiro adquirente que agir de má-fé (art. 518); f) trata-se de direito personalíssimo, que não se transmite por ato inter vivos ou causa mortis (art. 520).

Ao lado do direito de preempção contratual há a figura especial, também denominada retrocessão, decorrente de decreto de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Consiste na faculdade de o expropriado exercer a preferência na aquisição da coisa expropriada, pelo preço atual, na hipótese de o Poder Público não utilizar a coisa em obras ou serviços públicos indicados no ato administrativo (art. 519).

83.4. Venda com reserva de domínio

Venda com reserva de domínio é aquela em que o vendedor, por cláusula contratual escrita, reserva para si a propriedade de coisa móvel objeto da alienação, até que o preço esteja inteiramente pago.

Para validade contra terceiros, o contrato contendo a cláusula de reserva deve ser levado a registro no cartório de títulos e documentos e o objeto deve ser infungível, suscetível de caracterização perfeita, distinta de outros congêneres (CC, arts. 522-523).

O comprador detém a posse direta, respondendo pelos riscos desde que a coisa lhe foi entregue. O vendedor, na qualidade de proprietário e

possuidor indireto, pode cobrar o preço das prestações vencidas e vincendas ou recuperar a própria coisa, por meio de ação de reintegração de posse.

Após a vistoria, e arbitrado o valor do bem, com a descrição de seu estado e com sua individualização em todas as suas características, dar-se-á lugar à liquidação, procedendo-se à venda do bem. Se o valor apurado for superior ao valor da dívida, o credor devolverá o saldo. Se, por outro lado, o valor do bem for inferior ao valor da dívida, o credor prosseguirá na cobrança da diferença.

83.5. Venda sobre documentos

Venda sobre documentos é aquela em que a tradição da coisa vendida é “substituída pela entrega de seu título representativo e de outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos” (CC, art. 529).

Trata-se de modalidade de tradição simbólica da coisa que dá ao vendedor o direito de cobrar o preço da venda, na data e no local da entrega dos documentos (CC, art. 530), salvo se outro momento e lugar forem pactuados.

Em contratos com venda sobre documentos é comum a intervenção de instituição financeira, sobretudo em operações mercantis internacionais, nas quais o banco efetua o pagamento ao exportador mediante a entrega da documentação correspondente. Dispõe a lei que a causa subjacente à importação, suas falhas, irregularidades e ilícitos praticados por terceiros não podem ser imputados ao banco concedente do crédito porque é terceiro em relação ao negócio jurídico celebrado entre comprador e vendedor (CC, art. 532).

Para perfeita compreensão do tema, apresentamos, na sequência, o uso mais comum da venda sobre documentos – o crédito documentário.

83.6. Crédito documentário

Crédito documentário é operação de crédito realizada por bancos que intermedeiam vendas internacionais, geralmente realizadas sobre documentos.

O mecanismo de atuação é bastante simples, conforme descreve Waldirio Bulgarelli (1997(a):233): "(...) após a conclusão do contrato de compra e venda entre importador e exportador, ajustados os termos e as condições do negócio, aciona-se o mecanismo do crédito documentado. O comprador (importador) solicita ao seu banco (no seu país) a abertura de um crédito (acreditivo) ao exportador, no país deste. O banco comunica então à sua filial ou correspondente, no país do exportador, a abertura do crédito em favor do exportador, expedindo em favor deste uma carta de crédito. Quando esse crédito, aberto pelo banco do comprador ao vendedor, é confirmado e irrevogável, a garantia do vendedor passa a ser total, pois que o banco do comprador assume então a responsabilidade direta da obrigação. O vendedor pode então usar esse crédito antes ou por ocasião da entrega da mercadoria. Antes, através da emissão de uma letra de câmbio contra o banco, a tempo certo de vista, descontando-a junto a um banco em seu país, o qual, de posse dela, apresentá-la-á ao banco do comprador, junto com os documentos, por ocasião do despacho das mercadorias, para o aceite, representando-a novamente na ocasião do vencimento. Também poderá o vendedor emitir letra de câmbio à vista e apresentá-la ao banco do comprador, juntamente com os documentos da mercadoria, o qual, após examiná-los, fará o pronto pagamento. Por seu turno, o comprador fica garantido, pois que o banco só aceitará ou pagará o preço após o exame da regularidade dos documentos representativos das mercadorias".

83.7. Contrato estimatório

Contrato estimatório ou venda em consignação é aquele em que alguém (consignatário) recebe bem móvel de terceiro (consignante) para efetuar sua venda, obrigando-se a pagar o preço previamente ajustado se deixar de restituir a coisa consignada em sua integridade, no prazo contratado.

A expressão “estimatório” decorre do ajuste prévio de preço (valor estimado). É implícita, também, a temporária suspensão, por parte do consignante, do poder de disposição da coisa, agora exercido em nome próprio pelo consignatário (CC, art. 537). Contudo, o consignante conserva a propriedade do bem consignado que, assim, não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço (CC, art. 536).

83.8. Hedging

Hedging ou, literalmente, barreira/proteção, consiste em operação bolsística com vistas à cobertura de riscos de oscilações de preços, sobretudo no mercado de futuros.

O Vocabulário do mercado de capitais, publicado pela Comissão Nacional de Bolsas de Valores (1990:34), apresenta o seguinte conceito: “É a operação que consiste na tomada de uma posição no mercado futuro aproximadamente igual – mas em sentido contrário – àquela que se detém ou que se pretende vir a tomar no mercado à vista. É uma forma de o investidor se proteger contra os efeitos das oscilações de preço”.

83.9. Incoterms

Para facilitar a administração de conflitos em matéria de comércio internacional, a Câmara de Comércio Internacional (CCI) criou em 1936 os incoterms (International Commercial Terms) que, na data de hoje, somam treze siglas que representam, de forma abreviada, os usos frequentes das cláusulas de custos da entrega da mercadoria, adotadas no mercado

internacional.

Divididos em quatro grupos, os incoterms permitem conhecer, desde logo, as cláusulas convencionadas pelas partes, entre o mínimo de responsabilidade do vendedor pela Saída (E, de exit) até o máximo de obrigações pela entrega ao comprador (D, de delivery). No meio-termo estão os casos de incumbência ou não pelo transporte principal (F, de free, sem custo, ou C, de cost, com custo).

Grupo	Sigla	Significado	Despesas e Riscos
E	EXW	Ex works – a mercadoria é retirada do estabelecimento do vendedor. Neste momento ocorre a tradição ao comprador que passa a correr os riscos até o local de produção.	Desde a retirada, as despesas e riscos são do comprador.
F	FCA	Free carrier – o vendedor deve desembaraçar a mercadoria para a exportação.	O vendedor é responsável até o momento em que a mercadoria é levada à saída do País, inclusive pelo desembarço alfandegário. Elemento comum: o transporte principal não é pago pelo vendedor.
	FAS	Free Alongside Ship – o vendedor deve colocar a mercadoria ao lado do navio, no cais do porto. Este é o momento da tradição da mercadoria, correndo riscos pelo comprador a partir daí.	
	FOB	Free On Board – o vendedor deve colocar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador. A tradição da mercadoria se dá no navio, a partir do que os riscos são do comprador.	
	CFR	Cost and Freight – os custos de embarque e de frete são de responsabilidade do vendedor. Os riscos da mercadoria a bordo são do comprador. É exclusivo para transporte marítimo ou fluvial doméstico.	O vendedor é
		Cost, Insurance and Freight – amplia-se a obrigação do vendedor para incluir o seguro marítimo até a chegada. A tradição é feita no navio e, assim, os	

C	CIF	riscos da mercadoria a bordo são do comprador. É exclusivo para transporte marítimo ou fluvial doméstico.	responsável até o porto de destino. Elemento comum: o transporte principal é pago pelo vendedor.
	CPT	Carriage Paid To – o vendedor é obrigado ao frete até o local do destino e o comprador assume o ônus dos riscos, a partir do momento em que a transportadora, no país de destino, assume a custódia das mercadorias.	
	CIP	Carriage and Insurance Paid To – idêntico ao CPT, salvo quanto ao custo do seguro que deve ser pago pelo vendedor.	
D	DAF	Delivered At Frontier – a entrega é feita em ponto anterior ao da alfândega e desembarcada para exportação. Cabem ao comprador as providências até seu estabelecimento.	Elemento comum: a responsabilidade do vendedor estende-se até a chegada.
	DES	Delivered Ex-Ship – o vendedor deve colocar, à sua custa, a mercadoria no porto de destino. Somente para transporte marítimo.	
	DEQ	Delivered Ex-Quay – as despesas até o desembarque são do vendedor, inclusive direitos de exportação e taxas, à disposição do comprador.	
	DDU	Delivered Duty Unpaid – a mercadoria é entregue dentro do país do comprador, obrigando-se pelas despesas o vendedor, exceto os impostos e encargos de importação.	
	DDP	Delivered Duty Paid – a mercadoria é entregue livre ao comprador. O vendedor assume todos os riscos e custos até a entrega.	

84. Arrendamento mercantil (leasing)

84.1. Definição legal

O arrendamento mercantil foi inicialmente regulado pela Lei n. 6.099, de 12 de setembro de 1974, que o definiu como “negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta” (art. 1º, § 1º, com a redação que lhe deu a Lei n. 7.132, de 26-10-1983).

Posteriormente, a Resolução n. 2.309, de 28 de agosto de 1996, do Banco Central do Brasil, aprovou regulamento que disciplinou a modalidade de arrendamento mercantil operacional, autorizou a prática de operações de arrendamento mercantil com pessoas físicas em geral e consolidou normas a respeito de arrendamento mercantil financeiro, vindo a ser alterada pela de n. 2.659, de 28 de outubro de 1999, que modificou a redação do art. 7º, e a de n. 3.175, de 20 de fevereiro de 2004, que deu nova redação ao art. 9º.

De observar que a Lei n. 6.099/74 disciplina o tratamento tributário e remete, em inúmeros dispositivos, a regulamentação de aspectos operacionais ao Conselho Monetário Nacional que, por sua vez, o faz por atos exarados pelo Banco Central do Brasil, mencionados neste estudo.

84.2. Objeto

O contrato de arrendamento assegura ao arrendatário tríplice opção (continuar o arrendamento, terminá-lo ou comprar o bem). Para Waldirio Bulgarelli (1997a:374), o leasing envolve uma operação que se desdobra em cinco fases: a) a proposta do arrendatário à arrendadora ou vice-versa; b) o acordo de vontade entre ambas; c) a aquisição, pela arrendadora, do bem ajustado com o arrendatário; d) a arrendadora entrega o bem ao arrendatário; e e) o exercício, pelo arrendatário, de tríplice opção:

“continuar o arrendamento, dá-lo por terminado, ou adquirir o objeto do arrendamento, compensando as parcelas pagas a título de arrendamento e feita a depreciação”.

No arrendamento mercantil, a coisa está em poder do arrendatário apenas como alugada, e, contratualmente, pertence ao arrendador.

84.3. Modalidades

São conhecidas cinco modalidades de leasing, sendo a mais comum a denominada financial lease ou arrendamento financeiro, ou, ainda, “leasing” bancário, que consiste na operação feita por instituição financeira, que, na qualidade de arrendador, adquire o bem do fabricante e o entrega, mediante pagamento de parcelas previamente ajustadas, para uso do arrendatário por prazo determinado, ao final do qual este terá o direito de proceder à tríplice escolha. Se o arrendatário rescinde o contrato antecipadamente, obriga-se a pagar as prestações vincendas.

A caracterização dessa modalidade encontra-se nos arts. 5º e 8º da Resolução n. 2.309/96: a) as contraprestações e demais pagamentos devidos pela arrendatária são normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos; b) a arrendatária responsabiliza-se pelas despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado; c) o preço para o exercício da opção de compra é livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado; d) o prazo mínimo de arrendamento deve ser de dois anos entre a data da entrega dos bens e o vencimento da última prestação, para os bens com vida útil igual ou inferior a cinco anos e de três anos para outros bens.

A segunda modalidade – arrendamento operacional – é definida pelo art. 6º da Resolução n. 2.309/96 e alterações (a Resolução n. 2.465/98 alterou

o art. 6º; a n. 2.659/99, o art. 7º; a de n. 3.175/2004, o art. 9º), e se caracteriza pela ênfase no caráter locatício da operação, tanto que o arrendatário pode rescindir o contrato antecipadamente, sem obrigar-se ao pagamento das prestações vincendas.

Permite-se, ainda, que assistência técnica seja de responsabilidade tanto da arrendatária como da arrendadora. Exige-se, entretanto, que as operações desta natureza sejam realizadas privativamente por bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e por sociedades de arrendamento mercantil (art. 6º, § 1º, da Resolução n. 2.465/98).

Por força da Resolução n. 2.309/96, as sociedades de arrendamento mercantil serão sempre sociedades anônimas e deverão ostentar na denominação social a expressão "arrendamento mercantil". A respeito das operações dessas instituições, o glossário do Banco Central do Brasil acrescenta, ainda: "As operações passivas dessas sociedades são emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Suas operações ativas são constituídas por títulos da dívida pública, cessão de direitos creditórios e, principalmente, por operações de arrendamento mercantil de bens móveis, de produção nacional ou estrangeira, e bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins de uso próprio do arrendatário. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil" ⁴.

As características do arrendamento operacional (arts. 6º e 8º) são: a) as contraprestações devem contemplar o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o total dos pagamentos da espécie ultrapassar 90% do custo do bem arrendado; b) o prazo contratual deve ser inferior a 75% do prazo de vida útil econômica do bem; c) as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado ficam a cargo da arrendadora ou da arrendatária; d) o preço para o exercício da opção de compra é o valor de mercado do bem arrendado; e) o prazo

mínimo de arrendamento deve ser de noventa dias.

A terceira modalidade é o renting, que deu origem ao “leasing” operacional. O renting é, na verdade, o verdadeiro “leasing” operacional que, entretanto, ao ser disciplinado pela Resolução n. 2.309/96, não foi recepcionado em sua estrutura original.

No renting não há intermediários, o arrendamento é feito diretamente do fabricante, que se compromete a prestar assistência técnica ao bem arrendado. A Lei n. 6.099/74, embora não proíba sua contratação, afastou-a de se beneficiar do tratamento tributário diferenciado instituído a favor das outras modalidades. É o que dispõe o art. 2º: “Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens (...) contratado com o próprio fabricante”.

Leaseback, ou arrendamento mercantil de retorno, é a operação prevista nos arts. 13 e 14 da Resolução n. 2.309/96, sempre de cunho financeiro (não operacional), que envolve, de um lado, compra e venda ou dação em pagamento e, de outro, locação desse mesmo bem, figurando como contratantes o proprietário anterior e o novo adquirente. Nesta modalidade o proprietário, necessariamente pessoa jurídica, vende ou dá em pagamento o bem de sua propriedade e, simultaneamente, o arrenda do adquirente.

Self-leasing, ou arrendamento consigo mesmo, é aquele em que a arrendatária e a arrendadora confundem-se entre pessoas vinculadas de um mesmo grupo econômico. Da mesma forma que o renting, a Lei n. 6.099/74 o excluiu do tratamento tributário especial: “Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante”. Para o conceito de empresas coligadas, veja o item 7, “i”, supra.

85. Alienação fiduciária em garantia

85.1. Conceito

Segundo Orlando Gomes (2008:567), o contrato de alienação fiduciária conceitua-se como sendo “o negócio jurídico pelo qual o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, normalmente retendo-lhe a posse direta, sob a condição resolutiva de saldá-la”.

Previsto inicialmente na Lei do Mercado de Capitais (Lei n. 4.728, de 14-7-1965), que lhe reservou tão somente o art. 66, o contrato tinha por escopo dar garantia real aos contratos de abertura de crédito para a aquisição de bens móveis por parte do consumidor. Sua redação atual foi determinada pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969. Posteriormente, a Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel.

85.2. Objeto

Pelo mecanismo legal, na alienação fiduciária em garantia o devedor transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem. O alienante – devedor – passa a ser possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem. No caso de imóveis, a propriedade fiduciária é constituída mediante registro do contrato, no Cartório de Registro de Imóveis.

O domínio definitivo encontra-se sob condição resolutiva, daí por que a lei utiliza a expressão “domínio resolúvel”, visto tratar-se de domínio que jamais será pleno, nem tampouco definitivo. O credor possui uma propriedade restrita e transitória, enquanto não ocorrer a condição resolutiva. A condição resolutiva é uma garantia ao devedor: paga a dívida, ele readquire o pleno domínio sobre a coisa adquirida.

Na condição resolutiva, “enquanto esta se não realizar, vigorará o

negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido” (CC, art. 127) e “sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé” (CC, art. 128).

O credor – também chamado financiador – empresta determinada importância ao devedor – denominado financiado – que, por sua vez, com o dinheiro obtido dessa operação, adquire um bem e, ato contínuo, o transfere, em garantia da primeira operação, a seu financiador. O interesse deste último é receber o que lhe é devido e, quando isto ocorre, perde ele a propriedade do bem a favor do devedor, também chamado financiado, fiduciante ou alienante.

Aquele que recebe o financiamento – o devedor – aliena a coisa a favor do financiador, em garantia do pagamento da dívida, caracterizando eficientemente o contrato: o bem é garantia do dinheiro entregue ao devedor.

86. Contratos bancários

Inúmeros são os contratos em que uma instituição bancária pode figurar como uma das partes contratantes. Entre as operações mais comuns, nos limites desta obra serão citados o depósito bancário, o desconto e o redesconto e o empréstimo.

86.1. Depósito bancário

Segundo Maria Helena Diniz (2006:692), “depósito bancário é a operação bancária em que uma pessoa física ou jurídica entrega determinada importância em dinheiro, com curso legal no país, a um banco, que se

obrigará a guardá-la e restituí-la quando for exigida, no prazo e nas condições ajustadas”.

Quanto à movimentação, os depósitos podem ser: a) à vista: o contrato que permite a livre movimentação pelo depositante, isto é, seu saque parcial ou total a qualquer tempo; b) depósito de pré-aviso ou de aviso prévio: aquele que, para seu levantamento, exige anterior comunicação ao banco sacado; c) de prazo fixo: são aqueles em que as retiradas submetem-se a termos certos.

86.2. Desconto e redesconto

As operações de desconto e de redesconto referem-se a títulos de crédito.

No desconto, o cliente transfere ao banco título, de sua emissão ou de terceiro, ainda não exigível, recebendo determinada quantia que corresponde à antecipação de seu crédito, deduzidos juros e comissões remuneratórios da operação. Obriga-se o descontante pela solvabilidade dos títulos cedidos.

Redesconto é a operação realizada por instituição bancária que, recebendo títulos de seus clientes, em operações de desconto, realiza nova circulação em outros bancos, antecipando disponibilidades financeiras.

86.3. Empréstimo bancário

Mútuo bancário é o empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir ao banco mutuante a quantia recebida, no prazo contratado, acrescida de juros e encargos pactuados.

O mútuo bancário não difere o mútuo comum, regendo-se por regulamentação própria e disposições do Código Civil, arts. 586-592. Não vige, contudo, no mútuo bancário, a limitação da taxa de juros que, por força do art. 406 do Código Civil, não pode ultrapassar a taxa que estiver

em vigor para a mora do pagamento de impostos à Fazenda Nacional (12% ao ano).

Os juros bancários não encontram limitação, podendo ser pactuados livremente pelas partes. Sofrem, contudo, restrição quanto à forma de cobrança, sendo vedada sua capitalização mensal (Súmula 121 do STF). A MP n. 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, em seu art. 5º, dispôs de forma diversa, admitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. A matéria é ainda objeto de interpretação jurisprudencial.

87. Faturização (factoring ou fomento mercantil)

A Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que alterou a legislação tributária federal, definiu o contrato de faturização na alínea c.4 do § 1º do art. 28, com a seguinte redação: “prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)”.

Essa norma tributária federal sofreu duas alterações posteriores, no mesmo ano de 1995, decorrentes da promulgação das Leis n. 9.065 e 9.249. Esses dois diplomas introduziram modificação na base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (de 30% originais para 10% e 32%, respectivamente), sem modificar a definição de factoring, reproduzida, respectivamente, em seus arts. 10, § 1º, d, e 15, § 1º, III, d.

Pela definição, a empresa de faturização tem tríplice objetivo: a) dar assessoria (de crédito e mercadológica); b) administrar (créditos e riscos e a carteira de contas a pagar e a receber); c) comprar direitos creditórios resultantes de vendas.

As empresas de factoring não são instituições financeiras e, portanto, não podem exercer as atividades tipicamente bancárias (intermediação ou

aplicação de recursos financeiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros), sendo-lhes vedado, por esta razão, conceder empréstimos ou descontar títulos. Nesse sentido, o STJ decidiu recentemente: "As empresas de factoring não se enquadram no conceito de instituições financeiras, e por isso os juros remuneratórios estão limitados em 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura" (REsp 1.048.341/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, julgado em 10-2-2009, DJe, 9-3-2009).

Embora o objetivo principal seja o último mencionado, o contrato de factoring traz as duas outras feições que, somadas, traduzem-se numa só palavra: trustee, "gestão financeira de negócios, por intermédio do acompanhamento das contas a receber, das contas a pagar e da cobrança de títulos de crédito" (Arnaldo Rizzardo, 2004:86).

Segundo Fran Martins (1993(b):570), são cláusulas essenciais do contrato as relativas à: a) exclusividade ou totalidade das contas do faturizado; b) duração do contrato; c) faculdade de o faturizador escolher as contas que deseja garantir; d) liquidação dos créditos; e) cessão dos créditos; f) assunção de riscos pelo faturizador; g) remuneração do contrato.

A compra de créditos no fomento mercantil opera-se pela cessão de créditos e por endosso dos títulos a favor do fomentador (faturizador).

No caso de cessão, aplicam-se as regras próprias à transmissão das obrigações previstas nos arts. 286-298 do Código Civil: a) para ter validade em relação a terceiros, deve ser celebrado por instrumento público ou particular (art. 288); b) o devedor deve ser notificado (art. 289); c) completa-se com a tradição do título cedido (art. 291); d) se o devedor pagar ao credor primitivo antes de tomar conhecimento da cessão, fica desobrigado perante o cessionário (art. 292); e) o devedor pode opor ao cessionário exceções que tenha contra o cedente (art. 294); f) o cedente é responsável pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu (art. 295); g) o cedente não responde pela solvência do devedor, salvo

estipulação em contrário (art. 296) e, neste último caso, limitadamente ao quantum recebido, acrescido de juros e despesas da cessão e de cobrança (art. 297).

No endosso, o endossatário titulariza-se do direito de crédito que, contudo, recebe contornos distintos no contrato de faturização.

O factoring configura-se negócio complexo que não se identifica com a simples cessão e, tampouco, com o instituto do endosso, mas reveste-se de ambas, somadas ao objeto de financiamento da empresa ou de sua gestão financeira.

É permitido ao faturizador selecionar os créditos quando da apresentação das faturas pela empresa emitente dos títulos, ocasião em que assume o risco com a operação, não tendo, contra a faturizada, direito de regresso. Ao aceitar o título apresentado pelo faturizado, assume, de forma exclusiva, o risco pela solvência do sacado, não podendo transferir essa obrigação àquele, que se obriga tão somente quanto à existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu (CC, art. 295).

Na compra de créditos pela fomentadora, o endosso, por força do contrato, traz cláusula especial “sem garantia”, isto é, o endossante se desobriga a garantir o pagamento da letra (LUG, art. 15, segunda alínea).

Questão importante refere-se à obrigação da emitente do título (empresa fomentada, sacadora da duplicata cedida ao factor): dissemos que ela não é obrigada pela solvência do sacado e, neste caso, isentando-a do pagamento do título, não haveria violação do art. 9º do Anexo I da LUG, aplicável por força do art. 25 da Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474/68), in verbis: “O sacador é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O sacador pode exonerar-se da garantia da aceitação; toda e qualquer cláusula pela qual ele se exonere da garantia do pagamento considera-se como não escrita”?

Arnaldo Rizzardo (2004:104-105) sustenta o afastamento do emprego de princípios cartulares à operação de fomento:

“(...) O Decreto n. 2.044, e assim a Lei n. 5.474, bem como a Lei Uniforme de Genebra sobre letras de câmbio e notas promissórias, disciplinam a emissão e circulação de títulos de crédito não ligados ou utilizados em figuras distintas. Surgindo o factoring dentro de suas características peculiares, impõe o respeito e a obediência segundo o seu conteúdo. Não é admissível utilizar instrumentos ou princípios de outros institutos dentro do significado com o qual foram criados”.

“Nesta linha, impossível o endosso utilizado para a livre circulação de títulos, e manter seu significado e o tratamento previstos em leis especiais. Já que um mecanismo jurídico diferente apareceu, não se pode vê-lo como uma sombra, ou simbiose, ou remodelação de institutos que possuem a individualidade própria. Novas definições e componentes jurídicos apareceram, com a necessidade de desvinculação dos conceitos de figuras antigas e paralelas. A garantia do pagamento que acompanha a transferência pelo titular do crédito pode deixar de existir em situações diferentes do simples endosso. No factoring, há compra de crédito, ou do ativo de uma empresa, e não apenas de títulos. Não se opera o simples endosso, mas a negociação do crédito. Há uma individualidade própria, um conteúdo mais extenso que o mero endosso, ou a simples cessão de crédito”.

Trata-se, portanto, de contrato jurídico que não respeita de forma plena os princípios cartulares, sobretudo no que se refere ao emitente-endossante. É princípio cautelar a responsabilidade do sacador e do endossante pelo aceite e pelo pagamento do título, o que não ocorre no contrato de faturização.

Em outras palavras, o faturizado – emitente das duplicatas dadas no negócio com o faturizador – responde pela validade e existência do título (exigibilidade), mas não pela solvência do sacado.

88. Transporte e seguro

Contrato de transporte é aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas (CC, art. 730), por meio terrestre, hidroviário e aéreo.

88.1. Transporte

a) Transporte de pessoas

O transporte de pessoas obriga o transportador a conduzir pessoas e suas respectivas bagagens de um ponto a outro ponto geográfico e o contrato rege-se por normas distintas, conforme o meio utilizado e o limite territorial percorrido. Há, assim, além das disposições do Código Civil (arts. 734-742), regulamentos de âmbito municipal, estadual, nacional e internacional.

As regras comuns aos contratos de transporte de pessoas estão previstas no Código Civil e podem ser resumidas nos seguintes princípios: responsabilidade objetiva, obrigação de transportar no tempo e modo contratados, proibição de recusa, obrigação de concluir o itinerário, direito de retenção e obrigação solidária pelo transporte cumulativo.

O transportador (a) responde de forma objetiva pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (arts. 734-735), (b) deve efetuar o itinerário no tempo e no modo contratados, respondendo por perdas e danos, inclusive de natureza moral, salvo motivo de força maior (art. 737), (c) não pode recusar passageiros, salvo casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem (art. 739), (d) é obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo por sua conta as despesas de estadia e alimentação da pessoa transportada, durante o período de espera (art. 741), (e) pode exercer direito de retenção sobre a bagagem e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da

passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso (art. 742), (f) no contrato de transporte cumulativo, obriga-se solidariamente pelo resultado, isto é, responde primariamente pelo percurso assumido, mas se ocorrer atraso, o dano devido aos passageiros será determinado em razão da totalidade do percurso, mesmo que tenha ingressado na relação jurídica em substituição a outro contratante (art. 733 e §§ 1º e 2º).

Observe-se que as regras incidem sobre o contrato oneroso ou àquele do qual resultam vantagens indiretas ao transportador. O transporte gratuito não se subordina às normas do contrato de transporte (art. 735), submetendo-se ao regime da responsabilidade civil subjetiva, conforme Súmula 145 do STJ: “No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave”.

Além do regramento previsto no Código Civil, o transporte de pessoas é regido por legislação extravagante, sendo a mais recente a Lei n. 11.975, de 7-7-2009, que trata da validade dos bilhetes de passagens no transporte rodoviário terrestre, estabelecendo o limite de um ano para sua validade a partir da data de emissão (art. 1º), bem como a forma objetiva pela qual se dá o reembolso (pela simples manifestação da vontade do passageiro, art. 2º), o prazo para devolução do dinheiro em caso de desistência do passageiro (trinta dias, art. 2º, parágrafo único), os prazos máximos de tolerância para atrasos e para continuidade da viagem em caso de interrupção (uma e três horas, respectivamente, arts. 3º e 4º).

b) Transporte de coisas

No transporte de coisas, o transportador obriga-se a transferir objetos individualizados pelo expedidor, do ponto de expedição até determinado local ou endereço, mediante remuneração de frete.

As regras comuns ao contrato de transporte de coisa estão previstas no Código Civil e podem ser resumidas pelos termos: identificação, expedição de conhecimento de transporte; recusa decorrente de faculdade contratual

ou de obrigação legal, permissão de desistência e modificação por parte do expedidor, zelo no cumprimento, obrigando-se a buscar novas instruções em caso de demora, obrigação de entregar ao destinatário indicado e solidariedade no contrato cumulativo.

São elas: a) necessidade de identificação da coisa e do destinatário (art. 743); b) expedição de conhecimento de transporte, com base nas informações prestadas pelo expedidor (art. 744); em caso de inexatidão ou falsidade, o expedidor responde por prejuízos causados ao transportador (art. 745); c) possibilidade de recusa de transporte de coisa embalada de forma inadequada ou que coloque em risco a saúde das pessoas ou danifique o veículo e outros bens (art. 746), bem como de coisas não permitidas à comercialização, ao transporte ou desacompanhadas de documentação obrigatória (art. 747); d) possibilidade de desistência do transporte ou mudança de destinatário, pelo expedidor, sujeitando-o, contudo, às despesas e danos que acarretar (art. 748); e) obrigação de o transportador entregar a carga no prazo ajustado ou previsto, obrigando-se desde o momento que a receber a mantê-la em bom estado até o cumprimento junto ao destinatário, respondendo por perdas e avarias (arts. 749 e 750); f) no caso de longa interrupção durante o trajeto, o transportador é obrigado a buscar instruções do expedidor. Persistindo o impedimento sem motivo imputável ao transportador e deixando o expedidor de manifestar-se, abrem-se três caminhos ao contratante: depositar a coisa em juízo ou vendê-la, depositando o valor correspondente e informando o remetente e, ainda, conservar o objeto em custódia, mediante remuneração previamente contratada ou, na sua falta, aos usos adotados (art. 753); g) obrigação de o transportador entregar a coisa ao destinatário, à pessoa que apresentar o conhecimento endossado ou, ainda, de depositá-la em juízo, quando houver dúvida acerca de quem seja o destinatário e não tiver sido possível obter instruções do remetente (arts. 754 e 755); h) no contrato de transporte cumulativo, o transportador

obriga-se solidariamente pelo resultado: o dano devido será determinado em razão da totalidade do percurso, permitido o direito de regresso de uns contra os outros (art. 756).

Facultativamente, o contrato pode prever cláusula de aviso ao destinatário ou de entrega em domicílio (art. 752).

88.2. Seguro

Definido no art. 757 do Código Civil, contrato de seguro é aquele em que “o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

A partir dessa definição legal, alguns conceitos precisam ser esclarecidos:

Prêmio é a contraprestação em dinheiro paga pelo segurado.

Risco é a possibilidade de ocorrência de evento futuro e incerto prejudicial à pessoa ou aos bens do segurado ou de terceiros beneficiários.

Segurador é sempre uma pessoa jurídica, sujeita a autorização de funcionamento pelo Poder Executivo Federal, constituída sob a forma de cooperativa ou de sociedade anônima.

a) Características

São características do contrato de seguro: a bilateralidade, a onerosidade, a sujeição a um acontecimento incerto e futuro (aleatoriedade), o oferecimento por adesão e a consensualidade. Essa última característica encontra resistência em Maria Helena Diniz, ao dizer que o contrato é formal, por ser obrigatória a forma escrita (2006:524). Entendemos que o contrato é consensual, como também sustentam Orlando Gomes (2008:505) e Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:345-346), entre outros. A prova escrita é elemento valorativo de prova e não condição para o aperfeiçoamento do contrato.

b) Apólice e bilhete de seguro

Apólice e sua forma reduzida, o bilhete de seguro, são títulos que instrumentam o contrato de seguro e devem expressar necessariamente as seguintes cláusulas essenciais: riscos assumidos, início e fim de sua validade, limite de garantia e prêmio devido.

No caso de cosseguro, a apólice deve ainda indicar o segurador que administrará o contrato e representará os demais.

A emissão da apólice se dá à ordem, nominativa ou ao portador, sendo vedada esta última no contrato de seguro de pessoas.

c) Contrato de seguro de pessoas

Regido pelos arts. 789-802 do Código Civil é o contrato de seguro em que o contratante desembolsa determinada retribuição pecuniária (prêmio) a companhia seguradora que, em contrapartida, obriga-se a pagar – ao contratante ou a terceiros beneficiários – importância de capital ou de renda na ocorrência de eventualidade contratualmente prevista.

São característicos desse seguro: a) liberdade na estipulação do capital a ser pago e a contratação de mais de um seguro sobre o mesmo interesse; b) é vedada a sub-rogação pelo segurador dos direitos e ações do segurado ou do beneficiário (em caso de morte); c) abrange acidentes pessoais, sobrevida, morte, incapacidade, invalidez, tratamento etc.; d) pode ser estipulado sobre a vida de outrem, desde que o contratante declare seu interesse pela preservação da vida de quem quer ver segurado; e) o capital estipulado no contrato de seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte não se sujeita às dívidas do segurado, nem é considerado herança; f) pode ser estipulado prazo de carência no contrato de seguro de vida para o caso de morte; g) não pode excluir o pagamento de capital para o caso de suicídio que, entretanto, não será devido se esse evento ocorrer nos primeiros dois anos de vigência ou de prorrogação; h) é vedada a transação para redução do capital.

d) Contrato de dano ou de coisas

Regulado pelos arts. 778-788 do Código Civil é o contrato de seguro que, mediante pagamento de prêmio em dinheiro, visa garantir proteção ao contratante contra riscos predeterminados relativamente às coisas de seu patrimônio. Obriga-se a seguradora a pagar indenização se o dano vier a ocorrer.

Dois princípios devem ser observados na contratação do seguro de dano: a) equivalência: a garantia deve observar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato; b) boa-fé: o segurado deve fazer declarações exatas e não omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta.

São característicos desse contrato: a) a abrangência da indenização: incluindo os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar os danos ou salvar a coisa; b) exclusão, na garantia, de vício intrínseco da coisa; c) no contrato de transporte, a vigência do seguro tem início no momento em que a coisa é recebida pelo transportador; d) permite-se a cessão a terceiro e a sub-rogação dos direitos de crédito; e) no seguro de responsabilidade civil, o segurado deve comunicar à seguradora a ocorrência de fato que possa acarretar responsabilidade incluída na garantia securitária e também quando acionado judicialmente; f) nessa modalidade deve, ainda, abster-se de reconhecer sua responsabilidade, confessar a ação, transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente, sem anuência da seguradora.

Títulos de Crédito

89. Plano de estudo

O capítulo de Direito Cambiário abrange o estudo dos títulos próprios: letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata e compreende todos os institutos aplicáveis à generalidade dos títulos de crédito: saque, aceite, endosso, aval, pagamento, apresentação, protesto, ações cambiais, prescrição e ações causais:

{	Teoria geral – itens 90-92	{	Teoria geral e institutos cambiários – item 90
		{	Leis uniformes e leis nacionais – item 91
		{	Títulos de crédito no Código Civil – item 92
{	Títulos em espécie – itens 93-96	{	Letra de câmbio – item 93
		{	Nota promissória – item 94
		{	Cheque – item 95
		{	Duplicata – item 96

90. Teoria geral e institutos cambiários

É clássico o conceito de Cesare Vivante: (apud Fran Martins, 1995: 6): “Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado”. Há, contudo, um grande número de

documentos que se regem pela normatividade dos títulos de crédito, mas não representam relação de crédito. A doutrina os denomina títulos impróprios ou atípicos.

90.1. Classificação

A doutrina classifica os títulos de crédito quanto ao modo de circulação. A chave a seguir pertence a Carvalho de Mendonça, em seu clássico Tratado de direito comercial brasileiro (1955, 5.2:58-59):

Classificação quanto ao modo de circulação	a) nominativos, se o nome da pessoa, natural ou jurídica, com direito à prestação se acha anotado no próprio título ou nos registros especiais do instituto emissor, sendo transferíveis mediante ato formal; b) à ordem, se emitidos em benefício da pessoa indicada ou daquela a que esta determinar (<i>ordenar</i>) e transferíveis por meio do endosso, neles lançado; c) ao portador, se emitidos genericamente em favor do possuidor e transferíveis por simples tradição manual; d) mistos: títulos <i>nominativos</i> munidos de <i>cupões ao portador</i>.
--	--

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:389), contudo, distingue os títulos em (a) ao portador e (b) nominativos, subdividindo estes em “à ordem” e “não à ordem”, justificando que para o direito brasileiro não faz sentido separar os títulos à ordem dos títulos nominativos, como ocorre na Itália, onde há previsão legislativa.

Outra classificação refere-se ao conteúdo dos títulos. Pupo Correia (1999:106-108) visualiza, neste tópico, três ordens de categorias:

a) títulos de crédito propriamente ditos: letras de câmbio, livrança (nota promissória), extratos de fatura (duplicatas), obrigações (debêntures), papel comercial, certificados de depósito e títulos de participação (que, em Portugal, pelo Decreto-Lei n. 321/85, conferem remuneração pecuniária, que inclui participação nos lucros da empresa – no Brasil são chamados partes beneficiárias);

b) títulos representativos: são os que incorporam direitos sobre determinadas coisas: conhecimento de depósito e warrant, guia de transporte, conhecimento de carga ou de embarque, guia de transporte

aéreo;

c) títulos de participação social: as ações.

Enfim, outras classificações são possíveis:

a) Quanto ao emitente: os títulos podem ser públicos (apólices, letras do tesouro, títulos da dívida pública etc.) ou privados, quando emitidos por pessoas naturais ou jurídicas no interesse de seus negócios.

b) Quanto à causa subjacente ou à relação fundamental, dividem-se em causais, os que se ligam a uma relação jurídica criadora, e abstratos, os que, desde a criação, abstraem a causa inicial.

c) Quanto à nacionalidade: nacionais e estrangeiros.

d) Quanto ao prazo: à vista e a prazo.

e) Quanto ao número: individuais e seriados.

f) Quanto às leis que os regem: bancários, cambiais, imobiliários, rurais, cooperativos, acionários etc.

90.2. Títulos regulamentados no direito brasileiro

Uma lista não exaustiva dos títulos, típicos ou atípicos, conhecidos pode ser visualizada no seguinte quadro:

DENOMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Ações	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Bilhete de Mercadoria	Lei n. 165-A, de 17 de janeiro de 1890 (art. 4º). Lei n. 4.829, de 5 de novembro de 1965 (art. 25, V). Observação: no Decreto s/n, de 25 de abril de 1991, que trata de reconhecimento de cursos superiores, foi introduzido o art. 4º, que declarou revogados milhares de decretos relacionados em seu anexo, incluindo a Lei n. 165-A. Contudo, não há menção da revogação da Lei n. 4.829/65.
Bônus de	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Subscrição	
Cédula de Crédito à Exportação	Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975.
Cédula de Crédito Bancário	Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.
Cédula de Crédito Comercial	Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980.
Cédula de Crédito Industrial	Decreto-Lei n. 413, de 9 de janeiro de 1969.
Cédula de Produto Rural – CPR	Lei n. 8.929, de 22 de agosto de 1994.
Cédula Hipotecária	Decreto-Lei n. 70, de 21 de novembro de 1966, e Resolução n. 228, de 4 de julho de 1972, do Bacen.
Cédula Pignoratícia de Debêntures	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Cédula Rural Hipotecária	Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Cédula Rural Pignoratícia	Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária	Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Certificado de Depósito Agropecuário – CDA	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.

Certificado de Depósito Agropecuário Cooperativa CDA	de de –	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Certificado de Depósito Bancário	de	Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965 (art. 30).
Certificado de Depósito de Ações	de de	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Certificado de Depósito de Partes Beneficiárias	de de	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Certificado de Depósito Garantia	de em	Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965 (art. 31).
Certificado de Direitos Creditórios Agronegócio CDCA	de do –	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Certificado de Investimento	de	Resolução n. 145, de 14 de abril de 1970.
Certificado de Recebíveis Agronegócio CRA	de do –	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Cheque		Decreto n. 57.595, de 7 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme), e Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985.

Conhecimento de Depósito	Decreto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903 (art. 15).
Conhecimento de Depósito de Cooperativa	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Debêntures	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Duplicata de Prestação de Serviços	Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.
Duplicata Escritural	Lei 13.775, de 20 de dezembro de 2018.
Duplicata Mercantil	Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.
Duplicata Rural	Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Extrato de Registro Eletrônico de Duplicata Escritural	Lei 13.775, de 20 de dezembro de 2018.
Fatura ou Conta de Serviços	Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.
Letra de Arrendamento Mercantil	Lei n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008 (art. 2º).
Letra de Câmbio	Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (art. 1º), alterado pelo Decreto 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme).
Letra de Crédito	

do Agronegócio – LCA	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Letra de Crédito Imobiliário – LCI	Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.
Letra Hipotecária	Lei n. 7.684, de 2 de dezembro de 1988.
Letra Imobiliária	Lei n. 4.830, de 21 de agosto de 1964.
Nota de Crédito Rural	Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Nota de Crédito à Exportação	Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975.
Nota de Crédito Comercial	Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980.
Nota de Crédito Industrial	Decreto-Lei n. 413, de 9 de janeiro de 1969.
Nota Promissória	Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (arts. 54-56), alterado pelo Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme, arts. 75-78).
Nota Promissória Rural	Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Partes Beneficiárias	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Warrant	Decreto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903 (art. 15).
Warrant Agropecuário	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Warrant de Cooperativa	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.

Warrant Agropecuário de Cooperativa	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
-------------------------------------	---

90.3. Princípios

Decorrem da definição legal (CC, art. 887 – “O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”) as três características essenciais dos títulos de crédito: a cartularidade ou incorporação (documento necessário), a autonomia (direito autônomo nele contido) e a literalidade (direito literal nele contido).

a) Cartularidade

A cartularidade ou incorporação invoca a necessidade ou indispensabilidade, isto é, sem o documento não se exerce o direito de crédito nele mencionado. A pessoa detentora do título – de boa-fé – é reconhecida como credora da prestação nele incorporada e, inversamente, sem a apresentação do título não há como obrigar o devedor a cumprir a obrigação inscrita no título.

b) Autonomia

A autonomia é a característica dos títulos de crédito que garante a independência obrigacional das relações jurídicas subjacentes, simultâneas ou sobrejacentes à sua criação e circulação e impede que eventual vício existente em uma relação se comunique às demais ou invalide a obrigação literal inscrita na cártula.

Para se compreender este princípio e seus principais efeitos, convém lembrarmos que sempre existe uma causa – um fato jurídico – que dá origem à criação do título, como, por exemplo, um mútuo que contratamos com um banco. Recebemos o dinheiro emprestado e emitimos uma nota promissória com vencimento marcado para uma data futura.

Esta primeira causa é chamada de causa subjacente ou simultânea ao nascimento, isto é, originária do título e só interessa ao mutuário e ao banco que com ele contrata.

Circulação é o ato em que o banco endossa o título, transmitindo o direito de crédito, a outra pessoa (natural ou jurídica). Neste momento emerge uma das consequências da autonomia – a abstração –, isto é, o título se liberta da causa subjacente, ganha independência do negócio jurídico inicial. Pode haver aqui outra causa, outra relação jurídica. Por exemplo: o Banco “A” com quem contratei o mútuo, pela transmissão do crédito, com o endosso do título, está quitando uma dívida com fornecedores de móveis “B” para a agência situada em outra cidade.

Esta segunda causa – sobrejacente ou causa posterior à emissão – interessa apenas ao banco e ao fornecedor de móveis “B”.

Ao fornecedor de móveis, por sua vez, pode interessar o desconto do título junto a uma outra instituição financeira que lhe adiantará o numerário, mediante a entrega do título por novo endosso. Este terceiro negócio tem a natureza de mútuo e interessa somente ao fornecedor de móveis e à instituição financeira “C”.

Como se vê, as causas (mútuo, fornecimento de móveis e desconto) de emissão e de circulação são distintas e as relações decorrentes são independentes umas das outras.

Uma segunda consequência deriva da independência das relações jurídicas e da abstração das obrigações umas das outras: a inoponibilidade das exceções pessoais contra o portador de boa-fé (LUG, art. 17).

Anotamos que as expressões aqui utilizadas, “independência” e “abstração”, possuem correspondentes homógrafos, cujos significados, contudo, referem-se a classificações dos títulos de crédito. Independentes ou completos são os títulos que contêm “tudo aquilo ou só aquilo que a lei determina” (Eunápio Borges, 1975:13) e abstratos refere-se aos que não se

menção na emissão a causa, em oposição a títulos causais, como a duplicata, por exemplo.

Por força da **abstração** as obrigações mantêm-se independentes umas das outras e em decorrência da **inoponibilidade** das exceções pessoais os devedores não podem alegar vícios e defeitos de suas relações jurídicas contra o portador de boa-fé que não participou desse negócio jurídico.

c) Literalidade

A literalidade, na linguagem de Carvalho de Mendonça (1955, 5.2:52), “determina o seu conteúdo e a sua extensão”; é, portanto, medida do direito inscrito no título. O que está escrito é exatamente a quantidade do crédito do portador e a extensão da obrigação do devedor. Nem o primeiro pode exigir mais, nem o segundo deverá pagar além do que está escrito. Por este princípio implica dizer que vale o que está escrito e que, se algo diverso tiver sido contratado, não estando escrito no título, não pode ser alegado pelas pessoas intervenientes em defesa de seus direitos.

Consequências práticas encontram-se nas legislações que regulam os títulos de crédito ao exigir estrita obediência à formalidade de sua criação e, ainda, a determinar que as obrigações subsequentes sejam lançadas na própria cártula, como, por exemplo, o endosso “deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta – anexo” (LUG, art. 13) e “transmite todos os direitos emergentes da letra” (LUG, art. 14); “o aceite é escrito na própria letra” (LUG, art. 25); o aval é “escrito na própria letra ou numa folha anexa” (LUG, art. 30); o pagamento parcial deve ser mencionado no título (LUG, art. 39); o coobrigado que pagar a letra pode riscar o seu endosso ou dos endossantes subsequentes (LUG, art. 50); “o aceite por intervenção será mencionado na letra” (LUG, art. 57).

Em todos esses casos a lei exige a inscrição da operação cambial na própria cártula porque desse ato é que se extraem o crédito, sua modalidade e tratamento jurídico, o quantum exigível, quem está obrigado a pagar e, ainda, a existência ou não de direito de crédito de uns contra os

outros, conforme ordem de intervenção lançada no título.

91. Leis uniformes e leis nacionais

Coexistem no Direito Cambiário brasileiro as leis nacionais e a Convenção de Genebra para a uniformização das letras de câmbio e notas promissórias. Em regra, a lei posterior (Lei Uniforme de Genebra) prevalece. Entretanto, quando ocorre colidência entre a LUG e as leis nacionais, deve-se verificar a existência de reserva do legislador pátrio.

Quanto às letras e notas promissórias, o Brasil fez expressa reserva dos arts. 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 do Anexo II, que se refere expressamente às seguintes matérias:

ART.	MATÉRIA	SOLUÇÃO BRASILEIRA
2º	SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA Permite ser suprida a falta de assinatura, desde que por uma declaração autêntica escrita na letra se possa constatar a vontade daquele que deveria ter assinado.	A simples assinatura, de próprio punho ou por mandatário especial, é suficiente para obrigar no título, conforme decorre da lei brasileira (arts. 1º, V, 8º, 11 e 14 da LS).
3º	LETRA INCOMPLETA Faculdade de a lei nacional inserir o art. 10 que, por sua vez, não admite a possibilidade de o devedor opor-se ao portador em razão de a letra ter sido completada contrariamente aos acordos realizados, salvo se o portador a adquiriu de má-fé ou tenha cometido falta grave nessa aquisição.	A lei brasileira considera que os requisitos foram lançados no tempo de sua emissão, podendo o devedor fazer prova de má-fé do portador (art. 3º da LS).
	EFEITOS DA NÃO APRESENTAÇÃO DA LETRA NO DIA DE VENCIMENTO	O art. 20 da lei brasileira determina que se faça a apresentação da letra no dia do vencimento, salvo se cair em feriado, quando então deverá ser apresentada no primeiro dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de

5º	O art. 38 determina que a letra pagável em dia fixo ou a certo termo da data ou de vista deve ser apresentada no dia do vencimento ou num dos dois dias úteis seguintes. O art. 5º do Anexo II acrescenta: “a inobservância desta obrigação só acarreta responsabilidade por perdas e danos”.	regresso contra o sacador, endossadores e avalistas. Os efeitos, portanto, entre o que dispõe a LUG (art. 38) e a LS (art. 20) são distintos, prevalecendo, em razão da reserva, este último, salvo se o pagamento deve ser realizado no exterior, ocasião em que se impõe a regra da Lei Uniforme.
6º	CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO O art. 6º remete à cada legislação nacional a definição das instituições que devam ser consideradas câmaras de compensação, para cumprimento do art. 38, parte final: “a apresentação da letra a uma câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento”.	Cabe ao Brasil determinar quais as instituições devem funcionar como câmaras de compensação.
7º	CLÁUSULA RELATIVA À EMISSÃO E AO PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA O art. 41 permite a inclusão de cláusula de conversão cambiária na letra e, ainda, cláusula de pagamento efetivo em moeda estrangeira.	A legislação brasileira veda a estipulação em moeda estrangeira, salvo em alguns casos e não permite a inclusão de cláusula de pagamento efetivo nessa moeda.
9º	MOMENTO DO PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO O art. 44 regula o prazo e o modo que o protesto deve ser tirado, determinado nas suas alíneas que (1) é o ato que comprova a recusa de aceite ou de pagamento; (2) o protesto por recusa de aceite e de pagamento de título vencível à vista deve ocorrer nos prazos fixados para a apresentação; (3) se por falta de pagamento, pode ser feito nos dois dias úteis seguintes; (4) o protesto por falta de aceite dispensa tanto a apresentação a pagamento como também a prova de protesto por falta de pagamento; (5) é necessária a apresentação do título ao sacado para pagamento, depois de feito o protesto; (6) a falência do sacado ou do aceitante promove o vencimento do	A reserva brasileira permite a apresentação para protesto da letra no mesmo dia de vencimento, embora esta pareça não ter sido a pretensão brasileira que mantinha, por tradição (art. 28 da LS), proibição nesse sentido (Fran Martins, 1995: 69-70).

	título e dá ao portador do título o direito de exercer o direito de ação. A reserva do art. 9º permite à lei nacional fixar que o protesto por falta de pagamento se faça no dia do vencimento ou num dos dois dias úteis seguintes.	
10	EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO EM ALGUMAS SITUAÇÕES A reserva do art. 10 permite à lei nacional determinar as situações das alíneas 5 e 6 do art. 44: (5) se é necessária a apresentação do título ao sacado para pagamento, depois de feito o protesto; (6) se a falência do sacado ou do aceitante promove o vencimento do título e dá ao portador do título o direito de exercer o direito de ação. Além disso, permite que legisle sobre a matéria do art. 43, alíneas 2 e 3, isto é, quanto ao exercício do direito de ação contra os coobrigados nos casos de suspensão de pagamentos, falência ou execução frustrada de sacado (aceitante ou não) e nos casos de falência de sacador de letra não aceitável.	A lei brasileira regula os casos de falência do aceitante (LS, art. 19, II). A reserva, contudo, menciona direito de regresso contra os coobrigados em outras hipóteses no art. 43, alíneas 2 e 3: • falência do sacado (aceitante ou não); • suspensão de pagamentos do sacado; • execução frustrada do sacado; • falência do sacador de uma letra não aceitável (art. 43, alínea 3) O direito brasileiro desconhece o critério de suspensão de pagamentos, moldando a insolvência por outros critérios, todos dependentes de decisão judicial – declaração de insolvência civil ou falência do empresário. Só é relevante para o direito brasileiro a falência do sacado, quando este aceita o título, daí a norma contida no art. 19, II, da LS. O fato de o sacado que não aceitou ou o sacador se-
		rem declarados falidos em nada altera os prazos contidos no título, que se regerão pelas regras ordinárias de vencimento.

		No que se refere à letra não aceitável, isto é, a proibição de remeter a letra para o sacado aceitar, há de se discutir, no item próprio do aceite, a vigência ou não da proibição contida no art. 44, III, da lei brasileira, que considera não escrita a cláusula proibitiva da apresentação da letra.
13	TAXA DE JUROS Os arts. 48 e 49 fixam a taxa de juros de 6% ao ano. A reserva permite que a lei nacional estabeleça o montante.	No Brasil o teto está previsto no art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, que estipula a vedação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal prevista no art. 1.062 do CC de 1916, estabelecida em 6% ao ano. A partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se, quanto aos juros legais, o limite relativo à “taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406), que é a prevista no art. 161, § 1º, do CTN – 1% ao mês.
15	AÇÃO POR LUCROS ILEGÍTIMOS A reserva do art. 15 remete aos Estados subscritores da Convenção o direito de regular ação por enriquecimento indevido, no caso de perda do direito de ação ou ocorrência de prescrição, contra sacador, endossantes ou aceitante.	A ação ordinária para esse fim está prevista no art. 48 da lei brasileira.
16	OBRIGAÇÃO DE PROVISÃO DO SACADOR As questões quanto à necessidade de provisão pelo sacador à data do vencimento e sobre as relações jurídicas que serviram de base para a emissão da letra.	A lei brasileira é omissa quanto à necessidade de provisão pelo sacador, mas o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais está patente no art. 51.

17	CAUSAS DE INTERRUPTÃO OU DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO A reserva devolve à lei nacional sua regulamentação.	A quase-totalidade dos autores (veja RE 76.236 e RE 91.050/RJ) entende que o prazo prescricional é totalmente regido pelo art. 70 da LUG, isto é: • a ação contra o aceitante prescreve em 3 anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea 1);
		• a ação contra o endossador e seu avalista, em um ano da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento (LUG, art. 70, alínea 2); • a ação entre os endossantes e contra o sacador prescreve em seis meses do dia em que o endossante pagou a letra ou do dia em que foi acionado (LUG, art. 70, alínea 3). Para Fran Martins (1995:75-76), com a reserva, o quadro do art. 70 da LUG se modifica: • a ação contra o aceitante prescreve em 5 anos (LS, art. 52) da data em que a ação pode ser proposta e não em 3 anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea 1); • a ação contra o endossador e seu avalista, em 12 meses do dia do pagamento (LS, art. 52) e não em um ano da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento (LUG, art. 70, alínea 2); • a ação entre os endossantes e contra o sacador prescreve em 6 meses do dia em que o

		endossante pagou a letra ou do dia em que foi acionado, mantendo a redação do art. 70 da LUG, por falta de dispositivo na lei brasileira.
19	DENOMINAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA Reservada à lei nacional.	Dispositivo sem relevância, porque a denominação da nota promissória foi mantida no direito brasileiro.
20	EXTENSÃO DAS RESERVAS DO ANEXO II – arts. 1º a 18 – ÀS NOTAS PROMISSÓRIAS.	Aplicam-se, no que couber, as reservas às notas promissórias.

92. Títulos de crédito no Código Civil

O Título VIII do Código Civil de 2002 (arts. 887-926) é alvo de críticas da doutrina porque não rege os títulos de crédito submetidos a lei especial, isto é, todos os existentes quando da entrada em vigor do Código Civil.

É o que decorre do art. 903 do Código Civil: “Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código”, expressão que recebeu correta interpretação do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (Enunciado 52).

O regramento oferecido pelo legislador civilista restringe-se aos títulos criados a partir da entrada em vigor do Código Civil, se outra regência não lhes for determinada pela lei especial que os modelar.

Qual seria, então, a razão da inserção de uma rubrica específica a regular, no Código Civil, os títulos de crédito? Seriam meras diretivas ao legislador à criação de novos títulos? A resposta a esta segunda indagação nos parece afirmativa, sem esquecer o papel interpretativo no caso de lacuna ou omissão quanto aos títulos regulados por leis especiais.

Nesse sentido, o Enunciado 464 das Jornadas de Direito Civil: “As

disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil aplicam-se àqueles regulados por leis especiais no caso de omissão ou lacuna”.

93. Letra de câmbio

A letra de câmbio é ordem de pagamento, à vista ou a prazo. Essa concisa afirmação é suficiente para diferenciá-la de outros títulos de crédito, como, por exemplo, do cheque, que somente é emitido à vista, e da nota promissória, que não é ordem, mas promessa de pagamento.

Seis são os requisitos formais essenciais: (1) a palavra letra inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; (2) o mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada; (3) o nome daquele que deve pagar (sacado); (6) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; (7a) a indicação da data em que a letra é passada; e (8) a assinatura de quem passa a letra (sacador).

São essenciais, dependentes de complementação por equivalentes, as indicações (5) do lugar em que se deve efetuar o pagamento e (7b) do lugar onde a letra é passada. E é accidental a (4) época do pagamento.

Chama-se Teoria dos Equivalentes o tratamento que a lei provê à formalidade de época e lugar de pagamento e localidade de saque, suprimindo a ausência desses elementos:

REQUISITO AUSENTE	EQUIVALENTE
Época do pagamento	Vence-se à vista
Lugar do pagamento	Lugar ao lado do nome do sacado
Lugar de saque	Lugar ao lado do nome do sacador

93.1. Emissão em moeda estrangeira

A legislação brasileira (art. 2º do Decreto-Lei n. 857, de 11-9-1969, e art. 1º da Lei n. 10.192, de 14-2-2001) admite sejam firmados em moeda estrangeira: I – contratos e títulos referentes à importação ou exportação de mercadorias e a empréstimos; II – contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior; III – contratos de compra e venda de câmbio em geral; IV – empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; V – contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações anteriores, ainda que as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil.

Deve-se atentar, contudo, que o pagamento se faz após a conversão, em moeda nacional, na data do vencimento. A cláusula de pagamento efetivo em moeda estrangeira, prevista no art. 41 da LUG, foi objeto de reserva pelas autoridades brasileiras (art. 7º, Anexo II), o que impede sua estipulação e eficácia.

93.2. Cláusula de estipulação de juros

O sacador pode estipular, com a emissão e no próprio título, o rendimento de juros, presumindo-se, salvo indicação diversa, contados da data da emissão da letra. Essa faculdade encontra-se tão somente na criação de letras pagáveis à vista ou a um certo tempo da vista, considerando-se não escrita sua inscrição em outra espécie de letra.

A taxa de juros, escrita no título, obedece à limitação prevista no art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, que estipula a vedação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal prevista no art. 1.062 do

Código Civil de 1916, estabelecida em 6% ao ano. A partir da vigência do Código Civil de 2002, o limite relativo à “taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406), que é a prevista no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional – 1% ao mês.

Os bancos e instituições financeiras não sofrem qualquer restrição quanto aos limites de juros (Súmula 596 do STF), mas a eles também se veda contar juros sobre juros – capitalização de juros, também chamada anatocismo –, salvo anualmente (art. 4º do Decreto n. 22.626/33 e Súmula 121 do STF), ou em casos em que houver expressa autorização legal, como ocorre, por exemplo, em títulos de crédito rural, industrial e comercial.

93.3. A época do pagamento

O sacador pode indicar a época de vencimento de quatro modos: a) à vista; b) a um certo termo da vista; c) a um certo termo da data; d) pagável num dia determinado, sendo-lhe vedado sacá-la com vencimentos diferentes ou com vencimentos sucessivos, sob pena de nulidade (LUG, art. 33).

Além dessas quatro modalidades de vencimento, o título pode sofrer outras formas de vencimento não convencionais, também chamadas de formas legais de vencimento, previstas nos arts. 19 da LS e 43 da LUG: a) quando protestada pela falta ou recusa do aceite; b) pela falência do aceitante; c) pela falência do sacador nos casos de letra não aceitável. Este último caso, por reserva (Anexo II, art. 10) e falta de regulamentação brasileira, somente se aplica às letras pagáveis fora do País.

93.4. Saque

Saque é a operação de emissão da letra de câmbio.

Letra incompleta ou em branco: a letra de câmbio pode circular de forma

incompleta, isto é, sem atender a todos os requisitos exigidos pela lei, transferindo-se por endosso e sendo garantida por avais até chegar às mãos do portador. Assim emitida e assinada pelo sacador, aceita ou não pelo sacado, pode ser completada pelo credor de boa-fé, desde que o faça antes da cobrança ou do protesto, conforme entendimento jurisprudencial (Súmula 387 do STF).

Cláusulas adicionais: algumas expressões lançadas no título permitem tornar mais maleável a genérica estrutura cambial, adaptando sua emissão a determinadas situações pessoais, sendo as mais comuns: a) não à ordem: impõe a transferibilidade tão somente sob a forma e efeito de cessão de crédito, instituto tipicamente civil (LUG, art. 11); b) sem protesto: isenta o portador de promover o protesto, na falta de aceite ou de pagamento; c) juros; d) pagamento em moeda estrangeira, permitida nos casos especificados pelo legislador, vedando-se, contudo, a que imponha pagamento efetivo em moeda estrangeira; e) proibição de aceite: o sacador pode inserir cláusula de proibição de apresentação para aceite, salvo em três letras, nas quais é vedada a proibição: na vencível a certo termo da vista, em que a apresentação é obrigatória; na "domiciliada" e na pagável em localidade diversa da de domicílio do devedor; f) proibição de aceite antes de determinada data: o sacador pode preferir não proibir o aceite, mas, por outro lado, pode lhe parecer interessante estipular que a apresentação ao aceite não se efetue antes de determinada data (LUG, art. 22, alínea 3), em momento aquém ao do vencimento do título; g) sem garantia: uma outra maneira de o sacador não sofrer os efeitos da falta de aceite sem, contudo, chegar ao extremo de proibir a apresentação do título ao sacado é a possibilidade de eximir-se expressamente da garantia da aceitação da letra (LUG, art. 9º).

93.5. Aceite

Aceite é o ato de vontade materializado pela aposição de assinatura no

título, mediante a qual o sacado concorda com a ordem do sacador, tornando-se o principal responsável pelo pagamento da quantia expressa na letra de câmbio na data de seu vencimento.

Recusa do aceite: pode ser tácita, pela simples devolução do título ao portador, ou expressa, por manifestação escrita do sacado lançada no título e acarreta alguns efeitos: 1) a necessidade de o portador protestar o título no prazo legal para comprovar a falta de aceite (LUG, art. 44), sem o que perderá o direito de ação contra os endossantes e outros coobrigados (LUG, art. 53); 2) o vencimento antecipado do título, permitindo ao portador exercer seus direitos de ação antes do vencimento ordinário do título, mesmo se a recusa for apenas parcial (LUG, art. 43).

Aceite limitado é a anuência do sacado em pagar tão só parcialmente a quantia mencionada na cambial, vinculando-se, nesses limites, à obrigação cambial.

Efeitos da não apresentação para o aceite: se o portador perder o prazo para a apresentação para o aceite do título na modalidade em que ele é obrigatório – vencimento a certo termo da vista – perderá o direito de regresso contra todos os coobrigados ao título, salvo se comprovar a existência de motivo suficiente à prorrogação (LUG, arts. 53 e 54). Motivo insuperável é o decorrente de força maior, diverso de causa ligada ao interesse puramente pessoal do portador ou da pessoa encarregada da apresentação. O portador deve apresentar o título sem demora tão logo cesse a força maior. Se a circunstância impeditiva se prolongar por mais de trinta dias, ocorrerá vencimento antecipado, dispensando-se tanto a apresentação como o protesto.

Letra não aceitável: é a que traz cláusula de proibição de aceite. Pode ocorrer tão somente nas modalidades de apresentação facultativa, uma vez que a apresentação é indisputável nos casos de letra vencível a certo termo da vista e nas letras pagáveis em localidade diversa do domicílio do sacado.

93.6. Endosso

A letra de câmbio comporta três figuras: o sacador – emitente da ordem; o sacado – pessoa indicada a realizar o pagamento; e o tomador, beneficiário do título, portador originário que o recebe das mãos do sacador. A este último cabe dar início à circulação do título, tornando-se o primeiro endossante. O endossatário é a pessoa que passa a ser o beneficiário do título, seu portador. A sequência pode estender-se com a transmutação desse primeiro endossatário em segundo endossante, e assim sucessivamente.

A letra de câmbio é emitida à ordem, independentemente de cláusula expressa. É possível, entretanto, a inserção de cláusula não à ordem, tornando o título intransmissível por endosso.

O endossante pode transmitir o título pela simples aposição de sua assinatura, seguida ou não da expressão “ao portador” – neste caso faz endosso em branco que, para não se confundir com o aval, só pode ser lançado no verso do título, permitindo ao endossatário: a) preencher o espaço em branco, com o seu nome ou o de outra pessoa; b) endossar de novo a letra; c) remetê-la a um terceiro, sem endosso.

É possível, ainda, endossar em preto, bastando especificar o nome do novo beneficiário, endossatário do título.

Não há necessidade de indicar a data da operação: na omissão, presume-se ter sido lançada em data anterior ao prazo fixado para se fazer o protesto (LUG, art. 20).

A lei não admite o endosso parcial, exigindo que se o faça de fora “pura” e “simples” (LUG, art. 12). É possível, entretanto, lançar endosso acompanhado de expressões como “sem garantia, ou sem obrigação”, ambas restritivas da obrigação do endossante (LUG, art. 15), isentando-o de garantir tanto a aceitação como o pagamento da letra. O endossante pode, contudo, limitar a exclusão das obrigações a uma das isenções (sem

obrigação de aceitação; sem obrigação de pagamento).

Endossos impróprios são aqueles não traslativos de direito de propriedade, sendo conhecidos como endosso-mandato e endosso-caução. O primeiro é previsto no art. 18 da LUG. A assinatura do endossante contém a expressão “valor em cobrança”, “para cobrança”, “por procuração” ou equivalente, e, com ela, o endossante vincula-se aos endossatários tão somente com relação ao mandato ou ao serviço de cobrança que contratou. O segundo traz indicação de penhor ou em garantia: o endossante cede, em garantia real, os direitos que possui no título. A cláusula “em penhor” transfere ao endossatário a posse do título em garantia de um débito, outorgando-lhe o direito de cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível.

O endossatário que recebe o título a partir de endosso impróprio – em decorrência de mandato ou com a cláusula “em penhor”, “caução” ou equivalente –, ao lançar sua assinatura no título o faz com efeitos de mandato ao novo endossatário, o que é simples de se entender: não possuindo direitos de dispor, compete-lhe exercer todos os direitos atribuídos ao endossante anterior, à exceção do direito de transferir titularidade.

Chama-se endosso póstumo ou tardio o inscrito posteriormente ao vencimento que, assim lançado, perde seus efeitos cambiários e assume características de mera cessão civil, conforme dispõe a lei cambial brasileira (art. 8º do Decreto n. 2.044, de 1908 – Lei Saraiva).

Contudo, a LUG (art. 20) trata a matéria de forma distinta: somente assume efeitos de cessão civil o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou realizado depois de expirado o prazo de protesto.

93.7. Aval

À falta de outro termo, denomina-se aval tanto o instituto jurídico como o

ato de vontade, a obrigação (perante o credor) e a garantia (a favor de um dos devedores) resultantes dessa declaração.

A doutrina procura apresentar distintos conceitos, exaltando certas particularidades expressivas do instituto. Fran Martins prefere a visão obrigacional, Rubens Requião enfatiza a finalidade garantidora, Fábio Ulhoa Coelho elege a declaração de vontade e Pontes de Miranda (2000, 1:361) celebra as características do instituto: “vinculação típica, que é literal e expressa”.

Para nós, aval é instituto jurídico tipicamente cambiário por meio do qual alguém, signatário ou não da letra, promete o cumprimento de obrigação de pagamento de importância em dinheiro, no todo ou em parte e de forma autônoma, em posição equivalente à obrigação de um ou mais devedores integrantes do título de crédito.

Para distinguir de outros institutos cambiários, a assinatura para o aval deve ser acompanhada de expressões “bom para aval” ou fórmula equivalente, salvo se a assinatura for lançada no anverso do título, que dispensa qualquer qualificação. Desse modo, identificadas as assinaturas do sacador e do aceitante, todas as demais lançadas no anverso, sem expressão qualificadora, serão necessariamente de avalistas.

Havendo outras assinaturas, o avalista deve indicar o nome do signatário da letra a quem o aval é produzido (avalizado); se não o fizer, presume-se tenha sido oferecido ao sacador.

No verso do título, para não confundir com o endosso em branco, o aval deve ser sempre precedido da fórmula “bom para aval” ou equivalente. Como ocorre com o lançamento no anverso, a assinatura deve identificar o nome do avalizado – aval em preto, sob pena de ser considerada atribuída ao sacador do título.

Um quadro-resumo permite retratar os tipos, a posição e as expressões obrigatórias do aval:

MODO	LUGAR DE LANÇAMENTO	
	Lançado no anverso	Lançado no verso
Aval em branco	Com ou sem a expressão “por aval” ou equivalente. É sempre assinatura do avalista do sacador. Se houver várias assinaturas, excluídas as do aceitante e do sacador, todas as demais, em branco, são de avalistas do sacador.	É avalista do sacador, mas para essa conclusão é necessário que a assinatura esteja acompanhada da expressão “por aval” para não confundir-se com os endossos em branco. Havendo várias assinaturas “por aval” no verso, presumem-se dadas ao sacador.
Aval em preto	O avalista identifica a quem dá o aval. Exige a expressão “por aval” ou equivalente, para não confundir com o endosso que, “em preto”, também pode ser lançado tanto no verso como no anverso.	

Distinção entre aval e fiança:

- A fiança é negócio jurídico bilateral e, como tal, ligado a uma causa contratual; o aval é declaração de vontade cambial, abstrata.
- O aval é sempre prestado no título cambiário e se declarado fora dele não se presta à sua função.
- O fiador dispõe de benefício de ordem, como devedor subsidiário, isto é, pode exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor para depois serem executados seus próprios bens (CC, art. 827); o avalista ostenta, na linha de devedores do título, posição igual a do avalizado e, como tal, o portador pode empregar contra ele o mesmo direito que detém em relação ao avalizado, acionando-o em conjunto com aquele ou separadamente, independentemente de obediência a qualquer ordem ou excussão prioritária de bens (LUG, art. 47).
- O fiador que paga integralmente a dívida pode demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota (CC, art. 831); no aval esta situação somente ocorre em avais simultâneos, isto é, na hipótese de um mesmo devedor estar garantido por mais de um avalista.

Avais simultâneos e avais sucessivos: são simultâneos os avais prestados por várias pessoas à obrigação assumida por devedor ou devedores que se encontram na mesma posição. Avalistas simultâneos são devedores solidários e o instituto rege-se pela regra comum da solidariedade passiva (CC, arts. 275-285). São sucessivos os avais dados ao avalista do título –

aval de aval. Neste caso, a relação é tipicamente cambial e rege-se pelo Direito Cambiário: se o avalista do avalista pagar o título terá direito de regresso contra o avalizado. A norma de regência é cambial; o avalista sucessivo possui, como qualquer outro signatário de uma letra quando a tenha pago, o direito de acionar todas as pessoas que lhe precedem sem estar adstrito a observar a ordem por que elas se obrigaram (LUG, art. 47).

93.8. Pagamento

Pagamento é a execução voluntária da obrigação; é também o modo direto de extinção das obrigações (Clóvis, 1975, 2:66). Na cambial o portador, último endossatário do título, é o credor do título, podendo exercer seu direito contra qualquer pessoa que figure na sequência de devedores que se inicia com o aceitante, segue ao sacador e ao tomador e, a partir de então, pela cadeia de endossantes e seus avalistas.

Haverá pagamento extintivo quando o aceitante pagar o título, assim denominado por desobrigar todos os demais signatários. Chama-se recuperatório (Bulgarelli, 1996c:186) o pagamento feito por um dos coobrigados, libera tão somente os coobrigados posteriores.

Alguns atos marcam o exercício do direito do portador, quando do vencimento da letra: a) apresentação: o título deve ser apresentado para pagamento ao primeiro devedor, pessoa designada como sacado, mesmo que não tenha lançado seu aceite; b) protesto, ato cartorial que comprova a recusa de pagamento; c) exercício da ação: o portador tem o direito de acionar todos os signatários do título, sem estar adstrito a qualquer ordem por que elas se obrigaram; d) pagamento: qualquer pessoa que pagar o título, à exceção do devedor principal ou primeiro devedor, passa a ter o direito de acionar os devedores que lhe precedem na sequência de devedores; para esse fim, segue-se a ordem cronológica de assinatura; os avalistas seguem logo após os avalizados; e) o pagamento efetuado pelo devedor principal extingue todas as obrigações cambiais porque não há

outros devedores de regresso; f) devedor principal é o sacado aceitante ou, se não aceite o título, o sacador.

93.9. Pagamento por intervenção

Intervenção cambial é “ato pelo qual, no momento do protesto de um título cambiário, por recusa de aceite ou falta de pagamento, um terceiro interessado ou algum coobrigado participa para aceitar ou resgatar o título” (Houaiss, 2001). Pode ocorrer nos casos em que o portador tem direito de ação: a) na data do vencimento se o pagamento não foi efetuado; b) antes da data de vencimento, nas hipóteses em que a lei admite o vencimento antecipado, isto é, quando houver recusa de aceite ou falência do aceitante.

O pagamento deve abranger a totalidade da importância que teria que pagar aquele por honra de quem a intervenção se realiza e libera todos os endossantes e os avalistas posteriores ao signatário por honra de quem se fez o pagamento e deve ser feito no dia seguinte ao último dia em que é permitido levar o título a protesto.

Se várias pessoas se apresentam para pagar por intervenção terá preferência a que liberar, por seu pagamento, maior número de obrigados. Não sendo indicado em honra de quem se faz o pagamento, presume-se que tenha sido feito ao sacador.

A recusa do pagamento por intervenção acarreta a perda do direito de ação contra as pessoas que ficariam exoneradas pelo pagamento, isto é, os coobrigados posteriores àquele por quem se intervém.

Com a intervenção seguem-se, ainda, duas consequências jurídicas: o interveniente fica sub-rogado nos direitos contra aquele por quem pagou e contra os coobrigados anteriores a ele; àquele que intervém pagando a letra em nome de outrem não se permite endossar a letra, vedando-se a circulação do título a partir de sua assinatura.

93.10. Ressaque

É o direito atribuído ao signatário do título de emitir uma nova letra de câmbio à vista, sacada sobre um dos coobrigados de regresso anteriores, pagável no domicílio deste, visando ressarcir-se do valor do pagamento efetuado, acrescido de juros e despesas realizadas. Uma letra de ressaque pode suscitar outros ressaques porque quem paga adquire o mesmo direito em relação aos coobrigados que lhe antecedem.

Permite-se o ressaque de título que (a) esteja vencido, (b) foi protestado, (c) não se encontre prescrito.

De pouco uso, o ressaque é substituído com vantagem pela ação de regresso, mediante a qual o signatário que paga o título pode acionar, em execução, os devedores coobrigados, com a apresentação do título e memória de cálculo com os valores de ressarcimento e os decorrentes da mora.

93.11. Apresentação

Dois dispositivos legais tratam da apresentação: a) art. 38 da LUG: “o portador de uma letra pagável em dia fixo ou a certo termo da data ou de vista deve apresentá-la a pagamento no dia em que ela é pagável ou num dos dois dias seguintes”; (b) art. 20 da LS: “a letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento ou, sendo este dia feriado por lei, no primeiro dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossante e avalistas”.

Há, portanto, duas soluções: a letra deve ser apresentada no dia do vencimento e, se este não for dia útil, no dia seguinte ao vencimento (LS) ou nos dois dias subsequentes (LUG). No quadro referente à reserva brasileira à Convenção (art. 5º do Anexo II) anotamos a prevalência da Lei Uniforme, em conformidade ao entendimento de Fran Martins (1995, 1:65).

Consigna-se, agora, a divergência apontada por Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:424), que sustenta a aplicação do art. 20 da LS, salvo se o pagamento deva se realizar no exterior, situação que exigiria a aplicação do art. 39 da LUG.

O efeito da não apresentação do título para pagamento no prazo legal é a perda das ações contra os devedores à exceção do aceitante (LUG, art. 53, alínea 2), mas tão somente para as letras com cláusula “sem despesas”, isto é, a que dispensa o protesto para o exercício da ação. Nas demais letras, o protesto comprovará a falta de pagamento, suprimindo a formalidade legal de apresentação.

Na prática usual a apresentação é feita ao devedor principal na data do vencimento por boleto bancário e, se não é pago, o título é remetido a protesto, municiando o portador para o exercício da ação cambial contra os coobrigados.

Nas letras com a cláusula “sem despesas”, “sem protesto” ou “protesto desnecessário” o portador se vê desobrigado de promover o ato em cartório, mantendo inalterado seu direito de ação, tornando imprescindível, em contrapartida, a apresentação da letra para aceite ou pagamento e a expedição de avisos correspondentes ao endossante e ao sacador do título (LUG, arts. 45 e 46), o que torna mais custoso para o portador que o simples protesto em cartório.

93.12. Protesto

Protesto é o ato jurídico a cargo de tabelião de protesto de títulos, de natureza formal e solene, pelo qual se comprova o descumprimento de fatos de interesse cambiário: a recusa ou falta de aceite, a recusa ou falta de pagamento e a ausência de data de aceite.

Protesto por falta de aceite: é obrigatório nas letras com vencimento a certo termo da vista, exigindo que o portador apresente o título para

protesto (LUG, art. 44), sem o que perderá o direito de ação contra os endossantes e outros coobrigados (LUG, art. 53). Do protesto segue o vencimento antecipado do título, permitindo ao portador exercer seus direitos de ação antes do vencimento ordinário do título, mesmo se a recusa for apenas parcial (LUG, art. 43).

Protesto por falta de data de aceite: só tem relevância nas letras com vencimento a certo termo da vista, porque é da apresentação (vista) que se conta o prazo para o pagamento do título. Se o título foi apresentado e acolhido pelo devedor, mas não foi datado, deve o portador conservar seus direitos contra os endossantes e sacador, levando o título a protesto (LUG, art. 25, in fine).

Protesto por falta de pagamento: deve ser tirado num dos dois dias seguintes àquele em que a letra é pagável (LUG, art. 44, alínea 3) na hipótese de a letra não vencer à vista. Para esta, deve-se observar que a lei prevê que o prazo de apresentação estende-se até um ano da data de saque (LUG, art.34), seguindo-se, com a recusa, a necessidade de protesto no prazo legal.

93.13. Ação cambial

Duas são as ações cambiais: a ação direta que pode ser intentada contra aceitante e seus avalistas e a ação de regresso, assim chamada por se dirigir contra todos os demais coobrigados: sacador, endossantes e seus avalistas.

A ação direta pode ser promovida pela via executiva com a simples exibição da letra de câmbio e do demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, nos termos dos arts. 784, I, e 798, I e II, do Código de Processo Civil de 2015.

Para exercer a ação executiva, o credor deve apresentar o título original, somente se admitindo a cópia quando tirada na forma do art. 67 da LUG, o

que é de rara ocorrência. Em segundo lugar, a letra deve ostentar todos os requisitos extrínsecos ligados à validade da forma, bem como estar livre de defeitos – requisitos intrínsecos – que comprometam a constituição do crédito e a circulação do título, como, por exemplo, a falsidade da assinatura do executado e a ausência de poderes para obrigar o executado. E, finalmente, deve ser exigível, ou seja, não estar prescrito, nem ter ocorrido a perda do direito contra o executado, por falta de apresentação ou protesto no prazo devido.

A ação de regresso exige, além dos requisitos acima mencionados, a juntada de certidão de protesto tirado no prazo legal, isto é, num dos dois dias úteis seguintes à apresentação do título para pagamento.

A única exceção ocorre nos títulos em que se inscreveu a cláusula “sem protesto”, em que o portador terá que demonstrar a recusa e o fato de ter dado aviso da falta de pagamento a todos os signatários da letra atingidos pela cláusula. A extensão dos efeitos da cláusula “sem protesto”, “sem despesas” ou equivalente varia de acordo com a autoria de sua inscrição no título: se o ato emana do sacador, abrange todos os signatários; se quem clausulou foi outro signatário, só produzirá efeito em relação a ele, ou seja, o ato de protesto para o exercício da ação somente é dispensado em relação a este avalista ou endossante (LUG, art. 46).

A exigência de juntar o instrumento de protesto visa cumprir a regra cambial segundo a qual, depois de expirados os prazos para a apresentação, o portador perde o direito de ação contra todos os signatários, à exceção do aceitante e seus avalistas (LUG, art. 53).

O autor da ação cambial pode, num mesmo processo, pretender a execução de um, alguns ou todos os signatários da letra que, nessa condição, respondem solidariamente pela dívida toda. Pode pretender agir diretamente contra o aceitante e outros endossantes devedores de regresso; cuidará, então, de apresentar a certidão de protesto, sempre que necessário, isto é, se um dos executados não for o aceitante, nem tenha

dispensado o protesto.

A principal característica da ação cambial é a limitação das defesas a três matérias, conforme decorre do art. 51 da LS: a) direito pessoal do executado contra o exequente; b) defeito de forma do título; e c) ausência de requisito necessário ao exercício da ação.

Alegando a existência de direito pessoal contra o exequente, o devedor embargante deverá demonstrar a ocorrência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva das obrigações, como pagamento, novação, compensação com execução aparelhada, transação ou prescrição. Exemplo de causa extintiva das obrigações é o desfazimento de compra e venda que deu origem ao título ou, de causa modificativa, o pagamento ou compensação parcial, alterando o valor original do título. Qualquer causa que implique esse reconhecimento deve decorrer de vínculo jurídico existente entre o executado e o exequente.

Oposições do devedor com outro signatário não podem ser objeto de defesa em relação ao portador de boa-fé. Isto decorre da aplicação da regra cambial básica, prevista no art. 17 da LUG: “As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor”.

As questões relacionadas aos defeitos da cártula, seus requisitos extrínsecos e intrínsecos e à sua exequibilidade são defesas que independem de causa pessoal que vincule os litigantes.

93.14. Prescrição

Prescrição, segundo Clóvis (1975, 1:435), é “a perda da ação atribuída a um direito, de toda a sua capacidade defensiva em consequência do não uso delas, durante um determinado espaço de tempo”. A ação cambial

prescreve em períodos distintos em relação aos diferentes signatários da letra:

Credor	Devedor	Prazo	Fundamento legal
Qualquer signatário: portador, endossantes e avalistas, sacador e avalistas	Aceitante e seus avalistas	3 anos a contar do vencimento	LUG, art. 70, alínea 1
Portador	Endossantes e seus avalistas Sacador e seus avalistas	1 ano a contar do protesto feito em tempo útil 1 ano a contar da data de vencimento quando houver cláusula "sem protesto", "sem despesa" ou equivalente	LUG, art. 70, alínea 2
Endossantes	Endossantes Sacador	6 meses do dia em que pagou a letra ou 6 meses do dia em que foi acionado	LUG, art. 70, alínea 3

93.15. Ações causais

Além da ação cambial, de cunho executivo, com defesa limitada às matérias acima mencionadas, o portador poderá fazer uso de outra ação, de rito ordinário, em que buscará a condenação do devedor a restituir, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou a sua custa. Trata-se da ação de locupletamento injusto, também conhecida por enriquecimento indevido ou ilícito, prevista no art. 48 da LS, que foi preservada por força do art. 15 do Anexo II da Convenção de Genebra.

Neste caso há uma amplitude tanto nas alegações do autor como na defesa, porque o que se alega é a existência de uma situação que tenha causado prejuízo ao portador.

93.16. Ação monitória

Perdendo o direito de ação – por ocorrência da prescrição, por exemplo –, o portador pode, ainda, valer-se de outro procedimento de ampla utilização: a ação monitória, preferida por ser mais célere que a ação ordinária. O credor deve apresentar com a inicial o título que perdeu a eficácia executiva ou qualquer documento escrito, público ou privado, que justifique o direito à satisfação de uma determinada soma em dinheiro (CPC15, arts. 700 e ss.).

Define-se ação monitória como instrumento processual que tem por fim obter a expedição de mandado executivo a favor de quem, dispondo de prova escrita, sem eficácia de título executivo, pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

94. Nota promissória

Letra de câmbio é ordem de pagamento, à vista ou a prazo. Nota promissória é promessa escrita de pagamento de certa soma em dinheiro. Aquele que emite uma nota promissória afirma que é devedor de outrem e promete pagar-lhe a quantia inserta no título, em determinado tempo.

A nota promissória surge com a assinatura do devedor, razão pela qual não se lhe aplicam as regras relativas ao aceite, instituto típico da letra de câmbio.

Verifica-se, pois, que, na letra, o devedor principal é o aceitante, não o sacador; no segundo, é o próprio sacador, também chamado emitente ou subscritor, preferindo a legislação brasileira o primeiro termo (LS, art. 54, IV) e a legislação uniforme, o segundo (LUG, art. 75, 7).

94.1. Requisitos

O estudo dos requisitos formais envolve três questões: os essenciais, a nota promissória emitida em branco ou de forma incompleta e as indicações

não essenciais.

São requisitos essenciais da nota promissória:

- a) a denominação “nota promissória” inserta no próprio texto do título e expressa na língua em que for emitida (LUG, art. 75, 1, e LS, art. 54, I);
- b) a promessa “pura e simples”, isto é, sem qualquer condição, de pagar uma quantia determinada (LUG, art. 75, 2, e LS, art. 54, II);
- c) o nome da pessoa ou a ordem de quem deve ser paga, isto é, o tomador ou beneficiário (LUG, art. 75, 5, e LS, art. 54, III);
- d) a assinatura do emitente ou seu procurador com poderes especiais (LUG, art. 75, 7, e LS, art. 54, IV).

A lei brasileira exige que a assinatura seja lançada “abaixo do contexto” (art. 1º, V), exigência que não foi amparada pela Lei Uniforme, daí por que Fran Martins (1995, 1:123) entende que o sacador pode lançar a assinatura “no contexto ou fora dele”. Reflita-se, contudo, que, por ser a letra de câmbio expressão de um comando (“Pagará V. Sa. ...”), a assinatura deve posicionar-se em limite espacial que indique o arremate, desfecho, desse comando e, portanto, logo após a redação cambial.

Contudo, ao lado de Fran Martins, há jurisprudência entendendo que possa ser lançada no verso ou no anverso do título, sendo mais comum esta segunda modalidade (REsp 474.304/MG, rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 26-5-2003, DJ 4-8-2003, p. 316).

Observe-se, ainda, que a Lei Uniforme não exige mandatário com poderes especiais, mas a jurisprudência firmou-se no sentido de atender à regra da Lei Saraiva e, assim mesmo, de forma mitigada, visando abrandar eventuais abusos na contratação (REsp 2.453/MG, rel. Ministro Barros Monteiro, rel. para acórdão Ministro Athos Carneiro, 4ª Turma, julgado em 9-4-1991, DJ 10-6-1991, p. 7851);

- e) a indicação da data em que é passada (LUG, art. 75, 6);
- f) a indicação do lugar onde é passada (LUG, art. 75, 6). Valerá como

equivalente o lugar designado ao lado do nome do subscritor (LUG, art. 76, último parágrafo).

94.2. Nota promissória incompleta

Se iniciada a cobrança sem o preenchimento dos requisitos essenciais ou, quando indicado pelo legislador nos dois últimos casos, do mencionado equivalente, a nota é considerada inexistente, podendo, contudo, valer como princípio de prova. Entretanto, se contiver pelo menos a assinatura do emitente, é prova escrita sem eficácia de título executivo, apto a fundamentar pedido monitório nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil de 2015.

A lei brasileira permite que o preenchimento dos dois últimos requisitos possa ser feito pelo portador do título (LS, art. 54, § 1º), solução que a jurisprudência adotou, com a observação de que a complementação de qualquer requisito se faça por credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto do título (Súmula 387 do STF).

94.3. Requisitos não essenciais

A Lei Uniforme acrescenta, ainda, a época do pagamento (LUG, art. 75, 3) e a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento (LUG, art. 75, 4), não impondo pena de ineficácia ao título que omitir tais requisitos. São, portanto, requisitos não essenciais.

Para sanar a ausência da indicação da época de pagamento o legislador preferiu impor à nota promissória a qualidade de vencível à vista (LUG, art. 76, segundo parágrafo, e LS, art. 54, § 2º). À nota que não trouxer o lugar de pagamento a lei determina que se considere o lugar do saque como sendo tanto de pagamento como de domicílio do subscritor (LUG, art. 76, terceiro parágrafo). Nesse aspecto difere a Lei Saraiva, que escolheu o domicílio do emitente como lugar de pagamento (LS, art. 54, § 2º).

94.4. Direito aplicável – regras compatíveis

Os arts. 77 e 78 da LUG traçam as regras de ajuste da nota promissória ao regramento comum às letras de câmbio. São elas:

(1) Aplicam-se às notas promissórias as disposições relativas às letras que não forem incompatíveis com sua natureza, no tocante: a) às disposições relativas às letras pagáveis no domicílio de terceiro ou numa localidade diversa da do domicílio do sacado (arts. 4º e 27); b) à estipulação de juros (art. 5º); c) às divergências nas indicações da quantia a pagar (art. 6º); d) às consequências da aposição de uma assinatura nas condições indicadas no art. 7º; e) às da assinatura de uma pessoa que age sem poderes ou excedendo os seus poderes (art. 8º); f) às da letra em branco (art. 10); g) ao endosso (arts. 11 a 20); h) ao aval (arts. 30-32), com observação quanto à não indicação da pessoa por quem é dado, entendendo-se que se deu ao subscritor da nota promissória e ajustando a redação do art. 31 para equiparar a posição do sacador da letra de câmbio ao do emitente da nota promissória; i) ao vencimento (arts. 33 a 37); j) ao pagamento (arts. 38 a 42); l) ao direito de ação por falta de pagamento (arts. 43 a 50 e 52 a 54); m) ao pagamento por intervenção (arts. 55 e 59 a 63); n) às cópias (arts. 67 e 68); o) às alterações (art. 69); p) à prescrição (arts. 70 e 71); q) aos dias feriados, contagem de prazos e interdição de dias de perdão (arts. 72 a 74).

(2) Alguns ajustes vêm expressos no próprio texto legislativo, como ocorre com o aval: “no caso previsto na última alínea do art. 31, se o aval não indicar a pessoa por quem é dado, entender-se-á pelo subscritor da nota promissória” (LUG, art. 77, último parágrafo).

(3) Outros ajustes decorreram de simples regra de interpretação lógica. No endosso, por exemplo, não há que se aplicar a expressão do art. 15 quanto ao “endossante é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra”, porque na nota promissória não há o mecanismo de aceite. A

leitura fica reduzida ao texto que trata do pagamento da letra: "O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante do pagamento da nota promissória".

(4) A própria lei estipulou em dois casos tratamentos distintos ao regime da letra de câmbio, causando alguma perplexidade. A letra de câmbio pode ser emitida "a certo termo da vista", o que significa "a certo tempo da apresentação para aceite". Não existindo aceite, porque o subscritor é o devedor principal e é quem faz a promessa de pagamento, a conclusão lógica seria a impropriedade de emissão de nota promissória a certo termo da vista e, ainda, a inaplicabilidade dos arts. 22, 35, 36 e outros que tratam do aceite. Contudo, o art. 78 da LUG, em seu segundo parágrafo, traz regra aplicável às notas promissórias com vencimento a certo termo da vista e estabelece forma distinta da consideração dessa expressão, não mais significando "da data de apresentação para o aceite", mas "da data do visto dado pelo subscritor", cuja recusa será comprovada por protesto. Da data do protesto conta-se o início do termo fixado para o vencimento. Com acuidade Fran Martins (1995, 1:392-394) observa: "A estranheza que nos causa essa modalidade de vencimento da nota promissória se deve ao fato de, na letra de câmbio a certo tempo da vista, o aceite do sacado englobar o visto, dispensando-o. Mas, na realidade, aceite e visto são dois atos de natureza diversa, o primeiro significando a disposição do sacado de cumprir ordem que lhe é dada pelo sacador, tornando-se, com a sua assinatura, o obrigado principal pelo pagamento do título, e o segundo dizendo respeito ao início do prazo findo o qual a obrigação assumida com o aceite deve ser cumprida, ou seja, esgotado o qual o título deve ser pago. Em resumo: o aceite representa a assunção da obrigação de pagar por parte do sacado; o visto marca o início do prazo determinado no qual aquela obrigação deve ser cumprida. (...) Representa o visto, pura e simplesmente, o início do prazo para o vencimento da letra. E, se por acaso esse visto, posteriormente, for negado, ou dado sem data, cabe ao portador protestar

o título por falta de visto ou de data, não acarretando esse protesto o vencimento do título, mas marcando o início do prazo findo o qual a promissória será considerada vencida, como ocorre com o protesto por falta do aceite nas letras de câmbio a certo termo da vista”.

(5) O segundo caso de tratamento distinto refere-se à regra do art. 78: “O subscritor de uma nota promissória é responsável da mesma forma que o aceitante de uma letra”. Neste caso, a falência do emitente da nota promissória produz o vencimento antecipado (LUG, arts. 43-44), conforme também decorre do art. 77 da LREF (Lei n. 11.101, de 9-2-2005), podendo o portador executar individualmente os coobrigados e, concomitantemente, habilitar o crédito na falência do subscritor. Do mesmo modo, a ação contra o subscritor da nota promissória prescreve em três anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea 1), se considerada a primazia da Lei Uniforme sobre a lei brasileira, ou cinco anos, se adotada a posição de Fran Martins, que aplica a regra do art. 52 da LS. Na letra de câmbio decorrem inúmeras consequências quando ausente o protesto obrigatório no prazo legal, sendo a mais importante a perda do direito de ação contra os coobrigados, à exceção do aceitante e seu avalista (LUG, art. 53, alínea 1). Por equiparação determinada pelo art. 78 da LUG, esses mesmos efeitos ocorrem em relação ao subscritor da nota promissória e seu avalista, isto é, a falta de protesto não conduz à perda do direito de ação contra ambos.

94.5. Ação cambial e vinculação a contrato

A nota promissória acompanha o regime das letras de câmbio quanto às ações de natureza cambiária. Há, contudo, uma distinção a ser feita em relação à nota promissória vinculada a contrato.

A jurisprudência entende que as discussões acerca das causas contratuais que deram origem ao título irradiam sobre ele seus efeitos e, assim, a deficiência ou inadimplemento contratual repercutem sobre a nota promissória que a ele se vincula. Tornando-se ilíquido o contrato, o título

também o será. Por esta razão, os Tribunais têm entendido que a perda da exigibilidade do contrato implica necessariamente perda da exigibilidade pela via executiva.

Além da ação causal, é possível propor ação monitória no prazo de cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504 do STJ).

95. Cheque

Cheque é ordem de pagamento à vista, emitida por pessoa física ou jurídica, em benefício próprio ou de terceiro, contra instituição bancária ou financeira que lhe seja equiparada, com a qual o emitente mantém contrato que a autorize a dispor de fundos existentes em conta-corrente.

Caracteriza-se o cheque por ser título (a) executivo, (b) formal, (c) autônomo, (d) de prestação em dinheiro.

95.1. Legislação e regime jurídico do cheque

São três os diplomas legais que tratam do cheque no Brasil: o Decreto n. 57.595, de 7 de janeiro de 1966, que promulga as Convenções para adoção de uma Lei Uniforme sobre Cheques; a Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985, mais conhecida como Lei do Cheque, e o Decreto n. 1.240, de 15 de setembro de 1994, que promulga a Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Cheques, adotada em Montevideu, em 8 de maio de 1979.

95.2. Conflitos em matéria de cheque

Verifica-se entre a Lei Uniforme (Decreto n. 57.595/66) e a lei brasileira (Lei n. 7.357/85) a existência de conflitos quanto à regulamentação do cheque, como, por exemplo, o prazo para sua apresentação. O art. 29 do primeiro diploma indica o prazo de oito, vinte e setenta dias, conforme o

local de pagamento: se no mesmo país em que foi emitido; se em país diverso na mesma parte do mundo; e, ainda, se o lugar de emissão e de pagamento se encontrarem em diferentes partes do mundo. A lei brasileira (art. 33) dispõe de modo diverso: o prazo é de trinta ou de sessenta dias, levando em conta tão somente a identidade ou divergência entre o local de pagamento e o da emissão.

A solução para sanar o conflito entre as normas encontra-se na leitura atenta dos artigos em que ocorreram reservas do governo brasileiro, indicadas no preâmbulo da assinatura da Convenção, em que se lê expressamente a não adoção plena do disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29 e 30 do Anexo II.

95.3. Requisitos

O cheque deve conter os requisitos previstos no art. 1º da Lei n. 7.357/85:

a) a denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua do lugar da legislação de regência. Trata-se de pressuposto formal de existência do próprio título e pode ser lançado em qualquer parte do papel;

b) a ordem incondicional de pagar quantia determinada. Essa ordem deve ser expressa em algarismos ou por extenso, sendo que, presentes ambas expressões e havendo divergência entre elas, a última prevalece sobre a primeira. Se houver mais de uma indicação de valor com identidade gráfica – por extenso ou por algarismos – prevalece a que representar menor quantia;

c) o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. O nome do sacado deve constar do título, podendo haver mais de um banco ou instituição financeira que deva pagá-lo, de forma solidária entre eles;

d) a indicação do lugar do pagamento. Ocorrendo a omissão, será o do local designado junto ao nome do sacado – banco ou instituição assemelhada. Se houver multiplicidade de locais, como, por exemplo, agências e filiais do estabelecimento bancário ou instituição financeira, considera-se o primeiro deles. Se não houver lugar algum designado, presume-se que se pague no lugar de sua emissão. A lei autoriza que o pagamento se dê tanto no domicílio de terceiro quanto no do sacado (banco ou instituição), ou, ainda, em outra localidade, desde que o terceiro seja banco. A indicação do lugar de pagamento constitui importante dado para verificação do prazo para apresentação do cheque: quando emitido no lugar de pagamento, deve ser apresentado dentro de trinta dias da data da emissão; se emitido em lugar diverso ao de pagamento, esse prazo dilata-se para sessenta dias, conforme dispõe o art. 33 da Lei n. 7.357/85;

e) a indicação da data e do lugar de emissão. Considera-se lugar de emissão, à falta de estipulação especial, o lugar indicado junto ao nome do emitente;

f) a assinatura do emitente, ou de seu mandatário com poderes especiais. A assinatura pode ser feita por chancela mecânica, desde que autorizada pelo banco ou instituição financeira sacada.

95.4. Cheque incompleto ou em branco

Considera-se incompleto ou em branco o cheque que não preenche todos os cinco primeiros requisitos acima citados. Permite a lei que sua complementação se faça pelo portador, em momento posterior ao da emissão. Se o cheque for completado abusivamente, ainda assim não pode ser objeto de oposição contra o portador que não o tiver adquirido de má-fé (LC, art. 16).

O emitente, quando assina o cheque e o deixa em branco, responde perante eventuais portadores de boa-fé. A matéria de preenchimento

abusivo somente pode ser oposta contra aquele que primeiro recebeu o cheque e o preencheu sem observar o convencionado. Contra o terceiro o emitente não pode opor-se ao pagamento, salvo se provar má-fé de sua parte na aquisição.

95.5. Revogação e oposição

O emitente pode emitir contraordem de pagamento do cheque, devendo manifestar sua intenção por meio idôneo – por correspondência particular, por via judicial ou extrajudicial, indicando a motivação e sujeitando-se à responsabilização por danos civis e criminais decorrentes dessa manifestação.

A lei impede que o banco ingresse no julgamento da relevância da razão invocada pelo oponente (LC, art. 36, § 2º), conforme também deflui de entendimento jurisprudencial.

Diferenciam-se os institutos da revogação e da oposição no tocante ao momento da eficácia da ordem. A revogação somente será acatada depois do término do prazo de apresentação do cheque e a sustação mesmo durante esse prazo.

Outra distinção refere-se à pessoa legitimada a determinar o comportamento do banco: somente o correntista (que a lei denomina emitente) no primeiro caso e, no segundo, tanto ele como o portador legitimado poderão fazê-lo (LC, art. 36).

Em um ou em outro caso, ocorrido o pagamento não há mais possibilidade de se proceder à revogação ou à sustação do título.

95.6. Aval no cheque

Pode-se lançar aval no cheque, a favor do emitente, de qualquer um dos endossantes ou mesmo de outro avalista, apenas não se permitindo ao sacado que, por natureza, não se vincula na relação cambial. Trata-se, pois,

de garantia, total ou parcial, prestada por terceiro ou por qualquer signatário do título.

A Lei do Cheque brasileira admite o aval parcial (art. 29), no que colide com a regra do parágrafo único do art. 897 do Código Civil. Contudo, entende-se que as disposições relativas aos títulos de crédito, introduzidas pelo legislador civilista de 2002, não se aplicam aos títulos então existentes quando de sua promulgação.

Em regra, lança-se o aval no verso do cheque ou em folha de alongamento mediante assinatura com a expressão “por aval” ou equivalente. Qualquer assinatura no anverso do cheque, além da do emitente, é considerada aval e a omissão quanto ao nome do avalizado faz presumir que foi dado a favor do emitente.

95.7. Modalidades de emissão

As várias modalidades com as quais se reveste o cheque podem ser assim classificadas: a) quanto ao modo de circulação, os cheques podem ser nominativos, com ou sem cláusula à ordem e ao portador; b) quanto ao modo e segurança de liquidação, podem ser emitidos: cheque administrativo, cheque cruzado, com cruzamento geral ou especial, cheque para se levar em conta; c) quanto à reserva de numerário admite-se o cheque visado.

Nominativos são os cheques emitidos em favor de alguém indicado como beneficiário. Em regra, sempre são cheques à ordem, isto é, permite-se sua circulação mediante simples endosso, sendo possível, entretanto, inscrever-se cláusula “não à ordem”, vedando a circulação por endosso: qualquer transferência a partir de então será havida como cessão de crédito, regida pelo direito comum.

Cheques ao portador tornaram-se limitados a partir do Plano Real, sendo modalidade reservada aos emitidos em valor inferior a R\$ 100,00 (cem

reais). Considera-se ao portador o cheque que não indique o beneficiário, ou, ainda, aquele que contenha a indicação do beneficiário acrescida da expressão “ou ao portador” ou equivalente.

Cheques administrativos, bancários, de tesouraria ou comprados são os emitidos, sempre de forma nominativa, conforme determina a lei (art. 9º, III), por instituições financeiras que, assim, figuram simultaneamente como emitentes e sacadas.

Cheque cruzado caracteriza-se pela inscrição de suas linhas paralelas no anverso, com o fim de restringir sua circulação porque os traços indicam que seu pagamento somente pode ser a um banco (LC, arts. 44-45).

Se o cruzamento é geral, ou em branco, significa que não há indicação de instituição financeira entre os traços paralelos, e, neste caso, o banco pode pagá-lo a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. Se o cruzamento é especial, ou em preto, existirá entre os traços a indicação do nome do banco, e o pagamento somente deverá ser feito àquele banco indicado, ou se este for o próprio sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. O cruzamento não pode ser cancelado, mas a lei permite a conversão do cruzamento geral em especial, mas nunca o inverso.

Cheque para se levar em conta, previsto no art. 46 da LC, é aquele que indica, por inscrição transversal, no anverso do título, cláusula limitativa da circulação que impede seu pagamento em dinheiro. A inscrição “para se levar em conta” ou equivalente significa que o banco sacado somente poderá proceder a lançamento contábil (crédito em conta, transferência ou compensação), com força de pagamento. Não há como inutilizar a limitação; o depósito na conta do beneficiário dispensa o endosso.

Considera-se visado (LC, art. 7º) o cheque em que se inscreveu “visto, certificação ou outra declaração equivalente”, a pedido do emitente, pela qual o sacado se obriga a debitar na conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do beneficiário durante o prazo de apresentação.

95.8. Prazo para a apresentação

“O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de trinta dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de sessenta dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior” (LC, art. 33).

Em regra, toma-se o lugar da emissão, aquele que o emitente preenche ao inscrever a data.

Quanto ao tempo, presume-se verdadeira a data inscrita como a de emissão do cheque, devendo ser considerada, para esse efeito, a data lançada, abreviadamente ou por extenso, pelo emitente ou por terceiro que a tenha completado posteriormente.

Na prática bancária brasileira, vê-se muitas vezes o preenchimento do cheque com anotação de duas datas: uma de emissão e outra “pós-data”, relativa à marcação de outro dia para apresentação. É o chamado cheque pós-datado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende que o prazo de apresentação é ampliado, contando-se seu curso a partir da data consignada como de cobrança.

Quais os efeitos do descumprimento de cláusula de pós-datação? O apresentante que o faz de má-fé, em desobediência ao acordado com o emitente, responde por prejuízos causados ao emitente, conforme iterativa jurisprudência de nossos tribunais.

95.9. Perda do prazo para a apresentação

O portador que deixar transcorrer o prazo legal para a apresentação do cheque poderá colocá-lo em cobrança bancária dentro do prazo de prescrição, que é de seis meses contados da data em que expirou o prazo para apresentação (LC, art. 59). Se houver saldo, o banco não pode recusar

o pagamento, conforme decorre do art. 35, parágrafo único, da LC.

Dentro de dois intervalos – prazo de apresentação e antes da ocorrência da prescrição – haverá distintas consequências na hipótese de recusa de pagamento: a) se a apresentação se der dentro do prazo legal (LC, art. 33), o portador poderá executar todas as pessoas que figuraram no título como coobrigados: emitente, avalista do emitente, endossantes anteriores e seus avalistas; b) se um dos coobrigados pagar o título, poderá reaver esse valor dos coobrigados anteriores, devendo promover ação de execução até seis meses contados do dia em que pagou o cheque ou, se o fez em juízo, do dia em que foi demandado (LC, art. 59, parágrafo único); c) se a apresentação ocorrer após o prazo previsto, somente poderá promover a execução do cheque em relação ao emitente e seus avalistas, perdendo o direito no tocante aos endossantes e seus avalistas (LC, art. 47, II); d) contudo, também perderá o direito de executar o emitente se, nessa última hipótese (apresentação fora do prazo do art. 33), o emitente comprovar ter mantido saldo à disposição do portador, no valor da emissão do cheque, durante o período de apresentação, deixando de tê-lo posteriormente em razão de fato que não lhe seja imputável (LC, art. 47, § 3º).

Em outras palavras, a execução do cheque contra os endossantes e avalistas somente é possível se o portador apresentou o cheque dentro do prazo previsto no art. 33 – trinta ou sessenta dias –, exigindo-se, ainda, a comprovação de que houve recusa do pagamento.

Em relação ao emitente e seus avalistas, a execução é possível desde que o cheque tenha sido apresentado dentro do prazo de prescrição – até seis meses depois do decurso do prazo para a apresentação e o emitente não tinha fundos suficientes no prazo de apresentação, conforme art. 47, § 3º, da LC.

95.10. Ações judiciais

A execução e o enriquecimento indevido são ações cambiais previstas na

Lei do Cheque, a primeira nos arts. 47 e 51 a 54, e a segunda, no art. 62. Podem participar das ações cambiais todas as pessoas que figuram no título, à exceção do sacado, que não se obriga, em momento algum, no título.

O portador pode valer-se de outras ações, denominadas causais, tais como a ação monitória, prevista nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil de 2015, na hipótese de o cheque que possui já não dispor de eficácia executiva, por ter sido atingido pela prescrição, ou, ainda, a cobrança judicial pelo rito ordinário, fundada em causa que deu origem à relação cambial. Prazo para ajuizamento da ação monitória: cinco anos, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada no cheque (Súmula 503 do STJ).

As ações cambiais pressupõem a higidez do cheque como título executivo, sendo accidental o ingresso na relação originária. As ações causais ingressam, necessariamente, na causa subjacente à relação jurídica entre o credor e o devedor.

96. Duplicata

96.1. Conceito

Duplicata é título de crédito causal que representa saque relativo a crédito oriundo de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, firmado entre pessoas domiciliadas no território nacional, a partir de discriminação de operações constantes de fatura expedida pelo emitente.

96.2. Modalidades

Desse conceito é possível extrair as duas modalidades de duplicatas: a mercantil – oriunda de contrato de venda mercantil – e a de prestação de serviços, relativa a operações dessa natureza realizada por empresários

individuais, sociedades simples ou empresárias e fundações.

96.3. Criação e requisitos

São quatorze as indicações, em nove incisos, que devem ser inseridas na cédula (LD, art. 2º, § 1º) a qual se impõe, ainda, obedecer a normas de padronização formal fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução n. 102, de 26-11-1968, do Banco Central do Brasil):

Descrição	Inciso	Requisito
Identificação da duplicata	I	A denominação "duplicata"
		A data de emissão
		O número de ordem
Identificação da fatura	II	O número da fatura
Vencimento do título	III	A data certa do vencimento ou a declaração de ser duplicata à vista
Identificação dos contratantes	IV	O nome do vendedor
		O domicílio do vendedor
		O nome do comprador
		O domicílio do comprador
Valor	V	A importância a pagar, em algarismos e por extenso
Lugar de pagamento	VI	A praça de pagamento
Endossabilidade	VII	Cláusula à ordem

Aceite	VIII	A declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite cambial
Assinatura do sacador	IX	A assinatura do emitente

Os elementos de identificação da duplicata e da fatura (incisos I e II) destinam-se a distinguir o título de outras espécies cambiais (denominação duplicata), identificando-o (número de ordem) e relacionando-o com a respectiva fatura, em atenção ao que determina o art. 2º e seu § 2º da LD.

A data da emissão é essencial para conferir a capacidade e poderes do emitente, verificar a regularidade sequencial que pode ser conferida com os livros do empresário, em especial o Diário e o de Registro de Duplicatas e, ainda, analisar o andamento dos negócios, servindo, em especial, para os levantamentos das causas e demonstrações contábeis quando se fizer necessário, como ocorre, por exemplo, no pedido de recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 51, I e II).

O inciso III estabelece as modalidades possíveis de vencimento do título.

Aos dados de identificação das partes contratantes previstos no inciso IV acresce-se a exigência de documento de identificação fiscal (CPF ou CNPJ), prevista na Lei n. 6.268, de 24 de novembro de 1975 (art. 3º).

A importância a pagar (inciso V) é a que consta da fatura que deve considerar eventuais “abatimentos de preços das mercadorias feitos pelo vendedor até o ato de faturamento” (LD, art. 3º, § 1º).

O lugar de pagamento (inciso VI) é o convencionado pelas partes. O consumidor, contudo, pode alegar em juízo, na discussão sobre o pagamento do título, a prevalência do lugar de seu domicílio, invocando o princípio de facilitação da defesa de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII), sobretudo se o título resulta de contrato de adesão ou refere-se à duplicata não aceita. Há, contudo, de se assentar que o legislador exige a

determinação do lugar do pagamento no título; o fato de outro local resultar na discussão sobre a causa não acarreta sua nulidade, mas tão somente modificação de competência judicial.

A inserção da cláusula à ordem (inciso VII) reflete a finalidade da duplicata: “para circulação como efeito comercial” (LD, art. 2º). A menção à transmissibilidade por endosso evita dúvidas que poderiam ser suscitadas durante a circulação do título, sobretudo porque a vinculação do título à causa entre as figuras de criação – emitente e sacado – poderia afugentar eventuais interessados em sua circulação.

Em relação ao inciso VIII, devemos observar que o aceite é obrigatório, contudo nem sempre estará lançado por escrito na cártula; sua inscrição gráfica não é indispensável para a formalização do título, bastando que a duplicata tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, conforme dispõe o inciso II do art. 15 da LD, encontrando-se esta solução assentada em pacífico entendimento jurisprudencial.

Finalmente, a assinatura do emitente (inciso IX) identifica a responsabilidade do sacador que passa a figurar como principal obrigado, na hipótese de o título não ser legitimamente aceite pelo sacado.

96.4. Aceite

Aceite é o ato de vontade materializado pela aposição de assinatura no título, mediante a qual o sacado concorda com a ordem do emitente da duplicata, tornando-se o principal responsável pelo pagamento da quantia nela expressa na data de seu vencimento.

O emitente deve remeter o título ao sacado no prazo de trinta dias (LD, art. 6º, § 1º) ou fazer a remessa por representantes ou instituições financeiras que, então, deverão apresentar o título ao sacado no prazo de dez dias (LD, art. 6º, § 2º).

Cabe ao comprador aceitá-la, lançando sua assinatura na cártula ou recusá-la, fazendo declaração escrita das razões da falta de aceite, devolvendo, em qualquer caso, no prazo de dez dias (LD, art. 7º).

Se a instituição financeira apresentante do título concordar, o sacado pode reter o título em seu poder até o vencimento, expedindo notificação de aceite e retenção (LD, art. 7º, § 1º). Esta notificação é documento hábil à formalização do protesto ou juntada na execução judicial (LD, art. 6º, § 2º).

96.5. Aceite presumido

Distintamente do que ocorre na letra de câmbio, em que a emissão do título não obriga o sacado que poderá deixar de lançar seu aceite e, conseqüentemente, não se vincular ao pagamento do título, na duplicata a obrigação pode estar comprovada pela assinatura do devedor ou de seu preposto, lançada no canhoto de entrega de mercadorias ou de recebimento do serviço. Neste caso, mesmo sem aceitar o título, o sacado obriga-se pelo valor expresso na duplicata. É o chamado aceite presumido.

O aceite na duplicata é sempre obrigatório. A recusa em aceitar a duplicata – deixando de assiná-la ou de devolvê-la – não gera efeitos liberatórios, como ocorre na letra de câmbio em razão da natureza causal do título. Demonstrada a realização do negócio, pela assinatura no canhoto da fatura, a recusa do sacado não altera a exigibilidade do título.

96.6. Protesto por indicação

Deixando de devolver o título e de comunicar aceite e retenção, o título pode ser protestado por simples indicações fornecidas pelo emitente ou apresentante ao oficial do cartório de protestos (LD, art. 13, § 1º), acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço prestado, exigência imposta pelo

art. 15, § 2º, da Lei n. 5.474/68.

No Estado de São Paulo, a apresentação de duplicata sem aceite a protesto impõe que o credor e/ou o seu procurador apresentem ao oficial de protestos “os documentos que comprovam a venda e compra mercantil ou a efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que a autorizou, respectivamente, bem como, no caso de duplicata mercantil, do comprovante da efetiva entrega e do recebimento da mercadoria que deu origem ao saque da duplicata” (Provimento n. 30, de 19-12-1997, da Corregedoria-Geral da Justiça, alínea 11).

No tocante à duplicata de prestação de serviços, o oficial de Registro de Protestos deve exigir prova do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviços.

96.7. Motivos para a recusa

A recusa formal do sacado impede sua vinculação ao título, desde que legitimadas nas hipóteses previstas na lei. Neste caso, o protesto não pode se efetivar, respondendo por danos tanto o emitente como também o endossatário que resistir à pretensão do sacado.

São três os casos que legitimam a recusa (LD, art. 8º): a) avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco; b) vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na qualidade das mercadorias, devidamente comprovados; c) divergência no prazo e nos preços ajustados.

As alegações do comprador-sacado podem ser demonstradas por inúmeros meios de prova: laudos técnicos, notificação escrita com registro de seu recebimento, confronto da nota de pedido de encomenda com o documento fiscal de remessa etc.

96.8. Triplicata

Para prover-se de instrumento adequado à execução judicial, o emitente deve extrair triplicata que “terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades” (LD, art. 23) da duplicata extraviada ou perdida.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:465) entende que “a rigor, a lei autoriza o saque da triplicata apenas nas hipóteses de perda ou extravio”, considerando, contudo, lícita a emissão de triplicata para essa situação. Este tem sido o entendimento da jurisprudência, que classifica os casos do art. 23 como obrigatórios e os demais, facultativos.

Consagrou-se, com este entendimento, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça outra consequência de natureza prática-processual: a desnecessidade de juntar triplicata para o exercício da ação de execução, entendendo-se que o credor possa valer-se tão só do instrumento de indicação, alçando o boleto bancário à posição de título executivo.

Ousamos divergir deste entendimento. O boleto bancário ou qualquer outro instrumento de indicação emitido para efeitos de protestos não é título executivo. Somente às duplicatas e às triplicatas é que se aplicam “os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio” (LD, art. 25), não tendo o legislador conferido a mesma qualidade a outros documentos.

96.9. Endosso

A duplicata é, ao mesmo tempo, título causal e à ordem, isto é, liga-se, na origem, a um negócio de compra e venda mercantil e mantém a mais importante característica cambial: é endossável e apta à circulação de crédito. Navegaria, pois, entre a causa que lhe deu origem e a ausência (abstração) dessa causa durante seu percurso circulatório.

Surge, então, o dilema do endossatário que recebe duplicata não aceita. Na qualidade de portador do título, para fazer valer seu direito contra os endossantes e respectivos avalistas, terá que tirar o protesto dentro do

prazo de trinta dias, contado da data de seu vencimento (LD, art. 13, § 4º). Contudo, poderá ser responsabilizado por danos causados ao sacado não aceitante do título, porque desconhece as razões de sua recusa ao aceite e ao pagamento.

A solução jurisprudencial encontrada pelo extinto 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo foi no sentido de determinar a omissão do nome do sacado. A solução apresentada é jurídica e evita confundir causa subjacente – entre sacado e sacador e a consequente natureza causal do título – com a subsequente abstração, mantendo plena a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções contra o portador de boa-fé. Por outro lado, omitindo o nome do sacado, o portador de boa-fé vê-se resguardado contra possíveis ações de ressarcimento pelo prejuízo causado à imagem do devedor não aceitante.

96.10. Aval

Aplicam-se ao aval em duplicata as mesmas regras relativas ao aval em letra de câmbio (veja item 93.7). De forma similar ao mecanismo daquela cambial, o aval em duplicatas pode ser lançado em preto, com a indicação da pessoa a quem se dá a garantia. Se lançado em branco, deve-se observar regra própria (LD, art. 12): assegura obrigação da pessoa que se encontra acima de sua assinatura ou, na falta desta, da pessoa do comprador (LD, art. 12).

Aval em branco, antes do aceite: em regra o aval é lançado depois do lançamento da assinatura do avalizado, não sendo proibido, entretanto, que se faça antes, como expressamente permite o art. 14 da Lei n. 2.044, de 1908 (Lei Saraiva). Neste último caso – aval lançado antes da assinatura do avalizado – é denominado “aval antecipado”. É o que acontece, no mencionado dispositivo da Lei de Duplicatas, com a expressão “ao comprador”.

Aval posterior ao vencimento do título: parte da doutrina entende que o

aval deve ser lançado antes do vencimento do título, pois, por definição, refere-se à garantia de pagamento de uma letra, durante seu ciclo cambial. É a opinião de Carvalho de Mendonça (1955, 5.2:329-330) e de Waldirio Bulgarelli (1996:174). Pontes de Miranda diverge (2000, 1:374-375).

O legislador pátrio adotou este último entendimento: “O aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência” (LD, art. 12, parágrafo único), salvo se o aval for dado a favor de devedores de regresso que foram desonerados por falta de protesto tempestivo (art. 13, § 4º) ou posteriormente à proposição de ação de cobrança ou de execução relativa ao título porque será outra espécie de garantia, prestada no curso de processo.

96.11. Aval e ação monitória

Qual é a posição que o avalista ocupa na reconstituição da obrigação por força de tutela jurisdicional concedida em ação monitória?

Há julgados em ambos os sentidos: alguns (Juiz Gomes Corrêa, 4ª Câmara do extinto 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, Processo 1.308.174-4, em 15-9-2004) entendem que o avalista pode ser sujeito passivo de ação monitória e, outros, em sentido oposto (Juiz Rizzato Nunes, mesma Câmara e Tribunal, Processo 0818000-1, em 9-5-2001), porque prescrita a execução do título, desaparece a garantia cambial.

96.12. Protesto

Na criação da duplicata o sacador é obrigado a indicar uma data certa de vencimento ou declarar que se trata de vencimento à vista (LD, art. 2º, III). No primeiro, o título é remetido para aceite; no segundo, o título é remetido para pagamento, sendo desnecessária a apresentação para aceite.

Admite-se o protesto em três circunstâncias, sempre no lugar designado

para pagamento, conforme o direito que o titular do crédito pretenda ver preservado (LD, art. 13): a) se a duplicata não for devolvida, é possível, ao sacador, extrair triplicata ou apresentar, ao oficial do cartório, indicações que permitam o protesto por falta de devolução; b) se o título for devolvido sem aceite, cabe-lhe interpor o protesto por falta de aceite; e, finalmente, c) vencido o título, sem que ocorra o pagamento, cabe ao portador tirar o protesto, devendo fazê-lo em até trinta dias da data de seu vencimento, sob pena de perder o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas.

O protesto por falta de aceite dispensa a apresentação da duplicata para pagamento e, igualmente, o protesto por falta de pagamento. É o que sustentam Fran Martins (1995, 2:211) e Rubens Requião (1995, 2:453), invocando a regra da quarta alínea do art. 44 da LUG.

Parece-nos claro que o protesto é sempre indispensável em duas hipóteses: a) para prover o portador de condição necessária à execução do título, no caso de o título não ter sido aceite (LD, art. 15, II); e b) para evitar a perda do direito de regresso em relação aos endossantes e respectivos avalistas (LD, art. 13, § 4º). Para tais fins torna-se suficiente a promoção de um só protesto – um ou outro – realizado até trinta dias da data de vencimento.

96.13. Prazo para pagamento

O pagamento da duplicata à vista deve ser feito no momento de sua apresentação; quanto à duplicata com vencimento em data certa, o pagamento deverá ser realizado na data indicada. Prova-se o pagamento por qualquer meio extintivo de obrigação e, em especial, por: a) recibo lançado no próprio título; b) documento de recebimento em separado, com referência expressa à duplicata; e c) liquidação de cheque no qual conste, no verso, que seu valor se destina à amortização ou liquidação da duplicata nele caracterizada (LD, art. 9º, §§ 1º e 2º).

96.14. Pagamento antecipado

O art. 9º da LD permite alterar os momentos de pagamento, autorizando ao comprador resgatar a duplicata “antes de aceitá-la ou antes da data do vencimento”.

Pontes de Miranda (2000, 3:310) adverte que, no tocante às duplicatas, o pagamento antecipado somente tem validade se realizado antes do aceite, incidindo, depois dele, a regra geral das cambiais, prevista na Lei Uniforme de Genebra (art. 40) e na lei brasileira (LS, art. 22), que declaram que o portador não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra.

Até o vencimento do título algumas situações podem dar margem à legítima oposição ao pagamento, como, por exemplo, o extravio – desapossamento violento, ou por erro, dolo etc. Nas situações em que o título se encontra em poder de portador de má-fé ou de terceiro a quem aquele repassou, a antecipação de pagamento retira do legítimo credor a oportunidade para municiar-se com instrumentos legais necessários a impedir o pagamento por parte do sacado e a reivindicar o título em poder do portador de má-fé (LS, art. 36). Outra situação que inspira a cautela do legislador é a falência posterior do portador do título a quem se pagou antecipadamente.

Não é sem razão que as mencionadas leis cambiais advertem quanto aos riscos decorrentes de pagamento de letra não vencida: “O sacado que paga uma letra antes do vencimento fá-lo sob sua responsabilidade” (LUG, art. 40) e “Aquele que paga uma letra, antes do respectivo vencimento, fica responsável pela validade desse pagamento” (LS, art. 22).

96.15. Prorrogação de vencimento

Por declaração em separado ou escrita na duplicata, o endossatário, o vendedor ou seus mandatários com poderes especiais podem reformar ou

prorrogar o prazo de vencimento (LD, art. 11). Para validade contra os devedores de regresso deve obter anuência expressa de todos os endossantes e avalistas que intervieram no título. Se algum deles não declara sua concordância, fica desobrigado, retirando-se da cadeia obrigacional.

96.16. Ações fundadas na duplicata – incidência de juros e correção monetária

As ações cambiais foram estudadas no capítulo relativo às letras de câmbio, restando tão somente analisar a questão relativa à fluência de juros de mora.

Divergem doutrina e jurisprudência a respeito. Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:466) ensina que os juros incidem a partir do protesto do título e não de seu vencimento, como ocorre com as cambiais próprias, invocando, para tal conclusão, o art. 40 da Lei n. 9.492/97 (Lei de Protestos).

Lembramos, entretanto, que o art. 25 da LD determina a aplicação dos dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das letras de câmbio, devendo-se observar que a regra do art. 48 a respeito dos juros encontra-se no Capítulo VII, que trata “da ação por falta de aceite e falta de pagamento”, expressão que, a nosso ver, submete-se ao gênero “pagamento” e, portanto, aplicável às duplicatas. A jurisprudência reflete este último entendimento (REsp 11.998/Pr, rel. Ministro Fontes de Alencar, 4ª Turma, julgado em 16-12-1997, DJ 8-6-1998, p. 110, e REsp 197.294/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 23-2-1999, DJ 29-3-1999, p. 190).

96.17. Prescrição

Os prazos prescricionais da pretensão à execução da duplicata são os mencionados no art. 18 da Lei n. 5.474/68:

RESPONSÁVEL CAMBIAL	PRAZO	TERMO INICIAL
Sacado	3 anos	A partir da data do vencimento do título.
Avalista do sacado	3 anos	A partir da data do vencimento do título.
Endossante	1 ano	A partir da data do protesto.
Avalista do endossante	1 ano	A partir da data do protesto.
Coobrigados – uns contra os outros (regresso)	1 ano	A partir da data de pagamento do título.

96.18. Aspectos penais relacionados à duplicata

A emissão de duplicata simulada é crime previsto no art. 172 do Código Penal e, em se tratando de empresário falido – individual ou sociedade empresarial –, poderá sujeitar-se às penas do art. 168 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 – fraude a credores.

Em relação ao primeiro delito, jurisprudência do STF mantém a tipicidade, mesmo após o advento da Lei n. 8.137/90.

Na Lei Falimentar, o crime é punido com pena de reclusão de três a seis anos e multa, e se insere na prática de ato fraudulento “de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem” (LREF, art. 168). Se o vendedor, além da emissão fraudulenta, elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos, a pena é aumentada de um sexto a um terço, nos termos do § 1º, inciso I.

96.19. Duplicata escritural

A Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018, dispôs sobre a emissão da

duplicata sob a forma escritural, o que ocorre pelo simples lançamento em sistema eletrônico.

O lançamento deve ser feito por entidades autorizadas pelo Poder Público quando não o for por órgão ou entidade da administração federal, e a escrituração do título abrange a apresentação, o aceite, a devolução e a formalização da forma de pagamento, o controle de transferência de titularidade, a prática de atos cambiais sob a forma escritural (como, por exemplo, aval e endosso), a inclusão de indicações, informações ou de declarações referentes à operação com base na qual a duplicata foi emitida ou ao próprio título e de informações a respeito dos ônus e gravames constituídos sobre as duplicatas.

A legislação autoriza expressamente a Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos a exercer essa atividade. Trata-se de plataforma criada pelos diversos serviços registraais, com fundamento no que dispõem os arts. 37 a 39 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009.

Realizado o registro escritural da duplicata, qualquer solicitante pode requerer aos gestores do sistema a expedição do extrato, em forma física ou eletrônica, desse registro, contendo os dados previstos no art. 6º, § 1º, do diploma regulamentador: I — a data da emissão e as informações referentes ao sistema eletrônico de escrituração no âmbito do qual a duplicata foi emitida; II — os elementos necessários à identificação da duplicata, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968; III — a cláusula de inegociabilidade; e IV — as informações acerca dos ônus e gravames.

Ambos — a duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato dela emitido — são títulos executivos extrajudiciais, devendo o portador demonstrar, na execução, o que dispõe o art. 15 da LD, conforme acima exposto (veja item 96.6), aplicando-se, ainda, no que couber a legislação de regência comum às duplicatas, inclusive no que se refere ao protesto do título.

Consequência do sistema registral é a simplificação da prova de entrega de mercadoria e a de pagamento do título. Para tanto, a Lei n. 13.775/2018 estabelece que o sistema eletrônico “disporá de mecanismos que permitam ao sacador e ao sacado comprovarem, por quaisquer meios de prova admitidos em direito, a entrega e o recebimento das mercadorias ou a prestação do serviço, devendo a apresentação das provas ser efetuada em meio eletrônico” (art. 4º, § 3º) e, ainda, que a prova de pagamento, total ou parcial, pode ser feita por “qualquer meio de pagamento existente no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro” (art. 5º).

A previsão traz economia ao processo judicial, nas ações relativas às cobranças e defesas relacionadas à emissão e circulação de duplicatas.

Recuperação Judicial e Falência

97. Plano de estudo

Este último capítulo foi dividido em nove partes e abrange toda a Lei n. 11.101/2005. Os tópicos apresentados sequencialmente foram agrupados de acordo com unidades que guardam identidade temática, possibilitando visualizar o desenvolvimento integral da matéria. Optamos pela apresentação em forma de tabela, em virtude de sua extensão:

Disposições gerais – itens 98-102	Casos de incidência e de não incidência – item 98
	Unidade do juízo falimentar – item 99
	Prevenção do juízo falimentar – item 100
	Indivisibilidade do juízo falimentar – item 101
	Universalidade do juízo falimentar – item 102
Verificação e habilitação de crédito – itens 103-105	Verificação e habilitação de créditos – item 103
	Habilitação retardatária de créditos – item 104

	Ação ordinária de exclusão de crédito – item 105	
Órgãos comuns – itens 106-108	Administrador judicial – item 106	
	Comitê de Credores – item 107	
	Assembleia geral de credores – item 108	Classe de credores e direito a voto – item 108.1
		Quorum de instalação e de deliberação – item 108.2
		Sistemas de colheita de votos – item 108.3
Recuperação judicial ordinária – itens 109-117	Recuperação judicial – crise econômico-financeira e princípios norteadores – item 109	
	Sistemas e recuperação em juízo – item 110	
	Pedido inicial e processamento da recuperação – item 111	
	Meios de recuperação – item 112	
	Plano de recuperação – item 113	
	Impugnação ao plano – item 114	
	Deliberação sobre o plano de recuperação – item 115	
	Cumprimento da recuperação judicial – item 116	
	Conversão da concordata em recuperação judicial – item 117	
Recuperação judicial especial – item 118		
Recuperação extrajudicial – item 119		

Convolação da recuperação em falência – item 120		
Falência – itens 121-133	Pedido de falência – item 121	
	Procedimentos pré-falimentares – item 122	
	Recuperação judicial incidental – item 123	
	Sentença judicial e efeitos – itens 124-129	Sentença judicial e recursos – item 124
		Efeitos da falência sobre os credores – item 125
		Efeitos da falência sobre a pessoa do falido – item 126
		Efeitos da falência sobre os sócios – item 127
		Efeitos da falência sobre os bens do falido – item 128
		Efeitos da falência sobre os contratos – item 129
	Administração e arrecadação de bens – item 130	
	Classificação dos créditos na falência – item 131	
	Realização do ativo – item 132	
Pagamento aos credores – item 133		
Ações falimentares – itens 134-135	Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido – item 134	
	Ações de restituição – item 135	

98. Casos de incidência e de não incidência

A Lei de Recuperação e Falência aplica-se somente a quem exerce a empresa, isto é, ao empresário individual, à empresa individual de responsabilidade limitada e à sociedade empresária. Contudo, nem todas as atividades empresariais foram contempladas pela Lei n. 11.101, de 2005, tendo sido excluídas as empresas públicas, gênero que compreende tanto as assim chamadas *stricto sensu*, como as de economia mista; as instituições financeiras, públicas e privadas e cooperativas de crédito; empresas de consórcio; entidades de previdência complementar; sociedades operadoras de planos de assistência à saúde; sociedades seguradoras; sociedades de capitalização e todas as equiparadas a estas. A essa lista, prevista no art. 2º da LREF, devem-se acrescentar as concessionárias de serviço público de energia elétrica, por força do art. 18 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012.

Além desses casos, de não incidência em razão de seu objeto, há outros três pincelados na própria Lei Falimentar que se referem à inatividade. São os previstos no art. 96, VIII e § 1º: a) cessação das atividades empresariais mais de dois anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contraprova de exercício posterior ao ato registrado; b) sociedade anônima, depois de liquidado e partilhado seu ativo; c) espólio após um ano da morte do devedor.

Para uma perfeita compreensão dessas três situações, observe-se que os dois primeiros casos (cessação das atividades e partilha do ativo) são hipóteses de não incidência absoluta porque não permitem sujeição à falência e, tampouco, admitem pedido de recuperação judicial. Neste último caso, por força do que dispõe o art. 48, ao exigir que “o devedor, no

momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos”.

Quanto ao espólio, mesmo após um ano da morte do devedor, embora não seja permitido ao credor ingressar com pedido de falência, resta a possibilidade de o cônjuge sobrevivente, o herdeiro ou o inventariante requererem não somente a autofalência como igualmente a recuperação judicial (LREF, art. 47, parágrafo único). É o que decorre da lição de Miranda Valverde (1999, 1:154).

99. Unidade do juízo falimentar

Somente um juízo é competente para conhecer as questões envolvendo a empresa em crise econômico-financeira: o do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial do empresário individual ou sociedade empresária que tenha sede fora do Brasil.

O princípio da unidade do juízo falimentar, previsto no art. 3º da LREF, abrange todas as medidas judiciais visando à recuperação da empresa ou a decretação de sua falência: deferimento do pedido de recuperação judicial; concessão, convolação de recuperação em falência; decretação de falência; conversão de concordata preventiva em recuperação judicial e homologação de plano de recuperação extrajudicial.

Considera-se principal estabelecimento o “ponto central dos negócios, de onde partem todas as ordens, que imprimem e regularizam o movimento dos estabelecimentos produtores” (Miranda Valverde, 1999, 1:138).

100. Prevenção do juízo falimentar

A distribuição de pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido dessa natureza, relativo ao mesmo devedor.

101. Indivisibilidade do juízo falimentar

Por indivisibilidade do juízo falimentar entende-se o princípio que elege o juízo falimentar como único competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido.

O art. 76 da LREF, contudo, exclui alguns casos: a) causas trabalhistas que se submetem ao Juízo Especial até o encerramento do processo de conhecimento. Observa-se, contudo, que, apurado o crédito trabalhista na Justiça do Trabalho, cabe ao credor submetê-lo à habilitação e classificação perante o juízo falimentar; b) causas fiscais, por não se submeterem ao concurso de credores ou à habilitação nos processos falimentares; c) causas em que o falido figure como autor ou litisconsorte ativo, que não sejam reguladas pela Lei Falimentar. As que são regulamentadas pela Lei Falimentar – por exemplo: restituição de bens, mercadorias e valores, revocatórias, rescisória de quadro geral de credores – serão distribuídas e processadas no juízo falimentar.

Além dessas três hipóteses que excepcionam a incidência do princípio de indivisibilidade, a Lei de Recuperação e Falência agasalhou uma quarta situação, fruto de construção jurisprudencial no sistema da lei anterior: as causas em processamento que demandarem obrigação ilíquida permanecem no juízo em que foram primitivamente distribuídas e não são atraídas pelo juízo falimentar.

Há, ainda, outras exceções, previstas em leis não falimentares: a) causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, cujo julgamento se dará perante a Justiça Federal (CF88, art. 109, I); b) ações relativas a imóveis, cuja competência se determina pela situação do bem, de forma absoluta (CPC15, art. 47).

102. Universalidade do juízo falimentar

O princípio da universalidade do juízo falimentar, indicado no art. 126 da LREF, diz respeito à imposição de uma só regra para todos os credores, submetendo-os a um mesmo juízo.

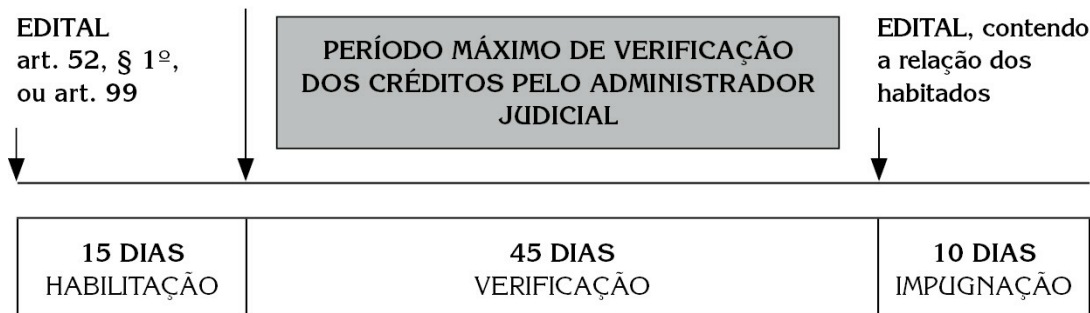
Devemos observar que nem todos os credores submetem-se à verificação e à habilitação no juízo falimentar, porque excetuados quanto à regra da indivisibilidade. Entretanto, quanto à classificação e ao pagamento, todos os credores sujeitam-se ao regramento estabelecido na lei falimentar.

Não há excepcionalidade na aplicação da universalidade. Credores por restituição, trabalhistas, fiscais, com privilégios, quirografários ou subquirografários, todos se submetem em maior ou menor extensão ao juízo falimentar, isto é, embora alguns prescindam do procedimento verificatório (em menor extensão, portanto ao juízo falimentar), todos se sujeitam à classificação.

103. Verificação e habilitação de créditos

O capítulo da verificação de créditos aplica-se à falência e aos procedimentos de recuperação judicial. Didaticamente podemos distinguir três fases:

A fase inicial, de chamamento dos credores, inicia-se, na recuperação judicial, com a publicação de edital contendo a decisão que defere o pedido (LREF, art. 52, § 1º), e, na falência, do edital que a decreta (LREF, art. 99, parágrafo único). Da publicação do edital conta-se o prazo de quinze dias para as habilitações tempestivas dos credores. No dia seguinte ao encerramento inicia-se novo prazo: de quarenta e cinco dias para que o administrador judicial publique edital contendo a relação de todos os credores habilitantes. Da publicação desse edital seguem-se mais dez dias para que os credores, Comitê, devedor ou seus sócios e o Ministério Público apresentem suas impugnações (LREF, art. 8º).



A segunda fase é a do tríplice encaminhamento. Decorrido o prazo para a apresentação dos pedidos de impugnação à relação dos créditos que foram habilitados, abrem-se três caminhos: a) ausência de impugnações – o juiz homologa a relação (LREF, art. 14); b) impugnação de alguns créditos – o juiz manda dar vista aos credores impugnados, no prazo de cinco dias (LREF, art. 11), seguindo-se vista ao devedor, Comitê de Credores, também no prazo de cinco dias (LREF, art. 12), e parecer do administrador judicial, em igual prazo. A lei não menciona o Ministério Público, que, contudo, deverá ser ouvido após o administrador, por força de sua função fiscalizatória nos autos; c) em relação aos créditos não impugnados, os autos são remetidos para decisão judicial.

A terceira fase é a decisão judicial: os créditos não impugnados serão incluídos. No tocante aos impugnados, o juiz deve fixar os aspectos controvertidos, decidindo eventuais decisões processuais pendentes (LREF, art. 15, III) e, se necessário, determinar provas a serem produzidas (art. 15, IV). Com a sentença julgando improcedente a impugnação, o crédito será incluído e a decisão remetida ao administrador para consolidar o quadro geral de credores, que será homologado e publicado no prazo de cinco dias. Da publicação inicia-se o prazo de dez dias para a interposição, pelos interessados, de agravo de instrumento (LREF, art. 17).

104. Habilitação retardatária de créditos

No tocante à pretensão de inclusão de créditos, a Lei de Recuperação e

Falência considera três períodos distintos: a) será tempestiva a habilitação realizada dentro de quinze dias da publicação dos editais mencionados nos arts. 52, § 1º, e 99; b) decorrido este prazo, a habilitação será considerada retardatária, podendo ser promovida até a homologação do quadro geral de credores; c) depois disso, o credor deverá promover ação de retificação de ato judicial, de rito ordinário, com curso no juízo falimentar (art. 10, § 6º; CPC15, art. 996, § 1º).

O credor retardatário terá seu pedido processado como impugnação de crédito (veja item 103, supra, segunda fase) e sofrerá restrições de quatro ordens, sendo que a primeira é comum a ambos os regimes (recuperação e falência) e as três últimas aplicam-se somente na falência:

(1) Direito a voto: até ser incluído no quadro geral de credores, o retardatário não pode votar nas deliberações da assembleia geral de credores, salvo se for titular de crédito derivado das relações de trabalho (LREF, art. 10, § 1º).

(2) Direito ao quinhão em rateio: o retardatário não se beneficia de rateios feitos aos credores da massa falida (LREF, art. 10, § 3º).

(3) Direito à integralidade do crédito: por ser tardio, o crédito não será incluído em sua totalidade, perdendo o titular o direito aos acessórios devidos entre a data do término do prazo e a do pedido de habilitação retardatária (LREF, art. 10, § 3º).

(4) Direito à isenção de custas: a lei não prevê pagamento de emolumentos por parte dos credores, salvo na hipótese de habilitação fora do prazo (LREF, art. 10, § 3º).

105. Ação ordinária de exclusão de crédito

O quadro geral homologado judicialmente pode ser retificado por meio de ação prevista no art. 19 da LREF, para a qual o legislador formatou as seguintes características:

a) Natureza da ação – o dispositivo abrange duas espécies distintas de ações: rescisória de sentença (quando referir-se a título judicial, julgamento de crédito retardatário ou de impugnação de crédito) ou anulação de ato judicial (homologação do quadro geral, sem que tenha havido impugnações dos credores). O rito de ambas as ações é ordinário.

b) Pedidos: exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores (LREF, art. 19).

c) Legitimidade ativa: podem promovê-la o administrador judicial, o Comitê de Credores, qualquer credor ou o membro do Ministério Público que atuar no processo. Observe que o devedor não está legitimado.

d) Competência: é competente o juízo universal, salvo se a falsidade, dolo, simulação etc. ocorreu em outro juízo, como é o caso de sentenças trabalhistas e das ações que demandem obrigação ilíquida, tenham sido promovidas antes da falência e julgadas em juízo diverso ao da quebra ou da recuperação judicial.

e) Decadência: a ação deve ser promovida até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

f) Efeito sobre o crédito atingido: o titular somente poderá receber ou levantar o valor de seu crédito mediante caução no mesmo valor do crédito questionado.

106. Administrador judicial

O juiz da falência ou da recuperação judicial nomeará um administrador judicial, fazendo recair sua escolha sobre advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou, ainda, empresa especializada, que, nomeada, deverá indicar profissional para exercer as funções, sendo vedada sua substituição sem autorização judicial (LREF, art. 21).

106.1. Natureza jurídica

Segundo Miranda Valverde (1999, 1:439-447) são dois os grupos de teorias que tentam explicar a natureza jurídica do antigo síndico, atualmente denominado administrador judicial: teorias da representação e da função judiciária, prevalecendo esta última em função da atividade estar ligada ao interesse da justiça.

106.2. Impedimentos

Os impedimentos (LREF, art. 30) referem-se a atos de desídia, relações de parentesco, dependência ou amizade com o devedor, administradores, controladores ou representantes legais da falida. Veda-se, portanto, a nomeação de: 1) pessoa que foi destituída nos últimos cinco anos, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve prestação de contas desaprovada; 2) parente ou afim até o terceiro grau do devedor, administradores, controladores ou representantes legais da falida; 3) amigo, inimigo ou dependente das mesmas pessoas anteriormente mencionadas.

106.3. Compromisso

O administrador judicial deve assinar o termo de compromisso em cartório no prazo de quarenta e oito horas depois de sua intimação pessoal (LREF, art. 33) e, não o fazendo, será imediatamente substituído pelo magistrado (LREF, arts. 33 e 34).

106.4. Funções e prazos

As funções do administrador compreendem atos de ordem administrativa, contábil e processual e podem ser resumidas no seguinte quadro:

FUNÇÕES NA FALÊNCIA	ART.	PRAZO E/OU FINALIDADE

Administrar a empresa falida, na continuação provisória.	99, XI	
Alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa, com o objetivo de produzir renda para a massa falida.	114	
Apresentar conta demonstrativa da administração.	22, III, p, e 148	10º dia do mês seguinte ao vencido.
Apresentar relatório final da falência.	155	10 dias do julgamento das contas.
Apresentar relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência.	22, III, e	40 dias da data da assinatura do compromisso. Prorrogável por igual período.
Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação.	22, III, f, e 108	Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso.
Assinar o auto de arrecadação.	109	No ato.
Assinar o termo de compromisso.	33	48 horas.
Avaliar os bens arrecadados.	22, III, g, e 110	No ato da arrecadação. Prazo máximo de 30 dias de seu requerimento explicando as razões pelas quais não a realizou no ato de arrecadação.
Avisar, pelo órgão oficial, o lugar e a hora em que os credores terão à disposição os livros e documentos do falido.	22, III, a	Antes de findo o prazo de 15 dias para as habilitações e a tempo para as consultas dos credores.
	18 e	

Consolidar o quadro geral de credores.	22, I, f	5 dias após a publicação da sentença que julgar as impugnações de crédito.
Contratar avaliadores.	22, III, h	Quando necessário, mediante autorização judicial.
Contratar profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-lo.	22, I, h	Quando necessário, mediante autorização judicial.
Cumprir ou denunciar os contratos.	117 e 118	Ao tomar conhecimento ou até 10 dias depois de notificado pelo contratante.
Dar extratos dos livros do devedor.	22, I, c	Antes de findo o prazo de 15 dias para as habilitações.
Declarar se cumpre ou não os contratos bilaterais.	117, § 1º	10 dias após a interpelação do contratante.
Diligenciar a cobrança de dívidas e dar quitação.	22, III, l	
Elaborar a relação de credores.	7º, § 2º, e 22, I, e	45 dias após findo o prazo para as habilitações tempestivas.
Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa.	22, III, q	
Enviar correspondência aos credores.	22, I, a	
Examinar a escrituração do devedor.	22, III, b	
Exercer as funções do Comitê de Credores, se este não for constituído e aquelas não forem incompatíveis.	28	

Exibir as certidões de registro dos imóveis.	110,§ 4º	15 dias após a arrecadação.
Exigir dos credores, do devedor ou de seus administradores quaisquer informações.	22, I, d	A qualquer tempo.
Fornecer todas as informações pedidas pelos credores interessados.	22, I, b	Com presteza.
Guardar os bens arrecadados.	108,§ 1º	
Manifestar-se nos pedidos de restituição.	87	5 dias da intimação.
Manifestar-se sobre a forma de alienação do ativo.	142	
Manifestar-se sobre impugnação às suas contas ou parecer contrário do Ministério Público	154,§ 3º	
Praticar os atos conservatórios de direitos e ações.	22, III, I	
Praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores.	22, III, i	
Presidir a assembleia geral.	37	
Prestar contas e apresentar relatórios omitidos no tempo certo.	23	Na omissão, 5 dias depois de intimado, sob pena de desobediência.
Prestar contas.	22, III, r, e	No final do processo, 30 dias depois de concluída a realização do ativo e distribuído o produto entre os credores.

	154	
Prestar contas.	22, III, r, e 31, § 2º	10 dias depois de sua substituição, destituído ou renunciar ao cargo.
Propor, sem exclusividade, ação revocatória.	132	Até 3 anos contados da decretação da falência.
Realizar atos pendentes em inventário do espólio falido, em relação a direitos e obrigações da massa falida.	125	
Realizar despesas, inclusive pagamentos antecipados.	150	
Receber a relação de associados sindicalizados que serão representados pelo sindicato na assembleia geral.	37, § 6º, I	10 dias antes da assembleia.
Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor.	22, III, d	
Relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa.	22, III, c	
Remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens apenados, penhorados ou legalmente retidos.	22, III, m	
Representar a massa em juízo, contratando, se necessário, advogado.	22, III, n	

Requerer a concessão de prazo para apresentar o laudo de avaliação, quando necessário.	110, § 1º	30 dias para a apresentação do laudo.
Requerer a convocação da assembleia geral de credores.	22, I, g	Quando entender necessária sua ouvida para tomada de decisões.
	22, I, g, e 35, II, b	Para constituir o Comitê de Credores.
	22, I, g, 35, II, c, e 145	Para a adoção de outras modalidades de realização do ativo.
Requerer a manifestação do Comitê de Credores	22, III, n	Para fixar honorários de advogados contratados pela massa.
Requerer a venda antecipada de bens.	22, III, j, e 113	Quando houver bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, mediante autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido, em 48 horas.
Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento da lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração.	22, III, o	
Restituir coisa móvel comprada com reserva de domínio, se resolver não continuar a execução do contrato.	119, IV	
Revogar ou confirmar representação judicial conferida em mandato	120	Ao tomar conhecimento e não sendo de interesse

outorgado pelo falido.		da massa.
Transigir sobre obrigações e direitos da massa falida.	22, § 3º	Somente após ouvir o Comitê de Credores e com autorização legal.

FUNÇÕES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ART.	PRAZO E/OU FINALIDADE
Apresentar ao juiz, para juntada nos autos, relatório mensal das atividades do devedor.	22, II, c	
Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput do art. 63.	22, II, d	
Assinar o termo de compromisso	33	48 horas.
Consolidar o quadro geral de credores.	18 e 22, I, f	5 dias após a publicação da sentença que julgar as impugnações de crédito.
Contratar profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-lo.	22, I, h	Quando necessário, mediante autorização judicial.
Dar extratos dos livros do devedor.	22, I, c	Antes de findo o prazo de 15 dias para as habilitações.
Elaborar a relação de credores.	7º, § 2º, e 22, I, e	45 dias após findo o prazo para as habilitações tempestivas.
Enviar correspondência aos credores.	22, I, a	
Exercer as funções de gestor enquanto a assembleia geral não deliberar sobre a escolha deste.	65, § 1º	
Exercer as funções do Comitê de Credores, se este	28	

não for constituído e aquelas não forem incompatíveis.		
Exigir dos credores, do devedor ou de seus administradores quaisquer informações.	22, I, d	A qualquer tempo.
Fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial.	22, II, a	
Fiscalizar os atos de administração do devedor.	64	
Fornecer todas as informações pedidas pelos credores interessados.	22, I, b	Com presteza.
Manifestar-se sobre a forma de alienação do ativo, quando o plano envolver essa alienação.	60 e 142	
Presidir a assembleia geral.	37	
Prestar contas e apresentar relatórios omitidos no tempo certo.	23	Na omissão, 5 dias depois de intimado, sob pena de desobediência.
Receber a relação de associados sindicalizados que serão representados pelo sindicato na assembleia geral.	37, § 6º, I	10 dias antes da assembleia.
Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação.	22, II, b	
Requerer a convocação da assembleia geral de credores.	22, I, g	Quando entender necessária sua ouvida para tomada de decisões.

106.5. Remuneração

Para decidir sobre a remuneração do administrador judicial, o juiz levará em conta aspectos relacionados ao montante, limite, momento de pagamento e os mesmos parâmetros para outras decisões semelhantes:

REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL		
Fundamentos	Critérios legais	Artigo(s) da LREF
Montante	Capacidade de pagamento do devedor. Grau de complexidade do trabalho. Valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Proporcionalidade ao trabalho realizado, quando substituído sem culpa. Parâmetros para outras decisões semelhantes: Estes mesmos critérios serão considerados pelo juiz ao fixar a remuneração dos auxiliares do administrador judicial. Pode servir de paradigma ao Comitê de Credores na fixação dos honorários do advogado contratado pela massa.	24 e § 3º 22, § 1º 22, III, n
Limite	Na falência: ordinariamente até 5% do valor de venda dos bens. Em se tratando de falência de microempresário ou empresário de pequeno porte: até 2%. Na recuperação judicial: até 5% dos créditos submetidos à recuperação. Nos pedidos realizados por microempresas e empresas de pequeno porte: 2%.	24, §§ 1º e 5º
Momento	60% durante o curso da falência. 40% após a conclusão da realização do ativo e do julgamento das contas da administração.	24, § 2º, e 154-155

106.6. Substituição e destituição

Distinguem-se a substituição e a destituição porque a segunda, mais grave, é causa impeditiva de nomeação para as funções de administrador ou de membro de Comitê de Credores (LREF, art. 30).

O juiz deverá substituir o administrador judicial, sem submeter sua

decisão à assembleia geral, nos seguintes casos: a) por iniciativa do devedor, qualquer credor ou Ministério Público (LREF, art. 30, § 2º), em virtude de irregularidade na nomeação, fundada em desobediência aos preceitos da lei; b) se, no curso de sua gestão, o administrador renunciar, apresentando ou não motivo relevante (LREF, art. 24, § 3º); c) na hipótese de o administrador não assinar o termo de compromisso no prazo de quarenta e oito horas de sua intimação (LREF, art. 34).

São casos de destituição e, igualmente, independem da manifestação da assembleia geral: a) recalcitrância do administrador em apresentar suas contas ou qualquer relatório previsto na lei, depois de intimado a fazê-lo em cinco dias (LREF, art. 23 e parágrafo único); b) por ato de ofício do magistrado ou mediante requerimento fundamentado de qualquer interessado, quando se verificar desobediência aos preceitos da lei, descumprimento dos deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou terceiros (LREF, art. 31).

106.7. Responsabilidade

O administrador judicial é pessoalmente responsável pelos atos que praticar em prejuízo à massa, ao devedor e aos credores, em razão de dolo ou culpa (LREF, art. 32).

106.8. Prestação de contas

No encerramento das atividades de sua administração, por renúncia, destituição ou substituição, ou porque findos os trabalhos de liquidação, o procedimento de prestação de contas tem curso incidental ao processo falimentar.

Em três momentos a lei obriga o administrador judicial a prestar contas: a) no final do processo, até trinta dias da conclusão da realização do ativo (LREF, art. 154); b) em dez dias da data do evento, se for substituído,

destituído ou renunciar ao cargo (LREF, art. 22, III, r); e c) ao receber valores durante o exercício de sua administração, apresentará conta demonstrativa até o décimo dia do mês vencido (LREF, arts. 22, III, p, e 148).

Na violação dos prazos marcados pela lei, o administrador será intimado pessoalmente a fazê-lo em cinco dias, sob pena de desobediência (LREF, art. 23), devendo ser destituído, perdendo direito à totalidade de sua remuneração (LREF, art. 24, § 3º).

107. Comitê de Credores

O Comitê de Credores é órgão de fiscalização, de constituição facultativa. Se não constituído, suas atribuições serão realizadas pelo administrador judicial e, na incompatibilidade deste, pelo juiz da falência (LREF, art. 28).

107.1. Formas de constituição

São três as formas de iniciativa de constituição: a) de ofício, pelo magistrado, na sentença de falência, ao determinar a convocação da assembleia geral de credores para esse fim (LREF, art. 99, XII); b) a pedido do administrador judicial (LREF, arts. 22, I, g, e 35, II, b); c) por deliberação de qualquer das classes de credores na assembleia geral (LREF, art. 26).

107.2. Composição e presidência

O Comitê de Credores pode compor-se de forma mínima, por representantes indicados por duas classes de credores ou de forma plena, a partir da Lei Complementar n. 147/2014, por quatro classes: (1) trabalhistas; (2) com direitos reais de garantia ou privilégios especiais; (3) quirografários e com privilégios gerais; e (4) representantes de microempresas e empresas de pequeno porte. Na forma mínima, terá seis membros: dois titulares indicados por classes distintas e quatro suplentes,

dois para cada classe representada; na forma plena terá doze membros, um titular e dois suplentes para cada uma das classes.

Excetuando a classe de titulares de crédito enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, a composição do Comitê é distinta daquela que distingue as classes da assembleia geral, fato que se atribui a defeito no processo legislativo (veja item 108.1).

Na formulação mínima, a classe não representada poderá, posteriormente, indicar seu representante e suplentes, sem a necessidade de convocação da assembleia geral, bastando apresentar ao juiz requerimento nesse sentido, assinado por credores que representem a maioria dos créditos dessa classe (LREF, art. 26, § 2º).

O presidente será eleito pelos próprios membros (LREF, art. 26, § 3º).

107.3. Impedimentos

Os impedimentos dos membros do Comitê de Credores são os mesmos previstos para a nomeação do administrador judicial (veja 106.2, supra).

107.4. Atribuições e deliberações

As decisões do Comitê de Credores são tomadas por maioria e consignadas em livro de ata rubricado pelo juiz da falência, podendo ser consultado pelo administrador judicial, credores, devedor (LREF, art. 27, § 1º) e pelo Ministério Público.

O administrador judicial e o juiz da causa poderão ser chamados a decidir quando não for possível obter a maioria (LREF, art. 27, § 2º), e a intervenção judicial somente se dará nos casos de incompatibilidade do administrador.

ATRIBUIÇÕES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ART.
Apresentar impugnação à relação de credores.	8º

Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados.	27, I, d
Comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores.	27, I, c
Eleger seu presidente.	26, § 3º
Fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 dias, relatório de sua situação.	27, II, a
Fiscalizar a condução da atividade empresarial durante o procedimento da recuperação judicial.	64
Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial.	27, II, b
Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial.	27, I, a
Manifestar-se nas hipóteses previstas na Lei Falimentar.	27, I, f
Manifestar-se sobre os pedidos do devedor de alienação ou sujeição a ônus de bens ou direitos, não previstas no plano de recuperação.	66
Manifestar-se nos procedimentos de impugnação de crédito.	12
Requerer ao juiz a convocação da assembleia geral de credores.	27, I, e
Requerer, em procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores.	19
Submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses	

previstas na Lei Falimentar, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.	27, II, c
Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei.	27, I, b
ATRIBUIÇÕES NA FALÊNCIA	ART.
Apresentar impugnação à relação de credores.	8º
Aprovar os honorários de advogado contratado para representar a massa falida em juízo.	22, III, n
Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados.	27, I, d
Autorizar o administrador judicial a alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida.	114
Autorizar o administrador judicial a cumprir os contratos bilaterais nos casos em que o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos.	117
Autorizar o administrador judicial a dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.	118
Comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores.	27, I, c
Eleger seu presidente.	26, § 3º
Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial.	27, I, a

Manifestar-se nas hipóteses previstas na Lei Falimentar: • acerca de proposta alternativa para a realização do ativo (art. 144); • antes da decisão acerca da modalidade de alienação do ativo (art. 142); • no pedido de autorização para os credores, de forma individual ou coletiva, adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação (art. 111); • no pedido de restituição de coisa arrecadada em poder do falido (art. 87, § 1º); • no pedido de venda imediata de bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa (art. 113); • no requerimento envolvendo ato de disposição ou oneração de bens do falido (art. 99, VI); • nos procedimentos de impugnação de crédito (art. 12); • sobre a restituição de coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor se o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do contrato, dos valores pagos (art. 119, VI); • sobre pedido do administrador judicial que o autorize a transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas (art. 23, § 3º).	27, I, f
Requerer a realização do ativo por outra modalidade de alienação judicial diversa das previstas no art. 142.	144
Requerer ao juiz a convocação da assembleia geral de credores.	27, I, e
Requerer, em procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores.	19
Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei.	27, I, b

107.5. Remuneração

Pelos atos de interesse das classes que representam os membros do Comitê de Credores não são remunerados pela massa concursal nem pelo devedor em recuperação judicial. Significa dizer que cabe aos credores

fornecer meios para sua eficiente atuação.

Cabe-lhes, contudo, o direito ao reembolso de despesas que comprovarem ter despendido para a realização de ato previsto na Lei de Recuperação e Falência. O pagamento será feito pelo devedor em recuperação ou pela massa e, neste último caso, somente quando houver disponibilidade de caixa.

107.6. Substituição e destituição

Além dos casos de substituição e destituição previstos para o administrador judicial (veja item 106.6), o membro do Comitê de Credores pode, ainda, ser substituído por decisão dos credores que representam a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia, apresentando simples requerimento ao juiz da falência (LREF, art. 26, § 2º, II).

107.7. Responsabilidade

O membro do Comitê de Credores é pessoalmente responsável pelos atos que praticar em prejuízo à massa, ao devedor e aos credores, em razão de dolo ou culpa (LREF, art. 32). Como as deliberações são realizadas por colegiado, presume-se que as propostas tenham sido aprovadas por consenso, razão pela qual a lei, com vistas a desobrigar o membro dissidente, exige a consignação de sua discordância em ata.

108. Assembleia geral de credores

A assembleia geral pode ser convocada para deliberar acerca de qualquer matéria que possa afetar os interesses dos credores (LREF, art. 35, II, d), atendendo a despacho judicial em requerimento do administrador (LREF, art. 22, I, g), de credores que representam 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe (LREF, art. 36, § 1º) ou do Comitê de Credores

(LREF, art. 27, e). No primeiro caso, as despesas de convocação correm por conta da massa falida ou do devedor em recuperação judicial (LREF, art. 36, § 3º) e, nos demais, por conta dos credores que convocaram ou da classe que aprovou a deliberação.

Especialmente, deve reunir-se para deliberar sobre (a) a constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros e sua substituição (LREF, art. 35, II, b) e (b) a adoção de outras modalidades de realização do ativo (LREF, art. 35, III, c).

A convocação é realizada por edital publicado no órgão oficial e em jornal de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de quinze dias (LREF, art. 36). Deve constar da publicação o local, data e hora em primeira e em segunda convocação e a ordem do dia, respeitando entre as datas consignadas um lapso de cinco dias. Cópia do aviso de convocação deverá ser afixada na sede e filiais do devedor, de forma ostensiva (LREF, art. 36, § 1º).

A mesa de trabalhos será presidida pelo administrador judicial, e, havendo incompatibilidades, assume o credor presente que seja titular do maior crédito (LREF, art. 37, 1º).

108.1. Classes de credores e direito a voto

A partir da promulgação da Lei Complementar n. 147/2014, quatro são as classes de credores: I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; II – titulares de créditos com garantia real; III – titulares de créditos com privilégio especial, com privilégio geral, quirografários e subordinados; e IV – titulares de créditos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte (LREF, art. 41).

Não participam das deliberações: credores não sujeitos, credores fiscais, credores retardatários ainda não incluídos no momento da homologação do

quadro geral de credores, salvo se forem titulares de crédito derivados da relação de trabalho.

Observe-se que o direito a voto independe de o credor figurar de forma definitiva no quadro geral de credores. Na medida do andamento do procedimento de verificação de créditos o quadro de credores admitidos à assembleia geral pode alterar-se: a) se o quadro geral encontrar-se constituído: todos os arrolados participam; b) se ainda não foi finalizada a verificação dos créditos, somente deliberam os credores constantes da relação provisória apresentada pelo administrador judicial após o decurso do prazo para as habilitações tempestivas; c) se nem mesmo seja possível apresentar a relação provisória, terão direito a voto os credores constantes da relação apresentada pelo devedor.

108.2. Quorum de instalação e de deliberação

Em primeira convocação devem estar presentes mais da metade dos créditos de cada classe, computados por seu valor e, em segunda convocação, qualquer valor.

Como regra geral, exige-se que a proposta obtenha votos favoráveis de credores detentores de mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia (LREF, art. 42). Colhem-se os votos de cada credor presente pelo valor de seu crédito, o que se denomina sistema da proporcionalidade.

Fogem à regra, contudo: a) a deliberação acerca da constituição e de escolha dos membros do Comitê de Credores, em que a maioria é obtida separadamente, por classe; b) a decisão sobre a forma de realização do ativo, em que são exigidos votos favoráveis de credores que representem dois terços do valor total dos créditos presentes à assembleia (LREF, arts. 46 e 145); c) a decisão sobre o plano de recuperação, que exige dupla maioria e maioria por cabeça.

108.3. Sistemas de colheita de votos

À exceção da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação, todas as demais deliberações obedecem ao sistema da proporcionalidade. São as hipóteses previstas no art. 35, I, b, d, e e f, e II, b, c e d, ou seja, (I) na recuperação judicial: constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros e sua substituição; pedido de desistência do devedor; nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores; (II) na falência: constituição do Comitê de Credores; adoção de outras modalidades de realização do ativo; e qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.

Nas questões relativas ao plano de recuperação, além da proporcionalidade, as classes II e III votam segundo sistema da dupla maioria (votam pelo valor de seu crédito e por cabeça) e as classes I e IV (dos credores trabalhistas e acidentários e dos titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte) seguem exclusivamente o voto por cabeça (veja item 108-1).

Há, portanto, três modalidades de colheita de voto: a) voto por cabeça – considera-se apenas o número de credores presentes, independentemente do valor de seus créditos. Assim, votam os credores da classe I (trabalhistas e acidentários) e os credores da classe IV (titulares de créditos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte) na deliberação sobre a recuperação judicial; b) voto proporcional – considera-se o valor do crédito (assim votam os credores com direito real de garantia, classe II, e os demais, classe III, na deliberação da recuperação. É também o voto comum nas demais deliberações) – art. 38; c) dupla maioria – consideram-se os dois sistemas anteriores: voto por cabeça e pelo valor do crédito (assim votam os credores das classes II e III, na deliberação da recuperação).

109. Recuperação judicial – crise econômico-financeira e princípios norteadores

A expressão “econômico-financeira” abrange tanto os males que impedem o empresário de perseguir o objeto de sua empresa como também a insuficiência de recursos para o pagamento das obrigações assumidas.

Fatores externos à atividade empresarial podem acarretar a crise econômica na atividade que, entretanto, não poucas vezes, deriva de causas internas, resultando da má gestão na administração.

Crises econômicas podem acarretar crises financeiras, que se resumem na insuficiência – momentânea ou sistemática – de recursos financeiros para o pagamento dos credores e cumprimento de todas as obrigações assumidas.

Ao atuar preponderantemente sobre a empresa em seu aspecto funcional, os novos instrumentos legais de recuperação em juízo trabalham com os seguintes fundamentos:

- Supremacia da recuperação da empresa (aspecto funcional) sobre o interesse do sujeito da atividade (aspecto subjetivo), permitindo-se o afastamento do empresário e de seus administradores, se sua presença comprometer a eficiência do processo (LREF, art. 64).
- Manutenção da fonte produtora (aspecto objetivo) e do emprego dos trabalhadores (aspecto corporativo), que se verifica com ações efetivas de preservação dos elementos corpóreos e incorpóreos (LREF, art. 66) e vedação à venda ou retirada de bens de propriedade de credores titulares da posição de proprietário fiduciário, de arrendador mercantil, proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, durante o período de suspensão (LREF, art. 49, § 3º).
- Incentivo à manutenção de meios produtivos à empresa, concedendo privilégio geral de recebimento em caso de falência, aos credores quirografários que continuarem a prover bens e serviços à empresa em recuperação (LREF, art. 67, parágrafo único).
- Manutenção dos interesses dos credores (LREF, art. 47), impedindo a desistência do devedor após o deferimento do processamento do pedido de recuperação (LREF, art. 52, § 4º), submetendo à assembleia de credores toda deliberação que afete o interesse dos credores (LREF, art. 35, I, f).

O Projeto do Código Comercial, em tramitação no Congresso Nacional, adota quatro princípios na disciplina da crise da empresa: (I) inerência do

risco a qualquer atividade empresarial; (II) impacto social da crise da empresa; (III) transparência nas medidas de prevenção e solução da crise; e (IV) tratamento paritário dos credores.

Significa dizer:

- a crise pode advir a qualquer atividade econômica, tenha ou não o empresário descuidado de seus deveres na administração de seu negócio. Evidentemente, a crise pode surgir por circunstâncias macroeconômicas adversas, embora o administrador atue com zelo no exercício da empresa.
- a crise atinge a todos: primeiro o seu empresário e, evidentemente os colaboradores (empregados e associados), fornecedores e outros interesses metaindividuais (a localidade ou região em que situado o estabelecimento empresarial; as finanças do Estado, na arrecadação tributária etc.).
- a prevenção e solução da crise deve ser apresentada de forma transparente pelo empresário, a quem somente não se exige revele informações estratégicas de sua empresa.
- os credores devem ser tratados de forma paritária, isto é, os titulares de créditos não podem ser discriminados entre os de igual classe.

110. Sistemas de recuperação em juízo

O instrumento mais amplo de recuperação de empresa em juízo é a modalidade prevista no Capítulo III da Lei n. 11.101, de 2005 (arts. 47-72), a que denominamos recuperação judicial ordinária.

Há, entretanto, outras modalidades: o plano especial (arts. 70-72), os pedidos de homologação de recuperação extrajudicial (arts. 161-166) e, ainda, outras formas de acordo privado entre devedor e seus credores (art. 167).

110.1. Requisitos comuns

Os requisitos comuns a todas as modalidades de recuperação foram estabelecidos no art. 48 da LREF, que, contudo, não se aplicam inteiramente à recuperação extrajudicial. No pressuposto “decorso de prazo” entre um pedido anterior e o atual, há regras especiais para cada modalidade: decurso de pelo menos cinco anos entre a concessão anterior e o novo pedido para a recuperação em juízo (LREF, art. 48, II e III) e de dois

anos para a recuperação extrajudicial (LREF, art. 161, § 3º).

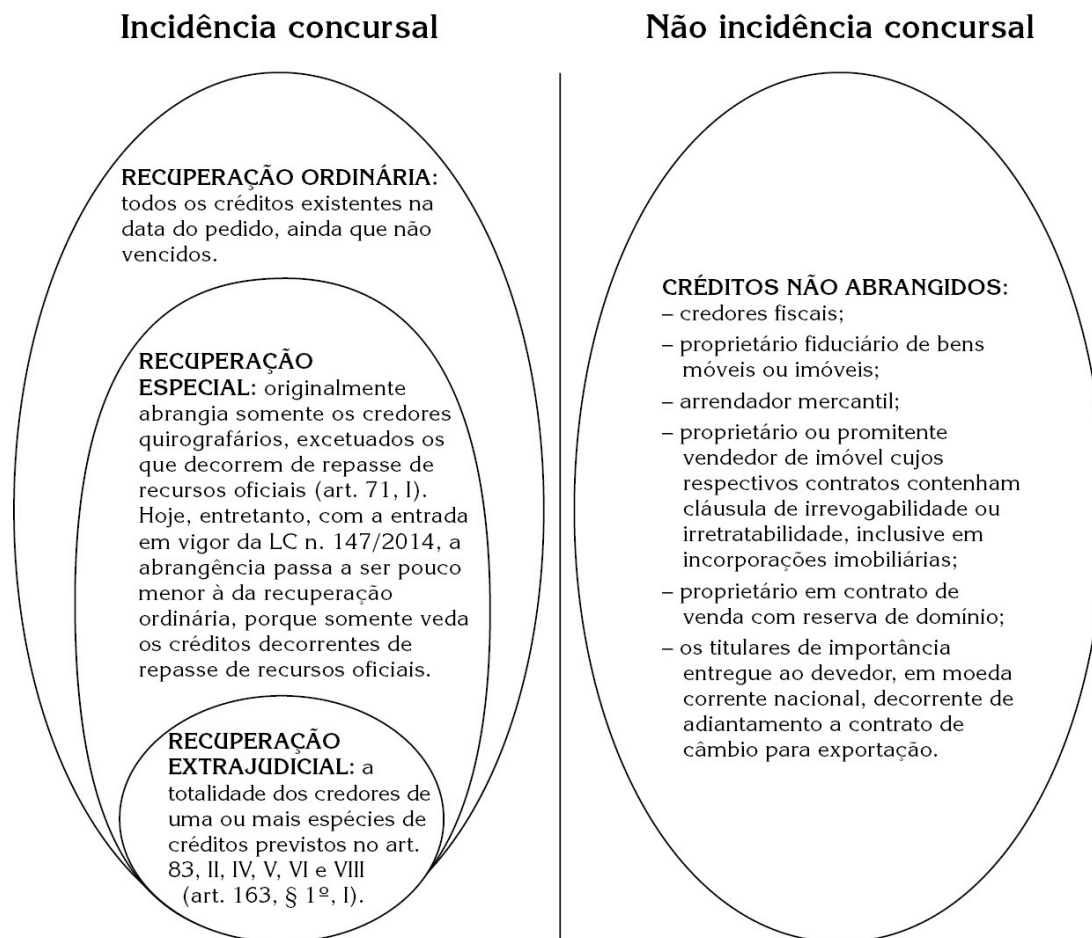
São comuns, portanto, os pressupostos previstos nos incisos I e IV do art. 48: a) não ser falido e, se o foi, demonstração de extinção de suas obrigações, por sentença transitada em julgado; b) não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei de Recuperação e Falência.

110.2. Distinções

Os três instrumentos de recuperação de empresa em juízo distinguem-se nos aspectos relacionados (a) à extensão econômica do exercício empresarial, (b) ao universo de credores, (c) ao curso da prescrição e das ações e execuções individuais dos credores, (d) aos meios de recuperação, (e) ao procedimento, (f) às restrições à administração da empresa.

a) Extensão econômica do exercício empresarial: o plano especial previsto nos arts. 70-72 é reservado tão somente aos microempresários e aos empresários de pequeno porte que, entretanto, podem preferir qualquer outra modalidade dentre as oferecidas pela Lei de Recuperação Falência;

b) Universo de credores: são distintos os continentes de credores sujeitos a cada uma das formas de recuperação em juízo, sendo o mais abrangente o que pertence à recuperação judicial, conforme se pode verificar pela redação dos arts. 49, 163, § 1º, e 71, I, da LREF:



c) Curso da prescrição e das ações e execuções individuais dos credores: a recuperação ordinária suspende o curso da prescrição e, pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive as do sócio solidário (LREF, art. 6º, § 4º). Na modalidade extrajudicial, isso ocorre somente em relação aos sujeitos ao pedido de homologação.

d) Meios de recuperação: no modelo ordinário (arts. 47-69) o devedor pode valer-se de inúmeros meios de recuperação, além dos relacionados no art. 50 da LREF, enquanto o plano especial contempla uma única forma: dilação do prazo para pagamento dos credores, em no máximo trinta e seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros à taxa SELIC, podendo conter ainda proposta de abatimento do valor das dívidas (art. 71, II, na redação dada pela Lei

Complementar n. 147/2014).

e) Procedimento: após a apresentação do pedido, o magistrado determina, em todas as modalidades, publicação para conhecimento dos credores e eventuais objeções no prazo de trinta dias (na recuperação ordinária, art. 55; na especial, art. 72, parágrafo único; e na extrajudicial, art. 164, § 2º).

Este ato processual é, portanto, comum, observando-se, contudo, que o termo inicial os distingue: na recuperação judicial o prazo de trinta dias conta-se da publicação da relação de credores, prevista no § 2º do art. 7º, ou do edital do art. 53. Na recuperação extrajudicial, o prazo de trinta dias conta-se do edital contendo o pedido de homologação.

A partir da apresentação de impugnação os procedimentos tomam rumos distintos, exigindo, para a modalidade ordinária, a convocação da assembleia geral de credores, o que não ocorre no plano especial ou na recuperação extrajudicial.

f) Restrições à administração da empresa: as restrições à livre administração da empresa podem ser classificadas como voluntárias, por imposição assemblear, legal e judicial.

São voluntárias as apresentadas pelo devedor, quando de seu pedido em juízo. É o que ocorre, por exemplo, quando se submete à administração compartilhada (LREF, art. 50, XIV), como meio de recuperação.

São imposições assembleares as deliberadas pela assembleia geral de credores, ao analisar o pedido de recuperação judicial ordinário.

É decorrência legal a regra do art. 66, que veda a alienação ou imposição de ônus sobre os bens do ativo permanente, “salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”.

É judicial a restrição que o magistrado pode impor, no plano especial, exigindo prévia autorização para que o devedor possa aumentar despesas

ou contratar empregado (LREF, art. 71, IV).

111. Pedido inicial e processamento da recuperação

O pedido deve trazer as causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira dele.

À inicial deverão integrar documentos contábeis, relações de credores, empregados, bens e ações judiciais e certidões de regularidade no Registro Público de Empresas e de protestos:

a) Documentos contábeis: referem-se às demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de (1) balanço patrimonial, (2) demonstração de resultados acumulados, (3) demonstração do resultado desde o último exercício social e (4) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção.

b) Extratos atualizados das contas bancárias e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.

c) Livros: a lei não exige expressamente o depósito dos livros empresariais, mas impõe que os documentos sejam mantidos em juízo “na forma e no suporte previstos em lei” (LREF, art. 51, § 1º), o que leva a considerar a necessária apresentação dos livros em que foram inscritos os resultados e informações contábeis, salvo se autorizada a juntada por cópia (LREF, art. 51, § 3º).

d) Quatro relações: (1) relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a

indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; (2) relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; (3) relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; (4) relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.

e) Duas espécies de certidões: (1) regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; (2) dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial.

f) Outros documentos: certidões ou declarações pessoais que demonstrem o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 48 da LREF.

Distribuído o pedido, o magistrado procede ao exame meramente formal dele, podendo determinar o processamento da recuperação, a emenda da inicial ou o cumprimento de alguma diligência que considerar indispensável ao conhecimento da matéria.

São efeitos da decisão que determina o processamento (LREF, art. 52):

a) a nomeação do administrador judicial; b) dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; c) suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, até o prazo de cento e oitenta dias contado do deferimento. A suspensão abrange tão somente as ações e as execuções contra o devedor (que é o empresário individual ou a sociedade empresária); as ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários e coobrigados por fiança, garantia real ou cambial, conforme reiterada

jurisprudência e entendimento sumular n. 581 do STJ; d) impossibilidade de o devedor desistir de seu pedido, salvo se obtiver aprovação na assembleia geral de credores; e) impossibilidade de alienar ou onerar de bens do ativo permanente (LREF, art. 66); f) realização de atos de publicidade, comunicando o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e dos Municípios em que o devedor tiver estabelecimento e publicação de edital em órgão oficial contendo a relação nominal dos credores, com valor atualizado e classificação de cada crédito, bem como a advertência quanto aos prazos de quinze dias para as habilitações tempestivas e do prazo de trinta dias para oferecerem objeção ao plano; g) demonstração mensal por parte do devedor das contas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores.

112. Meios de recuperação

É obrigatória a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, podendo o devedor valer-se da lista oferecida pelo legislador no art. 50 ou apresentar a que melhor lhe parecer conveniente.

A lista exemplificativa do legislador permite uma classificação segundo a Teoria da Empresa. Entre os meios sugeridos há:

Classificação	Meio legal
Meio dilatório ou misto de dilatório e remissório	I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
Meio meramente remissório	XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica.

Meios que agem diretamente sobre o perfil subjetivo da empresa	II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral (...); III – alteração do controle acionário; X – constituição de sociedade de credores;
Meios que agem diretamente sobre o perfil objetivo da empresa	II – (...) cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; VI – aumento do capital social; VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro; XI – venda parcial dos bens; XV – emissão de valores mobiliários; XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.
Meios que agem diretamente sobre o perfil funcional da empresa	IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar; XIII – usufruto da empresa; XIV – administração compartilhada
Meios que agem diretamente sobre o perfil corporativo da empresa	VIII – redução salarial, compensação de horários e redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva

A análise da melhor opção deverá considerar a verdadeira causa da situação da empresa, indicando o remédio jurídico adequado. O exame dessa coerência é matéria de mérito a ser submetida à assembleia geral de credores.

113. Plano de recuperação

O plano de recuperação deverá ser apresentado no prazo improrrogável de sessenta dias, contados da data da decisão que deferiu o processamento e deve conter, além do detalhamento dos meios de recuperação (veja item 112, supra), a demonstração de sua viabilidade econômica, mediante apresentação de documento técnico por especialista da área, possuidor de registro em órgão profissional de administração de empresas, contabilidade ou economia.

Esse parecer técnico deve estar fundamentado em laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens do ativo do devedor que o acompanham (LREF, art. 53, II e III).

114. Impugnação ao plano

Qualquer credor sujeito aos efeitos de recuperação pode apresentar objeção ao plano, devendo fazê-lo no prazo de trinta dias, contados de termos distintos, conforme a situação do procedimento de verificação de crédito (veja item 103, fase inicial): a) se publicado o aviso de recebimento do plano em juízo (LREF, art. 53, parágrafo único), o termo inicial do prazo é a data da publicação da relação de credores apresentada pelo administrador judicial (LREF, arts. 7º, § 2º, e 55); b) se não publicado aquele aviso, o prazo somente começa a correr a partir de sua publicação.

115. Deliberação sobre o plano de recuperação

A assembleia geral somente será convocada se houver objeções ao plano apresentado. Na ausência dessas impugnações, o magistrado decidirá, sem necessidade de ouvir os credores.

A deliberação pelos credores exige a obediência aos seguintes princípios:

- **Universalidade:** todas as quatro classes de credores sujeitos ao plano deverão ser ouvidas e aprovar a proposta. O credor que não sofrer, com o plano, alteração em seus valores ou condições originais de pagamento de seu crédito não terá direito a voto e não pode ser considerado para fins de verificação de quorum de deliberação.

- **Voto exclusivamente por cabeça:** nas classes I e IV, a proposta deverá ser aprovada por maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.
- **Voto por dupla maioria:** nas classes II e III, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

Entre as duas situações extremas – ausência e existência de impugnações dos credores – que convergem para uma das duas formas de deliberação, tácita ou assemblear, há uma terceira, mista de ambas. É o que ocorre na hipótese de, tendo havido impugnação, na assembleia geral de credores não se obter votos suficientes para aprovação ou rejeição do plano. Cabe ao magistrado verificar a presença dos requisitos legais que lhe permitem aprovar o plano. Convencionei denominar esta modalidade de deliberação assemblear-judicial.

É possível, portanto, distinguir três formas de aprovação do plano de recuperação:

a) aprovação tácita: pelo decurso do prazo de trinta dias da publicação do aviso do art. 53, parágrafo único, ou do edital do art. 7º, § 2º, sem objeções por parte dos credores ou do Ministério Público (art. 55);

b) aprovação assemblear: aprovação por todas as classes submetidas ao plano: 1) maioria simples dos credores derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho, presentes à assembleia, independentemente do valor do crédito; 2) mais da metade do valor total dos créditos dos titulares de créditos com garantia real presentes à assembleia e, cumulativamente, maioria simples dos credores presentes; 3) mais da metade do valor total dos créditos dos titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados presentes à assembleia e, cumulativamente, maioria simples dos credores presentes; 4) maioria simples dos credores titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte; e

c) aprovação assemblear-judicial: obtenção de: 1) voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos

presentes à assembleia, independentemente de classes; 2) a aprovação de duas classes de credores nos termos do art. 45, se houver mais de duas classes votantes e de uma classe, se forem apenas duas votantes; 3) o voto favorável de mais de um terço dos credores na classe que houver rejeitado o plano, respeitada a forma de computação dos votos prevista nos §§ 1º e 2º do art. 45.

Aprovado o plano, o devedor deve apresentar certidões negativas de débitos tributários (LREF, art. 57), seguindo-se, então, à prolação de sentença de concessão (LREF, art. 58).

116. Cumprimento da recuperação judicial

O devedor permanece em estado de recuperação judicial por dois anos, contados da data de concessão, devendo, nesse período, cumprir as obrigações previstas no plano aprovado.

Durante esse biênio, o descumprimento de qualquer cláusula acarreta a convolação em falência. Se cumpridas as obrigações, o magistrado proferirá sentença, decretando o encerramento da recuperação judicial e determinando (LREF, art. 63): I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial; II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas; III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de quinze dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor; IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial; V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis.

Depois de decorrido o biênio, se o devedor deixar de cumprir obrigação prevista no plano de recuperação, não cabe providência no âmbito da universalidade de credores, mas execução individual, em processo autônomo, ou pedido de falência do devedor, nos termos do art. 94, III, g.

117. Conversão da concordata em recuperação judicial

A lei prevê a conversão de concordata em recuperação judicial (LREF, art. 192, § 2º), vedando, contudo, pedido baseado no plano especial de recuperação. Significa dizer que os concordatários somente poderão requerer a recuperação judicial na modalidade mais ampla, aqui denominada ordinária.

Outra questão refere-se à qualificação da concordata que pode assumir uma das duas formas legais: preventiva ou suspensiva. A Lei n. 11.101, de 2005, não especifica o tipo de concordata, mas é possível responder que somente o devedor sob regime de concordata preventiva poderá requerer recuperação judicial, o que decorre da obediência ao requisito geral previsto no art. 48, I: não ser falido e se o foi estarem extintas suas obrigações. O devedor em concordata suspensiva é falido que teve a decisão de quebra suspensa e, portanto, não pode valer-se do pedido de conversão legal.

Em resumo: o devedor – de qualquer porte: microempresário, empresário de pequeno porte ou grande empresário – que cumpre regularmente suas obrigações no âmbito de processo de concordata preventiva pode valer-se de pedido de recuperação judicial, desde que o requeira na modalidade ordinária. É vedado o acesso: a) ao devedor que descumpriu obrigações no processo de concordata preventiva; b) ao devedor em regime de concordata suspensiva; c) à recuperação judicial na modalidade de plano especial previsto nos arts. 70-72.

118. Recuperação judicial especial

Os requisitos dos arts. 48 e 51 e as regras de processamento são comuns às modalidades de recuperação judicial ordinária e especial, impondo ao devedor que declare sua intenção de valer-se do procedimento especial ao apresentar seu pedido inicial, comprovando uma daquelas condições – microempresário ou empresário de pequeno porte (LREF, art. 70, § 1º).

As principais distinções entre os planos de recuperação judicial ordinário e especial são: a) a legitimidade ativa para o plano especial, destinado aos microempresários e empresários de pequeno porte; b) a extensão do universo de credores abrangidos; c) a simplificação do procedimento; e d) a possibilidade de adoção de um único meio de recuperação – dilatatório/remissório: dilação do prazo para pagamento dos credores em até 36 meses e proposta de abatimento do valor das dívidas.

119. Recuperação extrajudicial

A proposta e a negociação de meios que proporcionem ao devedor a recuperação de seu empreendimento são realizadas diretamente com os credores, antes de sua homologação em juízo.

A LREF impõe certos limites à elaboração e aos efeitos do plano extrajudicial: a) proíbe contemplar o pagamento antecipado de dívidas e o tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos (art. 161, § 2º); b) não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade de pedido de decretação de falência pelos credores que não lhe são sujeitos (art. 161, § 4º); c) veda pedido contemporâneo a outro de recuperação judicial pendente ou, ainda, sucessivo a outro de recuperação em juízo, obtido ou homologado há menos de dois anos (art. 161, § 3º); d) impede a desistência da adesão após a distribuição do pedido em juízo, salvo na hipótese de todos os demais signatários anuírem expressamente (art. 161, § 5º).

119.1. Modalidades

São duas as modalidades de plano de recuperação extrajudicial que podem ser apresentadas por instrumento público ou particular: o individualizado e por classe de credores.

O primeiro restringe-se à adesão individual de credores a certos termos e

condições (LREF, art. 162).

O segundo é obtido pela assinatura de credores que representem mais de três quintos de todos os créditos constituídos até a data do pedido, de uma ou mais classes entre as previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 83 (estão excluídas as classes de trabalhadores e de créditos tributários), obrigando a totalidade dos credores da espécie consignada no documento de adesão.

O percentual de 60% (três quintos) é obtido da seguinte forma: a) somam-se todos os credores da classe, levando-se em conta o valor e condições originais de pagamentos dos credores não aderentes ao plano e o valor dos créditos por ele abrangidos (LREF, art. 163, § 2º); b) o crédito em moeda estrangeira é convertido em moeda nacional pelo câmbio da véspera da data da assinatura do plano (LREF, art. 163, § 2º, I); c) não se computam os créditos dos sócios do devedor, das sociedades coligadas, controladoras, controladas ou das que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social (LREF, arts. 163, § 2º, II, e 43).

119.2. Efeitos

Homologado por sentença, o plano gera efeitos imediatos (LREF, art. 165), que não se suspendem pela interposição de recursos (LREF, art. 164, § 7º): a) constitui-se título executivo judicial (LREF, art. 161, § 6º); b) impede a alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição sem a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (LREF, art. 163, § 4º); c) mantém a variação cambial dos créditos em moeda estrangeira, salvo se o credor titular aprovar mudança, inserindo-a no plano de recuperação extrajudicial (LREF, art. 163, § 5º); d) se pactuado, pode alcançar efeitos anteriores à homologação, limitadamente à modificação do valor ou da forma de pagamento dos

credores signatários (LREF, art. 165, § 1º); e) ao estabelecer a alienação judicial de filiais ou unidades produtivas do devedor, a forma de venda obedecerá ao que dispõe o art. 142, que é regra geral para a mesma ocorrência em todas as modalidades de recuperação em juízo e no processo de falência (LREF, art. 166).

119.3. Documentação

Ao pedido, contendo justificativa, devem acompanhar: a) documento que contenha termos e condições do plano, subscrito pelos credores; b) exposição da situação patrimonial do devedor; c) demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do inciso II do art. 51 da LREF; d) documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.

119.4. Procedimento

Distribuído o pedido, o magistrado determina a publicação de edital em órgão oficial e, conforme a expressão nacional ou regional da empresa, em jornal de grande circulação nacional ou, das localidades da sede e filias do devedor, convocando todos os credores a apresentarem eventuais impugnações no prazo de trinta dias.

As impugnações devem limitar-se às seguintes alegações: a) não preenchimento do percentual mínimo; b) prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 (prática de atos de insolvência) ou do art. 130 (atos revogáveis) da LREF, ou descumprimento de requisito nela previsto; c) descumprimento de qualquer outra exigência legal.

O devedor terá vista nos autos de impugnação por cinco dias, voltando os autos conclusos ao magistrado para decidir no quinquídio subsequente, homologando ou indeferindo o pedido, cabendo apelação, sem efeito suspensivo.

Se o pedido for indeferido, devolve-se aos credores o direito de exigir o valor original sem alterações, deduzindo-se eventuais valores pagos aos credores (LREF, art. 165, § 2º).

120. Convolação da recuperação em falência

São causas que acarretam a decretação da falência do devedor em recuperação judicial: a) a não apresentação do plano no prazo improrrogável de sessenta dias depois da publicação da decisão que deferir o processamento; b) apresentação do plano e sua rejeição pela assembleia geral; c) deliberação da assembleia geral: que se distingue da anterior, no tocante ao momento e ao quorum. Neste caso, a deliberação pela decretação da falência é aprovada pelos votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia geral, em oportunidade diversa daquela que deliberou acerca do plano de recuperação judicial. Não se trata aqui de se deliberar sobre o plano, mas sim de assembleia convocada especialmente para o fim de discutir e aprovar a resolução do regime e sua convolação em falência; d) descumprimento das obrigações no biênio após a concessão.

121. Pedido de falência

O pedido de falência pode ser incidental à recuperação judicial ou, ainda, autônomo, promovido pelo próprio devedor ou por credor ou credores em litisconsórcio que apresentem um ou mais títulos executivos protestados que somem valor superior a quarenta salários mínimos, na data do pedido.

121.1. Natureza da dívida

Os credores requerentes da falência podem ser empresários ou não, e o título que apresentarem em juízo para legitimar seu pedido não necessita ter origem negocial. O credor que não ostenta a qualidade de empresário estará tão legitimado quanto aquele que ostenta essa qualidade. O que se objetiva não é a discussão em torno de um crédito em particular, mas a garantia de sobrevivência do instituto do crédito e a proteção da atividade econômica como um todo. Sob esta ótica, pouco importa saber se a dívida é ou não empresarial.

121.2. Credor empresário

Se o credor for empresário, com domicílio no Brasil, deve demonstrar sua regularidade, o que se cumpre com a apresentação de documento de arquivamento de seus atos constitutivos ou de sua declaração de firma individual, por certidão expedida pela Junta Comercial.

121.3. Credor domiciliado no exterior

O credor sem domicílio no Brasil deve prestar caução para pagamento de eventuais perdas e danos devidos ao requerido, o que se determinará em decisão que julgar improcedente o pedido (veja item 124.1).

121.4. Legitimidade ativa

Neste particular, não há mais qualquer distinção entre credores quirografários, trabalhistas ou com garantia real. Todos podem requerer a falência do devedor, apresentando prova de sua condição de credor.

Dúvida há quanto ao credor fiscal, persistindo as discussões doutrinárias a respeito do tema. Há os que entendem possível o pedido falimentar tendo por sujeito ativo o credor tributário. Dessa linha pertencem Fábio Konder Comparato (1972:48-54), Fazzio Júnior (1999:105 e 2005:252), Amador

Paes de Almeida (1998:59) e os votos dos Ministros Costa Leite e Eduardo Ribeiro (REsp 10.660-MG, em 12-12-1995). Em outra vertente, à qual nos filiamos (2005(a):12), em sentido contrário, sustentando a ausência de legítimo interesse em a Fazenda Pública requerer a falência do devedor-contribuinte, estão Rubens Requião (1975:90) e o Ministro Cláudio Santos, do Superior Tribunal de Justiça (voto vencido no REsp 10.660-MG, julgado em 12-12-1995).

121.5. Cônjuge, herdeiros e inventariante

Além dos credores, podem requerer a falência o cônjuge sobrevivente, herdeiros e inventariante (LREF, art. 97, II), suspendendo-se o processo do inventário a partir do decreto falimentar (LREF, art. 125), efeito que decorre da perda da administração e da arrecadação dos bens do falido.

Em relação ao cônjuge sobrevivente, como adverte Miranda Valverde (1999:153), “só quando ele tem interesses econômicos ligados ao espólio, em consequência do regime de casamento, é que lhe assiste o direito de requerer a falência do espólio”.

121.6. Sócios e acionista da sociedade requerida

Segundo o art. 97, III, a condição de sócio ou acionista possibilita apresentar pedido de falência da sociedade das quais participem, afirmação que apresenta certa dificuldade, uma vez que a sociedade é representada por seus administradores.

Evidencia-se que os sócios ou acionistas não agem como representantes da sociedade. Tampouco requerem na qualidade de credores, porque, neste caso, o legislador não precisaria explicitar sua qualidade.

Apresentamos a seguinte solução: o dispositivo refere-se à legitimidade decorrente da inércia dos órgãos responsáveis ou concede legitimidade concorrente para os casos em que a lei permite ao sócio o pedido de

dissolução de sociedades. No que se refere aos acionistas, a legitimação estaria fundamentada na ocorrência de atos violadores da lei ou do estatuto e se demonstrados indícios de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da administração da companhia (LSA, art. 105) e se a sociedade, em grave crise econômico-financeira, não preencher seu fim (LSA, art. 206, II, b).

121.7. Legitimidade passiva

A matéria foi tratada no item 98, quando discorreremos sobre casos de incidência e não incidência.

122. Procedimentos pré-falimentares

São três os procedimentos pré-falimentares previstos: a) falência requerida com base na impontualidade ou na frustração de execução (art. 94, I e II); b) falência requerida em razão da ocorrência de atos denominados falenciais, eleitos pelo legislador (art. 94, III); e c) pedido de autofalência (art. 105).

Nos pedidos iniciados pelos credores, “feita a citação por editais e ocorrendo à revelia é necessária a nomeação de curador especial ao devedor” (Súmula 38 do TJSP). A citação ficta se dá sempre “se o devedor não for encontrado em seu estabelecimento”, “independentemente de quaisquer outras diligências” (Súmula 51do TJSP).

122.1. Falência requerida com base na impontualidade ou na frustração da execução (art. 94, I e II)

Caracteriza o pedido fundado no art. 94, I e II, a necessidade de o autor do pedido trazer prova pré-constituída da situação do devedor: títulos e certidões correspondentes à situação descrita. Deve o autor, portanto, demonstrar desde logo que o requerido não pagou e teve protestado título

executivo de valor superior a quarenta salários mínimos ou, ainda, que foi executado e não pagou, nem depositou e não nomeou bens à penhora no prazo de três dias estabelecido no art. 829 do Código de Processo Civil de 2015.

Anote-se que “o protesto comum dispensa o especial para o requerimento de falência” (Súmula 41 do TJSP). Para ter validade, o recibo de notificação deve ser assinado por pessoa identificada (Súmula 52 do TJSP e Súmula 361 do STJ), seja ou não administradora da sociedade.

Observe que se distinguem as hipóteses desses incisos: no inc. I, a lei exige o protesto dos títulos e, ainda, que seu valor seja superior a quarenta salários mínimos e, no inc. II, pouco importa o valor dos títulos e não é necessário o protesto:

Súmula 39 do TJSP: “No pedido de falência fundado em execução frustrada é irrelevante o valor da obrigação não satisfeita”.

Súmula 50 do TJSP: “No pedido de falência com fundamento na execução frustrada ou nos atos de falência não é necessário o protesto do título executivo”.

Um requisito processual para o pedido de falência fundando no inc. II é a suspensão da execução singular anteriormente aforada (Súmula 48 do TJSP).

Outra característica é a possibilidade de o devedor, no prazo de contestação, dez dias (LREF, art. 98), depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Esse depósito, contudo, “não afasta a obrigação do exame do pedido de falência para definir quem o levanta” (Súmula 40 do TJSP).

Algumas linhas de defesa foram relacionadas pelo legislador (LREF, art. 96) que, contudo, não esgotam as possibilidades das matérias, preliminares e de fundo, que podem ser objeto da contestação.

122.2. Falência requerida em razão da ocorrência de atos denominados falenciais, eleitos pelo legislador (art. 94, III)

Os sete casos mencionados no inciso III do art. 94 são denominados atos de insolvência ou de falência, não admitem ampliação analógica e podem suscitar a necessidade de instrução probatória para sua demonstração em juízo.

É considerada indicação de falência a prática dos seguintes atos pelo devedor: a) liquidação precipitada de seus ativos ou lançar mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realização ou, por atos inequívocos, tentativa de realização, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, de negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transferência de estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) simulação de transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dação ou reforço de garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausência sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandono de estabelecimento ou tentativa de ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) descumprimento, no prazo estabelecido, de obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

Citado, o devedor deve apresentar sua defesa no prazo de dez dias (LREF, art. 98), seguindo-se o procedimento ordinário.

122.3. Pedido de autofalência (art. 105)

O devedor em crise econômico-financeira deve requerer sua própria falência e, para tanto, em petição inicial apresentará as razões da

impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, juntando documentos que servirão não somente para demonstrar a causa de seu pedido, como também trazer elementos que permitam dar ao processo falimentar transparência e celeridade: I – demonstrações contábeis referentes aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade; IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI – relação de seus administradores nos últimos cinco anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

O pedido de autofalência constitui dever do empresário em crise para o qual não se impõe qualquer pena. O pedido de autofalência é confissão, ato pessoal do devedor que julgue não atender aos requisitos da recuperação judicial, e, como tal, deve ser aceito quando presentes os elementos formais exigidos no art. 105. O magistrado deve ater-se tão somente ao exame formal.

A lei não tratou de incidentes ao pedido. Há, contudo, possibilidade de se vislumbrar algumas situações: a) Pedido promovido por espólio pode ensejar oposição de herdeiros que entendem não ser o caso de decretação de falência, ou, ainda, requeiram a recuperação judicial da empresa? b) Pedido feito por um dos sócios de sociedade empresária, havendo outros sócios, que não outorgaram poderes ao advogado requerente. Estes podem

apresentar oposição e, eventualmente, recuperação judicial? c) Sócios com responsabilidade ilimitada que não anuíram ao pedido inicial devem ser citados?

Em todos estes casos respondemos afirmativamente, porque as pessoas mencionadas detêm legitimidade para requerimento autônomo, e, portanto, nada impede que o façam incidentalmente ao pedido anteriormente distribuído. Na hipótese de sócios com responsabilidade ilimitada, sua citação é indispensável, tendo em vista os efeitos da sentença de quebra sobre seus bens (LREF, art. 81).

123. Recuperação judicial incidental

No prazo de contestação, o devedor – e, no nosso entendimento, o sócio, o cônjuge sobrevivente, os herdeiros, o inventariante – pode pleitear sua recuperação judicial, devendo fazê-lo segundo o procedimento que escolher, apresentando a documentação necessária (veja item 111).

124. Sentença judicial e recursos

A decisão que decreta a falência deve conter requisitos comuns às sentenças judiciais (CPC15, art. 489) e especiais, previstos no art. 99 da LREF.

Requisitos comuns: a) o relatório, que conterá o nome das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; b) os fundamentos, nos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito; e c) o dispositivo, onde serão resolvidas pelo magistrado as questões que as partes lhe submeteram.

Requisitos especiais: a) síntese do pedido, identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores; b) termo legal da falência, que deverá ser fixado em período até noventa dias anteriores aos

seguintes eventos: pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou primeiro protesto por falta de pagamento; c) determinação para que o falido apresente, no prazo máximo de cinco dias, relação nominal dos credores, sob pena de desobediência; d) fixação do prazo de quinze dias para as habilitações de crédito; e) suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor falido, salvo as que demandarem quantia ilíquida, ações de conhecimento decorrente das relações de trabalho, bem como todas aquelas que não se sujeitam aos princípios da indivisibilidade e da universalidade; f) proibição de prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido; g) determinação de lacração dos estabelecimentos empresariais do falido ou autorização, se convier à massa, de continuação provisória do negócio do falido com o administrador judicial; h) determinação de diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, como a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, conservação de bens ou manutenção de contratos de interesse da massa, em respeito aos princípios da celeridade, economia processual (LREF, art. 75, § 1º) e, ainda, atendendo “à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores” (LREF, art. 126); i) anotação da falência no registro público de empresas; j) nomeação de administrador judicial; l) determinação de expedição de ofício aos órgãos e repartições público e outras entidade; m) convocação da assembleia geral de credores para constituição de Comitê de Credores, se entender conveniente; n) notificação pessoal do Ministério Público e comunicação por carta às Fazendas Públicas.

124.1. Indenização

Na hipótese de ficar configurado dolo na propositura, o magistrado deve indicar, na sentença de improcedência do pedido falimentar, os atos caracterizadores da conduta dolosa que afastem a presunção de boa-fé ou de erro escusável e fixar o valor da indenização devida ao requerido ou, se

não for possível, postergar sua apuração à fase de liquidação da sentença.

124.2. Recursos

São poucos os recursos previstos na Lei Falimentar. Além do agravo para a decisão que decreta a falência e da apelação para a que julga a improcedência do pedido, outros recursos são listados abaixo, permitindo um rápido conhecimento da matéria.

Recurso	Decisão recorrida	Art.
Agravo	Decisão que julga impugnação de crédito ou divergência na lista	17
Agravo	Decisão que concede a recuperação judicial	59, § 2º
Agravo	Decisão que decreta a falência	100
Apelação	Decisão que julga improcedente pedido de falência	100
Apelação	Decisão que julga as contas do administrador judicial	154, § 5º
Apelação	Decisão que julga encerrada a falência	156
Apelação	Decisão que julga o pedido de extinção das obrigações do falido	159, § 5º

Para a sentença que decreta a falência cabe agravo de instrumento, com o rito marcado no Código de Processo Civil, podendo ser promovido por credor, devedor, Ministério Público ou terceiro prejudicado, sendo possível referir-se a todos ou somente a alguns pontos da sentença.

Para a sentença denegatória, o recurso é de apelação e legitimados estão o devedor, os credores e Ministério Público. Por que o devedor? Seu interesse pode estar na decretação da falência – na hipótese de pedido de autofalência – ou, nos processos em que foi requerido, pretender a fixação, complementação ou levantamento do valor da indenização de que trata o

art. 101, ou, ainda, o deferimento do pedido incidental de recuperação judicial, podendo o recurso limitar-se aos termos dessa autorização.

Observa-se, entretanto, a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 “no que couber” (LREF, art. 189), permitindo-se a interposição de recursos previstos na legislação processual comum, tais como embargos de declaração (CPC15, arts. 1.022-1.026) e agravo de instrumento, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015.

Os prazos recursais contam-se da intimação da parte recorrente (Súmula 25 do STJ).

125. Efeitos da falência sobre os credores

Com a falência, a situação jurídica do devedor se altera, gerando efeitos sobre o direito dos credores em relação aos negócios jurídicos anteriormente firmados: a) suspensão do curso da prescrição; b) suspensão das ações e execuções individuais dos credores; c) vencimento antecipado das dívidas do devedor; d) formação da massa de credores; e) suspensão do direito de retenção; f) suspensão da fluência de juros; e g) alteração de direito relativa a coobrigados solidários.

125.1. Suspensão do curso da prescrição

A regra trata apenas da prescrição, não alcançando os prazos decadenciais que não se interrompem nem se suspendem.

O curso da prescrição está suspenso a partir da decretação da falência, retomando sua fluência a partir da data em que transitar em julgado a sentença de encerramento da falência (LREF, art. 157). O período que antecede o decreto falimentar será somado ao período que transcorrer a partir da data do trânsito em julgado da sentença de encerramento.

Esta suspensão alcança as obrigações de responsabilidade do devedor, e, na sociedade com sócio de responsabilidade ilimitada, as obrigações desses

sócios. As dívidas ativas, aquelas em que o falido ou os sócios da falida com responsabilidade ilimitada são credores, o prazo corre normalmente.

125.2. Suspensão das ações e execuções individuais dos credores

O concurso de todos os credores do falido acarreta a suspensão das ações e execuções individuais.

As ações que venham a ser propostas contra o devedor falido ou contra sócios com responsabilidade ilimitada deverão ser comunicadas ao juízo da falência, obrigação que se impõe tanto ao magistrado que receber a petição inicial como também ao devedor tão logo receba o mandado citatório (LREF, art. 6º, § 6º).

As exceções são as mesmas da recuperação judicial: a) se o credor demandar quantia ilíquida; b) as ações relativas a créditos oriundos de natureza trabalhista, até sua apuração em sentença no juízo trabalhista.

Não há previsão legal, mas, atendendo aos princípios da celeridade e da economia processual (LREF, art. 75, parágrafo único), as execuções individuais, com bens em praça, com dia definitivo para a arrematação, não serão atraídas ao juízo indivisível da falência, nem serão suspensas. O administrador judicial será intimado para acompanhar a tramitação, sob pena de nulidade do processo (LREF, art. 76), cuidando para que o numerário apurado venha a juntar-se aos depósitos bancários eventualmente realizados.

125.3. Vencimento antecipado das dívidas

As dívidas do falido e dos sócios com responsabilidade ilimitada vencem-se antecipadamente com o decreto falimentar (LREF, art. 77), e, neste caso, os juros contratados ou legais devem ser abatidos, de forma proporcional ao período antecipado.

Em relação aos contratos em moeda estrangeira, a conversão em moeda

nacional deve ser feita pelo câmbio do dia em que for declarada a falência e, se não houver preço fixado pelo Banco Central neste dia, a conversão se dará no primeiro dia de cotação após esta data. A conversão, contudo, não aproveita aos fiadores e garantidores do falido, contra os quais se operará pelo câmbio do dia do efetivo pagamento.

A situação do garantidor é melancólica: pagando o título pelo preço maior (conversão na data do pagamento) somente pode sub-rogar-se contra o devedor principal (falido) até o limite do valor correspondente à conversão na data da falência.

125.4. Formação da massa de credores

Concorrem ao concurso falencial todos os credores comuns do devedor falido e dos sócios com responsabilidade ilimitada, submetendo-se ao quadro geral, de acordo com a classificação que seu crédito comportar (LREF, arts. 115 e 7º, § 1º).

A regra universal comporta exceções. Há créditos que não podem ser exigidos na falência: a) as obrigações a título gratuito (LREF, art. 5º, I); b) as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na falência, salvo custas judiciais em litígio com o devedor (LREF, art. 5º, II).

125.5. Suspensão do direito de retenção

Com a falência está suspenso o direito de retenção, devendo a coisa retida ser arrecadada pela massa (LREF, art. 116, I). Direito de retenção é a guarda de coisa alheia em garantia enquanto não satisfeita, a favor daquele que a retém, obrigação lícita prevista na lei ou em contrato.

O credor que, por força de exercício do direito de retenção, mantiver em seu poder coisa sujeita a arrecadação deverá, a partir da decretação da falência, entregá-la ao administrador judicial, podendo habilitar seu crédito junto à massa, na classe dos créditos com privilégio especial (LREF, art. 83,

IV, c).

125.6. Suspensão da fluência de juros

A falência suspende a fluência de juros a partir da decretação (LREF, art. 124), podendo ser retomada se o ativo comportar, uma vez realizado o pagamento do crédito principal a todos os credores.

A hipótese contempla juros contratados ou legais que incidem após a sentença de quebra. Os juros até a data da falência já estarão calculados na inclusão dos créditos habilitados.

Há uma exceção: os juros das debêntures e dos créditos com garantia real terão seu pagamento subordinado exclusivamente ao “produto dos bens que constituem a garantia”. Contudo, essa exceção somente tem aplicação após paga a classe imediatamente superior, a dos credores derivados da legislação do trabalho (LREF, art. 83, I). A precedência do crédito trabalhista inviabiliza o recebimento dos valores referentes à dívida principal e aos juros do credor com direito real de garantia, sem que primeiro sejam satisfeitos os credores laborais. Se, entretanto, pagos os credores trabalhistas e os extraconcursais (LREF, art. 84), nada obsta a que, restando garantias, sejam estas atribuídas exclusivamente aos credores com garantia real.

Atenção: a expressão “debêntures” é aqui restrita às emitidas com garantia real e não às outras espécies (debêntures com garantias flutuantes, debêntures sem garantia e debêntures subordinadas).

125.7. Alteração de direito relativa a coobrigados solidários

Se o credor dispuser de título sujeito ao concurso de duas ou mais falências por dívida solidária de seus devedores agora falidos pode habilitá-lo em cada uma das massas falidas. Recebendo parcialmente o crédito, o valor será anotado no título pelos administradores judiciais respectivos,

cabendo ao credor a obrigação de comunicar o quanto já recebido.

Se ficar integralmente satisfeito por uma ou algumas massas coobrigadas, as massas que pagaram terão direito de regresso em relação às demais, de forma proporcional, considerando seu encargo e o que pagou a mais. Recebendo mais do que lhe era devido, o credor deve, espontaneamente, devolver o valor às massas, na mesma proporção, sob pena de sua omissão ser havida como maliciosa, obrigando-o a restituir em dobro a quantia recebida, acrescida de juros legais (LREF, art. 152).

A Lei de Recuperação e Falência ressalva a hipótese de uma das massas garantir outra, estabelecendo o respeito à ordem das obrigações (art. 127, § 4º). É o que ocorre, por exemplo, na emissão de uma nota promissória, circulando e possuindo dois outros endossantes, além do sacador. O último endossante C exercerá o direito de ser ressarcido por B ou por A e este, por sua vez, somente poderá valer-se contra o sacador A. Sendo todos falidos e tendo o credor por dívida solidária, D (portador do título), habilitado o valor integral em todas as massas, recebendo integralmente o débito, em cotas pagas por algumas massas devedoras ou por uma delas, o direito de regresso de umas para com as outras massas respeitará a posição do garantidor, na ordem que o título lhes confere.

Deve-se atentar, ainda, para o fato de que nem sempre a responsabilidade das massas é idêntica, podendo haver massas solidárias devedoras por valores distintos.

Se o garantidor do devedor ou dos sócios com responsabilidade ilimitada é solvente e pagar a dívida, permite-se a habilitação das “quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal”. Seu direito é de sub-rogação dos direitos do credor que dele recebeu o crédito. Desembolsando quantias superiores ou não admitidas na falência, ficará limitado, em sua habilitação, ao montante admitido pela Lei Falimentar.

126. Efeitos da falência sobre a pessoa do falido

O empresário individual falido, os sócios com responsabilidade ilimitada e os administradores e controladores da sociedade empresarial falida sujeitam-se, com maior ou menor intensidade, a certas restrições e obrigações que, descumpridas, podem acarretar sanções de ordem administrativa, processual ou criminal.

Por outro lado, alguns direitos são expressamente indicados na legislação, sob pena de nulidade do ato praticado.

126.1. Restrições impostas

A decretação da falência implica limitação temporária de determinados direitos, restrita ao período falimentar, alcançando: a) a perda do direito à livre administração e disponibilidade de seus bens (LREF, art. 103); b) a perda da legitimatio ad causam para as ações sobre esses mesmos bens (LREF, art. 76, parágrafo único); c) a proibição ou exoneração do exercício da tutela e da curatela (CC, arts. 1.735, I, e 1.774); d) a proibição para o exercício de qualquer atividade empresarial (LREF, art. 102); e) a proibição para o exercício das profissões de corretor de seguros (art. 3º, d, da Lei n. 4.594, de 29-12-1964), de corretor de navios (art. 20 do Decreto n. 20.881, de 30-12-1931), de leiloeiro (art. 3º, c, do Decreto n. 21.981, de 19-10-1932); f) a perda do direito de sigilo de seus livros e da sua correspondência, no que for de interesse da massa (LREF, arts. 22, III, d, e 104, II).

Se condenado por crime previsto na Lei de Recuperação e Falência, dependendo dos efeitos considerados na sentença criminal, as restrições pessoais podem perdurar por tempo além do período falimentar, impedindo o devedor, até sua extinção, de exercer algumas outras atividades, tais como: a) empresário, administrador ou fiéis de armazéns gerais (art. 1º, § 5º, do Decreto n. 1.102, de 1903); b) exercício de mandato, de gestão de negócios ou das funções de gerente, membro do Conselho de Administração ou de Diretoria de qualquer sociedade empresarial (art. 35, II, da Lei n.

8.934/94 c/c os arts. 147, § 1º, da Lei n. 6.404/76 e 181 da LREF).

126.2. Obrigações impostas

O art. 104 da LREF impõe ao falido obrigações que podem ser classificadas como:

(1) obrigações de entregar bens, livros, papéis e relação de credores (incisos II, V, XI);

(2) obrigações de fazer, visando ao bom e ágil andamento do processo falimentar (incisos I – assinar termo de comparecimento e declaração, IV – comparecer a todos os atos, VI – prestar informações, VII – auxiliar o administrador judicial, VIII – examinar as habilitações de crédito, IX – assistir à verificação dos balanços e ao exame dos livros, X – manifestar-se sempre que determinado, XII – examinar e dar parecer sobre as contas); e,

(3) obrigações de se abster de ato, consistente em não se ausentar do domicílio falimentar (inciso III).

126.3. Direitos atribuídos

Entre os direitos do falido de dos sócios com responsabilidade ilimitada destacam-se os de: a) apresentar impugnação contra a relação de credores (LREF, art. 8º); b) participar da assembleia geral de credores, sem direito a voto (LREF, art. 43); c) manifestar-se nos autos de restituição (LREF, art. 87, § 1º); d) requerer o levantamento de sua inabilitação para a atividade empresarial (LREF, art. 102, parágrafo único); e) fiscalizar a administração da massa (LREF, art. 103, parágrafo único); f) requerer providências conservatórias de seus direitos ou dos bens arrecadados (LREF, art. 103, parágrafo único); g) intervir como assistente, nos processos em que a massa seja parte ou interessada, e interpor os recursos cabíveis (LREF, art. 103, parágrafo único); h) acompanhar a arrecadação e a avaliação (LREF, art. 108, § 2º); i) receber o saldo, se houver, depois de pagos todos os

credores (LREF, art. 153); j) requerer a extinção de suas obrigações (LREF, art. 159).

127. Efeitos da falência sobre os sócios

127.1. Efeitos sobre os sócios com responsabilidade ilimitada

O principal efeito decorre do status de sócio com responsabilidade ilimitada que responde ilimitadamente (LREF, art. 81), porque, com a falência da sociedade, terá sua própria falência decretada (veja item 18, supra).

Há duas situações que excluem este efeito: a) retirada da sociedade há mais de dois anos, contados entre a data do registro da alteração social no órgão de Registro Público de Empresa (Junta Comercial) e a data da quebra; b) retirada da sociedade há menos de dois anos, inexistindo dívidas a serem solvidas.

127.2. Efeitos sobre os sócios com responsabilidade limitada

No que se refere aos sócios que não ostentam responsabilidade ilimitada é possível lembrar a responsabilidade pessoal que decorre da qualidade de administrador (veja item 23.7) ou, ainda, como sócio, pelos fundos a que se comprometeu (veja item 11.1).

Pelos atos de responsabilidade na administração ou pela não integralização do capital social ou de reembolso dos fundos retirados cabe ação por parte da massa, visando recompor o patrimônio social.

127.3. Suspensão do direito de retirada, do recebimento de suas cotas e classificação do crédito

O decreto falimentar suspende o exercício do direito de retirada (art. 116, II). Para o conceito de direito de retirada veja item 11.8, supra.

O sócio que permanecer na data da quebra, em regra, somente recebe se houver saldo depois de pagos os credores (LREF, art. 153).

São, contudo, subordinados os créditos dos sócios não relativos à cota social, os dos administradores sem vínculo empregatício e os do sócio participante na sociedade em conta de participação (LREF, art. 83, VIII, b).

Em se tratando de acionista dissidente (veja item 34.5, "c") que ainda não recebeu o valor do reembolso, duas situações podem ocorrer: a) inexistindo dívidas relativas ao período anterior à data da publicação da ata da assembleia que motivou sua dissidência, sua classificação é a de credor quirografário (LSA, art. 45, § 7º); b) na hipótese de existirem dívidas relativas ao período anterior à data da publicação da ata da assembleia que motivou sua dissidência, é considerado credor subordinado, recebendo após o pagamento de todos os credores então existentes àquela data (LSA, art. 45, § 7º).

127.4. Efeitos não patrimoniais

Os sócios e as sociedades com vínculo de interesses (coligadas, controladoras, controladas, as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social) podem participar da assembleia geral de credores, sem direito a voto, extensível ao cônjuge, pessoa ascendente ou descendente, parente colateral (consanguíneo ou afim) até segundo grau de administrador, do sócio controlador, de membros dos conselhos (consultivo, fiscal ou semelhante) da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer pessoas exerçam essas funções.

128. Efeitos da falência sobre os bens do falido

O devedor é desapossado de todos seus bens e direitos que serão

arrecadados para formação da massa objetiva. O falido perde a livre administração dos bens de seu patrimônio, mas não sua titularidade, decorrendo desse entendimento o direito de fiscalizar a administração da massa, de requerer providências conservatórias dos bens arrecadados e o que for a bem de seus direitos e interesses, podendo intervir, como assistente, nos processos em que a massa seja parte ou interessada, e interpor recursos.

128.1. Casos de impenhorabilidade

São exceções ao desapossamento dos bens do falido as hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil de 2015, na Lei n. 8.009/90 (bem de família) e na Lei n. 10.931/2004 (patrimônio de afetação).

128.2. Patrimônio de afetação

O incorporador pode destinar o terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, exclusivamente à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.

A falência do incorporador não atinge bens que constituam o patrimônio de afetação averbado no Registro de Imóveis. Dentro de sessenta dias após o decreto de falência, os adquirentes das unidades deliberarão sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação desse patrimônio, obrigando-se, de forma solidária com o incorporador, ao pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas incidentes até a data da decretação da falência. A massa arrecada os saldos eventualmente existentes, após a venda do imóvel incorporado – na hipótese de se decidir não prosseguir a construção –, depois de pagas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias e reembolsados todos os adquirentes das unidades, proprietário do imóvel e instituição financiadora (Lei n.

10.931/2004, art. 31-F, e LREF, art. 119, IX).

129. Efeitos da falência sobre os contratos

129.1. Regras em relação aos contratos unilaterais

Se o falido é credor de contrato unilateral, incorre o vencimento antecipado, e, vencendo a dívida, o valor devido em contrato será cobrado pelo administrador judicial (LREF, art. 22, II, I).

Se o falido é a parte devedora, a quantia por ele devida é habilitada na falência pelo valor do dia do vencimento. Se esse vencimento é anterior, será acrescida de juros – contratuais ou legais – até a data da quebra. Se o contrato não está vencido, opera-se o efeito de vencimento antecipado, com o abatimento de juros eventualmente existentes (LREF, art. 77).

Estas são as regras gerais.

De forma especial, contudo, o administrador judicial pode realizar o pagamento de prestação decorrente de contrato unilateral (em geral quando a obrigação é de fazer ou de dar coisa certa, conforme Miranda Valverde, 1999, 1:231) mediante autorização do Comitê de Credores (LREF, art. 118): a) se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo; b) se convier à manutenção e à preservação de seus ativos.

129.2. Regras em relação aos contratos bilaterais

Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência, cabendo ao administrador decidir sobre sua resolução ou continuação, e, neste caso, deve ser ouvido o Comitê de Credores, que, igualmente, considerará se o cumprimento reduz ou evita o aumento do passivo da massa falida ou é necessário à manutenção e preservação de seus ativos (LREF, art. 117).

Se o administrador se omitir, cabe ao contratante o direito de interpelá-lo, no prazo de até noventa dias contados a partir da data constante do

termo de compromisso, para que se manifeste quanto ao cumprimento do contrato. A declaração negativa do administrador ou, decorridos dez dias, o seu silêncio dá ao contraente o direito à indenização a ser apurado em processo ordinário, com curso no juízo falimentar (LREF, art. 76), cujo título constituirá crédito quirografário (LREF, art. 117, §§ 1º e 2º).

Há, ainda, algumas regras especiais (LREF, art. 119) aplicáveis a certos contratos bilaterais que se agrupam em cinco situações específicas, considerando a condição de vendedor ou de comprador do falido: a) a falência do vendedor que não entregou a coisa contratada: incisos II e III; b) a falência do comprador que não pagou a coisa contratada: inciso I; c) contrato de compra de coisa móvel com cláusula de reserva de domínio: inciso IV; d) vendas a termo, em que houve a falência do comprador ou a do vendedor: inciso V; e) contratos imobiliários, de locação e venda: incisos VI e VII.

129.3. Falência do devedor que não entregou a coisa contratada

Se o falido obrigou-se a entregar coisa composta – a constituída por um todo complexo –, o administrador judicial, resolvendo não prosseguir com o contrato, fazendo as entregas faltantes, dará ao comprador o direito de colocar à disposição da massa as coisas recebidas e exigir perdas e danos (LREF, art. 119, II). A ação será distribuída ao juízo falimentar, e o juiz decidirá sobre o valor das perdas e danos, isto é, o valor da indenização, que incluirá os prejuízos efetivos (dano emergente), mas não o lucro cessante, porque não há como impor à massa culpa pelo não cumprimento do contrato.

No contrato de venda de coisas móveis vendidas a prestação e ainda não entregues, cabe ao comprador o direito de requerer a restituição do valor das prestações recebidas pelo falido (LREF, arts. 86, I, e 119, III). Se a falência é incidente a pedido anterior de recuperação judicial (LREF, arts. 67 e 84, V), o crédito será considerado extraconcursal.

129.4. Falência do comprador que não pagou a coisa contratada

No contrato em que o falido recebeu a mercadoria e não pagou o preço (art. 119, I), o vendedor não pode obstar a entrega de mercadorias adquiridas e que estejam em trânsito, se revendidas pelo falido, antes da quebra. Eventual ordem para impedir a entrega à massa somente será legítima se as mercadorias ainda não foram revendidas pelo falido.

129.5. Contratos em que o comprador falido detém a posse indireta da coisa, mas não o domínio e ainda não pagou o preço

Alguns contratos típicos assemelham-se à regra do inciso IV do art. 119: a) os contratos com cláusula de alienação fiduciária; b) os contratos de leasing; c) os contratos típicos com reserva de domínio.

No contrato de alienação fiduciária (veja item 85, supra) se a falência ocorre antes do pagamento de todo preço contratado, o administrador poderá prosseguir no contrato e, se não o fizer, dá o direito de o credor pedir sua restituição (veja item 135, infra).

É o que também ocorre no arrendamento mercantil (veja item 84, supra). A ação de restituição passa a ser o único meio processual adequado para satisfação dos direitos do credor fiduciário, mesmo que, anteriormente a ela, o credor tenha se valido da ação de reintegração de posse. Cabe ao arrendador, ao tomar ciência da falência, interpelar previamente o síndico para que este declare se cumpre ou não o contrato. No silêncio ou na negativa, competirá ao arrendador promover a ação de restituição. Se as partes constatarem que o bem não foi arrecadado em mãos do falido ou que esse mesmo bem está desaparecido, sem ter sido arrecadado pela massa, entende-se inviável a restituição em dinheiro, e a ação deve ser julgada improcedente, incluindo-se o credor no quadro geral de credores como credor quirografário (LREF, art. 89).

Para as aeronaves e suas partes, a Lei de Recuperação e Falência

excepcionou e permitiu ao contratante o direito (art. 199) de executar as cláusulas contratuais nele previstas, habilitando eventuais créditos remanescentes.

Nos contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio (veja item 83.4, supra), o administrador judicial deve ser interpelado sobre o seu cumprimento. A negativa obriga a massa a devolver o bem, sendo desnecessária ação de busca e apreensão. Os bens não mais se encontram sob a administração dos antigos gestores e sim arrecadados no juízo falimentar, sob a guarda do administrador judicial. Neste caso, o credor pode reavê-los mediante simples pedido de restituição. O bem será vistoriado, avaliado e vendido. Se o valor apurado for superior ao valor da dívida, o credor devolverá à massa o saldo. Se, por outro lado, o valor do bem for inferior ao valor da dívida, o credor habilitará a diferença na qualidade de credor quirografário.

129.6. Vendas a termo, em que houve a falência do comprador ou do vendedor

O inciso V do art. 119 trata de venda a termo em que, findo o prazo fixado, sem cumprimento, cabe ao vendedor o direito à indenização, que será estabelecida pela diferença entre a cotação da mercadoria no dia em que foram assinados o contrato e a cotação da época da liquidação, em bolsa ou mercado.

Observa-se que nem o comprador recebeu a coisa, nem o vendedor recebeu o preço. Tornando impossível o cumprimento do contrato, com a entrega da coisa na data aprazada e o recebimento do valor convencionado, dar-se-á a indenização pelo valor da diferença devida entre o preço determinado pelas taxas oficiais, fixadas no dia da assinatura do contrato, e a cotação oficial da época da liquidação, estipulada para aquele bem. Época da liquidação é o dia em que se vence e deve ser executado o contrato.

Pode suceder que, no momento em que o administrador declarar não ser

possível cumprir o contrato, a data para a liquidação ainda não tenha ocorrido. O credor, então, fará uma habilitação ilíquida, postergando-se a apuração do quantum para a data em que o contrato se der por liquidado.

129.7. Contratos imobiliários, de locação e venda

Os compromissos de compra e venda não se revolvem pela falência, cabendo distinguir: a) o compromissário comprador é falido: o imóvel é arrecadado e vendido, respeitadas as prestações vincendas, que serão pagas pelo novo adquirente, conforme determina a Lei n. 6.014/73; b) o compromissário vendedor é falido e o registro imobiliário ocorreu após o decreto falimentar: a transferência é ineficaz em relação à massa (LREF, art. 129, VII), o comprador de boa-fé tem o direito de requerer a restituição dos valores pagos (LREF, art. 86, III); c) o compromissário vendedor é falido e a venda e o registro imobiliário ocorreram após a falência: o ato é nulo (LREF, art. 99, VI); d) o imóvel foi dado dentro do termo legal da falência, para constituição de direito real de garantia, por dívida contraída anteriormente: o ato é ineficaz (LREF, art. 129, III).

Nos contratos de locação comercial (LREF, art. 119, VII), duas são as situações: a) o locatário é falido: o administrador judicial será intimado para purgar a mora. A falta de pagamento não opera, imediatamente, o direito do locador ao despejo, devendo-se observar o vencimento de dois meses de aluguel e as mesmas regras previstas pela Lei n. 8.245/91, em seu art. 62. Se o contrato não mais convier à massa, o administrador pode denunciá-lo a qualquer tempo; b) o locador é falido: o contrato não se resolve, prosseguindo a massa com sua regular execução e recebimento dos valores locatícios devidos.

Nos contratos no âmbito do SFH (Sistema Financeiro da Habitação) a parte não falida poderá considerá-los vencidos antecipadamente e liquidá-los na forma contratada ou prevista nas normas reguladoras, apurando-se os saldos que serão habilitados no quadro geral ou cobrados pela massa.

Quanto ao patrimônio de afetação (LREF, art. 119, IX), a matéria foi objeto de estudo no item 128.2.

129.8. Mandato e comissão

Se o falido é empresário individual, cumpre distinguir a finalidade do mandato porque a falência somente atinge os que se relacionam à atividade empresarial. Com a falência cessam os efeitos de todos os contratos de mandato, à exceção da representação judicial que prossegue até revogação expressa do administrador judicial.

Se o falido é o mandante ou comitente de contrato de mandato ou de comissão mercantil, o mandatário ou o comissário devem dirigir-se ao administrador judicial e prestar contas de seus atos. Se o falido é o mandatário ou comissário, seus atos cessam, competindo a ele prestar contas nos autos falimentares.

129.9. Conta-corrente

O contrato de conta-corrente regulado no art. 121 da LREF refere-se àquele em que “duas pessoas convencionam reunir em massa homogênea alguns ou todos os seus negócios, mediante recíprocas remessas que, anotadas na conta, se tornam partidas ou artigos de crédito e débito, verificando-se, por ocasião do seu encerramento, o saldo que deve ser pago por aquele que se mostrar devedor” (Carvalho de Mendonça, 1960, 7:352-353).

Essa modalidade de contrato considera-se encerrada no momento da declaração da falência, verificando-se o respectivo saldo (LREF, art. 121).

129.10. Compensação de dívidas

Para efeito de compensação, devem-se considerar, na falência, as seguintes condições quanto às dívidas passivas – aquelas em que o falido

figurar como devedor: devem estar vencidas ou se venceram em razão da falência (LREF, art. 122).

Quanto às dívidas ativas – o falido é credor – somente se compensam as que estiverem vencidas até a data da falência. Se não estiver vencida, não há incidência da regra falimentar: o administrador aguarda o vencimento e procede à cobrança.

Nessa leitura, portanto, somente são compensáveis: a) as dívidas em que o falido é devedor, que venceram antes da falência ou que venceram em virtude da falência; b) os créditos do falido, cujos vencimentos tenham ocorrido efetivamente até o dia da falência.

Assim, não são compensáveis as dívidas ativas – créditos do falido – que não se encontram vencidas, ou porque a data marcada para vencimento é posterior à sentença de quebra, ou porque o efeito da sentença de quebra não atinge essas dívidas.

Para impedir fraudes, o legislador vedou a compensação (LREF, arts. 122, parágrafo único, e 5º): a) dos créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; b) dos créditos transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira; c) dos créditos cuja transferência decorre de fraude ou dolo; d) das dívidas não exigíveis na falência.

Somam-se a estas vedações outros casos previstos no Código Civil (art. 373): os oriundos de atos ilícitos; de comodato, depósito ou alimentos; ou se um deles provier de coisa impenhorável.

129.11. Contrato de sociedade

Os haveres que o falido detiver em sociedade, decorrentes de sua participação social como cotista ou comanditário, serão apurados e arrecadados pela massa (LREF, art. 123).

Duas questões precisam ser lembradas:

Primeira: por que a lei menciona tão somente a qualidade de comanditário (na sociedade em comandita simples) e cotista?

Segunda: como se faz a apuração dos valores devidos?

A resposta à primeira indagação é simples: o legislador excluiu o sócio em nome coletivo e de sócio comanditado porque sobre estes incide a regra do art. 81 (veja item 127.1): todos os seus bens serão arrecadados. Exclui também o acionista porque, neste caso, as ações devem ser arrecadadas e livremente alienadas pela massa.

Mas, para os sócios com responsabilidade limitada, isto é, comanditários e cotistas de sociedade limitada, a liquidação da cota deverá ser realizada por apuração de haveres porque não há que se impor a estas sociedades, de formato personalista, o ingresso de terceiro estranho ao quadro social, o que ocorreria com a alienação das cotas do falido em venda pública.

A liquidação ocorre na forma que o contrato estabelecer ou, na omissão, judicialmente. A apuração se dará com base na situação patrimonial da sociedade à data da falência do sócio, verificada em balanço especialmente levantado, conforme dispõe o art. 1.031 do Código Civil.

Se a liquidação da cota operar a dissolução da sociedade (por exemplo: eram apenas dois sócios e um faliu), somente o saldo correspondente à participação do falido entrará para a massa, depois que forem pagos os credores sociais. O procedimento para a apuração de haveres encontra-se nos arts. 599-609 do Código de Processo Civil de 2015.

129.12. Condomínio indivisível

Se o falido participar de condomínio, o bem indivisível é alienado e o produto entra para a massa, deduzindo-se do valor apurado o que for devido aos demais condôminos, permitindo-lhes, contudo, o exercício do direito de preferência, nos termos da melhor proposta obtida (LREF, art. 123, § 3º).

130. Administração e arrecadação de bens

A arrecadação inicia-se assim que o administrador judicial assinar o termo de compromisso. Cabe-lhe, a partir de então, levantar a real situação dos estabelecimentos do empresário falido, podendo, se convier à massa, depois de autorizado judicialmente: a) continuar provisoriamente os negócios (LREF, art. 99, XI); b) prosseguir na execução de contratos (LREF, arts. 117 e 118); c) vender antecipadamente bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa (LREF, art. 113); d) dar em aluguel ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida (LREF, art. 114) e outras que impliquem exato conhecimento da realidade objetiva da empresa, o que se obtém pelos atos de arrecadação de livros, documentos e bens.

A arrecadação é o complexo de atos tendentes à efetivação do desapossamento dos bens, retirando do devedor o poder de deles dispor e submetendo-os à guarda do administrador judicial, ou, sob sua responsabilidade, a pessoa de sua escolha, ou, ainda, em depósito em mãos do falido ou de seus representantes, para, após avaliação, serem vendidos e realizados os pagamentos dos credores que compõem a massa concursal.

A lacração somente deve ser realizada se houver risco à arrecadação ou for necessária à preservação ou do interesse da massa falida.

A arrecadação se faz pessoalmente ou por carta precatória, nos estabelecimentos do falido ou em no local onde os bens, documentos e livros se encontrarem (oficina mecânica, residência do falido ou dos sócios, escritório do contador da empresa etc.), podendo ser acompanhada pelo falido (LREF, art. 108, § 2º). Elaboram-se inventários distintos para a massa falida e para as massas dos bens dos sócios solidariamente responsáveis.

A Lei Falimentar não prevê o acompanhamento por parte do Ministério

Público. Considerando que alguns crimes falimentares pressupõem diligências em torno da arrecadação de bens e de documentos (LREF, arts. 168, 171, 173 e 174), a notificação sobre o dia e hora em que ela se realizará é a única forma de dar plena vigência à construção constitucional desse órgão, permitindo que o representante do Parquet se faça presente, se entender necessário.

O arrolamento é reduzido em autos de arrecadação próprio, nos quais constará, distintamente, a relação dos bens, o inventário dos livros, a relação de papéis e de documentos encontrados, indicando o local da arrecadação e seu estado.

A exigência de descrição pormenorizada do estado e conteúdo dos livros funda-se na necessidade de não se deixar qualquer incerteza no momento da apreciação dos fatos criminais envolvendo o registro dos fatos contábeis.

Quanto aos bens, evita discussões futuras sobre a certeza quanto ao valor de alienação. O administrador judicial deve individualizar o quanto lhe for possível cada coisa, com descrição, marca, ano de fabricação, cor, estado e outros elementos identificadores, referindo-se no inventário: a) auto de bens, valores, dinheiro, papéis e documentos encontrados em poder do falido; b) auto de bens em poder de terceiros, entregues a título de guarda, depósito, penhor ou retenção; c) auto de bens em poder do falido, mas indicados como propriedade de terceiros – por contratos, documentos ou informação do próprio falido –, mencionando-se esta circunstância; d) auto para arrolamento dos bens pertencentes a cada um dos sócios solidários, observando-se que deve ser elaborado um termo individualizado para cada um deles.

Para os bens imóveis, o administrador deve completar o auto com certidões de registro imobiliário, extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações necessárias à sua individualização e regularidade.

A arrecadação de bens incorpóreos ou intangíveis (os que não possuem

qualquer consistência material) obedece a certos cuidados: a) créditos: o administrador deve identificar o devedor e qualificá-lo, descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; b) títulos de propriedade industrial (veja item 63, supra): número do registro, data de concessão, nome do titular, produtos ou serviços, características e prioridade, identificação do certificado, nome do autor, nome do titular, prazo de vigência etc.; c) contratos, em especial os de locação, a indicação do prazo para o exercício dos direitos relativos ao ponto empresarial; d) participação em sociedades empresariais ou não: a indicação do nome da pessoa jurídica, o número de cotas ou ações e a cópia da última alteração do contrato social registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

131. Classificação dos créditos na falência

A classificação de créditos interessa diretamente ao processo falimentar porque na recuperação, judicial ou extrajudicial, não há, a rigor, estrita observância de preferência nos pagamentos. Dizemos estrita porque alguns credores devem ser contemplados com prioridade, como, por exemplo, os trabalhistas e acidentários pelo pagamento, em até trinta dias, dos créditos salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação (LREF, art. 54, parágrafo único), e outros não se sujeitam ao regime recuperatório, como é o caso dos créditos previstos no art. 49, §§ 3º e 4º, da LREF.

Interessa, portanto, ao processo de recuperação distinguir a natureza e classe dos credores sujeitos, mas não a ordem de prelação.

A falência obedece a um rigoroso critério, segundo a classe de credores habilitados:

ORDEM GERAL	CLASSES E SUBCLASSES
----------------	----------------------

1	1. Despesas de pagamento antecipado	1.1 Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador (art. 151).
		1.2. Despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência (art. 150).
2	2. Créditos decorrentes de restituição (art. 149)	
3	3. Créditos extraconcursais (art. 84)	3.1. Remunerações do administrador judicial e seus auxiliares e créditos derivados da legislação de trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência.
4		3.2. Quantias fornecidas à massa pelos credores.
5		3.3. Despesas com arrecadação, administração e realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência.
6		3.4. Custas judiciais relativas às ações e execuções que a massa falida tenha sido vencida.
7		3.5. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência.
8	4. Créditos prioritários (art. 83, I):	(a) derivados da legislação do trabalho até 150 salários mínimos por credor, e (b) os decorrentes de acidentes de trabalho.
9	5. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado (art. 83, II)	
10	6. Créditos tributários relativos a fatos geradores anteriores à decretação da falência, excetuadas as multas tributárias (art. 83, III)	
		(a) previstos no art. 964 do CC;

11	7. Créditos com privilégio especial (art. 83, IV):	(b) definidos em outras leis; (c) a cujo titular a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia; (d) aqueles em favor dos microempresários individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar n. 123/2006.
12	8. Créditos com privilégio geral (art. 83, V):	(a) previstos no art. 965 do CC; (b) decorrentes das obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial com fornecedores de bens ou serviços, na forma do art. 67 da LREF; (c) definidos em outras leis.
13	9. Créditos quirografários (art. 83, VI):	(a) os que não foram privilegiados pela Lei de Recuperação e Falência; (b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;
13	9. Créditos quirografários (art. 83, VI):	(c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem a 150 salários mínimos; (d) créditos trabalhistas cedidos a terceiros (art. 83, VIII, § 4º).
14	10. Créditos subquirografários	Multas contratuais e penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive multas tributárias.
15	11. Créditos subordinados	Créditos subordinados por previsão legal ou contratual e os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
16	Devolução ao falido ou rateio entre os sócios (art. 153).	

Anotei no livro Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (2005:156) a existência de conflito entre a Lei Falimentar e o Código Civil no que se refere à contribuição do sócio participante da sociedade em conta de participação.

O estatuto civil dispõe que a conta de participação constitui patrimônio especial e seu saldo é classificado como crédito quirografário (CC, art. 994,

§ 2º). A Lei Falimentar estabelece a subordinação dos “créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício” (art. 83, VIII, b). A questão, portanto, é saber a classificação daquele saldo: crédito quirografário ou subordinado?

Em busca da harmonia entre os diplomas legais, chegamos à seguinte conclusão: os créditos de sócios não relacionados à parcela social seriam créditos subordinados (LREF, art. 83, VIII, b) e os decorrentes de direitos do sócio na partilha dos bens sociais regem-se por direito próprio de recebimento do saldo (LREF, art. 153), salvo se decorrente de participação em sociedade em conta de participação, classificado como quirografário pelo Código Civil (art. 994, § 2º).

132. Realização do ativo

Depois da avaliação dos bens, ou mesmo logo após a juntada do auto de arrecadação, contendo os inventários dos bens e sua avaliação, o administrador deve dar início à realização do ativo, na modalidade que melhor convier à massa, segundo dispõe a Lei de Recuperação e Falência no art. 140.

132.1. Alienação da empresa, de parte dela, dos estabelecimentos empresariais ou de bens individualmente

O administrador deve obedecer à prioridade determinada na lei. Em primeiro lugar, procurar manter a estrutura objetiva da empresa, a integridade das diversas universalidades formadas pelos estabelecimentos empresariais que compõem a falida (art. 140, I); pode, secundariamente, promover a alienação fracionada de filiais ou unidades produtivas (art. 140, II), de blocos de bens destacados do estabelecimento (art. 140, III) e de bens individualmente considerados (art. 140, IV).

Pretendeu-se o prosseguimento da empresa por novos adquirentes, razão

pela qual o administrador judicial deve, em todo o procedimento, manter, dentro do possível, os meios produtivos (LREF, art. 75), os contratos bilaterais e unilaterais que interessem à manutenção dos ativos (LREF, arts. 117 e 118).

A transferência da empresa, de seus estabelecimentos, de blocos de bens ou de bens individualmente considerados se faz sem ônus ao comprador. Ele não assume obrigações de qualquer natureza, de ordem tributária, trabalhista ou acidentária (LREF, art. 141, III).

Há uma exceção, cuja finalidade é evitar fraudes – o passivo anterior –, e persistirá se o arrematante for sócio da falida, de sociedade controlada pelo falido, parente (em linha reta ou colateral até o quarto grau, consanguíneo ou afim) do falido ou do sócio da sociedade falida e, ainda, se identificado como agente do falido, com o objetivo de fraudar a sucessão (LREF, art. 141, § 1º).

132.2. Constituição de sociedade de credores ou de empregados do devedor

Outra forma de realização do ativo é a constituição, mediante autorização da assembleia geral de credores, de uma sociedade de credores ou de empregados do devedor, da qual podem participar os sócios da falida ou terceiros (LREF, art. 145).

São características desta sociedade: a) aprovação por quorum especial: voto favorável de credores que representem dois terços dos créditos presentes à assembleia (LREF, art. 46); b) não sucessão por dívidas anteriores; c) possibilidade de ingresso de terceiros e dos antigos sócios da falida; d) os credores titulares de créditos derivados da legislação do trabalho poderão usar esses valores na aquisição ou arrendamento da empresa.

A Lei de Recuperação e Falência nada dispõe quanto ao direito dos

credores que não aderirem à proposta. Pelo sistema anterior, a minoria dissidente era paga em dinheiro pela maioria que assim deliberou, respeitadas as seguintes condições: a) considerava-se, inicialmente, o valor total do acervo arrecadado e sua avaliação; b) desse total descontava-se o valor devido aos encargos e dívidas da massa; e, finalmente, c) atribuía-se aos credores dissidentes a porcentagem a eles devida sobre aquele resultado (LF45, art. 123, § 1º).

Proponho, na ausência de solução legislativa, aplicar aos casos futuros a anteriormente prevista, sob o fundamento de preservar os princípios da liberdade de associação e da paridade de tratamento concursal.

132.3. Modalidades de alienações públicas

São três as modalidades de alienação, cuja deliberação dependerá da anuência do Comitê de Credores e da intimação do Ministério Público, sob pena de nulidade: a) leilão por lances orais; b) propostas fechadas; e c) pregão. Todas previstas no art. 142, que, por sua vez, traz defeito redacional nos incisos I e II do § 5º e no inciso I do § 6º. Nesses dispositivos impõe-se corrigir as menções que fazem, respectivamente, aos “§ 3º, § 2º e § 5º” por “§ 4º, § 3º e § 4º”.

A última modalidade introduz novidade no sistema falimentar e consiste em espécie híbrida das duas anteriores: 1) numa primeira etapa são recebidas propostas, em envelopes lacrados, mediante recibo do oficial do cartório; 2) no dia, hora e local designados no edital, o juiz abrirá os envelopes, determinará a lavratura do auto e a colheita das assinaturas dos presentes; 3) em seguida o juiz designará data para a realização do leilão, ordenando a intimação dos proponentes que apresentaram propostas não inferiores a 90% da maior proposta ofertada; 4) na data designada, o leilão será aberto com o valor da proposta recebida do maior ofertante presente, considerando-se esse valor como lance, ao qual ele fica obrigado; 5) se o ofertante da maior proposta não comparecer ao leilão e nenhum dos

presentes apresentar proposta igual ou superior ao seu valor, ele se obriga a pagar à massa a diferença entre o valor da arrematação, oferecido por outro licitante presente, e aquele que ofertou.

132.4. Outras modalidades de alienação judicial

A lei contempla a possibilidade de o juiz, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do Comitê de Credores, autorizar outras modalidades de alienação judicial (LREF, art. 144).

Decidido o modo em que se procederá à venda, o juiz determinará a publicação de anúncio em jornal de grande circulação, com quinze ou trinta dias de antecedência, conforme for o caso: se a alienação envolver tão somente bens móveis, o prazo menor, e o maior, para os demais casos – venda de imóveis ou da empresa.

A lei determina que a venda se faça pelo maior valor oferecido, ainda que inferior ao valor da avaliação (LREF, art. 142, § 2º). Não há, ainda, jurisprudência acerca do que vem a ser preço vil na alienação falimentar, servindo como parâmetro a jurisprudência processual civil (em regra, lance inferior a 50% do valor da avaliação atualizado).

132.5. Impugnações

Os credores, o devedor, falido e seus sócios e o Ministério Público poderão apresentar impugnação à alienação, no prazo de quarenta e oito horas (LREF, art. 143). Embora omissa a lei, convém que o juiz dê vista ao promotor de falências, quando este não for o impugnante, decidindo em cinco dias.

A lei não prevê recurso contra a decisão que julga impugnação à realização do ativo, devendo-se ter como irrecurável, a exemplo do que ocorrida no sistema anterior (RMS 474/SP, em 11-9-1990, rel. Ministro Gueiros Leite).

132.6. Especulação de lucro

As pessoas que atuam no processo falimentar (juiz, administrador judicial, membro do Ministério Público, perito, avaliador, escrivão, oficial de justiça, gestor judicial ou leiloeiro) não podem adquirir direta ou indiretamente bens da massa, tampouco entrar em especulação de lucros com esses bens (LREF, art. 177). Se o fizerem, sujeitam-se à condenação pelo crime de violação de impedimento, além das sanções de caráter administrativo de seu grau.

133. Pagamento aos credores

O pagamento dos credores obedece a ordem de preferência, seguindo procedimento próprio:

(1) O produto da alienação judicial permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo falimentar pelo prazo de um ano, contado da data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário (CTN, art. 133, § 3º).

(2) Os valores relativos à reserva de créditos ficarão depositados até o julgamento definitivo das habilitações, podendo ser utilizados posteriormente em rateio suplementar caso não se dê a inclusão pela totalidade do valor pretendido pelo credor que os reservou (LREF, art. 149, § 1º).

(3) Os credores extraconcursais (LREF, art. 84: despesas indispensáveis à administração da falência e à continuação provisória das atividades), inclusive os trabalhistas por salários vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador (LREF, art. 151), serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa, não se aguardando a definição do quadro geral de credores.

(4) O administrador recebe com os credores extraconcursais (LREF, art.

84, I), até o limite de 60% do que lhe for fixado. Neste momento o juiz deve fixar sua remuneração e fazer previsão do restante, em depósito judicial, do valor relativo ao pagamento após julgamento das contas e apresentação do relatório final, pelo administrador judicial (LREF, art. 24, § 2º).

(5) O juiz deve fixar prazo para que os credores providenciem o levantamento dos valores relativos a seus créditos. Os que não o fizerem serão intimados no prazo de sessenta dias que, findo sem atendimento, obrigará a rateio do saldo entre os credores remanescentes.

(6) O saldo, se houver, será entregue ao falido empresário individual ou, se sociedade, aos sócios na proporção de sua participação, conforme dispuser o contrato.

134. Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido

134.1. Prestação de contas do administrador judicial

Dentro do prazo de trinta dias da realização do ativo e do pagamento dos credores, o administrador judicial deverá apresentar, em autos apartados, a prestação de contas de sua gestão, juntando os documentos relativos às receitas e as despesas que realizou.

Recebidas as contas, o juiz ordenará a publicação de aviso em que se consigne que os autos encontram-se à disposição dos interessados para eventual consulta e impugnação no prazo de dez dias (LREF, art. 154).

Findo o prazo, o juiz determinará diligência que julgar pertinente e, em seguida, remeterá os autos ao Ministério Público, que ter o prazo de cinco dias para manifestar-se a respeito das contas e de impugnações.

O parecer contrário do órgão ministerial deverá ser objeto de consideração pelo administrador judicial, em até cinco dias, seguindo-se

sentença, que julgará boas as contas ou rejeitará as oferecidas, fixando, neste segundo caso, o alcance da responsabilidade e as providências necessárias à indenização da massa, tais como a indisponibilidade ou o sequestro de bens do administrador.

Da sentença cabe apelação, no prazo de quinze dias.

134.2. Sentença de encerramento

Julgadas as contas, segue-se, em dez dias, a apresentação do relatório final. Neste documento, o administrador judicial mencionará o valor do ativo e o produto de sua realização, o valor do passivo e os pagamentos realizados, indicando as responsabilidades remanescentes.

Com base no relatório final, o juiz encerrará, por sentença, a falência, determinando sua publicação em edital, correndo desse termo o prazo de quinze dias para a apresentação de eventuais recursos de apelação (LREF, art. 156).

Note que “quem não se habilitou, ainda que seja o requerente da falência, não tem legitimidade para recorrer da sentença de encerramento do processo” (Súmula 45 do TJSP).

134.3. Extinção das obrigações do falido

O encerramento da falência não extingue as obrigações do falido, o que se dará somente nos seguintes casos: a) o pagamento de todos os créditos ou de tão somente 50% dos créditos quirografários, facultando-se ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, depois de liquidado todo o ativo arrecadado (LREF, art. 158, I e II); b) extinção pelo decurso de prazo comum (LREF, art. 158, III e IV): a lei distingue os casos em que o falido tenha ou não sido condenado por crime falimentar. O decurso do prazo de cinco ou de dez anos conta-se da data do encerramento da falência e não do trânsito em julgado da sentença. O

prazo maior, para a hipótese de ter havido condenação, não sofre interferência da data em que foi prolatada a sentença criminal ou em que foi julgada extinta a punibilidade do réu.

Uma outra hipótese decorre da interpretação sistemática. Algumas ou todas as obrigações do falido podem prescrever antes da ocorrência dos termos acima mencionados.

É o caso dos créditos com prazos prescricionais inferiores aos previstos nos incisos III e IV do art. 158, em que se aplicam as regras dos arts. 6º e 157: a) durante o curso do processo falencial, fica suspenso o curso da prescrição relativa às obrigações do falido (LREF, art. 6º); b) o período que antecede a sentença de falência é somado ao período que começa a correr a partir da data do trânsito em julgado da sentença de encerramento (LREF, art. 157).

Demonstradas que todas as dívidas encontram-se prescritas, considerando-se o período que antecede à sentença declaratória e o que correu após a sentença de encerramento, dar-se-á a extinção das obrigações pela ocorrência da prescrição incidente sobre os títulos de sua dívida.

134.4. Extinção das obrigações antes do encerramento da falência

Em geral, o pedido de extinção de obrigações sobrevém à sentença de encerramento. Contudo, é possível a ocorrência de pedido temporão, anterior à sentença de encerramento: quando ocorrer pagamento integral dos créditos admitidos na falência. Nessa hipótese, a sentença de extinção declarará também o encerramento da falência (LREF, art. 159, § 3º).

134.5. Procedimento de extinção

Estão legitimados ao pedido de extinção das obrigações tanto o empresário individual falido como o representante da sociedade falida e

seus sócios solidários.

O requerimento é autuado em separado (LREF, art. 159, § 1º); publica-se edital com prazo de trinta dias, em dois órgãos: um jornal de grande circulação e um órgão oficial do Estado, onde houver. Decorrido o período fixado, com ou sem oposição, o juiz julgará em cinco dias, determinando, na hipótese de procedência, comunicação a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência. Transitada em julgado a sentença, o procedimento de extinção será apensado ao processo falimentar (LREF, art. 160, § 6º).

135. Ações de restituição

São seis os fundamentos de ação de restituição, sendo que cinco deles encontram-se regulados na Lei de Recuperação e Falência e o último em lei previdenciária: a) o bem arrecadado pela massa pertence ao autor por força de direito real ou de contrato; b) a coisa foi vendida pelo autor ao falido nos quinze dias anteriores ao pedido de falência; c) coisa que pertence ao autor não mais existe ao tempo do pedido; d) o autor entregou importância em moeda corrente nacional ao devedor, em virtude de adiantamento de contrato de câmbio para exportação; e) o autor, contratante de boa-fé, entregou valores ao devedor, sobrevivendo a revogação ou ineficácia do contrato firmado; f) o empregador falido descontou do salário de seus empregados valores destinados à Previdência e não os recolheu aos cofres públicos (Lei n. 8.213, de 24-7-1991, art. 51).

Note que o legislador utiliza duas palavras distintas: bem no caput e coisa a partir do parágrafo único. São conceitos distintos: coisa é espécie do gênero bem. O conceito de bem abrange objetos de direito materiais e imateriais. Coisa é todo objeto material valorável, excluindo-se desse conceito o direito autoral, a imagem, a marca e o nome empresarial.

Quanto ao objeto do pedido, os dois primeiros referem-se à devolução do próprio objeto e os quatro seguintes visam à restituição de valor em

dinheiro. Veja o seguinte quadro:

OBJETO DO PEDIDO	FUNDAMENTO LEGAL
Bem arrecadado	Decorrente de direito real ou de contrato (art. 85).
Coisa	Vendida a prazo pelo credor e entregue nos quinze dias anteriores à data do requerimento de falência, se ainda não alienada (art. 85, parágrafo único).
Dinheiro	Quando a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição (art. 86, I).
	Referente à importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação (art. 86, II).
	Valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato (arts. 86, III, e 136).
	Importância descontada do empregador falido do salário de seus empregados e não recolhida aos cofres públicos (art. 51 da Lei n. 8.213, de 24-7-1991).

135.1. Requisitos dos pedidos

Na ação movida pelo proprietário do bem arrecadado é indispensável demonstrar se (a) o bem foi arrecadado pela massa falida em poder do falido, (b) o bem é devido ao reivindicante, seu proprietário, ou (c) a coisa pode ter deixado de existir ou foi vendida, posteriormente à arrecadação.

A lei exige que o credor fundamente seu pedido e descreva o objeto reclamado (LREF, art. 87), isto é, deve documentar a origem de seu direito de propriedade e a razão pela qual o bem se encontra em poder da massa falida.

Se a coisa reivindicada deixou de existir ou foi vendida pela massa falida,

distintas são as soluções: no primeiro caso, a devolução se fará pelo valor atualizado da avaliação e, no segundo, pelo preço atualizado da venda realizada pela massa.

A lei prevê a restituição de coisa vendida a prazo e entregue ao falido dentro de quinze dias anteriores ao requerimento da falência, se ainda não alienada pela massa (LREF, art. 85, parágrafo único). Vale dizer que, se revendida anteriormente pelo falido, sem fraude, descabe o direito à restituição.

Por força da jurisprudência, entende-se que a venda por meio de cheque pós-datado, devolvido pelo banco sacado em razão de insuficiência de fundos, equivale à realizada a prazo.

135.2. Contratos de câmbio

A modalidade de restituição por adiantamento em contrato de câmbio independe de se observar o prazo de quinze dias anteriores à entrega do numerário. Basta comprovar o contrato e o adiantamento realizado.

135.3. Restituição de valor devido à Previdência

Regulada na Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n. 8.213, de 24-7-1991, art. 51), a restituição “de crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os juros de mora”, é modalidade que se faz em dinheiro.

Origina-se da Súmula 417 do STF (“Pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade”) e da jurisprudência posterior que a mandou aplicar às contribuições de previdência dos empregados retidas pelo falido.

O entendimento jurisprudencial ressaltava que, se os salários não

tivessem sido efetuados, só após esse pagamento teria lugar a restituição à instituição previdenciária, se a massa tivesse recursos. A lei previdenciária não faz essa ressalva, e a Lei Falimentar traz regra especial: devem ser pagos prioritariamente os créditos trabalhistas vencidos três meses antes da falência, no limite de cinco salários mínimos (LREF, art. 151; veja quadro no item 131).

135.4. Procedimento

O juízo falimentar é competente, de forma absoluta, mesmo na hipótese de o reivindicante ser uma das pessoas previstas no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, como ocorre na restituição previdenciária.

O procedimento é simplificado: autuado o pedido em separado, abre-se vista, por cinco dias, sucessivamente, ao falido, credores, Comitê e administrador judicial para manifestação, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição.

A lei não prevê a manifestação do Ministério Público que, entretanto, deve ser ouvido, em razão do interesse público e para extrair subsídios à investigação criminal.

Contestado o pedido, abre-se breve fase probatória, com realização de audiência de instrução e julgamento, designada pelo magistrado, em prazo não definido pelo legislador. Se o pedido for julgado procedente, a sentença determinará a entrega do bem ou valor ao credor no prazo de quarenta e oito horas. E, no caso de improcedência, se for o caso, o juiz pode mandar incluir o autor no quadro geral de credores, na classe que o crédito comportar, aproveitando os atos processuais até então verificados (LREF, art. 89). É o que ocorre, por exemplo, em contrato de venda de mercadorias a prazo em que se constatou que a entrega se deu no décimo sexto dia anterior ao requerimento da falência: o autor não tem direito à restituição, mas é credor quirografário.

135.5. Execução da sentença

Na ausência de credores trabalhistas amparados pela regra dos arts. 86, parágrafo único, e 151, a devolução se fará antes mesmo do momento da liquidação, se houver dinheiro em caixa, descontadas as despesas de conservação realizadas pela massa ou por terceiros (LREF, art. 92).

Se houver mais de um credor reivindicante e o numerário não for suficiente, os valores serão rateados entre os participantes da classe (LREF, art. 91, parágrafo único), isto é, classe de credores à restituição.

É possível a reserva de crédito? Sim, por aplicação analógica do disposto no art. 6º, § 3º, porque o bem pode ser vendido pela massa e, com o pagamento dos credores concursais, não restar qualquer valor para a satisfação do crédito do reivindicante. Se o pedido de restituição sobrevier aos rateios, não cabe desfazimento dos pagamentos já realizados aos credores legitimamente habilitados. Aplica-se aqui, subsidiariamente, a regra do § 3º do art. 10: “Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados...”.

135.6. Recurso

Cabe apelação contra a sentença que julga o pedido de restituição, sem efeito suspensivo (LREF, art. 90), ficando sua execução imediata sujeita a caução idônea e à indisponibilidade da coisa objeto da reclamação (LREF, arts. 90, parágrafo único, e 91).

135.7. Honorários e atualização monetária

Se o pedido foi contestado e, ao final, julgado procedente, a massa será condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Pouco importa saber se a oposição à pretensão do credor foi apresentada por credor, pelo Comitê, pelo administrador judicial ou mesmo pelo Ministério Público, quando de sua manifestação nos autos.

No tocante à correção monetária, há duas soluções: a) nos pedidos originários de restituição em pecúnia aplica-se, por analogia e para manter a igualdade de tratamento dos credores, a Súmula 36 do STJ ("A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência"); b) nos casos de extinção ou alienação da coisa reivindicada, isto é, o pedido não reivindica originariamente valor em dinheiro, a regra de atualização monetária está na Lei de Recuperação e Falência: "o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado" (art. 86, I).

136. Ações revocatórias

A declaração de ineficácia e as ações revocatórias visam tão somente tornar certos atos sem efeito em relação à massa falida.

São dois os instrumentos legais para esse fim: a simples declaração de ineficácia (LREF, art. 129) e a ação revocatória *stricto sensu* (LREF, art. 130), que diferem essencialmente porque a primeira funda-se em situações taxativamente arroladas na lei, não exige prova de fraude e condiciona-se a certo prazo em relação à falência; a segunda abrange um grande número de situações não reguladas pelo legislador, exige prova de fraude entre o devedor e terceiro, não se prende a um lapso temporal, bastando a demonstração de que houve intenção de prejudicar credores.

Outra distinção: a declaração de ineficácia nem sempre exige iniciativa em ação própria, podendo ser declarada de ofício pelo juiz nos autos falimentares e, ainda, ser apreciada em defesa ou em pedido incidental em outra ação movida contra ela (LREF, art. 129, parágrafo único).

Os casos de ineficácia abrangem três situações que ocorrem dentro do termo legal de quebra (LREF, art. 129, I, II e III; veja item 124), duas relativas a atos praticados no período de dois anos anteriores à sentença de

falência (incisos IV e V), uma em que não se leva em conta o aspecto temporal (inciso VI) e outra que considera o ato praticado após o decreto falimentar (inciso VII).

136.1. Atos praticados dentro do termo legal

1) Pagamento de dívidas não vencidas, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título (art. 129, I): é o que ocorre com pagamento, cessão de crédito, dação em pagamento etc., não estando vencida a dívida, privilegiando alguns credores.

2) Pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, por qualquer forma não prevista em contrato (art. 129, II): semelhantemente, o pagamento de dívida vencida por modo não contratado indica execução antecipada, em prejuízo dos credores que se encontram na mesma situação.

3) Constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, tratando-se de dívida contraída antes do termo (art. 129, III): coíbe-se a prática de privilegiar alguns credores, alçando-os a uma posição superior aos demais, alterando sua condição de quirografário para privilegiado. Para o conceito de direito de retenção, veja item 125.5, supra.

136.2. Atos praticados dentro do biênio anterior à falência

1) Atos a título gratuito: podem compreender a remissão, o perdão da dívida, a renúncia gratuita, tácita, ou expressa, de um direito patrimonial; a constituição gratuita de direitos reais, como o usufruto, a servidão (...) o legado; a renúncia à sucessão, legado ou usufruto; a constituição do bem de família (Vampré, 1921:453).

2) A renúncia à herança ou a legado: é modalidade de ato gratuito. A prova de sua ocorrência se faz por certidão extraída dos autos de inventário ou por escritura pública (CC, art. 1.806).

136.3. Ato em que não se leva em conta o elemento temporal

É a hipótese de venda ou transferência do estabelecimento empresarial sem o consentimento de todos os credores, salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu passivo (LREF, art. 129, VI). Veja os itens 54-57.

136.4. Atos praticados após a decretação da falência

São ineficazes os atos de registro após a decretação da falência, isto é, o registro de direitos reais ou a transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou, ainda, averbação relativa a imóveis, salvo se houver prenotação anterior. Não se refere à transferência de propriedade após o decreto falimentar que, neste caso, é tida como nula, mas à ineficácia dos atos de registro imobiliário, ocorridos depois do decreto falimentar.

Prenotação é a apresentação do título para registro ou para averbação. Os títulos apresentados ao oficial são numerados por ordem rigorosa de sua apresentação (LRP, art. 182).

136.5. Ação revocatória

A modalidade prevista no art. 130 exige efetivo prejuízo e consilium fraudis. A fraude de ambos os contraentes, o falido e o terceiro, revela-se pelos atos que antecederam o ato fraudulento e a ciência do estado patrimonial do devedor.

136.6. Processamento da ação revocatória

O rito é ordinário, com curso no juízo falimentar (LREF, art. 134), e pode ser iniciada pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público em até três anos contados da decretação da falência (LREF, art. 132).

No polo passivo podem figurar, se houver necessidade: 1) todos os que figuraram no ato; 2) todos os que, por efeito do ato, foram pagos, garantidos ou beneficiados; 3) os terceiros adquirentes se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do falido de prejudicar os credores; 4) os herdeiros e legatários das pessoas anteriormente indicadas.

136.7. Medidas cautelares

Admite-se o sequestro dos bens retirados do patrimônio do falido (LREF, art. 137), podendo ser concedida liminar, com ou sem oitiva do réu ou justificação prévia, nos casos do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, isto é, se demonstrada a urgência e se a citação do réu pode tornar ineficaz a medida requerida, decidindo o magistrado quanto à necessidade de prestação de caução para garantir prejuízos que o requerido possa vir a sofrer.

136.8. Efeitos das ações revocatórias

Os principais efeitos são: a) retorno à situação anterior quando houver o pagamento dos credores ou o encerramento da falência; b) devolução dos bens com seus acessórios, e, na falta, o valor do mercado, acrescido de perdas e danos (LREF, art. 135), o que pode não ocorrer, como é o caso de ineficácia de atos simplesmente registrários; c) devolução de eventuais prestações e valores pagos pelo contratante de boa-fé (LREF, art. 136); e d) possibilidade de propositura de ações de perdas e danos por parte de terceiros de boa-fé contra o devedor e seus garantes (LREF, art. 136, § 2º).

REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Nelson. O síndico na administração concursal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
- ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
- ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1972.
- ARAÚJO, Luiz Antonio Mattos Pimenta. A responsabilidade tributária na sucessão da empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 76.
- ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- ASCARELLI, Tullio. Corso de diritto commerciale: introduzione e teoria dell'impresa. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1962. Capítulo 1º traduzido pelo Prof. Fábio Konder Comparato, Revista de Direito Mercantil, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 103, 1996.
- _____. Iniciación al estudio del derecho mercantil. Introducción y traducción de Evelio Verdera y Tels. Barcelona: Bosch, 1964.
- _____. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947.
- _____. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 2001.

_____. Studi in tema di società. Milano: Giuffrè, 1952.

_____. Teoria geral dos títulos de crédito. Campinas: Red Livros, 1999.

ASQUINI, Alberto. Profili dell'impresa. Rivista del Diritto Commerciale, v. 41, I, 1943, traduzida por Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. 1996.

ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 4. ed. Revista dos Tribunais, 1997.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: teoria geral das obrigações. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

BARNEY, Oscar Cruz. El riesgo en el comercio hispano-indiano: préstamos y seguros marítimos durante los siglos XVI e XIX. Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Ed. histórica fac-símile da publicada em 1940, Rio de Janeiro: Rio – Sociedade Cultural, 1975.

_____. Direito das coisas. Ed. histórica fac-símile da publicada em 1941. Rio de Janeiro: Rio/Sociedade Cultural, 1976.

BÍBLIA SAGRADA, Miami: Ed. Vida, 1999.

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1997.

BORGES, Eunápio. Curso de direito comercial terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1959.

_____. Títulos de crédito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1975.

BOVESPA. Uma história centenária. São Paulo: MPF Produções Culturais, 1990.

BRAUDEL, Fernand. Os jogos das trocas. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1997(a).

_____. Direito comercial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1997(b).

_____. Manual das sociedades anônimas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1996(a).

_____. Questões de direito societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

_____. Sociedades comerciais. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996(b).

_____. Títulos de crédito. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996(c).

_____. Tratado de direito empresarial. 29. ed. São Paulo: Atlas, 1995.

BUZAID, Alfredo. Do agravo de petição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1945.

_____. Da ação renovatória. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Concorrência desleal – atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013.

CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no Novo Código Comercial. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords.). Reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 529-547.

CARVALHO, Raimundo M. B. Da responsabilidade dos sócios por dívidas da sociedade: sociedade anônima e por cotas de responsabilidade limitada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, jan./mar. 1989, v. 73, p. 33.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 1. ed. atualizada por Ricardo Negrão. Campinas: Bookseller, 2000. v. 1, t. 1.

_____. Tratado de direito comercial brasileiro. 1. ed. atualizada por Ricardo Negrão. Campinas: Bookseller, 2001. v. 2, t. 1.

_____. Tratado de direito comercial brasileiro. 5. ed. atualizada por Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958. v. 3.

_____. Tratado de direito comercial brasileiro, 5. ed. atualizada por Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. v. 5.

_____. Tratado de direito comercial brasileiro. 5. ed. atualizada por Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956. v. 6, t. 2.

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 4, t. II.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CICU, Antonio; MESSINEO, Francesco. Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: Giuffrè, 1972. v. XXVIII.

CNBV – Comissão Nacional de Bolsas de Valores. Introdução ao mercado de ações. Rio de Janeiro, 1986.

CODICE CIVILE. Editio Minor, 1973.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.

_____. Curso de direito comercial. 6. ed. 2003. v. 2.

_____. Curso de direito civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 3.

- _____. Curso de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3.
- _____. A sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003.
- _____. Manual de direito comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- _____. Princípios do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2012.
- _____. O futuro do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2011.
- _____; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords.). Reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial direito de empresa. São Paulo: RT, 2016.
- _____. Novo manual de direito comercial. 29. ed. São Paulo: RT, 2017.
- COMPARATO, Fábio Konder. Falência. Requerimento por credores trabalhistas – se estão eles adstritos a renunciar ao seu privilégio para exercício do direito. Revista dos Tribunais, v. 432, p. 53-55, out. 1971.
- _____. Falência – legitimidade da Fazenda Pública para requerê-la. Revista dos Tribunais, v. 442, p. 48-54, ago. 1972.
- CORDEIRO, António Menezes. Manual de direito bancário. Coimbra: Almedina, 1998.
- _____. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000.
- CORREIA, A. Ferrer. Lições de direito comercial. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1998.
- CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de direito romano. 5. ed. Guanabara: Cadernos Didáticos.
- COSTA, Carlos Celso Orcesi da. Responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e

Financeiro, v. 56.

COSTA, Mário Júlio de Almeida. Ordenações Afonsinas. Fundação Calouste Gulbenkian, impressão fac-símile pela Fundação Calouste Gulbenkian, Rio de Janeiro/Lisboa, 1792.

_____. Ordenações Manuelinas, Fundação Calouste Gulbenkian, impressão fac-símile pela Fundação Calouste Gulbenkian, Rio de Janeiro/Lisboa, 1792.

COSTA, Philomeno J. da. Anotações às companhias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.

CRUZ, Aloysio Álvares. Compêndio de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

DE CICCIO, Cláudio. Interpretação histórica para as lacunas do novo Código Civil de 2002. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, dez. 2003. Disponível em <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.

DE PLÁCIDO E SILVA. Noções práticas de direito comercial. 6. ed. Curitiba: Guaíra, 1946.

_____. Vocabulário jurídico. 15. ed. atualizada por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Rio de Janeiro: Forense, 1998.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 3.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

DI SABATO, Franco. Società. 6. ed. Turim: UTET, 1999.

DOMÍNGUEZ, Maria Del Refugio González. Comercio y comerciantes en la

legislación mexicana del siglo XIX. In: Anuário mexicano da história do direito, Universidade Autônoma do México, 1990.

DORIA, Dylson. Curso de direito comercial. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

EIZIRIK, Nelson. Mercado de capitais e S/A: jurisprudência. Rio de Janeiro: Comissão Nacional de Valores. 1987.

ESTRELA, Hernani. Curso de direito comercial. Rio de Janeiro: Konfino, 1973.

FARIA, Antonio Bento de. Código Comercial brasileiro comentado. 3. ed. J. Ribeiro dos Santos Editor, 1920.

FAZZIO JÚNIOR. Waldo. Lei de Falência e Concordata comentada. São Paulo: Atlas, 1999.

_____. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2005.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio século XXI. Edição coordenada por Margarida dos Anjos e Marina Baird Ferreira, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

FERREIRA, Waldemar. Instituições de direito comercial. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1955.

_____. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1966.

FRANÇA, R. Limongi. Instituições de direito civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.

FUHRER, Maximilianus Cláudio Américo. Crimes falimentares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972.

_____. Resumo de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.

_____. Roteiro das falências e concordatas. 15. ed. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 1998.

GALGANO, Francesco. Le società di persone. In: Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: Giuffrè, 1972. v. XXVIII.

GOMES, Orlando. Contratos. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973.

_____. Contratos. 26. ed. Atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

_____. Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968.

GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de marcas. Coimbra/Portugal: Livr. Almedina, 2000.

GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998.

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Juizados Especiais Criminais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

HENTZ, Luiz Antonio Soares. Problemas das sociedades limitadas e soluções da jurisprudência. São Paulo/Leme: Ed. de Direito, 1997.

_____. A teoria da empresa no novo Código Civil brasileiro. Disponível em: <www.saraivadata.com.br>. Acesso em: janeiro de 2002.

HOUAISS, Antonio (Org.). Pequeno dicionário enciclopédico Koogan Larousse. Rio de Janeiro: Larousse do Brasil, 1984.

_____. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Instituto Antônio Houaiss e Ed. Objetiva, 2001.

LACERDA, J. C. Sampaio de. Manual de direito falimentar. 14. ed. revista e atualizada por Jorge de Miranda Magalhães. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999.

LACERDA, Paulo Maria de. Do contrato de conta-corrente. 2. ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos Ed., 1928.

LAZZARINI, Álvaro. Temas de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1973.

LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974. v. VI, t. I e II.

LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2. ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

LOBO, Carlos Augusto da Silveira. O voto múltiplo na eleição de administração das sociedades anônimas. Revista Forense, n. 270.

LOPES, Mauro Brandão. A sociedade em conta de participação. São Paulo: Saraiva, 1990.

LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por cotas de responsabilidade limitada. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

MACHADO, Sylvio Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: Freitas Bastos, 1956.

MARCONDES, Sylvio. Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977.

MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1974.

MARSHALL, Carla Izolda Fiuza Costa. Temas polêmicos da sociedade por quotas, posição da jurisprudência – cessão de cotas, responsabilidade e exclusão de sócios. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo. v. 102.

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense,

1993(a).

_____. Contratos e obrigações comerciais. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993(b).

_____. Títulos de crédito. 11. ed. Rio de Janeiro, 1995.

MAZZILI, Hugo. A defesa dos interesses difusos em juízo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.

MIRANDA, Maria Bernardete. A reorganização da empresa como objetivo principal do processo falimentar: aspectos que emergem do direito positivo, direito francês e direito brasileiro. Dissertação apresentada como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Comercial à PUC-SP, sob orientação do Prof. Dr. Newton de Lucca, PUC-SP, 1993.

MIRANDA VALVERDE, Trajano. Comentários à Lei de Falências. 4. ed. atualizada por J. A. Penalva Santos e Paulo Penalva Santos. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1973.

NAVARRINI, Humberto. La quiebra. Tradução e notas sobre o Direito Espanhol por Francisco Hernandez Borondo. Madrid: Reus, 1943.

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3; 2. ed., 2007.

_____. Curso de direito comercial e de empresa. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1.

_____. Curso de direito comercial e de empresa. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2.

NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 3

_____. Manual de direito comercial e de empresa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005; 5. ed., 2007, v. 1.

_____. Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2005(a).

_____. Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência. In: Direito falimentar e a nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Coordenação de Luiz Fernando Valente de Paiva. São Paulo: Quartier Latin, 2005(b).

_____. Recuperação judicial. In: A nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Coordenação de Paulo Penalva Santos. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira. Código Civil e legislação civil em vigor, 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

NERY Jr., Nelson. Código de Processo Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

NUNES, Luiz Antonio. Manual de introdução ao estudo do direito. São Paulo: Saraiva, 1996.

OLIVEIRA, Jorge Rubem Folea. Empresa: uma realidade fática e jurídica. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 1999.

PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

PEREIRA, Luiz C. Bresser. Empresas multinacionais e interesses de classes. Disponível em <www.bresserpereira.ecn.br>.

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. Regime dissolutório do Código Comercial. Dissolução total e dissolução parcial. Dissolução judicial e extrajudicial. Justitia, Órgão do Ministério Público do Estado de São Paulo, v. 172, p. 115-135, 1995.

PEREIRA CALÇAS, Manoel de Queiroz. Sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 2003.

PEREZ, Gabriel Nettuzzi. A ordem e a classificação dos créditos habilitáveis na falência. Justitia, Órgão do Ministério Público de São Paulo, v. 86, p. 6-16, 1974.

PIMENTA, Eduardo Goulart. O estabelecimento. In: RODRIGUES, Frederico Viana (coord.). Direito de empresa no novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

PINHEIRO, Frederico Garcia. Empresa individual de responsabilidade limitada. Conteúdo Jurídico, Brasília, 3 ago. 2011. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.32963>>. Acesso em: out. 2011.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

_____. Tratado das ações. 1. ed. atualizada por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998.

_____. Tratado de direito cambiário. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000. 3. v.

_____. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.

_____. Tratado de direito privado. 2. ed. atualizada por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2001.

PUPO CORREIA, Miguel J. A. Direito comercial. 6. ed. Lisboa: Ediforum, 1999.

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, 1975.

RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000(a).

_____. Locação: questões processuais. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000(b).

RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. Campinas: Bookseller, 2000.

_____. Tratado elemental de derecho comercial. Tradução de Felipe de Solá Cañizares. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1954.

RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

_____. Factoring. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1972.

_____. Direito civil: parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

_____. Direito civil: parte geral das obrigações. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Os valores mobiliários na Lei das S/A, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Malheiros, São Paulo, v. 107, jul./set. 1997.

- SANTOS, J. A. Penalva. Defesas do devedor no processo de abertura da falência. Revista dos Tribunais, v. 632, p. 32-43, jun. 1988.
- SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1976. v. IV.
- _____. Primeiras linhas de direito processual civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1985.
- SANVICENTE, Antônio Zoratto; MINARDI, Andrea Maria A. F. Identificação de indicadores contábeis significativos para previsão de concordata de empresas. Disponível em: <www.risktech.com.br>. Acesso em: out. 1998.
- SEGURADO, Milton Duarte. O direito no Brasil. São Paulo: José Bushatsky/Edusp, 1973.
- SILVA, Ovídio. Curso de processo civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 1993.
- SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários ao Código da Propriedade Industrial. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.
- _____. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
- SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
- TEIXEIRA, Egberto Lacerda. As sociedades limitadas e o Projeto do Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 99, jul./set. 1995.
- TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades anônimas no direito brasileiro. São Paulo: José Bushatsky, 1979.

- TELLES, José Araldo da Costa. Anotações sobre a responsabilidade civil na falência. Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 5, n. 2, jul./dez. 2004.
- THEODORO JÚNIOR, Humberto. Contrato de agência e distribuição no novo Código Civil. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 24, p. 110-132, jul./ago. 2003.
- TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. O conselho de administração na sociedade anônima. São Paulo: Atlas, 1997.
- TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2005.
- VAMPRÉ, Spencer. Tratado elementar de direito comercial. F. Briguier, 1921. v. 1.
- VEIGA, Vasco Soares da. Direito bancário. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1997.
- VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade civil especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- VEYNE, Paul (Org.). História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- VITIRITTO, Benedito Mário. Julgamento antecipado da lide e outros estudos. Belo Horizonte: Lemi.
- VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. 5. ed. Milano: Vallardi. v. 3.
- ZANETTI, Robson. Direito falimentar: a prevenção de dificuldades e a recuperação de empresas. Curitiba: Juruá, 2000.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

(referência aos itens)

Alberto Asquini – 2, 3

Alberto Luís Camelier da Silva – 63

Amador Paes de Almeida – 121.4

Arnaldo Rizzardo – 87

Barros Monteiro – 94.1, 96.6

Caio Mário da Silva Pereira – 8.2

Carvalho de Mendonça – 9.3, 74, 75.1, 80.1, 90.3, 96.10, 129.9

Castro Filho – 95.8

Cesare Vivante – 90.3

Cláudio Santos – 121.4

Clóvis Beviláqua – 83.2, 93.8, 93.14

Costa Leite – 121.4

De Plácido e Silva – 44, 55, 74

Dylson Dória – 47.1

Eduardo Ribeiro – 121.4

Egberto Lacerda Teixeira – 47.3, d

Eunápio Borges – 90.3

Fábio Konder Comparato – 121.4,

Fábio Ulhoa Coelho – 20, 21, 30.1, 51.2, 58, 64, 67.2, 75.1, 75.7, 78.1, 82.2, 82.5, 88.2a, 90, 93.7, 93.11, 96.16

Fontes de Alencar – 96.16,

Fran Martins – 90, 91, 93.7, 93.11, 94.1, 94.4, 96.12

Franco Di Sabato – 13.2, 33

Frederico Garcia Pinheiro – 21

Gomes Corrêa – 96.11

Humberto Theodoro Junior – 77.4, 78.1

Manoel de Queiroz Pereira Calças – 30.1

Marco Antonio Marcondes Pereira – 51.2

Marco Aurélio – 96.18

Maria Helena Diniz – 78.1, 80.2, 82.2, 83.1, 86.1, 88.2a

Miranda Valverde – 99, 106.1, 129.1

Moacyr Amaral Santos – 75.6

Orlando Gomes: 85.1, 88.2a

Oscar Barreto Filho – 58, 59, 60

Paulo Leonardo Vilela Cardoso – 21

Pontes de Miranda – 93.7, 96.10

Pupo Correia – 63, 90

Restiffe Neto – 62

Rizzato Nunes – 96.11

Rubens Requião – 64, 67.2, 96.12

Ruy Rosado de Aguiar – 94.1, 96.16

Sálvio de Figueiredo Teixeira – 95.8, 96.8

Spencer Vampré – 136.2

Sylvio Marcondes – 75.2

Vidari – 80.1

Waldirio Bulgarelli – 3, 22, 40, 78.2, 82.2, 83.6, 84.2, 93.8, 96.10

Waldo Fazzio Junior – 121.4

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

(referência aos itens)

Abuso de poderes gerenciais – 23.7

Ação – 40

- classificação – 40.1
- valores da – 40.2

Ação de restituição

- contratos de câmbio – 135.2
- execução da sentença – 135.5
- fundamentos – 135
- honorários e correção monetária – 135.7
- procedimento – 135.4
- recurso – 135.6
- requisitos – 135.1

Ação ordinária de exclusão de crédito – 105

Ação revocatória

- biênio anterior – 136.2
- efeitos – 136.8
- ineficácia – 136
- instrumentos – 136
- medidas cautelares – 136.7
- por fraude – 136.5
- processamento – 136.6
- termo legal – 136.1

Aceite cambial

- conceito – 93.5

- em duplicata – 96.4
- limitado – 93.5
- presumido em duplicata – 96.5

Acionista

- direitos essenciais – 39

Acionista dissidente

- reembolso – 34.5

Acionista remisso

- reembolso – 34.5

Administrador

- deveres – 23.4
- eleição – 47.2
- formas de exercício – 23.3
- incompatibilidades e impedimentos – 23.1
- poderes – 23.6
- substituição – 23.5

Administrador judicial

- compromisso – 106.3
- funções – 106.4
- impedimentos – 106.2
- natureza jurídica – 106.1
- nomeação – 106
- prestação de contas – 106.8, 134.1
- remuneração – 106.5
- responsabilidade – 106.7
- substituição e destituição – 106.6

Aeronave e falência – 129.5

Affectio societatis – 9.3

Agência – veja Contrato de agência

Agente fiduciário – 42.3

Alienação de empresa na LREF – 132

Alienação fiduciária

- conceito – 85.1
- objeto – 85.2
- e falência – 129.5

Alienação judicial

- especulação de lucro – 132.6
- impugnação – 132.5
- na falência – outras modalidades – 132.4

Alienações públicas

- modalidades – 132.3

Apólice e bilhete de seguro – 88.2b

Apresentação para aceite e pagamento – 93.11

Arquivamento – 72.5

Arrendamento mercantil

- de retorno – 84.3
- e falência – 129.5
- financeiro – 84.3
- modalidade – 84.3
- objeto – 84.2
- operacional – 84.3
- origem e conceito – 84.1

Assembleia de debenturistas – 42.4

Assembleia de sócios – 11

Assembleia geral

- conceito – 47.1
- espécies – 47.3
- quorum de instalação e de deliberação – 47.3

Assembleia geral de credores

- apuração de votos – 108.3
- convocação – 108
- quorum de instalação e de deliberação – 108.2

Atividade empresarial

- características – 2

Autenticação de documentos – 72.5

Autofalência – 122.3

Aval

- conceito – 93.7
- e fiança – distinções – 93.7
- em duplicata – 96.10
- em duplicata e ação monitória – 96.11
- simultâneo – 93.7
- sucessivo – 93.7

Aviamento – 58

Balanço patrimonial – 47.2, 75.9

Benefício de ordem – 16

Bolsa de valores

- conceito – 36

Bônus de subscrição – 44

Câmara de Comércio Internacional – 83.9

Capital social

- avaliação de bens – 47.2
- constituição – 9.2
- redução – 34.5
- inicial – 34.4

Certificado de ações – 40.3

Certificado de depósito de ações – 40.5

Cessão de uso – 68

Cheque

- ações judiciais – 95.10
- administrativo – 95.7
- ao portador – 95.7
- aval – 95.6
- bancário – 95.7
- conceito – 95
- cruzado – 95.7
- de tesouraria – 95.7
- incompleto ou em branco – 95.4
- legislação – 95.1
- modalidades de emissão – 95.7
- nominativo – 95.7
- para se levar em conta – 95.7
- prazo para a apresentação – 95.8
- requisitos – 95.3
- revogação – 95.5
- visado – 95.7

Cisão de sociedade – 49.4

– deliberação – 47.2

Classes de credores

- direito a voto – 108.1

Classificação das ações – 40.1

Classificação de créditos na falência – 131

Cláusula sem despesas – 93.11

Cláusula sem protesto – 93.11

Cláusulas de interdição de concorrência – 59

Clientela – 58

Comerciante

– conceito objetivo – 2

Comércio marítimo – 2

Comissão mercantil – 79

Comissão mercantil e falência – 129.8

Comitê de Credores

– atribuições e deliberações – 107.4

– composição e presidência – 107.2

– conceito – 107

– formas de constituição – 107.1

– impedimentos – 107.3

– remuneração – 107.5

– responsabilidade – 107.7

– substituição e destituição – 107.6

Commercial papers – 45

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – 40.6

Companhia hipotecária

– capital inicial – 34.4

Companhia subsidiária integral – 9.1, 34.3

Compensação de dívidas e falência – 129.10

Compra e venda mercantil

– conceito – 82.1

– elementos formadores – 82.2

– entrega da coisa – 82.4

– evicção – 82.5

– obrigações do vendedor – 82.3

– vícios – 82.5

Concessão comercial – 78

Concordata preventiva

– conversão em recuperação judicial – 117

Condomínio indivisível e falência – 129.12

Confissão de falência

- deliberação – 47.2

Conflitos em matéria de cheque – 95.2

Cônjuge e falência de espólio – 121.5

Conjunto-imagem – 63

Conselho de Administração

- atribuições – 48.2
- composição – 48.3

Conselho Fiscal

- na sociedade limitada – 31
- nas sociedades por ações – 48.5

Conselho Fiscal permanente ou não – 48.6

Consórcio – 50.3

Constituição

- de sociedade de credores – 132.2
- de sociedade de empregados – 132.2
- privada de companhia – 10.1
- pública de companhia – 10.1
- simultânea de companhia – 10.2
- sucessiva de companhia – 10.3

Conta-corrente e falência – 129.9

Contabilista – 74

Contrato aleatório – 82.5

Contrato comutativo – 82.5

Contrato de agência

- conceito – 77.1
- extinção – 77.6

- natureza jurídica – 77.2
- retribuição – 77.5

Contrato de distribuição

- distinção – 77.4
- por conta própria – 78

Contrato de seguro

- definição – 88.2
- características – 88.2a
- de pessoas – 88.2c
- de coisas – 88.2d

Contrato de sociedade e falência – 129.11

Contrato de transporte

- conceito – 88.1
- de coisas – 88.1b
- de pessoas – 88.1a

Contrato estimatório – 83.7

Contratos bancários – 86

Contratos bilaterais e falência – 129.2

Contratos de câmbio

- ação de restituição – 135.2

Contratos imobiliários e falência – 129.7

Coparticipação nos lucros e perdas – 9.4

Corretagem

- características – 80.2
- conceito – 80
- espécies – 80.3

Crédito documentário – 83.6

Credor domiciliado no exterior e falência – 121.3

Credor empresário e falência – 121.2

Credor pignoratício

- direito de voto – 40.7

Crise econômico-financeira – 109

Custódia de ações – 40.4

Debêntures – 42

- autorização de emissão – 47.2
- conversibilidade – 42.1
- garantias outorgadas – 42.2

Demonstração de fluxos de caixa – 47.2, 75.10

Demonstração de valor adicionado – 47.2, 75.10

Demonstração do resultado do exercício – 47.2, 75.9

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados – 47.2, 75.9

Demonstrações financeiras – 47.2, 75.8 a 75.11

Depósito bancário – 86.1

Desconto e redesconto – 86.2

Desenho industrial

- conceito – 63
- requisitos – 66

Direito de propriedade industrial

- caducidade – 70.3
- cessão de uso e licenças – 68
- conceitos – 63
- extinção – 70
- nulidade de concessão – 70.5
- prazos de vigência – 70.1
- renúncia – 70.2

Direito de retirada – 11.8

Direitos do acionista

- suspensão – 47.2

Direitos e deveres dos sócios – 11

Direitos essenciais do acionista – 39

Diretoria – 48.4

Disregard of legal entity – 20

Dissolução de sociedades

- na LSA – 52
- no Código Civil – 51

Dissolução e liquidação de sociedade

- deliberação – 47.2

Distribuição – veja Contrato de distribuição

Dividendo

- intercalar – 39
- intermediário – 39
- obrigatório – 39
- semestral – 39

DNRC – 72.2

Duplicata

- aceite – 96.4
- ações fundadas em – 96.16
- aspectos penais – 96.18
- aval – 96.10
- aval e ação monitória – 96.11
- conceito – 96.1
- criação e requisitos – 96.3
- endosso – 96.9
- escritural – 96.19
- modalidades – 96.2
- pagamento antecipado – 96.14

- prazo para pagamento – 96.13
- prescrição – 96.17
- prorrogação de pagamento – 96.15
- protesto – 96.12
- protesto por indicação – 96.6

Empresa

- conceito politérico – 3
- constituição de nome – 73
- de pequeno porte – caracterização – 75.7
- institutos complementares – 71
- pública – 9.1
- registro – 72

Empresa individual de responsabilidade limitada

- arquivamento no Registro de Empresa – 72.5
- constituição do capital – 9.2
- efeitos jurídicos do registro – 72.4
- formação do nome empresarial – 73.7
- impedimento ao registro – 72.6
- incidência da teoria do superamento – 20
- nome empresarial adotado – 73.2
- regras da sociedade limitada aplicáveis – 30.3
- responsabilidade do titular – 20
- transformação de sociedade em EIRELI – 49.1

Empréstimo bancário – 86.3

Endosso

- conceito – 93.6
- em duplicata – 96.9
- em penhor – 93.6
- impróprio – 93.6
- mandato – 93.6
- parcial – 93.6
- póstumo – 93.6
- sem garantia – 93.6

- sem obrigação – 93.6
- tardio – 93.6

Escrituração empresarial – 75

- espécies de livros – 75.4
- funções – 75.1
- princípios – 75.2
- recusa em apresentação – 75.6
- sanções penais, 75.3
- valor probante, 75.5

Espólio e falência

- legitimidade – 121.5

Estabelecimento empresarial

- definição – 54
- natureza jurídica – 54
- principal – 99
- sub-rogação de contratos – 57
- trespasse – 56

Estatuto social

- reforma – 47.2

Evicção – 82.5

Exceção de retomada – 62

Exclusão de crédito do QGC – 105

Extinção das obrigações do falido – 134.3

- antecipada – 134.4
- procedimento – 134.5

Factoring – veja Faturização

Falência

- arrecadação dos bens – 130
- atos de insolvência – 122.2
- confissão – 47.2

- credor domiciliado no exterior – 121.3
- credor empresário – 121.2
- e compensação de dívidas – 129.10
- efeitos sobre a pessoa do falido – 126
- efeitos sobre os bens do falido – 128
- efeitos sobre os contratos – 129
- efeitos sobre os credores – 125
- efeitos sobre os sócios – 127
- encerramento – 134
- extinção das obrigações do falido – 134.3
- impontualidade – 122.1
- incidental à recuperação – 120
- indenização – 124.1
- legitimidade ativa – 121.4
- legitimidade passiva – 121.7
- natureza da dívida – 121.1
- pedido – 121
- realização do ativo – 132
- requerimento por sócio ou acionista – 121.6
- sentença de encerramento – 134.2
- sentença judicial e recursos – 124

Faturização

- conceito – 87

Financial lease – 84.3

Firma individual – 73.2

Firma social – 73.2

Fomento mercantil – veja Faturização

Franchising – veja Franquia

Franquia

- conceito – 81.1
- elementos – 81.4
- natureza jurídica – 81.3

– objeto – 81.2

Fusão de sociedades – 49.3

– deliberação – 47.2

Gerente – 74

Grupos de sociedades

– consórcio – 50.3

– grupo de direito – 50.2

– grupo de fato – 50.1

Habilitação de crédito – 103

Habilitação retardatária de crédito – 104

Hedging – 83.8

Herdeiro e falência de espólio – 121.5

Holding – 50.2

Honorários advocatícios e ação de restituição – 135.7

Impenhorabilidade e falência – 128.1

Incorporação de sociedade – 49.2

Incoterms – 83.9

Indicação geográfica

– conceito – 63

Instituições financeiras

– capital inicial – 34.4

Invenção

– conceito – 63

– de empresa, de empregado e comum; distinções e conceito – 65

Inventariante e falência de espólio – 121.5

Joint venture – 50.3

Lease back – 84.3

Leasing – veja Arrendamento mercantil

Leasing bancário – 84.3

- e falência – 129.5

- operacional – 84.3

Legitimidade ativa

- falência – 121.4

Legitimidade passiva

- falência – 98, 121.7

Leilão na falência – 132.3

Leis uniformes – 91

Letra de câmbio

- ação cambial – 93.13

- ação causal – 93.15

- ação de regresso – 93.13

- aceite – 93.5

- conceito – 93

- e ação monitória – 93.16

- emissão em moeda estrangeira – 93.1

- época do pagamento – 93.3

- juros – 93.2

- não aceitável; conceito – 93.5

- prescrição – 93.14

- requisitos – 93

- saque – 93.4

Licença

- compulsória – 69

- contrato de – 68

Liquidação

- conceito – 39, b

Livro Diário, 75.2

Livros empresariais e microempresa – 75.7

Livros obrigatórios e facultativos, 75.4

Mandato – 79

Mandato e falência – 129.8

Marca

- colidência com nome empresarial – 73.5
- conceito – 63
- classificações – 67.1
- requisitos – 67.2

Matrícula – 72.5

Matriz, filiais e sucursais – 55

Meios de recuperação – 112

Mercado de balcão – 36

Mercado primário – 36

Mercado secundário – 36

Microempreendedor individual – 75.7

Microempresa

- caracterização – 75.7
- e livros empresariais – 75.7

Modelo de utilidade

- conceito – 63
- requisitos – 64

Nome empresarial

- características – 73
- alteração – 73.9
- colidência com marca – 73.5
- espécies – 73.2

- formação do – 73.7
- princípios de tutela – 73.4
- sistemas de formação – 73.6
- sociedade estrangeira – 73.8
- tutela legal – 73.3

Nota promissória

- ação cambial – 94.5
- conceito – 94
- direito aplicável – 94.4
- incompleta – 94.2
- requisitos – 94.1
- requisitos não essenciais – 94.3

Órgão de registro – 72.2

Pagamento

- conceito – 93.8
- de credores na falência – 133
- por intervenção – 93.9

Papéis comerciais – 45

Partes beneficiárias – 43

- autorização de emissão – 47.2

Patrimônio de afetação e falência – 128.2

Penhor de ações – 40.7

Perfis da empresa – 3

Personalidade jurídica

– das sociedades – 4

- teoria do superamento – 20

Plano de recuperação – 113

- deliberação – 115
- impugnação – 114

Ponto empresarial

- conceito e espécies – 61
- conversão – 62

Preempção ou preferência – 83.3

Prêmio – 88.2

Preposto – 74

Princípio jurídico

- abstração cambial – 90.3
- anualidade – 75.8
- autonomia cambial – 90.3
- cartularidade cambial – 90.3
- competência exclusiva da assembleia geral – 75.8
- da especialidade – 73.5
- da novidade ou precedência de registro – 73.5
- igualdade de tratamento dos credores – 109
- incentivo a manutenção dos meios produtivos – 109
- indivisibilidade do juízo falimentar – 101
- informadores da escrituração – 75.2
- inoponibilidade cambial – 90.3
- literalidade cambial – 90.3
- manutenção da fonte produtora – 109
- manutenção do interesse dos credores – 109
- periodicidade – 75.8
- prevenção do juízo falimentar – 100
- supremacia da recuperação da empresa – 109
- unidade do juízo falimentar – 99
- universalidade do juízo falimentar – 102

Procedimentos pré-falimentares – 122

Protesto – conceito – 93.12

Quadro

- ações de restituição – 135

- administração da sociedade de pessoas – 23
- atos de registro de empresa – 72.5
- atribuições do Comitê de Credores na falência – 107.4
- atribuições do Comitê de Credores na recuperação judicial – 107.4
- classificação das ações – 40.1
- classificação das marcas – 67.1
- classificação dos créditos na falência – 131
- direito de retirada na sociedade por ações – 11.8
- direitos de propriedade industrial – 63
- direitos de propriedade industrial
- prazos de vigência – 70.1
- distinções entre contratos de agência, distribuição, mandato e comissão – 79
- distinções entre nome, marca, título de estabelecimento e insígnia – 73.1
- elementos do contrato de franquia – 81.4
- emissões públicas e privadas de valores mobiliários – 42
- enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte – 75.7
- funções do administrador judicial na falência – 106.4
- funções do administrador judicial na recuperação judicial – 106.4
- impedimentos ao arquivamento de documentos no Registro de Empresa – 72.6
- incoterms – 83.9
- instrumentos de recuperação de empresa em juízo – distinções – 110.2
- lugar de lançamento do aval – 93.7
- matéria negociável ou não negociável entre os sócios – 30
- matérias sujeitas à deliberação dos sócios na sociedade limitada – 11.4
- matérias suscetíveis ou não de contratação pelos sócios – 30
- meios de recuperação – 112
- prescrição em duplicata – 96.17
- prescrição nas letras – 93.14
- recursos em matéria falimentar – 124.2
- remuneração do administrador judicial – 106.5
- requisitos da duplicata – 96.3
- requisitos específicos dos estatutos sociais – 34.2
- reserva brasileira em matéria de letra de câmbio – 91
- responsabilidade por ingresso, retirada e falência – 19
- resumo dos valores mobiliários – 46

- retribuição de patentes e de registros – 70.4
- teoria dos equivalentes – 93
- tipos de responsabilidade patrimonial dos sócios – 15
- títulos de crédito em espécie – 90.2
- verificação judicial de crédito – 103

Quadro geral de credores

- exclusão de crédito – 105

Realização do ativo na falência – 132

Recuperação de empresas em juízo

- requisitos comuns – 101.1

Recuperação extrajudicial

- documentação – 119.3
- efeitos – 119.2
- limitações – 119
- modalidades – 119.1
- procedimento – 119.4

Recuperação judicial

- casos de incidência – 98
- convação em falência – 120
- cumprimento da – 116
- especial – 118
- judicial incidental – 123
- meios de recuperação – 112
- ordinária e especial, distinções – 118
- pedido inicial e processamento – 111

Recursos em matéria falimentar – 124.2

Registro de empresa – 72

- efeitos jurídicos – 72.4
- finalidades – 72.3
- impedimentos – 72.6
- órgãos – 72.2

Renting – 84.3

Reorganização de sociedades – 49

Reserva de domínio e falência – 129.5

Resolução da sociedade em relação a sócios – 12

Ressaque – 93.10

Retrovenda – 83.1

Reunião de sócios – 11

Revenda de automóveis – 78.3

Risco – 88.2

Self-leasing – 84.3

Sentença falimentar

- requisitos – 124

SINREM – 72.2

Sistema único de custódia – 40.6

Sistemas de colheita de votos na LREF – 108.3

Sistemas de recuperação em juízo

- distinções – 110.2

- modalidades – 110

Sociedade anônima – 34

- aberta e fechada – 36

- de capital autorizado – 35

- estatutos – 34.2

- fundadores – 34.1

- multinacional – 38

Sociedade coligada – 7

Sociedade contratual – 7, 10

Sociedade controlada – 7

Sociedade de capital – 7

Sociedade de economia mista – 37

Sociedade de grande porte – 75.11

Sociedade de pessoas – 7

- administração – 23
- administração; incompatibilidades e impedimentos – 23.1
- formas de exercício de administração – 23.3

Sociedade de simples participação – 7

Sociedade em comandita por ações – 33

Sociedade em comandita simples – 29

Sociedade em comum – 24

Sociedade em conta de participação – 25

Sociedade em nome coletivo – 28

Sociedade empresária – 6

- por equiparação – 7
- por força de lei – 7

Sociedade estrangeira

- nome empresarial – 73.9

Sociedade filiada – 7

Sociedade ilimitada – 7

Sociedade institucional – 7, 10

Sociedade limitada – 7, 30

Sociedade limitada e sociedade simples; distinções – 30.2

Sociedade mista – 7

Sociedade não personificada – 7, 24, 25

Sociedade por ações

- características – 32

Sociedade simples – 6, 27

- normas de regência – 26

Sociedades

- características – 5
- classificação – 7
- empresárias – 6
- simples – 6, 26, 27
- reorganização – 49

Sócio

- com responsabilidade ilimitada – responsabilidade por ingresso e retirada – 16
- com responsabilidade limitada – responsabilidade por ingresso e retirada – 17
- direitos e deveres – 11
- exclusão de – 13
- execução de cota de – 14
- falência de – 14
- incapacidade de – 13.3
- minoritário – exclusão de – 13.4
- morte de – 14
- remisso – 13.1
- responsabilidade – 15
- responsabilidade em caso de falência – 18
- retirada de – 12

Teoria da aparência, 74

Teoria da desconsideração – 20

- aspectos processuais – 21

Teoria da empresa – 2

Teoria da penetração – 20

Teoria do superamento – 20

Teoria dos atos de comércio – 2

Teoria ultra vires societatis – 22

Título(s) de crédito

- à ordem – 90.1
- ao portador – 90.1
- atípico – 90.1
- conceito de Vivante – 90
- definição legal – 90.3
- participação social – 90.1
- espécies – 90.2
- misto – 90.1
- no Código Civil – 92
- nominativo – 90.1
- privado – 90.1
- público – 90.1
- representativo – 90.1
- típico – 90.1

Trade dress – 63

Transformação de sociedade – 49.1

- deliberação – 47.2

Transporte – veja Contrato de transporte

Triplicata

- conceito – 96.8

Valores das ações – 40.2

Valores mobiliários – 41

Venda a contento – 83.2

Venda a prestação e falência – 129.3

Venda com reserva de domínio – 83.4

Venda de coisa composta e falência – 129.3

Venda por pregão – 132.3

Venda por propostas – 132.3

Venda sobre documentos – 83.5

Venda sujeita a prova – 83.2

Vendas a termo e falência – 129.6

Verba previdenciária – restituição – 135.3

Verificação e habilitação de crédito – 103

Vícios redibitórios – 82.5

Voto múltiplo – 48.3

1. Cf. PINHEIRO, Frederico Garcia. Empresa individual de responsabilidade limitada. Conteúdo Jurídico, Brasília, 3 ago. 2011. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.32963>>. Acesso em out. 2011; CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no Novo Código Comercial. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords.). Reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 536-537.

2. AR 512/DF, rel. Min. Waldemar Zveiter, Segunda Seção, julgado em 12-5-1999, DJ, 19-2-2001, p. 129.
3. REsp 418.580/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, julgado em 11-2-2003, DJ, 10-3-2003, p. 191.

4. <http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/sam.asp>